Universidad de Concepción
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Fondo de Publicaciones

HERNÁN TRONCOSO LARRONDE
CARLOS ÁLVAREZ CID

CONTRATOS

COLECCIÓN DE MANUALES

QUINTA EDICIÓN ACTUALIZADA

Basados en la legislación chilena vigente y de acuerdo a la ley 17.336 del año 1972 y su modificación del 04 de mayo del 2010, acogiéndonos al Título III de las Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos que indica en su

Articulo 71 C:

"Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, que se realice en beneficio de personas con discapacidad visual, auditiva, o de otra clase que le impidan el normal acceso a la obra, siempre que dicha utilización guarde relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleve a cabo a través de un procedimiento o medio apropiado para superar la discapacidad y sin fines comerciales.

En los ejemplares se señalará expresamente la circunstancia de ser realizados bajo la excepción de este artículo y la prohibición de su distribución y puesta a disposición, a cualquier título, de personas que no tengan la respectiva discapacidad."

Por tanto damos cumplimiento al inciso 2 de la norma citada

HERNÁN TRONCOSO LARRONDE CARLOS ÁLVAREZ CID

CONTRATOS

QUINTA EDICIÓN ACTUALIZADA

CONTRATOS

© HERNÁN TRONCOSO LARRONDE - CARLOS ÁLVAREZ CID

1ª edición septiembre 2006

2ª edición marzo 2007

3ª edición febrero 2009

4ª edición enero 2010

5ª edición mayo 2010

Tiraje: 300 ejemplares

Contenido

PRESENTACIÓN 11

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1. - Generalidades. 13
2. - Concepto de contrato en el Código Civil. 13
3. - Funciones económica y social de los contratos. 14
4. - Requisitos del contrato. 15
5. - Fundamento de la obligatoriedad de los contratos. 15
6. - El consentimiento. 16
7. - Contratos de derechos patrimoniales y de derecho de familia. 17
8. - Elementos de los contratos. 17
9. - La autonomía de la voluntad. 17

CAPÍTULO II

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

1. - Contratos unilaterales y bilaterales. 21
2. - Contratos gratuitos y onerosos. 22
3. - Contratos conmutativos y aleatorios. 23
5. - Contratos reales, solemnes y consensúales. 24
6. - Contratos nominados e innominados. 25
7. - Contratos de libre discusión y de adhesión. 26
8. - Contratos individuales y colectivos. 26
9. - Contratos de ejecución instantánea y de ejecución sucesiva. 26

CAPÍTULO III

EFECTOS DE LOS CONTRATOS

1. - Efectos entre las partes. 29
2. - Efectos respecto de terceros. 30

2.1. - Estipulación por otro o en favor de otro. 31

2.2. - Promesa de hecho ajeno. 34

CAPÍTULO IV
LA INOPONIBILIDAD 37
CAPÍTULO V
EL AUTOCONTRATO 41
CAPÍTULO VI
INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS Y SU CALIFICACIÓN JURÍDICA 45
1. - Interpretación de los contratos. 45
2. - Calificación jurídica de los contratos. 50
CAPÍTULO VII
CONTRATO DE PROMESA
1. - Generalidades y circunstancias que inducen a la celebración de un contrato de promesa. 51
2. - Definiciones. 52
3. - Particularidades del contrato de promesa. 52
4. - Validez de la promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral. 53
5. - Requisitos del contrato de promesa. 54
6. -Efectos del contrato de promesa. 59
7. -Acción de resolución del contrato de promesa. 59
CAPÍTULO VIII
CONTRATO DE COMPRAVENTA
1. - Definición. 61
2. - Naturaleza del contrato de compraventa. 61
3. - La compraventa es título traslaticio de dominio. 62
4. - Requisitos generales del contrato de compraventa. 63
4.1. - La cosa vendida. 63
4.2. - Venta de cosa ajena. 65
4.3. - El precio. 66
5. - Las solemnidades en el contrato de compraventa. 67
5.1. - Solemnidades legales. 68
5.2. - Solemnidades voluntarias o convencionales. 69
5.3. - Casos especiales de compraventa en relación con las solemnidades. 69
6. - Las arras. 70
7. - Normas sobre capacidad para el contrato de compraventa. 71
8. - Efectos del contrato de compraventa. 73
9. - Obligaciones del vendedor. 73
9.1. - Obligación de entregar la cosa vendida. ^ 73
9.1.1. -Lugar en que debe hacerse la entrega. 77

9.1.2. -Momento en que debe efectuarse la entrega o tiempo de la entrega. 77
9.1.3. - Cómo debe efectuarse la entrega. 78
9.1.3. - La entrega en la venta de predios rústicos. 78
9.1.5. - Acciones del comprador contra el vendedor que no cumple la obligación de entregar. 81
9.1.6. - Derecho de retención del vendedor. 82
9.2. - Obligación de sanear la cosa vendida. 82
9.2.1. - Saneamiento de la evicción. 82
9.2.2. - Saneamiento de los vicios redhibitorios. 88
10. - Obligaciones del comprador. 90
10.1. - Obligación de recibir la cosa comprada. 90
10.2. - Obligación de pagar el precio. 90
11. - Pactos accesorios al contrato de compraventa 92
11.1. - Pacto comisorio. 92
11.2. - Pacto de retroventa. 92
11.3. - Pacto de retracto. 93
12. - Rescisión de la venta por lesión enorme. 93
13. - Contrato de permuta. 95

CAPÍTULO IX

DE LAS CAUCIONES

1. - Generalidades. 97

TÍTULO I

EL CONTRATO DE PRENDA

1. - Definición. 98
2. - Acepciones de la palabra prenda. 98
3. - Características de la prenda. 99
4. - Obligaciones susceptibles de caucionarse con prenda. 99
5. - Requisitos de la prenda. 100
6. - Especialidad de la prenda. 101
7. - Cláusula de garantía general prendaria. 103
8. - Prenda de cosa ajena. 103
9. - Efectos del contrato de prenda. 104
10. - Extinción de la prenda. 108

TÍTULO II

DEL CONTRATO DE HIPOTECA

1. - Definición. 111
2. - Características. 111

2.1. - Es un derecho real. 111
2.2. - Es un derecho inmueble. 111
2.3. - Es un derecho accesorio. 112
2.4. - Constituye una limitación del dominio. 115
2.5. - Constituye un principio de enajenación: 115
2.6. -Da origen a una preferencia. 115
2.7. - Es indivisible 115
3. - Clases de hipoteca. 115
4. - Fuentes de la obligación de constituir hipoteca. 116
5. - Características del contrato de hipoteca. 117
6. - Elementos del contrato de hipoteca. 119
7. - Bienes que pueden hipotecarse. 120
8. - Adquisición del derecho real de hipoteca. 123
9. - Cosas a las que se extiende la hipoteca. 124
10. - Efectos de la hipoteca. 125
11. - Derechos del acreedor hipotecario. 126
12. - Extinción de la hipoteca 128

TÍTULO III

CONTRATO DE FIANZA

1. - Definición. 133
2. - Carácter contractual de la fianza 133
3. - Características del contrato de fianza. 133
4. - Requisitos del contrato de fianza. 134
5. - Clases de fianza. 135
6. - Obligación de rendir fianza y calidades del fiador. 136
7. - Efectos de la fianza. 136

CAPÍTULO X

CONTRATO DE MANDATO

1. - Definición. 143
2. - Mandato y representación. 143
3. - El mandato versa siempre sobre actos jurídicos. 143
4. - Características del contrato de mandato 143
5. - Diferencias entre mandato y arrendamiento de servicios. 145
6. - Diferencias entre mandato y agencia oficiosa. 145
7. - Requisitos del mandato. 146
8. - Mandato general y mandato especial. Artículo 2130. 146
9. - Facultades del mandatario. 146

10. - Responsabilidad del mandatario. 148
11. - Rendición de cuenta de la gestión del mandato. 148
12. - Delegación del mandato. 149
13. - Obligaciones del mandante. 149
14. - Efectos del mandato entre mandante y terceros. 150
15. - Extinción del mandato. 150
16. - Naturaleza de los servicios de las profesiones que suponen largos estudios. 153
17. - Prueba. 153

CAPÍTULO XI

CONTRATO DE MUTUO

1. - Definición. 155
2. - Características del contrato de mutuo. 155
3. - Capacidad de las partes. 156
4. - Efectos del contrato de mutuo. 156
5. - Plazo para la restitución de las cosas dadas en mutuo. 157
6. - Obligaciones eventuales del mutuante. 158
7. - Los intereses. 158

CAPÍTULO XII

CONTRATO DE COMODATO

1. - Definición. 161
2. - Características del contrato de comodato. 161
3. - Responsabilidad de comodatario. 162
4. -El comodato y la prueba testimonial. 162
5. - Requisitos del contrato de comodato. 162
6. - Comodato de cosa ajena. 162
7. - Obligaciones que surgen del comodato. 162
8. - Pluralidad de comodatarios de una cosa. 163
9. - Obligaciones del comodante. 164
10. - Acciones para demandar la restitución de la cosa. 164
11. - Extinción del comodato. 164
12. - Comodato precario. 164

PRESENTACIÓN

El Programa de Proyectos de Apoyo a la Docencia de la Universidad de Concepción, nos permite, una vez más, poner a disposición de los alumnos de Derecho, un texto sistematizado que contiene las materias fundamentales para un curso sobre el Derecho de Contratos.

Como en oportunidades anteriores, en los demás cursos que comprenden el ciclo de Derecho Privado, nuestros lectores no encontrarán el desarrollo de las teorías clásicas o individualistas, ni de las modernas teorías del derecho, aplicables a esta materia. En la primera, en que toda persona con una voluntad sana de manifestarse claramente, es en sí misma un sujeto de derechos que puede fijar libremente, mediante la convención, sus relaciones patrimoniales con las demás personas; o en éstas, en que los individuos, en sí mismos, no son sujetos de derecho sino en cuanto el legislador se los confiere, concesión que no busca beneficiar a unos respecto de otros, sino porque es necesario concederlos a fin que desenvuelvan plenamente su actividad intelectual, física o moral, para obtener de cada uno de ellos el valor social que les corresponde.

El contrato carece, así, de un valor jurídico absoluto y sólo tiene un valor relativo, ya que debe encuadrarse dentro de los marcos que haya fijado el legislador. En todo acto jurídico existe un fin y un objeto es la situación jurídica que persiguen las partes; el fin es la razón por la cual se quiere crear aquella relación jurídica. Ihering ejemplifica esta figura cuando dice que, en un contrato de compraventa de un automóvil el objeto es adquirir el dominio del auto, y el fin podrá ser tenerlo para pasear y movilizarse, o para atropellar a un vecino. El art. 1467 del Código Civil, en su versión de 14 de diciembre de 1855 y en la de 29 de agosto de 2000, mantiene idéntica redacción y contenido. Ambos consignan:

1467.- No puede haber obligación sin una causa real ilícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; i por causa ilícita la prohibida por lei, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.

Así las personas de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; i la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita.

Tampoco nos adentramos en las distintas teorías que se han formulado, en pro y en contra, de la teoría de la causa, ni siquiera en las teorías de la formación del contrato, como ha sido nuestra permanente meta, a tratar los temas paradigmáticos de Derecho de Contratos.

La obra está estructurada en doce capítulos que corresponden, de I al VI a los Aspectos Generales del Contrato, continuando con un análisis de compraventa, de las cauciones, el contrato de mandato, mutuo y comodato.

Reiteramos nuestro objetivo central, servir de base para iniciar el estudio y análisis de las materias jurídicas que comprende la asignatura. No es otro nuestro objetivo posibles lectores y estudiantes.

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1. - Generalidades.

El contrato constituye la manifestación más tradicional de la autonomía de la voluntad como generadora de obligaciones, intuitivamente concebida como la primera fuente de las mismas.

Especie prioritaria del género de las convenciones, cuenta con una abundante y pormenorizada reglamentación lo que, habitualmente, lleva a olvidar que la primera regla en cuanto a la determinación de su contenido arranca del libre albedrío de las partes. Producto de lo anterior, en ocasiones, se procura encuadrar, en forma más o menos forzada, el verdadero querer de los contratantes en modelos contractuales típicos y nominados, obrar que no es ajeno a abogados e incluso al propio legislador, tendiendo a contentarnos con las formas existentes por cómodas y conocidas.

Tal proceder dificulta muchas veces la labor del juzgador a la hora de interpretar el real querer de los contratantes, por cuanto éstos, al revestir su consentimiento con un ropaje que no le acomoda, restringen el rango de acción del tribunal, el cual, enfrentado a la inadecuada calificación hecha por las partes, se ve inhibido de salir del marco impuesto para buscar la verdadera voluntad contractual.

El contrato mantiene en nuestro país un razonable grado de respetabilidad, en el sentido de que quienes lo otorgan sienten en su fuero interno el deber de cumplir lo pactado. No obstante, no puede dejar de observarse que tal sentimiento pareciera estar en decadencia, ya que cada vez un mayor número de personas han descubierto que el incumplimiento de los deberes contractuales no acarrea una sanción fulminante sino, de contrario, lleva a las partes a la necesidad de arrastrarse en un largo peregrinaje judicial en que no siempre la parte diligente y cumplidora obtiene lo que le corresponde.

Por lo anterior, el estudio de los contratos cobra hoy en día mayor importancia. Sólo un acabado conocimiento de su estructura y funcionamiento permitirá su adecuada elaboración y afinamiento, lo que ciertamente contribuirá a evitar el abuso de personas inescrupulosas que pretendan burlar el cumplimiento de las obligaciones que de ellos se originan.

2. - Concepto de contrato en el Código Civil.

En relación con los contratos, el art. 1437 establece que en ellos las obligaciones nacen “del concurso real de las voluntades de dos o más personas”, y el art. 1438 define el contrato como “un acto por el cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”.

Los autores critican esta definición desde dos puntos de vista.

"Se sostiene que es equivocada la terminología que se emplea en dichos artículos, en cuanto se identifican o dan como sinónimos los términos contrato y convención, en circunstancias que la convención sería el género -acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones- y el contrato sólo sería una especie de acuerdo de voluntades destinado a crear derechos personales y las correlativas obligaciones. Todo contrato es convención, pero no a la inversa. Así, la resciliación, el pago y la tradición son actos jurídicos bilaterales o convenciones, pero no son contratos. Al respecto es conveniente tener presente que son numerosos los ordenamientos en que se identifica el contrato con la convención (BGB, C.C. Italiano)".

"La otra crítica dice relación con la elipsis contenida en el art. 1438 ya que en verdad el objeto del contrato son las obligaciones que él crea, por su parte toda obligación tiene por objeto una o más cosas que se trata de dar hacer o no hacer, según el art. 1460. De modo que cuando el art. 1438 establece que en el contrato una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer, se salta una etapa, pues alude a la prestación como objeto del contrato, a pesar de que la prestación como objeto del contrato, siendo que ella es el objeto de la obligación y no el objeto del contrato. Mejor habría sido que el legislador hubiese dicho que el contrato engendra obligaciones y que éstas tienen por objeto dar, hacer o no hacer alguna cosa". (Los contratos - Jorge López Santa María).

3. - Funciones económica y social de los contratos.

"A veces el contrato aparece como un utensilio casi primitivo, que sirve para canalizar jurídicamente las necesidades más simples o rudimentarias de intercambio. Múltiples contratos son negocios menores, de trámite rapidísimo, puramente manuales, en los que ni siquiera media la conciencia de estar contratando. El contrato se presenta, entonces, como un instrumento despersonalizado, apto para el constante flujo de bienes y servicios indispensables para la vida cotidiana de una civilización de consumo como la actual. No pocas convenciones se celebran a través de máquinas automáticas. El acuerdo de voluntades, si existe, pasa desapercibido.

En otras ocasiones, en cambio, el contrato aparece como una fina herramienta que permite a las partes satisfacer necesidades más complejas en los campos de la computación, de la transferencia de tecnología, de las actividades mineras, y en varios otros, generalmente el contrato se celebra luego de largos y difíciles tratos preliminares que al fin se cierran en una armonización de las posturas e intereses divergentes de las partes. Lo mismo ocurre, en cualquier campo, y generalmente hay grandes sumas de dinero comprometidas.

Simple o complejo, el contrato cumple evidentemente una función económica de la máxima importancia constituyendo el principal vehículo de las relaciones económicas entre las personas. La circulación de la riqueza, el intercambio de los bienes y de los servicios, primordialmente se efectúa a través de contratos. El mundo de los negocios sería imposible sin contratos. Así las cosas, la vida de todos se halla salpicada de contratos y nadie escapa, de consiguiente, al influjo de las normas legales que los regulan.

La importancia práctica del contrato se mantiene cualquiera sea el régimen económico en vigor, aunque algunos principios y dogmas puedan entrar en crisis si se acentúa el intervencionismo estatal. Cualesquiera sean las relaciones económicas, la contratación subsiste como fenómeno sociológico y jurídico fundamental.

Fuera de la función económica el contrato cumple una función social. No sólo sirve para la satisfacción de necesidades individuales. Además, es medio de cooperación o colaboración entre los hombres.

El trabajo, el acceso a la vivienda, el estudio, la recreación, el desenvolvimiento cultural, el transporte urbano, etc., implican casi siempre la dimensión social o relación cooperadora de unos con otros. Esas y otras actividades son incomprensibles sin contratos.

Sólo en este siglo ha llegado a ser ostensible la función social del contrato. El contrato voluntarista del siglo XIX permitió tantas veces la explotación del débil por el fuerte, que el legislador hubo de intervenir, dictando normas imperativas reguladoras de las principales cláusulas de los contratos socialmente más significativos; apareció así el contrato dirigido, iniciándose el siglo del orden público social o de protección de aquellos carentes de poder negociador.

Pero no siempre la cooperación viene impuesta a los contratantes desde afuera; a veces ésta se genera (la cooperación se realiza) espontáneamente por los participantes en la relación contractual.

Desde un punto de vista más técnico, la función social del contrato se relaciona directamente con el principio de la buena fe, el cual impone a cada parte, el deber de lealtad y de corrección frente a la otra durante todo el trayecto contractual. O sea, desde las conversaciones preliminares o fase precontractual, pasando por la celebración, hasta la ejecución del contrato y las relaciones post contractuales". (Jorge López Santa María - De los Contratos).

4. - Requisitos del contrato.

Para que haya contrato basta un acuerdo de voluntades creador de obligaciones, esto es lo único que exigen las disposiciones de nuestro derecho positivo. Así los arts. 1437 y 1438 no requieren más que el acuerdo de voluntades de dos o más personas destinado a crear obligaciones.

Hay autores, como Demogue y Claro Solar, que sostienen que no puede haber contrato si los intereses de las partes no son contrapuestos. Se argumenta en contrario señalando que la sociedad es un contrato y los intereses de los socios no son opuestos, ya que aunque son distintos, tienen un mismo fin: la utilidad en el negocio.

Otros, como Hauriou, sólo consideran contratos a los actos jurídicos que crean obligaciones de efecto temporal o transitorio, como la compraventa y la permuta. Dentro de esta doctrina, no serían contratos los acuerdos de voluntad que dieran origen a situaciones jurídicas permanentes. Según ella, el Matrimonio, la Adopción, la Sociedad, etc., no serían contratos, pues a más de generar obligaciones, crean estados o situaciones jurídicas de carácter permanente, destinadas a durar largo tiempo.

La expresión contrato envuelve, tanto a las convenciones que dan origen a obligaciones patrimoniales, como a las que generan obligaciones morales.

5. - Fundamento de la obligatoriedad de los contratos.

La determinación del fundamento en que se basa la fuerza obligatoria de los contratos es un problema que pertenece a la Filosofía del Derecho y sobre cuya solución discrepan los autores.

Algunos justifican la obligatoriedad de los contratos por una exigencia de la vida social, en cuanto es un imperativo de ésta la contratación, por cuya virtud se operan los cambios y se satisfacen las necesidades humanas. Esta opinión peca de ser ambigua, ya que de esta manera se justifican todas las normas jurídicas, pero no se explica de modo específico la norma que impone la observancia de la obligación contractual.

Bentham recurre al concepto de utilidad o interés individual, que impulsa, por motivos de conveniencia, a guardar las promesas. Los contratos tienen fuerza obligatoria, porque es útil y conveniente para los interesados, pues si una persona no cumpliese nadie querría contratar con ella.

Pufendorf basa la obligatoriedad del contrato en un pacto social tácito, según el cual cada hombre se compromete con los demás a guardar fidelidad a su palabra.

Giorgi recurre al concepto de la veracidad: estando el hombre obligado a decir la verdad y a obrar en conformidad a ella, tal deber le alcanza cuando manifiesta su voluntad de obligarse.

Otros autores hallan la razón de la fuerza obligatoria en la limitación que la persona impone a su propia libertad. Si el derecho de crédito se concibe como una relación que vincula en favor del acreedor, la libertad del deudor limitadamente a uno o más actos determinados, se adecua a la naturaleza del vínculo contractual y es plenamente satisfactoria la construcción que afirma que se trata de una voluntad de abdicación de una parte de la propia libertad por un lado, y de la correspondiente apropiación de ésta por el otro. El que se obliga contractualmente renuncia relativamente a uno o varios actos a regir por sí la propia actividad, y como la renuncia se hace en favor de otro, éste adquiere el derecho de penetrar en la esfera no libre de aquél.

Pero, de este concepto, en opinión de Ruggiero, hay que remontarse a otro más elevado que constituye el verdadero fundamento de la obligatoriedad del contrato: La unidad de la voluntad contractual. Las voluntades aisladas de los contratantes en el momento en que declaradas coinciden, pierden cada una su propia autonomía y al fundirse dan lugar a una nueva voluntad unitaria (voluntad contractual) y ésta será la que regirá dentro de la esfera preestablecida, las relaciones entre las partes; las voluntades aisladas no pueden sustraerse a la voluntad contractual, porque su contenido se ha independizado totalmente de esa libre voluntad de las mismas.

6. - El consentimiento.

La base fundamental sobre la que reposa el contrato es el consentimiento de las partes, esto es el acuerdo de voluntades de dos o más personas sobre el objeto jurídico. Todo contrato, cualquiera sea su naturaleza o calificación, cualquiera sea la obligación que genere, para una o ambas partes, supone el consentimiento de las mismas, porque nace del acuerdo de voluntades: sin él no hay contrato. Sólo quedan afectados los que han concurrido con su voluntad a celebrar el contrato; son las partes contratantes quienes pueden beneficiarse de los derechos que engendre o ser afectados por las obligaciones que pueda crear. Todo contrato, legalmente celebrado, es ley para los contratantes, art. 1545.

Quien no ha concurrido con su voluntad al contrato, quien no ha expresado su voluntad para generarlo, es un tercero ajeno al mismo. Él no puede invocar los derechos que origina ni quedar afectado por las obligaciones que del contrato emanan.

Sin embargo, la regla señalada no tiene carácter absoluto. Hay casos en los cuales la ley considera de interés público admitir contratos que puedan afectar y obligar a personas que no han prestado su consentimiento. Esto ocurre en los contratos colectivos, que pueden definirse como “Aquellos que afectan y obligan a todos los miembros de un grupo o colectividad determinada, aunque no hayan consentido en el contrato, por el hecho de formar parte de dicho grupo”.

Si la ley exigiere en los contratos colectivos la aplicación rigurosa del principio que sólo se obliga el que ha

consentido, habría casos en que sería imposible su aplicación: nunca faltarían quienes se opusieran a su realización, y como el interés de los más debe prevalecer sobre el de los menos, la ley admite que la mayoría, con su decisión, imponga su pronunciamiento.

Nuestra legislación presenta varios casos de aplicación del contrato colectivo, ej.:

a) El convenio judicial de acreedores;

b) El acuerdo de los tenedores de debentures, y

c) El contrato colectivo de trabajo.

7. - Contratos de derechos patrimoniales y de derecho de familia.

En los contratos de derecho patrimonial, la ley es la voluntad de las partes; impera el principio de la autonomía de la voluntad.

Las partes pueden convenir todo respecto de su contenido, efectos y extinción *(eliminar de los contratos)*, porque su voluntad es la suprema ley en todos los contratos creadores de derechos y obligaciones patrimoniales.

En los contratos de derecho de familia no ocurre lo mismo. Las partes no pueden atribuirle efectos diferentes a los que la ley señala y, tampoco, fijarles duración distinta a la establecida por la ley. Los individuos que contraen matrimonio no pueden pactar que se generen tales o cuales obligaciones, ni pueden estipular condiciones o subordinar su duración a un plazo. Estos contratos son tales en cuanto nacen del concurso de las voluntades de las partes. Ellas son libres para celebrarlos o no, y en este sentido puede decirse que son contratos. Mas una vez prestado el consentimiento cesa la libertad de los individuos, debiendo aceptar los contrayentes los efectos que la ley señala.

El principio de la autonomía de la voluntad rige con mayor amplitud en las relaciones patrimoniales, especialmente las relativas a los derechos personales o créditos. Tratándose de los derechos reales, la voluntad no es tan absoluta. En efecto, la propiedad, sea mueble o inmueble, está organizada por la ley, ya que determina cómo se adquiere el dominio, sus efectos, etc., es decir, todo lo concerniente a organización de la propiedad está excluido de la voluntad de las partes, no sucediendo lo mismo con los derechos personales o créditos, donde la voluntad de las partes puede desarrollarse ilimitadamente.

8. - Elementos de los contratos.

De acuerdo con el art. 1444, en cada contrato se distinguen las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales.

9. - La autonomía de la voluntad.

En materia de contratos, la suprema ley es la voluntad de las partes. Ella es la que dicta el derecho, la que elige la regla jurídica por la cual se van a regir el o los vínculos que crean. Los contratos necesitan el acuerdo de voluntades de dos o más partes y es éste, salvo ciertas restricciones establecidas por la ley para proteger a los incapaces y en interés público o de la moral, el que determina su alcance, extensión, efectos y duración.

Esta facultad para determinar a su entera voluntad y sin más restricciones el alcance, efectos y duración del contrato que celebran, constituyen la autonomía de la voluntad, principio que sigue siendo la base de la teoría contractual.

La autonomía de la voluntad puede definirse diciendo que "Es la libre facultad de los particulares para celebrar el contrato que les plazca y determinar su contenido, efectos y duración". En virtud de este principio, los particulares son libres de celebrar los contratos que más convengan a sus intereses, sean o no previstos y reglamentados especialmente por la ley. Ellos tienen la más amplia libertad para pactar del modo que sea más útil y conveniente a sus fines, para atribuirles a los contratos que celebren efectos distintos de los que la ley les atribuye, y aun, para modificar su estructura jurídica.

En virtud de la autonomía de la voluntad, las partes pueden transformar en solemne un contrato consensual, arts. 1802 y 1921; modificar un contrato suprimiendo cosas de la naturaleza del mismo, alterar su contenido, objeto, efecto, alcance, los derechos y obligaciones que engendra, su duración, etc.

Por esto, las leyes que rigen los contratos son supletorias de la voluntad de los contratantes, aplicándose únicamente en el silencio de éstos.

La misión de los jueces sobre el particular es establecer la voluntad de las partes, mas no crearla ni sustituirla.

Este principio de la autonomía de la voluntad, que establece la libre facultad de los particulares para pactar los contratos que les plazcan, determinar sus efectos, duración, contenido, etc., no es una libertad ilimitada, ella tiene restricciones, que son:

a) No pueden los particulares alterar o modificar las cosas de la esencia de los contratos, pues si lo hacen éste no produce efecto alguno o degenera en otro diferente, art. 1444. Así las partes contratantes, invocando la autonomía de la voluntad, están impedidas de pactar una compraventa sin precio o un arrendamiento sin renta. La voluntad es insuficiente para crear un contrato donde según la ley no puede existir.

b) Las limitaciones impuestas por las leyes fundadas en el orden público o la defensa de las buenas costumbres. Las partes nada pueden estipular contra las prohibiciones legales, el orden público o las buenas costumbres. Es nulo absolutamente el contrato que adolezca de ilicitud de objeto o causa, art. 1682.

La autonomía de la voluntad, tal como la consagra el C.C. y la casi totalidad de la legislación mundial, no es sino la aplicación de las ideas de la Revolución Francesa aplicadas a los contratos. Se dice que si los derechos son meras facultades que la ley reconoce a los individuos para la satisfacción de sus propias necesidades, es lógico que los individuos puedan ejecutar aquellos actos que les plazcan o conduzcan a ello (a *la satisfacción de sus necesidades)*, siempre que se mantengan las limitaciones fundadas en el orden público y las buenas costumbres. La consecuencia es que la voluntad de los contratantes debe ser limitada en los casos extremos.

La intervención del legislador en materia contractual debe reducirse al mínimo, porque siendo el contrato resultante del acuerdo de voluntades de dos personas en pie de igualdad jurídica, no puede ser fuente de injusticias.

La teoría de la autonomía de la voluntad lleva a tal extremo el rol creador de la voluntad, que, según ella, muchas disposiciones legales no serían sino la interpretación de la voluntad tácita o presunta de las partes. Así, la sociedad conyugal nace a falta de otra estipulación por ser el deseo de los contrayentes; en la sucesión intestada se supone que el difunto quería que se le sucediera en el orden que la ley determina.

Las exageraciones del principio de la autonomía de la voluntad produjeron una reacción y severas críticas en su

contra.

No sólo se ha negado a la autonomía de la voluntad toda fuerza creadora de obligaciones, sino que se ha criticado el fundamento mismo del principio.

Se arguye, por los detractores, que no es efectivo que el contrato no pueda engendrar injusticia, que no es verdad que los contratantes se encuentren en pie de igualdad, puede haber una igualdad jurídica, que la situación ante la ley sea tal, pero ello puede no corresponder a las circunstancias reales de los contratantes. Señalan que muchas veces el contrato es impuesto por una de las partes a la otra, la cual o acepta las condiciones o no contrata.

CAPÍTULO II

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

El Código Civil en los artículos 1439 a 1443 contiene algunas clasificaciones de los contratos, a ellas deben agregarse otras formuladas por la doctrina:

1. - Contratos unilaterales y bilaterales.

Los define el art. 1439 del Código Civil. Para clasificarlos se atiende al número de obligaciones que el contrato engendra, no al número de partes que al momento de la formación del mismo quedan obligadas.

La clasificación de los contratos en uni y bilaterales no es de orden público. Las partes pueden libremente darles el carácter de unilaterales o bilaterales. Pero, en los contratos bilaterales parece que ello no es posible, ya que tal carácter debe desprenderse de su propia naturaleza. En el caso del contrato unilateral sí es procedente; por ej.: la donación entre vivos, arts. 1405, 1426 inc. 2º.

El mandato puede ser unilateral o bilateral, al arbitrio de las partes, según el art. 2117, ya que puede ser gratuito o remunerado.

Determinar si un contrato es bilateral o unilateral, es decir, si impone obligaciones a una sola de las partes o a ambas simultáneamente, es una cuestión de hecho que corresponde establecer a los jueces de la instancia.

Existen contratos que en el momento de su formación originan obligaciones sólo a una de las partes, pero que en el transcurso de su existencia, entran a obligar a la otra parte. Ej. el comodato: si el comodatario ha hecho gastos de conservación de la cosa o si ésta ha sufrido daños, nacen para el comodante las obligaciones de restitución o de indemnización de perjuicios.

Otro tanto sucede en el mandato, art. 2158 N° 5. Estos contratos, que en su formación sólo imponen obligaciones a una de las partes y en que ulteriormente resulta también obligada la otra son los que se conocen con el nombre de "sinalagmáticos o bilaterales imperfectos".

La clasificación de los contratos en unilaterales y bilaterales presenta interés práctico, porque muchos de ellos están sometidos a reglas diferentes.

En los contratos bilaterales se dice que la causa de la obligación de una de las partes es la obligación de la contraparte; lo que no sucede en los contratos unilaterales en razón de su propia estructura.

De este concepto de causa en los contratos bilaterales se desprenden importantes consecuencias, que son a la vez diferencias entre los contratos uni y bilaterales:

1) La regla de que la mora purga la mora, art. 1552, tiene sólo cabida en los contratos bilaterales;

2) La condición resolutoria tácita, art. 1489, sólo se subentiende en los contratos bilaterales.

2. - Contratos gratuitos y onerosos.

Da un concepto de ellos el art. 1440. De acuerdo con esto para calificar un contrato de gratuito u oneroso se atiende a la utilidad que el acto reporta a los contratantes. Si sólo reporta utilidad a uno de ellos, quien nada da en cambio, el contrato es gratuito o de beneficencia. Si ambos contratantes se benefician o reportan utilidad del contrato, éste es oneroso.

Son contratos onerosos: la compraventa, la permuta, el arrendamiento, la sociedad, el mandato remunerado, el mutuo con interés, etc.

Son contratos gratuitos: la donación, el comodato, el depósito, el mandato gratuito, el mutuo sin interés.

Para calificar de oneroso o gratuito un contrato, no hay que atender a la reciprocidad de las obligaciones que el contrato pueda engendrar, sino a la reciprocidad de beneficios.

Hay contratos unilaterales que son onerosos, por ej. el mutuo con intereses, que sólo impone obligaciones al mutuario, y es oneroso porque ambas partes se benefician.

De aquí se desprende que si los contratos bilaterales son siempre onerosos, no ocurre igual con los unilaterales. Esto se debe a que el carácter de gratuito u oneroso no es de esencia de los contratos.

Las partes pueden, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, por lo general, darles uno u otro carácter. Se dice "por lo general" por cuanto hay contratos, como el comodato, que por su esencia es gratuito y no podrían las partes cambiar su estructura.

Los contratos gratuitos pueden importar o no una disminución del patrimonio de parte de quien soporta el gravamen. Importa una disminución del patrimonio el contrato de donación, art. 1398.

Pero hay contratos gratuitos que no significan disminución de patrimonio y que se llaman en doctrina contratos desinteresados. Son gratuitos, porque una sola de las partes reporta utilidad de ellos; mas no constituyen carga patrimonial, pues no hay transferencia de bienes. Ej. el mandato gratuito, el comodato, el mutuo sin interés, arts. 1395, 1396 y 1397.

En la práctica es difícil determinar si un contrato es gratuito u oneroso. Para establecerlo hay que tomaren consideración toda la operación en conjunto. Así, es necesario analizar no sólo la utilidad material, sino también la intención de los contratantes. De aquí que será menester atender a las relaciones preexistentes o futuras entre las partes. Por ej. tratándose de la fianza, prenda o hipoteca, cuando es el propio deudor el que da fianza, prenda o constituye hipoteca, no cabe duda que esas cauciones son onerosas, pues tienen por objeto la utilidad de ambas partes; pero la duda se presenta cuando es un tercero el que lo hace. Si se celebra sin exigir remuneración, será entre acreedor y fiador un contrato gratuito.

Un contrato puede ser en parte oneroso y en parte gratuito. La donación remuneratoria es ejemplo típico de ello, arts. 1188, 1405 y 1434.

Determinar si un contrato es gratuito u oneroso es una cuestión de hecho que corresponde calificar a los jueces de fondo.

La clasificación de los contratos en gratuitos y onerosos presenta interés práctico, pues en muchos aspectos están sometidos a reglas diferentes:

1) Para determinar los efectos del error en las partes, art. 1455.

2) Para el efecto de determinar la responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas, art. 1457.

3) Para los efectos de saber si incumbe o no responsabilidad por la evicción de la cosa objeto del contrato: por regla general el deudor responde del saneamiento de la evicción en los contratos onerosos, pero en los contratos gratuitos, en principio no responde de ella, arts. 1422, 1423 y 1435.

4) En materia de acción pauliana, art. 2468.

3. - Contratos conmutativos y aleatorios.

Es una subdivisión de los contratos onerosos y se encuentra contemplada en el artículo 1441.

En los contratos aleatorios la contingencia incierta de ganancia o pérdida debe existir para ambos contratantes. Es imposible que sea solamente aleatorio para una sola de las partes.

La regla general es que los contratos onerosos sean conmutativos. Los aleatorios constituyen la excepción. Son tales los que enumera el art. 2258 del Código Civil, pero dicha enumeración no es taxativa, existiendo otros que no figuran en ella. Por otra parte, nada obsta a que los contratantes puedan transformar en aleatorios contratos que no lo son, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, ej. art. 1813.

Presenta interés esta subclasificación para los efectos de determinar la procedencia o improcedencia de la acción rescisoria por lesión enorme.

4. - Contratos principales y accesorios.

Contempla esta clasificación el art. 1442.

La regla general es que los contratos sean principales.

Los contratos accesorios necesitan ir adheridos a uno principal y nada importa la naturaleza de la obligación que garantizan. Estas pueden ser contractuales, cuasicontractuales, etc. Todo contrato que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, es un contrato accesorio. Estos contratos accesorios corresponden a lo que ordinariamente se llama cauciones, art. 44.

La clasificación de los contratos en principales y accesorios no tiene importancia sino para determinar la extinción de los mismos. “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. Confirman la aplicación de este principio los arts. 2381, N° 3; 2434 y 2516.

Contratos dependientes: Hay muchos contratos que para producir sus efectos necesitan de la existencia de otro contrato. Ej. las capitulaciones matrimoniales, que si bien suponen la existencia de otro contrato -el matrimonio- no están destinadas a asegurar el cumplimiento de éste.

Estos contratos se llaman dependientes, porque están subordinados en cuanto a sus efectos a otro contrato, pero se diferencian de los accesorios en que su existencia no depende de otro contrato y no está destinado a asegurar su cumplimiento.

5. - Contratos reales, solemnes y consensúales.

Se contiene esta clasificación en el art. 1443.

La regla general en los contratos es que sean consensúales. No son reales o solemnes sino en los casos expresamente señalados por la ley.

1) Contrato consensúa!: para que haya contrato es necesario que las partes se hayan puesto de acuerdo en los elementos esenciales del mismo. Cuando la ley dice que los contratos son consensuales, no quiere decir que en este caso únicamente el contrato se perfeccione por el consentimiento de las partes, ya que todos lo necesitan, sino que basta el "solo consentimiento", que no precisa de solemnidad ni de entrega de la cosa.

2) Contrato solemne: es aquel, en que a más del consentimiento, la ley requiere la observancia de ciertas formalidades de manera que sin ellas el contrato no produce ningún efecto civil.

En estos contratos no se producen los efectos que le son inherentes mientras el consentimiento no se otorgue en la forma prescrita por la ley. Si las solemnidades no se cumplen, la ley entiende que el consentimiento no se produce.

Las formalidades pueden ser de diversa índole: instrumentos públicos o privados, presencia de un funcionario, etc. Pero sólo son solemnidades aquellas que la ley prescribe en consideración a la naturaleza del acto en sí mismo. Las formalidades que se imponen en razón de la calidad o estado de las personas que en ellos intervienen, no son solemnidades, sino formalidades habilitantes o de protección de determinadas personas.

Por eso, no todos los requisitos externos son solemnidades, se distinguen: solemnidades propiamente tales, formalidades hábilitantes, formalidades por vía de prueba, por vía de publicidad, etc.

La ley es la que da a un contrato el carácter de solemne, pero las partes pueden hacer solemne un contrato que no lo es. Así sucede con la compraventa de cosas muebles y con el arrendamiento, cuando se pacta que se harán por escrito, arts. 1802 y 1921.

Pero, mirando el fondo del asunto, no es lo mismo un contrato que es solemne por mandato de la ley que uno que lo es por la voluntad de las partes, porque si, en el primer caso, faltan las solemnidades, el contrato es nulo; en cambio, en el segundo caso, el contrato puede producir efectos aun cuando no se cumpla la formalidad convenida.

3) Contrato real: La redacción del art. 1443 contiene una impropiedad al emplear la expresión "tradición", porque el contrato real se perfecciona por la entrega, pues el término "entrega" es genérico y la tradición una especie de entrega que sirve para transferir el dominio.

En los contratos reales el consentimiento no se manifiesta sino mediante la entrega de la cosa.

La mayoría de los contratos reales se perfecciona por la entrega de la cosa, a excepción del mutuo, en que hay tradición y transferencia del dominio, art. 2197. El comodato, la prenda y el depósito se perfeccionan por la entrega, si no hay entrega la ley estima que no ha habido consentimiento y que no hay contrato.

El concepto de contrato real descansa en la naturaleza de las cosas; teniendo el deudor la obligación de restituir la cosa materia del contrato. El contrato nace cuando el deudor recibe la cosa materia de éste.

No se concibe que el deudor esté obligado a restituir el objeto materia del contrato si, previamente, no se le ha entregado el mismo. Hoy en día se critica el concepto de contrato real, por considerársele artificioso y cuyo desaparecimiento del derecho no causaría problema alguno.

Se señala que no es efectivo que la principal obligación del deudor en un contrato real sea la de restituir la cosa objeto de él. Sería absurdo celebrar un contrato para el único efecto de que la otra parte que recibe la cosa tenga que

restituirla posteriormente. No es éste el objeto primordial de tales contratos. La razón determinante en cada uno de estos contratos, en virtud de la cual se entrega la cosa al mutuario o comodatario es la de proporcionarle el uso y goce la cosa prestada. Para eso se contrata: para que el comodatario y el mutuario gocen del objeto materia del contrato. Quien entrega la cosa al depositario no lo hace con el fin de que éste se la restituya; la razón determinante es confiarle el cuidado de la cosa que el depositante no puede conservar en su poder. El deudor prendario que entrega la cosa dada en prenda al acreedor es el de suministrar una garantía especial de la obligación preexistente entre las partes.

No es lógico sostener que la restitución de la cosa es consecuencia de la entrega de la misma y que la restitución no puede tener lugar sino una vez que la cosa ha sido entregada por el deudor. No se ve qué inconveniente pueda haber para que el contrato se forme aun sin esa entrega. Por ej. el arrendatario no tiene como principal obligación la de restituir la cosa arrendada al término del arrendamiento. Este devolverá la cosa una vez que le haya sido entregada, porque si el arrendador no cumple sus obligaciones no puede exigirle al arrendatario que cumpla las suyas. El cumplimiento de las obligaciones por parte del arrendatario supone la entrega de la cosa por parte del arrendador, y el arrendamiento en toda época ha sido un contrato consensual y no real.

Es, pues, posible que desaparezca el concepto de contrato real y los actuales contratos reales puedan ser contratos consensúales, donde la entrega no representa más que el cumplimiento de la principal obligación que el contrato impone.

6. - Contratos nominados e innominados.

Esta clasificación se hace atendiendo a si el contrato está o no reglamentado por la ley.

Un contrato es nominado cuando está reglamentado por la ley, ej.: compraventa, mutuo, arrendamiento, etc.

Los contratos innominados son los que escapan a la previsión del legislador y no tienen reglamentación.

Los contratos innominados pueden ser celebrados en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, que autoriza para pactar cualquier contrato, sea cual fuese su naturaleza, siempre que se respete la ley, el orden público y las buenas costumbres. Estos contratos son múltiples, tantos cuantos la imaginación humana pueda concebir.

Los contratos innominados se rigen:

1) Por las reglas generales aplicables a todos los actos jurídicos;

2) Por las estipulaciones de las partes, y

3) Se le aplican por analogía las reglas de los contratos nominados más semejantes, siempre que lo permita la naturaleza especial del contrato innominado.

En Chile, los contratos innominados tienen plena validez en virtud del principio consagrado en el artículo 1545.

No deben confundirse los contratos innominados con los mixtos o complejos, que son aquellos formados por la reunión de varios contratos nominados cada uno de los cuales conserva su individualidad y, por lo mismo, quedan sujetos a las reglas que les son propias. Ej.: arrendamiento con promesa de venta. En estos casos nos encontramos, no frente a contratos innominados, sino ante dos o más contratos distintos, y aunque agrupados, cada uno conserva su individualidad propia, de tal modo que uno puede extinguirse sin que ocurra lo mismo con el otro.

Sin embargo, y ello no debe llevar a confusión, hay ciertos contratos innominados que presentan las características de varios contratos nominados, como sucede por ejemplo con el hospedaje, que participa de los caracteres de la compraventa y del arrendamiento.

7. - Contratos de libre discusión y de adhesión.

Atendiendo a la forma como se produce el acuerdo de voluntades de las partes, los contratos se clasifican en contratos de libre discusión y de adhesión.

Contrato de libre discusión es aquel en que las partes estipulan libremente sus diversas cláusulas.

Constituyen el tipo normal de contratos, y son la resultante de una discusión entre las partes.

Contrapuestos a los contratos de libre discusión están los contratos de adhesión, aquellos en los cuales no hay discusión posible entre las partes y que se forman mediante la aceptación lisa y llana, por una de ellas de las condiciones señaladas por la otra. Mientras en los primeros cada parte propone algo, produciéndose una discusión hasta llegar a un acuerdo, en los contratos de adhesión una de las partes impone a la otra las condiciones del contrato, pudiendo esta última sólo aceptarlo o rechazarlo.

8. - Contratos individuales y colectivos.

El contrato es individual cuando para su formación requiere el consentimiento unánime de las partes que lo celebran. Lo que caracteriza al contrato individual es el hecho que sólo puede originarse cuando todas las partes han consentido en él.

Contrato colectivo, en cambio, es aquel que afecta a todos los miembros de un grupo o colectividad, aunque no hayan consentido en él, por el solo hecho de formar parte de ese grupo.

Lo que caracteriza al contrato colectivo es que afecta a personas que no han consentido, que no han concurrido a su celebración. Mientras en el contrato individual todas las partes deben consentir, en término que sólo afecta a quienes han prestado su consentimiento para celebrarlo, el contrato colectivo, en cambio, afecta a personas que no han consentido.

Se puede decir que el contrato individual es aquel que se celebra por la unanimidad de las partes y que contrato colectivo, aquel celebrado por la mayoría de los interesados.

La regla general es el contrato individual, siendo el colectivo la excepción.

9. - Contratos de ejecución instantánea y de ejecución sucesiva.

En los contratos de ejecución instantánea las obligaciones se cumplen en un solo momento.

En cambio, el contrato es de ejecución o tracto sucesivo cuando las obligaciones de las partes, o de una de ellas a lo menos, consisten en prestaciones periódicas o continuas.

Se caracterizan porque una de las obligaciones de las partes, a lo menos, se desarrolla continuamente en el tiempo. Las prestaciones que ella envuelve se van desarrollando a medida que el tiempo transcurre.

En el contrato de ejecución instantánea la obligación se cumple en el momento preciso en que la prestación se ejecuta; en los contratos de tracto sucesivo, es menester el transcurso del tiempo, porque la obligación consiste en proporcionar a la otra parte el goce eficaz, del que es condición el tiempo.

Ejemplo típico de contrato de tracto sucesivo es el de arrendamiento.

No deben confundirse los contratos de tracto sucesivo con los contratos de ejecución escalonada o a plazo, que son

aquellos en que las obligaciones de las partes se cumplen por parcialidades en diferentes oportunidades. Es el caso de la compraventa cuyo precio se paga a plazo, en cuotas. Este no es un contrato de tracto sucesivo donde las obligaciones de las partes se van desarrollando minuto a minuto, sino un contrato en que las obligaciones se dividen en diversas cuotas, cada una de las cuales se cumple en un momento dado.

Esta clasificación de los contratos tiene importancia en diversos aspectos:

1) El efecto retroactivo de la resolución sólo opera en los contratos de ejecución instantánea.

2) También se diferencian los contratos de ejecución instantánea y los de tracto sucesivo en los efectos que en el contrato produce la pérdida fortuita del objeto debido o la imposibilidad de ejecución por el deudor.

Si el objeto perece, la obligación del deudor se extingue, y si el contrato es bilateral, el deudor queda relevado de su obligación, no ocurriendo lo mismo con la otra parte. Estos principios tienen plena aplicación en los contratos de ejecución instantánea. En los contratos de tracto sucesivo ocurre lo contrario. Como las obligaciones se desarrollan en el transcurso del tiempo y la obligación de una de las partes supone la de la otra, la extinción de una de las obligaciones de las partes, la imposibilidad de ejecución de una de ellas tiene por efecto la extinción total del contrato o su modificación mientras dure el impedimento.

3) Por último, la teoría de la imprevisión sólo se admite por la doctrina y la jurisprudencia en los contratos de tracto sucesivo. Sólo en estos contratos, llamados a cumplirse en un tiempo lejano, es posible que las transformaciones económicas hagan oneroso cumplirlos. En los contratos de ejecución instantánea no se admite la teoría de la imprevisión.

CAPÍTULO III

EFECTOS DE LOS CONTRATOS

Para estudiar los efectos de los contratos hay que distinguir las siguientes clases de personas: las partes y los terceros y, dentro de éstos, los terceros relativos y los terceros absolutos. En cuanto a cada una de ellas los efectos son distintos.

1. - Efectos entre las partes.

Por regla general el contrato sólo produce efectos respecto de las partes.

Nuestro legislador no dijo que el contrato sólo produce efectos entre las partes, a diferencia del Código francés, en el cual hay una disposición expresa que consagra este principio. Pero, el hecho que no exista tal disposición en nuestro Código no puede llevar a la conclusión contraria; Bello no lo dijo porque lo consideró obvio e innecesario consignarlo.

Esto es una aplicación del principio de que nadie puede quedar obligado sino en virtud de una declaración de voluntad, y esta declaración sólo la hacen las partes y no terceros.

Los efectos que produce el contrato entre las partes están señalados en el artículo 1545. Esta disposición contempla en forma clara y precisa el principio de la autonomía de la voluntad.

Se discute sobre el alcance de la palabra ley que el legislador emplea en el artículo citado. Algunos sostienen que la obligatoriedad de los contratos constituye una verdadera asimilación a la ley, otros la niegan totalmente.

Se dice que el contrato es una ley en el sentido que no puede ser invalidado por la sola voluntad de una de las partes, así como la ley no puede ser derogada por ninguno de los individuos a que se refiere; pero no es en su esencia una ley.

Otros señalan que la voluntad de las partes es lo que constituye la ley del contrato, ley que ellas se dan a sí mismas, limitando la libertad respectiva en que antes se hallaban la una frente a la otra, y esta voluntad es la que ha sido elevada a la categoría de ley; y la violación de esta ley debe ser sancionada del mismo modo que la violación de cualquier ley a que de un modo general están sometidos los convenios de los contratantes y a la cual han entendido someterse desde que siéndoles permitido no han modificado esa ley general. Hay una verdadera razón de orden público y de interés social para proceder de este modo, a fin de asegurar el estricto cumplimiento de las convenciones; y es precisamente esa consideración de equidad absoluta la que el legislador ha tenido en mira al decir que los contratos son una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causa legal.

Por otra parte, se agrega que los efectos jurídicos que de los contratos nacen, son los que la ley les ha fijado teniendo en consideración los fines económicos perseguidos por los contratantes y con la mira de resguardarlos, de

modo que la violación de dichos fines no sería otra cosa que la violación de la ley.

Entre las partes el contrato es una ley. Y para estos efectos se entiende que es parte no sólo aquel que actúa por sí mismo, sino también el que actúa por medio de representante.

Un principio fundamental en esta materia es que los contratos deben ejecutarse de buena fe, art. 1546.

2. - Efectos respecto de terceros.

En términos generales, son terceros aquellas personas extrañas al contrato, los que no han concurrido materialmente a su celebración. Todo aquel que no es parte, es tercero.

Dentro de estos terceros hay que hacer una subclasificación. Porque puede haber algunos que con posterioridad a la celebración del contrato entren en relaciones jurídicas con las partes. Estos son los terceros relativos, y a ellos también afecta el contrato.

Estos terceros relativos son dos: los sucesores a título universal y los sucesores a título singular.

Se está en presencia del sucesor a título universal en caso del heredero, aquel que sucede en todos los bienes o en una cuota de ellos. En este caso, cuando se celebró el contrato entre el causante y el otro contratante los herederos no tenían ninguna relación con éste; pero a virtud de la muerte del causante, nacen relaciones jurídicas entre ellos, y por eso obligan a los herederos las estipulaciones del contrato. Porque los herederos son los continuadores de la persona del difunto. Jurídicamente cuando el causante fallece, éstos *(los herederos)* entran a ocupar el lugar de aquél. De ahí el aforismo; el que contrata para sí lo hace también para sus herederos.

Luego, el contrato produce efectos respecto de los sucesores a título universal, pero esta regla también tiene excepciones:

1) No alcanzan a los herederos los efectos del contrato cuando las obligaciones contraídas fueren intransmisibles;

2) Tampoco les alcanzan (a los herederos) los efectos del contrato cuando el contrato celebrado fuere intuito-persona, ej.: mandato.

3) Tampoco afectan a los herederos los efectos del contrato cuando así se hubiere estipulado expresamente.

Además, entran en la categoría de los terceros relativos aquellos que hubieren sucedido a alguno de los contratantes a título particular. A éstos también les afectan los contratos celebrados por su causante. Algunos sucesores a título singular son:

1) El legatario de especie o cuerpo cierto, por ej. si el bien en que sucede está afecto a una hipoteca, el contrato hipotecario celebrado por su causante le afecta; igual sucede si se vende un bien raíz que está hipotecado, el comprador que es sucesor a título singular respecto del vendedor en lo que se refiere al bien vendido, también es afectado por la hipoteca;

2) En la cesión de créditos, el cesionario sucede a título singular al cedente.

Los otros terceros son los terceros absolutos, aquellos totalmente extraños al contrato, aquellos que no han sido parte ni que, con posterioridad, entran en relaciones jurídicas con los contratantes. A estos terceros absolutos no pueden afectarlos los contratos; respectos de ellos no son obligatorios los derechos y obligaciones que emanan de él ***(del contrato)***.

Sin embargo la regla señalada tiene algunas excepciones:

En primer lugar, es necesario destacar que lo dicho respecto de los efectos de los contratos tienen relación

solamente con los contratos patrimoniales, pero no con los contratos de familia. Éstos no producen efectos relativos, sino absolutos.

En segundo lugar, otra excepción a la relatividad de los contratos se encuentra en los contratos colectivos.

Y, finalmente, una tercera excepción la ofrece en principio "la estipulación por otro".

2.1. - Estipulación por otro o en favor de otro.

Está reglamentada en el Código Civil en un solo artículo, el 1449. Ejemplo de estipulación en favor de otro: el marido que se asegura en favor de su mujer; aquí el contrato se celebra entre el marido y la compañía de seguros, siendo la mujer totalmente extraña a él.

En la estipulación en favor de otro intervienen tres personas: el estipulante, el promitente y el tercero beneficiario.

En el ejemplo propuesto, el marido es el estipulante; la compañía de seguros el promitente y la mujer el beneficiario.

El Código Civil acepta la estipulación en favor de otro en forma amplia, ya que el art. 1449 no contiene ninguna limitación.

a) Requisitos de la estipulación en favor de otro:

I. Requisitos respecto del estipulante:

El estipulante debe ser capaz para celebrar el contrato objeto de la estipulación. De ahí que no pueda darse una regla general. Si es una compraventa, debe tener la capacidad necesaria para la compraventa; si es donación, la necesaria para la donación, etc.

Pero, naturalmente que para que tenga valor la estipulación en favor de otro, se requiere que el estipulante no sea mandatario o gestor de negocios del tercero beneficiario, porque si contrata a favor de terceros en virtud de un mandato o de una gestión de negocios no nos encontramos en el campo de la estipulación en favor de otro, sino que se entra al campo del mandato o de la gestión de negocios. Por eso el art. 1449 dice "aunque no tenga derecho para representarla".

II. Requisitos respecto al promitente:

El promitente también debe tener capacidad necesaria para celebrar el contrato prometido y, además, debe tener la intención de crear el derecho en favor del tercero.

III. Requisitos que deben concurrir en el tercero beneficiario:

El tercero beneficiario se caracteriza porque no ha tenido ninguna injerencia en la celebración del contrato; éste se ha celebrado exclusivamente entre estipulante y promitente. De aquí resulta una consecuencia importante relativa a la capacidad que requiere el tercero beneficiario: no es necesario que tenga capacidad para contratar, es decir, capacidad de ejercicio; basta la capacidad de goce, capacidad necesaria para adquirir derechos; y por lo mismo nada impide que una persona se obligue en favor de un absolutamente incapaz.

No obstante lo anterior el tercero beneficiario debe estar en situación jurídica de adquirir el derecho establecido en su favor.

Ello tiene importancia en relación con las prohibiciones que establece la ley para ciertas personas de celebrar determinados actos y contratos, que podrían eludirse a través de la estipulación a favor de otro. Ej.: La Corte Suprema

declaró nulo el contrato por el cual el padre vendió a un hijo mayor de edad un inmueble, expresando este último que lo adquiría para sí y sus hermanos menores, porque a través de la estipulación a favor de otro se vulneraba el art. 1796.

La doctrina clásica exigía que el tercero beneficiario fuese siempre persona determinada y no aceptaba que fuere una persona futura, que no existía o indeterminada.

La tendencia actual es la propia legislación, especialmente en materia de seguros, es permitir que el beneficiario sea persona futura o indeterminada, con tal que pueda determinarse al momento de hacerse exigible el derecho, como ocurre por ejemplo en el seguro de vida a favor de los herederos que tenga el estipulante al tiempo de su fallecimiento: el seguro beneficia a los herederos, y no únicamente a los que existían al tiempo del contrato.

b) Naturaleza jurídica:

Tres son las principales doctrinas que tratan de explicar la naturaleza jurídica de la estipulación a favor de otro:

I. Doctrina de la oferta:

Según ella, en la estipulación a favor de otro sucedería lo siguiente: a virtud de la celebración del contrato entre estipulante y promitente, el derecho se radicaría primero en el patrimonio del estipulante, y entonces éste, a su vez, lo ofrecería al beneficiario, quien al aceptarlo, lo ingresaría a su patrimonio.

Esta doctrina no ha tenido mucho éxito, porque deja al tercero en una situación precaria sometido a todas las contingencias que pueda sufrir la oferta; así por ej.: en caso de fallecimiento del estipulante caducaría la oferta y se terminaría la estipulación. Además si el derecho se radica primero en el patrimonio del estipulante, dicho derecho sería susceptible de las acciones que los acreedores puedan intentar en contra del estipulante a favor de otro. Donde más aparece de manifiesto el error de esta doctrina es en el contrato de seguro de vida, ya que el beneficiario acepta el seguro a la muerte del estipulante, y según esta doctrina la estipulación caducaría a la muerte de éste.

I. Doctrina de la gestión de negocios:

Según ella el estipulante no sería sino un gestor de negocios con respecto al tercero y, entonces, la aceptación de que habla el art. 1449 que debe dar al beneficiario, no sería sino la ratificación que éste hace de la gestión realizada por el estipulante en su favor.

Pero a esta doctrina también se le han formulado objeciones. Porque no es lo mismo la estipulación en favor de otro que la gestión de negocios. Si lo fueran no habría razón para que el legislador las trate separadamente. Además, esta doctrina presenta otro inconveniente: en la gestión de negocios el agente oficioso contrata a nombre de otra persona; en cambio, en la estipulación en favor de otro el contrato lo celebra personalmente el promitente con el estipulante, pero no se atribuye representación alguna. La otra diferencia que hace inconfundibles ambas instituciones está en que una vez efectuada la estipulación, en realidad no hay vínculo jurídico alguno entre estipulante y tercero; en cambio, en la gestión de negocios nacen vínculos jurídicos entre el agente oficioso y la persona cuyos negocios se gestionan.

II. Doctrina de la creación directa del derecho a favor del tercero beneficiario:

Según esta doctrina al momento de celebrado el contrato entre el estipulante y el promitente nace, directamente en el patrimonio del tercero, el derecho que le otorga dicho contrato. Esta doctrina es la de mayor aceptación, sobre todo porque es la más beneficiosa para el tercero. Indiscutiblemente tiene una base legal en el art. 1449 que señala que sólo el tercero puede demandar lo estipulado.

La importancia de esta doctrina radica en que naciendo el derecho directamente en el patrimonio del tercero beneficiario, resulta que si éste fallece antes de la aceptación, nada obstaría para que ésta la hagan sus herederos.

a) Efectos de la estipulación en favor de otro:

Debe considerarse los efectos que se producen entre: estipulante y promitente; promitente y tercero, y estipulante y tercero.

I. Efectos entre promitente y estipulante:

Ambos son las personas que otorgan el contrato, de manera que por regla general los efectos serán los mismos que los de todo contrato. Pero hay ciertas características en estos efectos que son propios de la estipulación en favor de otro:

I) El estipulante no puede solicitar el cumplimiento de lo convenido. Sabemos que todo acreedor puede solicitar el cumplimiento de la obligación, pero en la estipulación en favor de otro el estipulante no puede exigir al promitente que cumpla lo estipulado, el art. 1449 señala expresamente que sólo el tercero beneficiario podrá demandarlo.

Pero existe una forma indirecta en que el estipulante puede compeler al promitente a cumplir la estipulación: a través de una cláusula penal, art. 1536, la cual se haría efectiva si el promitente no cumple lo convenido.

No hay inconveniente alguno en que el promitente se sujete a una pena a favor del estipulante si no cumple oportunamente lo convenido en favor del tercero beneficiario. A esto se refiere el art. 1536 inc. 3º. En síntesis, esta disposición establece que valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga efecto, si la persona con quien se estipula se sujeta a una pena para el caso de no cumplirse lo prometido. Lo excepcional del caso es que el estipulante no está facultado para exigir el cumplimiento de la obligación principal, pero por no haberse cumplido ésta al tercero beneficiario, nace su derecho a cobrar la pena. El estipulante que normalmente no tiene ningún derecho, pasa a tenerlo en el evento de incumplimiento.

2) De acuerdo al art. 1449 antes que intervenga la aceptación expresa o tácita del beneficiario pueden, estipulante y promitente de común acuerdo, revocar la estipulación y dejarla sin efecto.

En realidad este derecho que el art. 1449 otorga al promitente y estipulante no es sino una aplicación de la regla general contemplada en el art. 1567.

II. Efectos entre el promitente y el tercero:

El principal de estos efectos es que sólo el tercero puede demandar lo estipulado, art. 1449.

Como se ha señalado, antes que el tercero acepte la estipulación, puede ésta revocarse de común acuerdo entre estipulante y promitente. De ahí la importancia de la aceptación del tercero beneficiario. Porque, si bien la aceptación que hace el tercero no es necesaria para adquirir su derecho, el cual nace directamente en su patrimonio, esta aceptación tiene importancia para los efectos de la revocación que pueden hacer estipulante y promitente. Antes de ella, puede revocarse el contrato; después de ella no sería posible.

La aceptación no es la que hace nacer el derecho en el patrimonio del tercero beneficiario, sino que es necesaria para tomar posesión del derecho, para impedir la revocación que hasta ese momento pueden efectuar promitente y estipulante.

La aceptación puede ser expresa o tácita, art. 1449, mirándose como actos de aceptación tácita aquellos que podría efectuar el tercero sólo en virtud del contrato celebrado.

Existe acuerdo en el sentido de que el tercero no puede pedir la resolución de lo estipulado. Si el promitente no cumple no podría solicitar el tercero beneficiario la resolución; ello, porque el tercero no es contratante, no ha formado parte del contrato y la resolución sólo corresponde a los contratantes.

Por otro lado, el promitente puede oponer al tercero beneficiario las mismas excepciones que podría hacer valer contra el estipulante.

III. Efectos entre estipulante y tercero:

En principio, no se produce relación jurídica alguna entre estipulante y tercero beneficiario, puesto que el derecho nace directamente para éste, el derecho no existe en momento alguno en el patrimonio del estipulante, y, en consecuencia, no está sujeto a la garantía general de sus acreedores.

2.2. - Promesa de hecho ajeno.

A esta institución se refiere el art. 1450.

De esta disposición se desprende que la promesa de hecho ajeno no altera las reglas generales de los contratos. No es una excepción al efecto relativo de éste, como ocurre con la estipulación a favor de otro, porque en ésta el tercero beneficiario ajeno al contrato adquiere un derecho. En la promesa de hecho ajeno, en cambio, el tercero no contrae obligación alguna, así lo destaca el artículo citado. Es lógico que así sea, ya que el tercero no tiene por qué quedar obligado por el contrato celebrado y al cual no ha concurrido con su consentimiento.

El tercero sólo se obliga en virtud de su ratificación, únicamente entonces nace su obligación y ella deriva de su propia voluntad.

Por la promesa de hecho ajeno, sólo contrae obligación el que se comprometió a que el tercero hará, no hará o dará una cosa, y su obligación es de hacer, que el tercero ratifique, esto es, consienta en la obligación que se ha prometido por él.

En consecuencia, esta institución no es sino una modalidad especial de la prestación en la obligación de hacer, cuyo objeto es que el tercero acepte.

Como en la estipulación en favor de otro, aquí intervienen tres personas: el promitente, que es el que contrae la obligación de hacer; el prometido o acreedor, y el tercero que sólo será obligado una vez que ratifique. Y al igual que en la estipulación en favor de otro, es requisito indispensable para que se esté frente a una promesa de hecho ajeno que no medie representación, pues en tal caso hay lisa y llanamente obligación para el representado que no ha sido ajeno al contrato, art. 1450.

La promesa de hecho ajeno es de aplicación general; no hay limitaciones al respecto.

a) Requisitos de la promesa de hecho ajeno:

También hay que separarlos en referencia al contrato entre promitente y acreedor y a la ratificación del tercero.

No es posible sentar reglas generales, por cuanto los requisitos dependerán de la especie del contrato de que se trate. Desde luego, es consensual, por cuanto el legislador no lo somete a ninguna solemnidad especial.

Respecto del tercero deberá cumplir las exigencias necesarias para efectuar la ratificación. Como la ley no ha definido en qué consiste ésta, se ha fallado que debe ser entendida en su sentido natural y obvio y la constituirán todos

los actos del tercero que importen atribuirse la calidad de deudor que se le ha otorgado. La única limitación que han impuesto los tribunales es que si la obligación del tercero versa sobre bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, la ratificación debe otorgarse por escritura pública.

b) Efectos de la promesa de hecho ajeno:

Hay que distinguir entre las distintas partes que intervienen:

Entre promitente y tercero no resulta ningún efecto, salvo lo que ellos hayan convenido para que este último otorgue la ratificación.

Las relaciones entre el acreedor y el tercero sólo tendrán lugar cuando éste ratifique y, entonces, dependerán de la clase de obligación prometida. Como lo señala el art. 1450, ella puede ser de dar, hacer o no hacer. Prestada la ratificación, el deudor queda ya obligado como cualquiera otro, y procederá en su contra la ejecución forzada y la indemnización de perjuicio si no cumple.

Lo que nunca faltará en la promesa de hecho ajeno, es la responsabilidad del promitente. Éste contrae una obligación de hacer: obtener la ratificación.

Si el promitente fracasa en su intento, el acreedor no podrá obtener el cumplimiento forzado de la obligación, pues no hay forma de obligar al tercero a ratificar. Por ello, el art. 1450 da acción al acreedor para obtener que el promitente le indemnice los perjuicios del incumplimiento; es su único derecho.

Los perjuicios que debe indemnizar el promitente en caso de no obtener la ratificación del tercero, pueden ser prefijados en el contrato en que se prometió el hecho ajeno, mediante una cláusula penal. No hay inconveniente alguno que en la promesa de hecho ajeno, las partes fijen de antemano por medio de la cláusula penal, el monto de la indemnización que pagará el promitente al acreedor si aquél no obtiene la ratificación del tercero, art. 1536 inc. 2º.

Este precepto ha dado lugar a problemas de interpretación, porque se le ha querido conectar directamente con el art. 1450 y se ha encontrado el inconveniente de que ambas redacciones no coinciden: al parecer hay dos situaciones bien diferentes:

I. El promitente se ha sujetado a una pena para el caso de que el tercero no ratifique la obligación prometida por él. Dicha cláusula penal es válida y nada tiene de anormal porque está accediendo a una obligación principal existente, que es la que el art. 1450 impone al promitente, y cuyo incumplimiento lo obliga a la pena. El art. 1536 no tendría porqué referirse a esta situación que es igual a la de cualquier cláusula penal.

II. El caso previsto por el precepto es diferente: la pena ha sido impuesta al promitente para el caso de no cumplirse por el tercero la obligación prometida. El promitente está garantizando más que la ratificación, el cumplimiento de la obligación misma. Y entonces, es evidente que si el tercero no ratifica, no habrá cumplimiento posible, y el promitente deba la pena. En tal caso, la situación ya no es normal, porque la obligación principal no existe, pues habría nacido sólo con la ratificación, pero el Código no es muy preciso al determinar que ella hace excepción al inciso primero, ya que éste habla de nulidad. En el evento propuesto no hay nulidad, sino una obligación que no alcanzó a nacer.

En esta cláusula penal, pueden ocurrir dos cosas: el tercero ratifica y no cumple, se deberá la pena y nada hay de anormal porque la obligación principal existe. Y si el tercero no ratifica, se deberá la pena, y la situación es excepcional porque la obligación principal no existe. La expresión “aunque” que utiliza el precepto confirma esta interpretación: aun si no hay ratificación, se debe la pena, con mayor razón se la deberá si se ratifica la obligación y no

se cumple.

CAPÍTULO IV

LA INOPONIBILIDAD

Las personas a las que se aplica la inoponibilidad son los sucesores a título particular, esto es a aquellos terceros, excluyendo a los sucesores a título universal, que con posterioridad al contrato entran en relaciones jurídicas con las partes. No se considera a los contratantes, porque ellos son siempre los afectados, y a los sucesores a título universal, porque no son más que los representantes y continuadores del causante, y por ello los obliga el contrato al igual que a los contratantes.

Los terceros relativos pueden ser muchos y muy variados. No únicamente el legatario respecto del testador, ni el comprador del vendedor. Hay otras personas que son terceros relativos, como acontece con los acreedores de uno de los contratantes. Indiscutiblemente ellos tienen interés en los contratos que celebren sus deudores y, por lo tanto, la situación no puede ser la misma para un tercero absolutamente extraño que para este tercero acreedor. Por ello la noción de tercero no es del todo precisa.

La expresión "inoponibilidad" es extraña a la terminología del Código, si bien se usan expresiones semejantes como "no podrán oponerse".

a) La inoponibilidad no toca al contrato sino a sus efectos:

En esta institución hay que distinguir entre el contrato mismo y los efectos que produce. Porque la inoponibilidad no afecta al contrato en sí mismo. El contrato inoponible es perfectamente válido, no le falta ninguna condición esencial para su validez. La inoponibilidad se caracteriza porque los efectos del contrato no van a poder oponerse a los terceros relativos.

De lo señalado surge la diferencia entre la nulidad y la inoponibilidad: cuando un contrato se declara nulo, se extingue tanto entre las partes como respecto de terceros, se reputa como si jamás se hubiere celebrado. En la inoponibilidad, al contrato se le priva de sus efectos respecto de terceros, pero subsiste entre las partes. Por otro lado hay lugar a la nulidad cuando se ha omitido ciertos requisitos referentes a la existencia o validez del contrato, en tanto en la inoponibilidad el contrato es válido, sólo que por falta de ciertos requisitos no afecta a terceros.

b) Definición y clasificación:

Se la define como la ineficacia respecto de terceros de un derecho nacido como consecuencia de la celebración o de la nulidad de un acto jurídico.

Son variadas las causales que mueven al legislador a privar de eficacia ante terceros a un acto o contrato, o a su revocación o nulidad. Por ello se distingue entre inoponibilidad por causa de forma y por causa de fondo, a las cuales hay que agregar una tercera categoría, bastante excepcional: las inoponibilidades derivadas de la pérdida de eficacia de

un contrato.

A) Inoponibilidades de forma

Es sabido que las formalidades de publicidad tienden a permitir a los terceros enterarse de la existencia del contrato que puede afectarlos. Si no se cumplen, el legislador defiende al tercero estableciendo en su favor la inoponibilidad del acto o contrato mientras no se cumplan las formalidades omitidas.

Estas inoponibilidades son numerosas, las más conocidas son:

1) Las contraescrituras: el art. 1707 inc. 2º exige para que las contraescrituras públicas de escrituras públicas afecten a terceros, que se tome razón de ellas al margen de la escritura original y de la copia en virtud de la cual está obrando el tercero.

2) Prescripción adquisitiva: la sentencia judicial que declara la prescripción del dominio o derechos reales sobre inmuebles no valdrá contra terceros sin la competente inscripción, art. 2513.

3) La cesión de créditos: ésta se perfecciona entre las partes por la entrega del título y respecto del deudor y terceros por la notificación o aceptación del deudor, arts. 1901 y 1902. Mientras la notificación no se efectúe o el deudor acepte la cesión, ésta es válida entre cedente y cesionario, pero no puede oponerse ni al deudor ni a terceros.

4) Embargo de bienes raíces: conforme al art. 453 C.P.C si el embargo recae sobre inmuebles o derechos reales constituidos en ellos, no producirá efecto legal alguno respecto de terceros sino desde que se inscriba en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Mientras ella no se efectúe el embargo es inoponible a terceros. Ello tiene importancia entre otros aspectos para la aplicación del art. 1464 N° 3.

B) Inoponibilidades de fondo

Por causa del fondo del acto o contrato, las inoponibilidades pueden presentarse en varias circunstancias. Las más frecuentes derivan de la falta de concurrencia y del fraude.

I. Inoponibilidad por falta de concurrencia:

Se presenta cuando una persona no concurre con su consentimiento al otorgamiento de un acto o contrato que lo requería para producir sus plenos efectos:

Son casos representativos de esta forma de inoponibilidad:

1) La venta de cosa ajena: art. 1815. Este es uno de los casos más claros de inoponibilidad. La inoponibilidad consiste aquí en que para el verdadero dueño de la cosa vendida el contrato de compraventa no produce efecto y, por lo tanto, puede reivindicar la cosa de su dominio.

2) Mandato: El mandatario actúa como tal mientras se mantenga en los límites del poder que ha recibido: si los excede no hay representación, es como si actuara un tercero ajeno al mandante, y, en consecuencia, éste no queda obligado por los actos ejecutados por el mandatario excedido.

II. Inoponibilidad por fraude:

Uno de los peligros del efecto oponible del contrato para los terceros es que las partes se pongan de acuerdo para perjudicarlos, esto es, que lo otorguen con fines fraudulentos.

Así sucede en la simulación, en la cual el tercero no está obligado a reconocer sino el acto aparente; el oculto no le es oponible.

Otro caso de inoponibilidad por fraude, se presenta en la acción pauliana, que es justamente el derecho de los acreedores a dejar sin efecto los actos o contratos ejecutados en fraude de sus derechos. Ello en protección del derecho de prenda general.

C) Inoponibilidades derivadas de la nulidad o revocación

Determinadas situaciones jurídicas pueden afectar a terceros, y ser posteriormente dejadas sin efecto, con daño para los intereses de éstos.

Así ocurre con la nulidad que, judicialmente declarada, opera con efecto retroactivo y da derechos contra terceros. En casos muy excepcionales el legislador, sin embargo, no permite que la nulidad pueda ser invocada en contra de ellos no obstante su declaración judicial, como por ejemplo:

1) El matrimonio putativo, art. 122 inc. 1º.

2) La sociedad: de acuerdo al art. 2058 la nulidad del contrato de sociedad no perjudica las acciones que corresponden a terceros de buena fe en contra de todos y cada uno de los asociados por las operaciones de la sociedad, si existiere de hecho.

c) Efectos de la inoponibilidad:

La inoponibilidad obliga a distinguir los efectos entre las partes y en cuanto a los terceros a quienes puede afectar el contrato.

Entre las partes el acto o contrato es perfectamente válido y produce todos sus efectos. Pero respecto de terceros el acto no obstante su validez no les afecta.

Sin embargo, cuando se niega efectos al contrato es justamente en los casos en que existe interés por oponerlo a terceros, de manera que al privarlo de este poder, no hay duda que ello repercute en las relaciones entre los contratantes. Así, por ej., en la venta de cosa ajena, si el verdadero dueño reivindica la cosa vendida y el comprador es privado de ella, puede hacer efectiva la obligación de garantía contra el vendedor, para que éste le defienda en el pleito y le indemnice la evicción.

La inoponibilidad es un derecho del tercero; éste si quiere la invoca, pero si no tiene interés en ella, puede renunciarla, pues está establecida en su protección y beneficio.

d) Forma de hacer valer la inoponibilidad:

La inoponibilidad puede hacerse valer como acción o como excepción.

Como acción, reclamando del acto inoponible, ej. en la venta de cosa ajena, haciendo valer la acción reivindicatoría.

El tercero interpondrá la inoponibilidad por la vía de excepción cuando se invoque en su contra el acto afecto a esta sanción, así ocurrirá normalmente cuando la inoponibilidad se produzca por la inobservancia de una medida de publicidad.

En cuanto a quiénes pueden invocar la inoponibilidad, ello depende de los casos que se presenten.

e) Extinción de la inoponibilidad:

Tampoco es posible establecer reglas generales que abarquen todas las situaciones en que la inoponibilidad se presenta para determinar las causales de extinción de ella.

Las inoponibilidades por falta de publicidad se sanean por el cumplimiento de las formalidades omitidas.

Toda inoponibilidad termina por la renuncia de ella; semejante renuncia afecta sólo a quien la efectúa, y en consecuencia, otros terceros podrán siempre invocarla. Naturalmente en la inoponibilidad por falta de concurrencia, ella corresponde exclusivamente a aquel cuyo consentimiento fue omitido, él es el único que puede invocarla, y su renuncia, que toma el nombre de ratificación, sanea totalmente el acto.

Finalmente puede extinguirse la inoponibilidad por prescripción, cuando ella se haga valer como acción. Así la acción de simulación que no tiene un plazo especial prescribe en 5 años, etc.

Normalmente el acto inoponible dejará de serlo por prescripción para los efectos de oponerla como excepción, salvo que ella haya podido hacerse valer como acción. Ej.: venta de cosa ajena, si el poseedor adquiere el dominio por prescripción, y el antiguo dueño es demandado por cualquier causa no podrá excepcionarse con la inoponibilidad.

CAPÍTULO V

EL AUTOCONTRATO

Esta figura se presenta cuando una misma persona interviene en un negocio jurídico invistiendo dos o más calidades jurídicas distintas.

Puede definirse el autocontrato en la siguiente forma "es el acto realizado por una sola persona en el cual ella actúa a la vez como parte directa y como representante de la otra parte o como representante de ambas partes o como titular de dos patrimonios que le pertenecen".

Lo que caracteriza el autocontrato es que en un acto jurídico bilateral, y que por lo mismo requiere de la voluntad de dos o más partes, una sola persona actúa en un doble carácter; sea como parte directa y como representante de la otra parte, o como representante de las dos partes entre quienes se celebra el contrato, sea como titular de dos patrimonios a los que afecta el contrato.

El autocontrato supone necesariamente la existencia de dos o más patrimonios cuya propiedad o representación corresponde a un solo sujeto de derecho que, en virtud de su declaración de voluntad crea entre ellos una relación jurídica de obligación.

Puede darse en los siguientes casos:

A) En materia de representación, situación que se presenta cuando:

1. El contratante actúa por sí mismo y a la vez como representante legal o contractual de otra persona, y

2. El contratante concurre en el mismo acto como representante legal o convencional de dos o más personas naturales o jurídicas.

Esta distinción tiene especial importancia, porque reconoce, en este último caso, que la contraposición de intereses es menos marcada. Evidentemente existe peligro de este tipo de intervención de una misma persona representando dos posiciones en el contrato, por lo que los autores son más bien contrarios a esta figura.

B. Cuando una persona tiene dos patrimonios o fracciones de patrimonios sometidas a regímenes jurídicos distintos.

En relación con este punto hay que señalar que tradicionalmente ha prevalecido la opinión sustentada por Aubry y Rau sobre la unidad del patrimonio. Según ellos el patrimonio por ser un atributo de la personalidad y, por consiguiente, inseparable de la persona, era uno solo.

La tendencia moderna es aceptar la pluralidad de patrimonios, pues ven en éste un conjunto de bienes activos y pasivos afectos a un fin determinado. Siendo así es posible que una sola persona tenga diversos patrimonios sometidos a regímenes jurídicos distintos.

Naturaleza jurídica del autocontrato:

Este es un aspecto bastante complicado, pues estamos ante una figura jurídica que sale de la nomenclatura clásica, ya que en un acto jurídico bilateral, como lo es el contrato, que por su esencia misma requiere de la concurrencia de dos o más partes, interviene una sola persona.

Hay diversas teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica del autocontrato:

Para algunos el autocontrato es un verdadero contrato, en el cual concurren las dos voluntades que se precisan para generar un acto jurídico bilateral, ellas son la del representante y la del representado. En el fondo, lo que en realidad sostienen es que más que un vínculo jurídico entre personas distintas, se trata de uno entre patrimonios distintos que se ven afectados por obra de una sola voluntad.

Otros, en cambio, estiman, que el autocontrato es un acto jurídico unilateral que produce efectos contractuales (Demogue, Alessandri). Sostienen que el contrato requiere necesariamente del acuerdo de voluntades de dos o más partes, de tal modo que si éste no existe no hay contrato, y en el autocontrato dicho acuerdo no se presenta, no puede extremarse la ficción para poder sostener que existe un acuerdo entre dos o más voluntades, cuando en la realidad una sola está generando el acto jurídico.

Por otra parte, en la actualidad no puede sostenerse que el contrato celebrado por medio de representante, sea generado por el representado, es claro que es la voluntad del representante la que concurre y genera el acto.

Indican, además, que en el autocontrato interviene la de una sola persona, que inviste dos calidades diferentes y habiendo una sola no puede sostenerse que existe contrato, porque éste supone necesariamente un acuerdo de voluntades.

Tampoco aceptan que el contrato más que un vínculo entre personas es uno entre patrimonios. Los actos jurídicos, en general, en definitiva son vínculos entre patrimonios, desde que crean, modifican, transfieren o transmiten, y extinguen derechos. Es evidente que el contrato produce efectos patrimoniales, pero lo que lo caracteriza es el acuerdo de voluntades, y éste no se da en el auto- contrato.

Por ello estiman que el autocontrato es un acto jurídico unilateral, ya que nace de la voluntad de una sola persona, pero que produce efectos contractuales, porque genera los mismos efectos que si el acto se originara en un acuerdo de voluntades.

Procedencia de la autocontratación:

Tiende a admitirse con dos condiciones:

a) Que no esté legalmente prohibida. Es evidente que no podrá otorgarse un autocontrato si la ley lo ha excluido expresamente, como sucede en el art. 412 que prohíbe a los curadores celebrar contratos en que tengan interés ellos o ciertos parientes suyos, también en el art. 1800 relacionado con el 2144.

b) Que haya sido autorizado expresamente o no exista conflicto de interés. Ejemplo de los primeros son los arts. 2144 y 2145.

Discutible es la legitimidad de la autocontratación en el caso en que no esté ni expresamente prohibida ni autorizada, pero no haya contraposición de interés en la gestión del representante.

Podría sostenerse que las prohibiciones legales señaladas son manifestaciones de una regla general para negar validez a estos actos, pero la mayoría se inclina por reconocérsela, porque las prohibiciones son de derecho estricto y las existentes se fundan en la contraposición de intereses.

No hay en la legislación positiva chilena una disposición que prohíba el autocontrato, como tampoco una que lo autorice, incluso la expresión autocontrato no es empleada por el legislador. Pero, existen una serie de normas que consideran aisladamente este problema, y del análisis del conjunto de ellas se concluye:

1º) Que el autocontrato es posible en Chile.

2º) Que por regla general es válido.

Entre dichas disposiciones cabe destacar los siguientes artículos del Código Civil: 410, 412, 1800, 2144 y 2145.

Por último, es necesario destacar que el autocontrato es inadmisible en materia judicial. No se puede sostener un juicio consigo mismo. Una persona que inviste la calidad de guardador no puede litigar con él mismo como representante legal del pupilo. En relación con este aspecto debe tenerse presente lo dispuesto en los artículos 154, 506, 263 inc. Iº. Todas estas normas dejan en claro que el representante legal de una persona no puede litigar consigo mismo asumiendo las dos calidades que inviste.

CAPÍTULO VI

INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS Y SU CALIFICACIÓN JURÍDICA

1. - Interpretación de los contratos.

El contrato es la exteriorización de la voluntad de dos o más partes, dando expresión a la voluntad concordante de éstas. Y como lo forman dos declaraciones de voluntad distintas, viene a hallarse integrado por el sentido de esas dos declaraciones, en aquello en que concuerden.

"Interpretar es la determinación del sentido que debe darse a una frase o sentencia que aparece obscura" (Diccionario de Legislación y Jurisprudencia Chilenas). En el mismo sentido se pronuncia el diccionario de Escriche, refiriéndose ahora específicamente a los contratos: "Interpretar un contrato significa explicar o declarar el sentido del contrato que aparece obscuro o dudoso".

Llámase interpretación del contrato el procedimiento en virtud del cual se tiende a esclarecer y determinar el sentido y alcance de las declaraciones que lo forman.

En mayor o menor medida, todas las declaraciones de voluntad necesitan ser interpretadas, es absolutamente imposible expresar una idea o voluntad sin que en la expresión se deslice alguna posibilidad de duda.

Toda vez que las partes contratantes, o quienes legal mente toman su lugar, discuten el significado o resultados generados por la convención, vale decir, cuando no existe acuerdo respecto a las consecuencias producidas por el negocio jurídico, es menester interpretarlo.

La Corte Suprema en sentencia de 19 de junio de 1929, falló en el sentido que "...la interpretación del contrato tiende a determinar la explicación o el sentido que debe atribuirse a las declaraciones o términos empleados en alguna convención, susceptibles de ambigüedad o de falta de precisión..." (R.D.J. T.27, s. I °, p. 365). "Cuando el contrato está concebido en términos claros y precisos... son inaplicables las reglas de interpretación del Título XIII del Libro IV del Código Civil que tienden a resolver las dudas que pueden nacer de pasajes obscuros o de inteligencia ambigua" Corte Suprema, Repertorio de Legislación y Jurisprudencia, T. IV, Código Civil, pág. 246, N° 29.

Sistemas de interpretación:

Hay dos grandes escuelas relativas al sistema de interpretación que postulan:

1) Sistema objetivo o de la voluntad declarada, y

2) Sistema subjetivo.

El primero tiene exclusivamente en cuenta la voluntad declarada, sin considerar la voluntad real del autor del acto o de los contratantes; se hace abstracción de la voluntad subjetiva de los contratantes, para atender fundamentalmente a las circunstancias objetivas en que se ha emitido la declaración de voluntad.

El segundo, por el contrario, considera exclusivamente la voluntad real existente tras la declaración expresada con mayor o menor perfección. Significa "reconocer al acuerdo de voluntades de los contratantes un poder creador de situaciones jurídicas sin necesidad de ninguna habilitación". Se caracteriza por la búsqueda de la voluntad psicológica de las partes.

Actualmente, no hay legislación que tome uno solo de estos sistemas, todas tienen elementos de ambas alternativas.

El Código Civil chileno da mayor importancia a la intención de los contratantes, siendo el elemento intencional el principal medio de interpretación, como lo señala expresamente el artículo 1560.

Reglas de interpretación del Código Civil:

Se encuentran contempladas en el título XIII del Libro IV, arts. 1560 a 1566. Otros Códigos no contemplan reglas de interpretación dejando al juez en absoluta libertad para interpretar los contratos.

Los artículos 1560 al 1566 del Código Civil fijan normas de interpretación, algunas para los actos jurídicos en general, otras específicamente para los contratos.

Fuera de éstas hay normas especiales para ciertos contratos específicos, y especialmente para el testamento.

Las reglas de interpretación de los contratos de nuestra legislación son las siguientes:

1) Art. 1560: "Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras".

Es la regla básica.

Esta disposición no hace sino confirmar o aplicar el principio de la autonomía de la voluntad, y ella aparece, a priori, como diametralmente opuesta a la interpretación de la ley, porque para interpretar la ley se está más a lo literal de las palabras que al espíritu del legislador. Supone el Código que el legislador sabe expresarse en términos que no traicionen su pensamiento. En cambio, en los contratos, las partes muchas veces son personas que tienen un dominio relativo del idioma, y puede acontecer que las palabras no manifiesten su verdadera intención.

Para que la intención sea preferida a la declaración, debe estarse seguro de aquélla. "El artículo 1560, empleando las expresiones "claramente conocida", ha querido decir que la intención debe tener un carácter de evidencia; en consecuencia, no solamente es necesario probarla, sino que la prueba debe procurar al juez una convicción sin equívocos" (Carlos Rojas, Estudio Crítico de la Jurisprudencia del artículo 1560 del Código Civil Chileno).

Esta misma regla de interpretación del art. 1560 está repetida en la interpretación de los testamentos, porque el art. 1069 hace primar la voluntad del testador sobre lo literal de las palabras, y ello como consecuencia de ser el testamento una manifestación de voluntad.

2) Aplicación de los términos del contrato:

Art. 1561: "Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado".

Este artículo establece una norma de aplicación restrictiva de interpretación de los contratos. Ejemplo: "Si se estipula que en la administración de los bienes del poderdante, podrá el Banco mandatario, entre otras cosas, prestar y exigir fianzas, la facultad de afianzar que se concede sólo se refiere al otorgamiento dentro de la administración de los bienes del poderdante. En consecuencia, sale de los términos del mandato y no obliga al mandante la fianza otorgada por el Banco para asegurar el pago de letras propias de él mismo" (R.D.J T. 18, s. I^{o}, p. 267).

Esta disposición recibe aplicación en el art. 2462 en materia de transacción en cuanto a si en ella se renuncia a todo derecho, acción o pretensión, esto debe entenderse restringido a los objetos respecto de los cuales se está transigiendo.

3) Sentido efectivo y sentido inefectivo:

Art. 1562: "El sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto, deberá preferirse a aquél en que no sea capaz de producir efecto alguno".

Se trata de una cláusula de un contrato que interpretada en determinada forma no tiene aplicación e interpretada en otra sí la tiene. El legislador establece que debe estarse a esta última interpretación, porque supone que si hay una cláusula en un contrato es porque los contratantes desean que produzca sus efectos, luego es lógico entenderla en tal sentido. El clásico ejemplo es el de Pothier: "si se conviene entre Pablo y Pedro que Pablo podrá pasar por 'sus heredades' puede entenderse respecto de las de Pablo o de las de Pedro; no es dudoso que debe entenderse respecto de las de Pedro; de otro modo la cláusula no produciría ningún efecto, pues Pablo no tiene ninguna necesidad de estipular que él podrá pasar por sus propias heredades". Las partes con su declaración de voluntad, persiguen obtener resultados útiles procurando la estabilidad de los contratos.

No obstante, no cabe aplicar la disposición en comento cuando el sentido determina que una cláusula no tenga eficacia jurídica por adolecer de nulidad. En tal situación la cláusula tiene un efecto que no es válido, que es un problema distinto del que resuelve esta regla de la utilidad de las cláusulas, por lo tanto sería salirse del marco de la ley dar validez a una cláusula nula, buscando con ahínco un sentido eficiente diverso del que fluye naturalmente de ella. Así lo ha resuelto la Corte Suprema (R.D.J. t. 31, s. I°, p. 178).

4) Cláusulas de un contrato en relación con la naturaleza de éste:

Art. 1563, inc. I°: "En aquellos casos en que no apareciera voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadra con la naturaleza del contrato".

La disposición del Código es aplicable al caso que las partes contratantes no manifiesten en el contrato voluntad de interpretarlo en sentido determinado. El autor señor Ducci Claro estima que esta voluntad contraria a que se refiere este artículo en su inciso 1 °, no es necesario que se encuentre manifestada en el contrato, ella puede provenir de la aplicación práctica hecha por las partes del contrato o manifestada en cualquiera otra forma que la haga "claramente conocida", dentro de los términos del artículo 1560.

Ej.: "Si se estipula que al final del arrendamiento se abonarán al arrendatario los álamos y demás árboles frutales que plantara, en estos últimos no se comprenden las plantas de viña. Estas últimas no caen dentro del término árboles, atendiendo a lo que expresa el Diccionario de la Lengua y la práctica uniforme de los agricultores, que siempre en sus contratos acostumbran a distinguir entre las plantas de viña y los árboles frutales". Así lo ha resuelto la Corte de Apelaciones de Santiago.

5) Cláusulas de uso común:

Art. 1563 inc. 2°: "Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen".

Consiste en incorporar al contrato las cláusulas usuales, silenciadas en la declaración.

La palabra "uso" está tomada en el sentido de "costumbre". Esta norma más que de interpretación, es una norma referente al contenido del acto.

Don Luis Claro Solar opina que "más que una regla de interpretación, es sólo la aplicación del principio consagrado en el artículo 1546 que hace obligatorias para los contratantes todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza del contrato, o que por la Ley o la costumbre le pertenecen".

Don Carlos Ducci Claro le da un significado más amplio, que se aplica en general a todos los actos jurídicos, sería un mandato expreso y nuevo, cuando dispone que las cláusulas de uso común se presuman en aquellos actos que no tienen precisamente un carácter contractual.

5) Interpretación armónica de las cláusulas:

Art. 1564 inc. 1º: "Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad".

Este precepto establece la regla de la armonía de las cláusulas.

Normalmente las cláusulas de un contrato deben encontrarse en una necesaria relación y armonía, subordinadas las unas a las otras, por lo que nada más lógico que sean examinadas en su conjunto. Esta interdependencia de las cláusulas de un contrato la ha establecido nuestra jurisprudencia en numerosas sentencias. Así, si en un mandato se autoriza al mandatario para cobrar la suma debida hasta obtener el pago, y se agrega, en una cláusula distinta, que él pedirá que los valores sean entregados a otra persona, debe concluirse que el mandatario no está facultado para percibir (R.D.J. t. 42, s. 1º, p. 388).

6) Analogía:

Art. 1564 inc. 2º: "Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia".

Se está estableciendo una regla extrínseca de interpretación de los contratos, el intérprete debe atribuir especial valor a las circunstancias de la especie, que configuran el contorno del contrato aunque no se encuentre en la misma declaración.

En esta regla encontramos dos requisitos copulativos:

1. que el otro contrato sea celebrado entre las mismas partes;
2. que verse sobre la misma materia.

La expresión "podrán" parece indicar un carácter discrecional que tendría el juez para buscar la intención de las partes fuera del texto de la declaración. No compartimos tal criterio por cuanto estimamos que el sentenciador, enfrentado a la existencia de los supuestos de la norma, debe necesariamente aplicarla, no pudiendo quedar a su mero arbitrio el hacerlo o no.

Aplicando esta disposición se ha fallado que "siendo vago un contrato en que el actual demandado se compromete a pagar una comisión por ciertos servicios, debe recurrirse, para interpretarlo, a un convenio que sobre la misma materia celebraron las partes con anterioridad (Corte de Apelaciones de Santiago, R.D.J. t. 29, s. 1º, p. 435).

La convención susceptible de ser considerada en la interpretación puede ser anterior o posterior al contrato objeto del litigio, y pueden ser uno o varios los contratos a considerar, pues lo que interesa es la comprobación de la voluntad interna de las partes.

7) Interpretación por aplicación práctica de las cláusulas:

Art. 1564 inciso final. "O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con

la aprobación de la otra".

Es una regla de interpretación auténtica, don Luis Claro Solar señala que esta interpretación es "la reina de todas las interpretaciones". Compartimos este entendimiento, en la medida que creemos que nada puede reflejar mejor la verdadera intención de las partes al contratar, que la forma como ellas cumplieron el contrato en los hechos. Al respecto la Corte Suprema ha dicho "La regla del inciso 3º del artículo 1564 es de importancia, principalmente en la interpretación de los contratos que contienen obligaciones de dar o de hacer, ya que nada puede indicar con más acierto la voluntad de las partes en esta materia que la ejecución llevada a cabo por ellas mismas de las cosas que, con arreglo a lo pactado, estaban obligadas a dar o hacer".

La disposición contempla dos situaciones:

a) la aplicación práctica hecha por ambas partes;

b) o por una de las partes con aprobación de la otra.

Debe señalarse, que esta regla rige sólo a condición de que dicha aplicación haya sido hecha por ambos partícipes o por uno con la aprobación del otro, implicando la idea de aprobación, la aceptación sin reservas ni protestas de lo obrado por la otra parte.

En este sentido se ha fallado que no procede acoger la acción de incumplimiento del contrato de trabajo si el empleado, sin protesta alguna, aceptó el desahucio dado por el empleador. Así debe concluirse aunque, conforme al contrato de trabajo, el derecho de dar el desahucio, antes de cierto plazo, fuera dudoso, pues las cláusulas de un contrato deben interpretarse -entre otros modos- por la aplicación práctica que haya hecho de ella una de las partes con aprobación de la otra. (R.D.J. t. 33, s. Iº, p. 43).

La aplicación práctica del contrato es una cuestión propia de los jueces del fondo, no susceptible de casación; así lo han resuelto nuestros Tribunales R.D.J. t. 5. s. Iº, p. 393).

9) Interpretación por los ejemplos:

Art. 1565. "Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda".

Esta norma tiene un fundamento lógico, ya que la inclusión de un ejemplo se hace precisamente para aclarar los demás casos semejantes a que se refiere el contrato y que podrían originar una controversia.

10) Interpretación de las cláusulas ambiguas:

El art. 1566 inc. Iº. "No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor".

Esta es una regla subsidiaria de interpretación; y reconociéndolo así la jurisprudencia ha señalado que "sobre las reglas que para la interpretación de las cláusulas ambiguas indica el artículo 1566, priman conforme al tenor literal de la misma disposición, las que señalan los demás artículos del mismo Título XIII" R.D.J. t. 45, s.1º, p. 120).

Art. 1566 inc. 2º: "Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella".

Esta norma constituye una novedad del Código Civil chileno, pues en el Código francés no encontramos norma semejante, ni en los tópicos interpretativos formulados por Domat y Pothier.

La norma del artículo 1566 inc. 2º debe considerarse como una excepción a la disposición general del inciso 1°. Se está protegiendo al jurídicamente más débil. Quien dicta o redacta un contrato, no importando su rol jurídico, debe responder por la ambigüedad resultante. Esta norma cobra aplicación en los contratos que hoy se extienden en formularios pre-redactados, también en los contratos de adhesión, donde existe una oferta dirigida, en que cada cláusula está unilateralmente diseñada; por ej.: los contratos de seguros, transportes, etc., pudiendo constituir para los jueces una poderosa herramienta para atenuar los abusos de la adhesión contractual. Ej.: "suponiendo ambiguas o dudosas las cláusulas del seguro, relativas a doble indemnización por muerte o por accidente, debe interpretárselas contra el asegurador que redactó el formulario contenido en la póliza, ya que la ambigüedad provendría de una falta de explicación que debió dar el asegurador. Por lo tanto debe acogerse la demanda en que se cobra la doble indemnización (R.D.J. t. 29, s. 1°, p. 557).

2. - Calificación jurídica de los contratos.

No hay que confundir la interpretación de los contratos con su calificación jurídica. Ésta viene después de aquélla e importa la determinación de la naturaleza jurídica del contrato, la operación de incluirlo, atendido su contenido, en una de las categorías contractuales establecidas por el legislador, con los efectos específicos que le son propios de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.

En este análisis jurídico del contrato no es fundamental ni decisivo el nombre que las partes le den; la calificación se hace atendiendo a la voluntad real de las partes, tal como se desprende de la interpretación de las cláusulas que estipulan en los contratos.

Se estima que sólo cuando se trate de dos tipos de contratos muy afines y el contenido del convenio no ofrezca criterios seguros para calificar el contrato, debe el juez atenerse a la designación de las partes.

En principio, la interpretación de los contratos es una cuestión de hecho, pero la calificación es una cuestión de derecho que puede dar lugar a un recurso de casación y en tal sentido según lo ha entendido mayoritariamente nuestra jurisprudencia, la determinación de cuál es la voluntad real de las partes es una cuestión de hecho, pero establecida ésta, la calificación de los contratos que de tal voluntad se derive, es cuestión de derecho que, pudiendo derivar en infracción de ley, es susceptible de casación.

Las disposiciones sobre interpretación de los contratos ¿son meros consejos del legislador o son normas obligatorias?

Algunos opinan que los jueces deben sujetarse a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil, y si las violan la Corte Suprema podría enmendar el fallo porque habría infracción de ley.

Para otros, las normas legales relativas a la interpretación de los contratos son obligatorias sólo en cuanto ordenan estar a la intención de los contratantes para interpretar el acto, pero no en cuanto indican los elementos que pueden servir de medios para interpretar el acto.

Según esta opinión el recurso de casación procedería cuando el juez no hubiere realizado la investigación dirigida a conocer la intención de los contratantes, esto es, cuando no hubiere interpretado el contrato; pero no procedería dicho recurso cuando hubiere interpretado el contrato y determinado la intención contractual, aunque lo hubiere hecho erróneamente.

CAPÍTULO VII

CONTRATO DE PROMESA

1. - Generalidades y circunstancias que inducen a la celebración de un contrato de promesa.

La naturaleza del contrato de promesa y el establecimiento de sus elementos esenciales, constituyen uno de los problemas más debatidos en la ciencia del derecho. La falta de antecedentes dignos de tomarse en cuenta en el Derecho Romano, la extensión en que puede aplicarse esta institución y la diversidad de criterios con que abordan las distintas legislaciones esta cuestión, son circunstancias que motivan amplias especulaciones jurídicas. Sin ir más lejos el Código Civil chileno sigue un sistema propio cuyos precedentes son desconocidos.

Los romanos no conocieron el contrato de promesa, pero esto no quita que en Roma hubiera ciertos contratos tales como los pactos y la estipulación que fueron, por así decirlo, el antecedente histórico de la promesa, tal como lo concibe la ciencia jurídica moderna. Lo que puede llamarse promesa en tal derecho fue más bien un contrato verbal solemne que obliga al deudor al cumplimiento de una prestación futura. Es verdad que la teoría de la promesa de venta puede considerarse el gennen en el pacto de retroventa.

Las circunstancias que inducen a la celebración de un contrato de promesa:

El contrato de promesa es de mucha aplicación práctica y, generalmente, se celebra en aquellos casos en que existen circunstancias que impiden celebrar de inmediato el contrato futuro -"contrato prometido". En otras palabras, el resultado económico-jurí- dico que las partes se proponen es irrealizable de inmediato; pero, al propio tiempo ellas juzgan conveniente comprometerse, de inmediato, para la conclusión del contrato específico que proyectan.

Es frecuente que se recurra a este contrato cuando el contrato definitivo no puede celebrarse por faltar algunos trámites legales para perfeccionarlo de inmediato (ej. venta de bien raíz hereditario y faltan inscripciones del art. 688), o que exista una prohibición judicial o legal transitoria para celebrar el contrato deseado, o falte el cumplimiento de ciertas formalidades, o la terminación de la obra, o haya problemas de financiamiento, etc.

Los ejemplos relativos a la promesa pueden multiplicarse enormemente si se considera que la promesa de contrato es un contrato preparatorio general y, por lo mismo, puede prometerse una sociedad, un arrendamiento, un mutuo, etc., dando por consiguiente lugar a muchos casos.

En suma, la función de crear un vínculo jurídico necesario y de seguridad, orientado directamente a la conclusión de un contrato futuro que hoy no se quiere o no se puede otorgar, la cumple el contrato de promesa de celebrar un contrato.

Por regla general, se puede prometer la celebración de cualquier contrato y sobre cualquier cosa. Sin embargo hay casos en que la ley prohíbe expresamente la celebración de este contrato, así por ejemplo en la Ley General de

Urbanizaciones y Construcción, se prohíbe la celebración de contratos de promesa de venta respecto de terrenos en que no se hayan ejecutado totalmente los trabajos de urbanización.

2. - Definiciones.

Son muchas las definiciones que se han dado de este contrato, algunas de ellas son:

1) "Es un contrato por el cual las partes se obligan a concluir un contrato futuro" (Andrea Torrente).

2) "La promesa es un contrato por el cual una de las partes o ambas se obligan dentro de cierto plazo a celebrar un contrato futuro determinado" (Rafael Rojina).

3) "Es un contrato preparatorio general, por el cual una parte o ambas, se obligan a celebrar otro que ha de ser legal mente eficaz y que se especifica de momento por lo menos en sus elementos esenciales, estipulándose al propio tiempo un plazo o una condición, o ambos a la vez, que fijen su futuridad, y concediendo la ley los medios judiciales eficientes para su ejecución forzada" (Femando Fueyo).

4) "Es aquel por el cual las partes se obligan a celebrar otro contrato determinado en cierto plazo o en el evento de cierta condición" (R. de D. y J. Tomo 58, sec. 1ª, pág. 179 y Tomo 60 sec. 2ª, pág. 85).

3. - Particularidades del contrato de promesa.

El contrato de promesa en Chile presenta peculiaridades que le son totalmente propias, y otras que son comunes con otros ordenamientos jurídicos. Ellas son:

1) En Chile no cabe duda que la promesa es un contrato, ello sin embargo es materia de discusiones en otros países. La Jurisprudencia entre nosotros ha establecido que de los términos del art. 1554 se deduce que la promesa de celebrar un contrato es, a su vez, un contrato, porque es fuente de derechos y obligaciones entre las partes que la generan.

2) Es un contrato general, o sea, por su intermedio puede prometerse la celebración de un número ilimitado de contratos, salvas las excepciones legales. Es decir, que el contrato de promesa es apto para la preparación de cualquier tipo de contrato, sea cual fuere su naturaleza, las solemnidades que debe cumplir, si son uni o bilaterales, etc.

Respecto de los contratos innominados, por su propia naturaleza, debe tenerse presente que si se promete la celebración de uno de ellos, el contrato prometido debe ser especificado minuciosamente a objeto de evitar incomprensión y disparidad de opiniones a su respecto.

3) Es un contrato solemne, pues siempre debe constar por escrito, incluso cuando el contrato prometido sea consensual, art. 1554 N° I.

4) Es un contrato principal, ya que el art. 1554 al reglamentarlo no subordina su existencia a la de otro contrato.

Debe tenerse presente que el contrato de promesa es independiente del contrato prometido -no obstante la íntima relación que tiene con éste-, porque existe válidamente siempre que concurran en su otorgamiento las circunstancias indicadas en el art. 1554 y aun cuando no se celebrare nunca el contrato prometido.

5) Es un contrato preparatorio, peculiaridad que lo distingue de otros contratos, dándole fisonomía propia.

6) Es un contrato sujeto a modalidad, art. 1554 N° 3.

7) Es de derecho estricto, a pesar de estar concebida la promesa como un contrato de aplicación general, del art.

1554 se desprende que es el derecho estricto, pues dados los términos en que éste se encuentra redactado, se deduce que la regla general es no aceptar la promesa de celebrar un contrato y reconocerla sólo por excepción cuando reúne los requisitos que en dicho artículo se expresan.

4. - Validez de la promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral.

Se ha discutido bastante la validez de esta clase de promesas. Algunos las rechazan considerando que por no darse cumplimiento a las exigencias de los números 2 y 4 del art. 1554 son legalmente inadmisibles.

Otros, en cambio, sostienen que dichas promesas son perfectamente válidas. Los argumentos de ambas posiciones son los siguientes:

1) La promesa unilateral de un contrato bilateral es nula, por las siguientes razones:

1.1. El N° 4 del art. 1554 exige que en la promesa se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban.

Ahora bien, especificar, conforme al diccionario es explicar, declarar con individualidad una cosa, o sea, determinar con la mayor exactitud la especie del contrato y las características que lo distinguen de los demás, darlo a conocer por sus requisitos especiales o esenciales, de manera que no haya duda acerca de su naturaleza. Así en la compraventa, que es un contrato bilateral, figura como requisito esencial el acuerdo de voluntades de vendedor y comprador, y sin este requisito no se concibe la existencia de la compraventa, art. 1793.

1.2. La promesa unilateral de celebrar una compraventa no se cumple con el requisito del N° 2 del art. 1554, porque un contrato en que uno solo se obligue a vender, no produce efecto alguno, o lo que es lo mismo, adolece de ineficacia.

1.3. En la promesa unilateral de venta queda exclusivamente a voluntad del comprador contraer las obligaciones inherentes a su calidad o, en otros términos, su aplicación está subordinada a una condición potestativa que depende de su mera voluntad, obligación que es nula según el art. 1478 y, por lo tanto, es nulo también el contrato de que emana.

Claro Solar refuta el argumento anterior, pues señala que el art. 1478 se refiere a una condición que consiste en la mera voluntad de la persona que se obliga; y en la promesa de venta el promisor queda obligado desde que se celebra la promesa de venta y el presunto comprador no contrae obligación alguna que dependa de su voluntad, sino que se reserva el derecho a resolver si compra o no compra. En cuanto a la convención en que se contiene la promesa misma, él la ha aceptado y por eso queda obligado el promisor a mantener su oferta hasta la época en que la otra parte la acepte o no. No debe confundirse la promesa con el contrato prometido: la promesa se ha celebrado desde luego, el contrato prometido puede o no celebrarse.

1.4. No desvirtúa el valor de las razones anteriores en orden a la nulidad absoluta de las promesas unilaterales de contratos bilaterales, la circunstancia de existir algunos actos o contratos, como el pacto de retroventa y la venta a prueba o gusto, sea porque no se trata de promesas unilaterales, sino de contratos en que ambas partes se obligan, o de casos de excepción que confirman la regla.

Como puede apreciarse esta doctrina discurre sobre la base del contrato de compraventa, pero sus argumentos son aplicables a todos los otros contratos bilaterales.

2) La promesa unilateral de un contrato bilateral es válida, por las siguientes razones:

2.1. Si, conforme al N° 4 del art. 1554, es indispensable conocer la especificación que corresponde a la esencia o naturaleza del contrato prometido, esto no significa en manera alguna que el contrato de promesa haya de tener la misma esencia y naturaleza del contrato prometido cuya especificación hace, porque en tal caso no se podría, por ejemplo, es una promesa bilateral prometer la celebración de un contrato unilateral como el mutuo.

2.2. Ninguna disposición legal exige que en el contrato de promesa ambas partes se obliguen recíprocamente. La validez del contrato de promesa unilateral también se desprende de diversas disposiciones legales, por ej.: el art. 1438 no exige que pese obligación sobre ambas partes, y el art. 1439 señala que los contratos pueden ser uni o bilaterales. Por otra parte, la autonomía de la voluntad autoriza aun para celebrar contratos innominados, y no puede entenderse limitada sino cuando disposiciones legales expresas así lo digan, debiendo ser toda interpretación al respecto restrictiva.

1.4. Hay diversas disposiciones en nuestro ordenamiento jurídico que revelan el espíritu de aceptar, en materia de promesa de compraventa, obligaciones unilaterales. Por ej.: el art. 1881 establece el pacto de retroventa que es una obligación unilateral que se impone al comprador.

1.5. Invocando en la interpretación la analogía y el espíritu general de la legislación, podría citarse el art. 1953, que consagra la libertad contractual para determinar el predominio de una sola voluntad aun en los contratos bilaterales.

1.6. Los antecedentes de la historia fidedigna de la ley también están en pro de la tesis que aquí se sostiene, ej.: en el Código Civil francés es posible la promesa unilateral de compraventa, art. 1589.

1.7. No se divisan razones morales, jurídicas, económicas o de otra índole que pudieran haber inducido al legislador a prohibir las promesas unilaterales debidamente especificadas. Por el contrario, se ve que ellas responden a las necesidades de la vida social que están consagradas en la práctica diaria, que el mismo legislador ha ratificado y sancionado expresamente, como ocurre en la Ley N° 2.754 de 28 de enero de 1913, que autoriza al Presidente de la República para adquirir una propiedad de acuerdo con un contrato de promesa, que era unilateral, pues sólo contenía una promesa de venta y no una compra.

1.8. En el Código de Minería, artículo 169, se validó expresamente la promesa unilateral de venta, esto es aquella en que solamente el promitente vendedor se obliga a vender, pero el promitente comprador no se obliga a comprar, siendo por consiguiente facultativo para él celebrar el contrato de compraventa prometido. Hay que tener presente sí que para validar la promesa unilateral de venta en materia minera se tuvo en consideración la especial naturaleza de esta actividad, cuyos negocios son esencialmente aleatorios. La decisión del promitente comprador dependerá de los estudios, análisis y prospecciones que haga.

Además, entre los autores nacionales puede decirse que casi la unanimidad sostiene la tesis de la invalidez: Leopoldo Urrutia, Manuel Somarriva, Luis Claro Solar, etc.

5. - Requisitos del contrato de promesa.

Como la promesa de celebrar un contrato es también un contrato, deben concurrir en ella todos los requisitos que la ley exige para éstos en general: consentimiento, capacidad de las partes, objeto y causa lícita.

Pero, además de los requisitos generales de todo contrato, en la promesa deben concurrir requisitos especiales para ésta, establecidos por la ley y que son tanto de fondo como de forma; ellos se encuentran enumerados en el art. 1554

del Código Civil.

La omisión de cualquiera de estos requisitos -que son esenciales y deben concurrir copulativamente- hace que el contrato de promesa no produzca obligación alguna.

La jurisprudencia ha establecido que "de los propios términos del art. 1554 del Código Civil se desprende que es de índole especial e imperativa y que sus requisitos deben concurrir tanto simultánea como copulativamente" y que la omisión de uno de estos requisitos, exigidos por la ley para el valor del acto en consideración a su naturaleza, produce, según el art. 1682 la nulidad absoluta de la promesa.

Analizaremos cada uno de estos requisitos.

1) Que la promesa conste por escrito:

El contrato de promesa es solemne y la solemnidad consiste en que debe constar por escrito, sea en instrumento público o privado.

Si se omite el instrumento, esto es si la promesa se otorga verbalmente ella es nula absolutamente, arts. 1443, 1682 y 1554; otra consecuencia es que el contrato de promesa no podrá probarse, ya que para probar un contrato solemne es inadmisible todo medio de prueba que no sea la solemnidad.

Hemos señalado que este requisito se cumple haciendo que el contrato de promesa conste por escrito, siendo indiferente si el instrumento en que se otorga es público o privado.

¿Pero, se mantiene esta norma si el contrato prometido debe constar por escritura pública?

En relación con la compraventa de bienes raíces, que debe constar por escritura pública, se pensó, en otros tiempos, que del mismo modo debía constar el contrato de promesa que la precediera. Se daban los siguientes argumentos: a) La especialidad del art. 1801, en cuanto a la naturaleza del contrato y del bien respectivo, supera la especialidad del art. 1554, que para estos efectos tendría el carácter de disposición general; b) La accesoriedad del contrato de promesa frente al definitivo de venta, lo cual le transmitiría el grado de solemnidad, y c) La modalidad de ejecución forzada de la obligación prometida, que no podría traducirse en venta si la promesa constara sólo por escrito.

Este criterio, sin duda, se basa en la mezcla y confusión de los contratos que no tienen más relación que ser sucesivos en el tiempo y contener el uno las bases del otro.

La conclusión de bastar en todo caso un instrumento privado no se dejó de esperar, y ella se funda en las siguientes razones: a) Separación de ambos contratos, los cuales teniendo individualidades propias, reconocen estructuras, efectos y reglamentación diferentes, al punto de que mal podría aplicarse al contrato de promesa las normas de otro contrato, como el de compraventa; b) La exigencia de simple escrito, sin más, por el N° 1 del art. 1554; c) La oportunidad que la propia ley establece para el otorgamiento de la solemnidad relativa al contrato prometido, N° 4 art. 1554.

En materia minera el contrato de promesa sobre las materias correspondientes a dicha actividad es solemne y la solemnidad consiste en que debe constar por escrito, y debe cumplir con los demás requisitos establecidos en el artículo 1554 del Código Civil.

Pero en el Código de Minería se establecen ciertos requisitos para hacer oponibles a terceros el contrato de promesa de compraventa y el contrato de promesa unilateral de venta.

De acuerdo al artículo 169 del Código de Minería, si el contrato de promesa de compraventa y el unilateral de venta se otorgan por escritura pública y ésta se inscribe en el Registro de Hipotecas y Gravámenes correspondiente, todo aquel a quien se transfiera la cosa, a cualquier título, estará obligado a celebrar la compraventa en los mismos

términos en que lo habría estado el promitente vendedor.

Por otra parte, habiéndose cumplido las solemnidades indicadas (escritura pública e inscripción), y si estando pendiente el cumplimiento del contrato de promesa de compraventa minera, y si contar con el consentimiento del promitente comprador, se ejecuta un acto o celebra un contrato que limita o afecta o puede limitar o afectar la tenencia, posesión o propiedad de la cosa prometida, quedará resuelto ipso facto el contrato, una vez celebrada la compraventa, salvo que el promitente comprador exprese su propósito de respetarlo, sustituyéndose en los derechos y obligaciones de sus antecesores en el dominio, artículo 169 incisos 3º y 4º.

2) Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces:

Por eficacia del contrato prometido debe entenderse que éste produzca efectos jurídicos, que establezca un vínculo de derecho entre los contratantes, origine derechos y obligaciones. Así, si se celebra un contrato de promesa en que una de las partes se obliga a ejecutar un hecho inmoral o prohibido, será ineficaz, porque tendrá un objeto ilícito; como lo será también el contrato de promesa que se refiera a una obligación físicamente imposible.

Es decir, que el propósito de las partes al celebrar el contrato de promesa no debe ser celebrar u otorgar en el futuro, al cumplirse la promesa, un contrato nulo por estar prohibido por la ley.

En otros términos, la promesa no debe ser un medio para celebrar un contrato nulo, sino que para la celebración de contratos válidos y eficaces. Si se promete celebrar un contrato que al tiempo de cumplirse la promesa será nulo, la sanción es la nulidad absoluta de la promesa por infracción al N° 2 del art. 1554.

Pero puede ocurrir que el contrato prometido sea ineficaz al momento de celebrarse el contrato de promesa, y que en cambio, pueda ser válido al tiempo de cumplirse ésta, en este caso el contrato de promesa será perfectamente válido siempre que las partes al celebrarlo, lo sujeten a la condición de que el contrato prometido sea válido al momento de cumplirse la promesa. (Ejs. arts. 1796, 1464 y 1810).

En relación con este requisito se ha planteado el siguiente problema: la promesa de venta o hipoteca de un inmueble perteneciente a un incapaz requerirá o no las autorizaciones que la ley exige para la celebración de dichos contratos. Podría estimarse que el contrato prometido es ineficaz, porque adolecería de nulidad relativa al no darse cumplimiento a las formalidades habilitantes.

La opinión mayoritaria es que no es necesario obtener la autorización habilitante para la validez del contrato de promesa. Se dan las siguientes razones:

B) El contrato prometido no es, en este caso, ineficaz según la ley, es decir no es absolutamente nulo, no está prohibido por la ley, sino que él puede celebrarse válidamente concurriendo la formalidad habilitante; Las formalidades son de derecho estricto y el art. 1554 no las ha exigido para el contrato de promesa, sino que otras disposiciones las requieren para el acto de enajenación o gravamen, que es distinto del contrato de promesa;

C) No faltaría la especificación del contrato prometido, exigida en el N° 4 del art. 1554, ya que el contrato prometido se especifica por la mención en la promesa de sus elementos esenciales y no por la concurrencia de las formalidades habilitantes;

D) El art. 1554 en su N° 4 permite omitir en el contrato de promesa las solemnidades que la ley exige para el contrato prometido, luego, con mayor razón puede omitirse las formalidades habilitantes que tienen menos significación jurídica que las solemnidades.

No debe confundirse la situación anterior, que se refiere al contrato de promesa de venta o hipoteca celebrado

respecto de bienes raíces de incapaces, con la del contrato de promesa celebrado por incapaces, ya que en el último caso debe cumplirse con las formalidades habilitantes, so pena de la nulidad relativa del contrato de promesa.

3) Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de celebración del contrato prometido:

Lo que la ley ha querido con esta exigencia es que no se haga el contrato sin base cierta, sin tiempo o condición que determine la época del cumplimiento de lo prometido.

Luego, la fijación de la época de celebración del contrato prometido debe hacerse por medio de una condición o un plazo, pero no hay impedimento para que se estipule una condición y un plazo, para que en defecto de la condición pueda celebrarse el contrato de todas maneras.

I) Determinación de la época de la celebración del contrato prometido por medio de una condición:

No existe acuerdo sobre si la condición en el contrato de promesa tiene que ser necesariamente determinada para que fije la época de celebración del contrato prometido, o si puede ser indeterminada.

Condición determinada es aquella que de acaecer el evento futuro e incierto se sabe cuando ocurrirá, y es indeterminada cuando no se sabe la época en que ocurrirá.

Algunos sostienen que la condición a que se refiere el N° 3 del art. 1554 debe revestir el carácter de determinada. Si para el cumplimiento del hecho incierto constitutivo de la condición, no se fija época o plazo, se trata de una condición indeterminada, y en este caso no puede darse el valor de promesa de un contrato a la convención celebrada bajo tal condición.

El problema de la determinación o indeterminación de la condición se ha planteado principalmente a propósito de una cláusula bastante común en los contratos, que es más o menos del siguiente tenor: “el contrato de venta prometido se celebrará tan pronto como acepte al promitente comprador la operación de préstamo hipotecario para adquirir el predio”.

Esta cláusula importa una condición indeterminada, porque es un hecho futuro e incierto que de acaecer no se sabe cuándo.

Quienes sostienen que es procedente la condición indeterminada en el contrato de promesa señalan que: “el espíritu de la ley es no mantener las condiciones por un plazo indeterminado, de ahí que se señale un plazo máximo para que se realicen -plazo de caducidad. El hecho de que el legislador no lo haya dicho en el art.
1554 no es obstáculo para que se aplique al N° 3 la regla general, tampoco lo es para que se la pueda aplicar por analogía, la circunstancia de que tal norma no aparezca el título correspondiente a las condiciones.

Se agrega que en el caso que las partes fijen una condición, es requisito esencial que ésta sea adecuada, esto es, que sirva en forma efectiva al objeto; sin que pueda sostenerse que un contrato de promesa sólo es válido cuando contenga una condición determinada. Lo que la ley exige es que pueda saberse con certeza la fecha desde la cual el acreedor podrá hacer efectiva la obligación de hacer que se deriva de la promesa o cuándo ha de establecerse en forma cierta que no podrá verificarse, sea que haya vencido el plazo estipulado, sea que ha llegado a ser cierto que la condición no se realizará.

En lo que respecta a la condición que consiste en la aprobación del préstamo, antes indicada, se señala que se sabe cuándo ocurrirá ya que cualquiera de los interesados puede recabar el pronunciamiento al respecto.

Lo aconsejable es, que en aquellos casos en que deba ponerse en el contrato de promesa una condición indeterminada o que pueda configurarse como tal, señalar un plazo dentro del cual deba cumplirse la condición.

II) Determinación de la época de celebración del contrato prometido mediante un plazo:

Respecto del plazo se discute en esta materia si él puede ser suspensivo o extintivo, o si siempre debe ser extintivo.

En realidad el contrato de promesa puede estar sujeto tanto a un plazo suspensivo como a uno extintivo, porque tanto el uno como el otro fijan una época en la cual se puede exigir la obligación de hacer que emana del contrato de promesa, es decir, se puede exigir la celebración del contrato prometido, y esa es la finalidad del N°3 del art. 1554.

Esta materia del plazo debe entenderse en relación con la exigibilidad de las obligaciones y con la mora.

En el caso del plazo suspensivo, sólo puede exigirse el cumplimiento de la promesa una vez vencido el plazo. En cambio, si el plazo es extintivo se puede exigir dicho cumplimiento en cualquier momento antes del vencimiento del plazo, pero no una vez acaecido éste porque con ello se produce la extinción del derecho.

Ahora, en lo que respecta a la mora, si el plazo es suspensivo la parte cae en mora por el solo transcurso del plazo, en cambio si es extintivo, según algunos, para que se produzca mora, debe requerirse judicialmente conforme al art. 1551, según otros la mora también se produce en este tipo de plazo por el solo vencimiento del mismo.

Ante esta situación es aconsejable redactar el contrato de promesa en este aspecto en alguna de las formas siguientes:

a) Pactando un plazo suspensivo, pero agregando uno extintivo que correrá después del vencimiento del plazo suspensivo y durante el cual se podrá exigir el cumplimiento de la promesa.

b) Sujetar la promesa a un plazo extintivo con estipulación expresa que no será exigible después del plazo.

En lo que respecta a la mora es aconsejable agregar a la promesa una cláusula, según la cual una de las partes caerá en mora si no comparece a firmar la escritura de compraventa en determinada Notaría tal día a equis hora, bastando para acreditarlo un certificado del notario que así lo acredite.

1) Especificación del contrato prometido:

Tanto en doctrina como en jurisprudencia hay diversas opiniones sobre la extensión que debe darse al requisito de la especificación del contrato prometido.

Las situaciones planteadas son las siguientes:

I. Algunos piensan que el deber de "especificar" importa una franca identificación de estipulaciones, esto es que nada de lo que ha de estipularse en el contrato prometido puede faltar en el contrato preparatorio. Incluso no debe faltar el consentimiento recíproco de obligarse que es propio del contrato prometido.

II. Otros piensan que no es necesario tan acabada identificación, al punto de llegar a exigir la inclusión del consentimiento.

Señalan que la ley ha querido dejar establecido desde luego en todas sus partes el futuro contrato para evitar discusiones ulteriores sobre sus diversas cláusulas. Se intenta que se conozca desde luego todo lo que se ha prometido diciéndolo señaladamente.

En otros términos cuando la ley exige que se especifique el contrato prometido no hay que entender que se trata de especificaciones que sólo caractericen el contrato en lo esencial.

Según ellos la enunciación del contrato prometido en la promesa debe ser casi perfecta, en forma que si en ese instante fuese llegado el momento de celebrar el referido contrato, bastare sumarle a esas cláusulas el consentimiento con sus formalidades o la tradición, según el caso, para tener el contrato prometido perfecto.

III. Otros señalan que para especificar el contrato prometido bastará con la mención de las cosas de la esencia del contrato prometido, no siendo indispensable señalar las de la naturaleza ni las accidentales.

Nadie podría dudar de que las especificaciones del contrato preparatorio, que se extendiera a las cosas de la naturaleza y a las accidentales, tendría fuerza obligatoria como para ser exigidas en el contrato definitivo.

Se indica que en los elementos esenciales está la voluntad de las partes en relación con el contrato que se proponen celebrar, bastando con ellas para especificarlo, y siendo las posibilidades de error muy pequeñas.

Los elementos de la naturaleza del contrato son presumidos por la ley, se entienden incorporados al contrato, no siendo por consiguiente necesario señalarlos expresamente para que formen parte de él.

En cuanto a los elementos accidentales son una expresión de la autonomía de la voluntad de las partes, y nacen si las parles quieren incorporarlas al contrato, pues éste en su forma normal no los comprende.

Las partes son dueñas de hacer al contrato las agregaciones o modificaciones que deseen, pero jamás podrá decirse que la ausencia de tales elementos pueda significar falta de especificación del contrato prometido.

6. -Efectos del contrato de promesa.

Se refiere a este aspecto el inciso final del art. 1554, el cual establece que cuando el contrato de promesa es válido de él surge una obligación de hacer, que no es otra que la celebración del contrato prometido.

Luego, los efectos del contrato de promesa son generalmente diferentes a los que produce el contrato prometido.

El cumplimiento de esta obligación de hacer puede exigirse con arreglo a lo establecido en el art. 1553, pero de esta disposición sólo le son aplicables los números 1 y 3.

En esta materia hay que hacer presente que a través del procedimiento ejecutivo de la obligación de hacer, la legislación procesal civil complementa las reglas sobre cumplimiento del contrato de promesa. Así el art. 532 C.P.C. faculta al juez para firmar el documento cuando requerido el deudor no lo hiciere dentro del plazo fijado por el Tribunal.

Este es un caso, en que el juez, resguardando los intereses del acreedor, asume legalmente la representación del deudor y presta por él, válidamente el consentimiento. Y con este consentimiento se forma el contrato prometido.

7. -Acción de resolución del contrato de promesa.

El art. 1489 por ser un principio de carácter general es aplicable al contrato de promesa

El art. 1553 se limita a reglar los derechos que la ley otorga al acreedor de obligación de hacer, esto es, exigir compulsivamente su cumplimiento al deudor que no se allana voluntariamente a satisfacerla.

El inciso final del art. 1554 al remitirse al artículo anterior, no tiene otra consecuencia que recalcar el tipo de obligación que engendra la promesa de contrato, que es de hacer y, como tal, ha de cumplirse forzadamente por algunas de las formas alternativas que señala el art. 1553.

El citado inciso final, pues, no modifica la disposición común general aplicable al incumplimiento de un contrato bilateral. Por lo que, rige respecto de la promesa de contrato tanto la posibilidad de intentar la acción de cumplimiento forzado dispuesta en el art. 1489 y pormenorizada en el art. 1553, como la de accionar por la resolución, en ambos casos con indemnización de perjuicios.

Ahora bien, el deudor demandado por cumplimiento o resolución de la promesa, puede oponer la excepción de contrato no cumplido, art. 1552, en caso que el acreedor demandante no haya cumplido ni se allane a cumplir la obligación de hacer que le impone el contrato de promesa.

CAPÍTULO VIII

CONTRATO DE COMPRAVENTA

1. - Definición.

El contrato de compraventa lo define el art. 1793 en la siguiente forma: "la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio".

La compraventa supone necesariamente dos personas: una que se obligue a dar una cosa, o sea, el vendedor, y otra que se obligue a pagarla en dinero, o sea el comprador. No ha definido el Código lo que debe entenderse por vendedor y comprador, sólo se limita a expresar en el art. 1793 que la parte que se obliga a dar una cosa "se dice vender" y la que se obliga a pagarla en dinero "se dice comprar".

Pero de los propios términos de la definición transcrita se desprende claramente quién es el vendedor y quién el comprador.

2. - Naturaleza del contrato de compraventa.

Atendiéndose a las características que presenta el contrato de compraventa admite ser clasificado en la forma siguiente:

a) Es un contrato bilateral: ya que da origen a dos obligaciones recíprocas, que consisten, una en dar una cosa, y la otra, en pagar su valor en dinero. Es esencial, por lo tanto, para que este contrato exista que una de las partes se obligue a dar una cosa, desprendiéndose del dominio que de ella tenga, y la otra se obligue a entregar por esa cosa, cierta cantidad de dinero.

Éstas son las dos obligaciones principales que nacen del contrato de compraventa, no siendo las otras sino accesorias de ellas. Así la obligación de saneamiento que tiene el vendedor es la consecuencia lógica de su obligación de entregar la cosa, porque de nada le serviría al comprador adquirirla, si posteriormente se viera privado de ella total o parcialmente. Es la existencia de estas dos obligaciones la que constituye en su esencia este contrato; de modo que si una falta, éste no existe o degenera en otro diverso.

b) Es un contrato conmutativo: por regla general, en el sentido de que las obligaciones recíprocas de los contratantes se miran como equivalentes.

No es sin embargo el ser conmutativo, de la esencia del contrato de compraventa, de modo que si lo pierde degenera en otro diferente. En efecto, muchas veces se vende una posibilidad incierta de ganancia o pérdida, y en tal caso el contrato de compraventa no será conmutativo sino aleatorio.

c) Por regla general, es un contrato consensual, se desprende así del artículo 1801 inc. I°, excepcionalmente es un contrato solemne, en los casos a que se refiere el inciso 2° del mismo artículo.

d) Es un contrato oneroso, porque las partes se gravan recíprocamente una en beneficio de la otra.

e) Es un contrato principal, porque subsiste por sí sólo.

3. - La compraventa es título traslaticio de dominio.

La compraventa es el ejemplo clásico de título traslaticio de dominio. El art. 703 la señala entre tales títulos. De ello resulta que por el solo contrato de compraventa nadie adquiere el dominio en nuestro país; de la compraventa, sólo nacen derechos personales y para que se adquiera el dominio es necesario que se realice la tradición. En esto el derecho chileno presenta una fundamental diferencia con el francés, sistema en que la compraventa es suficiente para adquirir el dominio.

Don Arturo Alessandri R. dice sobre esto: "Nuestro Código Civil al definir en su art. 1793 la compraventa, expresa únicamente las obligaciones que ambas partes contraen por el contrato y que son las que constituyen su esencia. Pero dicha definición no dice nada, absolutamente nada, sobre si el vendedor está o no obligado a transferir el dominio de la cosa vendida al comprador.

Sin embargo, si nos fijamos detenidamente en las palabras de esa definición, podemos ver que la ley habla de obligarse "a dar una cosa", frase que en realidad emplea una idea mucho más comprensiva de la que tiene el contrato de compraventa, por lo que respecta a la obligación del vendedor.

En efecto, según el art. 1548 del Código Civil "la obligación de dar contiene la de entregar la cosa", de donde se desprende que la obligación de dar lleva envuelta la de entregar la cosa. Luego, una y otra significan algo muy diverso y producen también efectos distintos.

La obligación de dar significa transferir el dominio o la propiedad y es una obligación que sólo puede contraer quien es dueño de la cosa.

La obligación de entregar, por el contrario, no transfiere el dominio de la cosa; puede contraería quien no es dueño de ella, desde que significa el hecho de pasar la tenencia de una mano a otra.

En resumen, dar, en sentido jurídico, es transferir el dominio, y entregar, es traspasar la tenencia de una cosa. En el hecho toda obligación de dar comprende la de entregar, ya que la manera de ejecutar la obligación es entregando la cosa materia de ella; pero no toda obligación de entregar lleva envuelta la obligación de dar.

Pero, si bien de las expresiones empleadas en la definición parece desprenderse que la compraventa tiene carácter traslaticio de dominio, del contexto de las demás disposiciones legales aparece en forma indubitable su aspecto meramente productivo de obligaciones.

El contrato de compraventa, como todos los demás, es productivo de obligaciones. De él nacen únicamente obligaciones personales entre los contratantes. Por consiguiente, el efecto que produce la compraventa en nuestro derecho no es transferir el dominio, sino dar al comprador un título que lo habilite para adquirirlo.

De lo dicho se infiere que en nuestro Código, para que el comprador llegue a adquirir en virtud del contrato de compraventa el dominio de la cosa vendida, necesita ejecutar dos actos consecutivos, esto es, debe haber título y modo de adquirir. Sólo por la coexistencia de esos dos elementos puede el comprador llegar a ser dueño de la cosa y mientras no ejecute ese proceso jurídico el dominio no se radicará en sus manos. Para que el comprador llegue a ser dueño de la

cosa vendida necesita: I°) celebrar el contrato de venta, que hace nacer la obligación de entregar la cosa vendida, o sea, le da el título que lo habilita para adquirir el dominio, y 2°) la tradición, que es el modo de adquirir el dominio y que sirve para ejecutar y cumplir aquella obligación.

Esos dos actos, el que da nacimiento a la obligación y el que sirve para ejecutarla son los que debe realizar el vendedor para transferir el dominio al comprador.

Consecuencia de este carácter que nuestra ley asigna al contrato de compraventa es la validez del contrato de venta de cosa ajena. A. Alessandri R. "De la compraventa y de la promesa de venta, pág. 23).

4. - Requisitos generales del contrato de compraventa.

El contrato de compraventa a más de los requisitos primales de validez de todo contrato consentimiento, capacidad. objeto y causa lícitos- debe contener los elementos esenciales que le son propios, cuales son: la cosa vendida y el precio.

Estos dos requisitos son la esencia del contrato de compraventa, luego si faltare alguno de ellos la compraventa no producirá ningún efecto o degenerará en un contrato diferente, art. 1444.

4.1.- La cosa vendida.

La cosa vendida es el objeto de la obligación del vendedor, por consiguiente no puede faltar; y si llegare a faltar la obligación del vendedor carecería de objeto, y por ello no habría obligación de éste y si no hay obligación del vendedor, la del comprador carecería de causa. De ahí que la falta de la cosa vendida trae la destrucción total del contrato de compraventa.

No se concibe, ni jurídica ni materialmente, una venta sin que haya cosa que se venda, porque lo que constituye la esencia misma del contrato de compraventa es el cambio de una cosa por dinero.

a) Requisitos de la cosa vendida:

La cosa vendida, sea corporal o incorporal, para ser tal y para que el contrato de compraventa sea válido, debe reunir los siguientes requisitos:

1) Que sea comerciable, esto es que su enajenación no esté prohibida por ley;
2) Que sea real;
3) Que sea determinada, y
4) Que no pertenezca al comprador.

1) La cosa vendida debe ser comerciable:

Sólo son susceptibles de venderse las cosas comerciables, o sea aquellas cuya enajenación no está prohibida por ley.

Las cosas comerciables son aquellas que pueden constituir un objeto licito al enajenarse, y las cosas incomerciables son las que al enajenarse constituyen un objeto ilícito.

El art. 1810 del Código Civil dice que pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté prohibida por ley. En consecuencia, si se vende alguna de estas cosas habrá objeto ilícito por tratarse de un contrato prohibido por la ley (art. 1466) y, consecuencialmente, el contrato adolecerá de nulidad absoluta, art. 1682.

Así, por ejemplo, son especies no enajenables las que indica el art. 1464, luego si se celebra contrato de compraventa sobre alguna cosa de las que señala dicha norma el contrato será nulo absolutamente.

2) La cosa vendida debe ser real:

Esto es, que la cosa vendida tiene que existir efectivamente al tiempo de celebrarse el contrato de compraventa, ya que si así no fuese éste carecería de objeto y sería nulo absolutamente, arts. 1461 y 1814.

Pero, no sólo las cosas que existen al momento de la celebración del contrato pueden ser objeto de la compraventa, sino también aquellas que no existen, pero se espera que existan, es decir, las cosas futuras.

En realidad, el objeto de la venta debe tener existencia material. De otro modo, no podría formarse; pero esta regla sufre excepción respecto de las cosas que si no existen al tiempo de celebrarse aquélla, existirán más tarde. De ser así, la venta se perfecciona una vez que la cosa adquiere vida material.

Cosa futura, dice Manresa, es la que no tiene existencia real y positiva al momento de prestarse el consentimiento. Esta cosa que no existe en el momento existirá posteriormente y entonces se formará la venta en definitiva. Si no llega a existir el contrato es inexistente por falta de objeto. Sin embargo, hay casos en que la venta de cosa futura es válida siempre, aunque la cosa exista. Esto sucede cuando lo que se vende es la suerte o la esperanza.

Podemos distinguir dos especies de venta de cosa futura, según sea que se venda la cosa misma que va a existir o la esperanza o suerte de que pueda realizarse un hecho o producirse una cosa.

En el primer caso, la venta es condicional. Se entiende hecha bajo la condición de que la cosa llegue a existir. En el segundo, la venta, es aleatoria, ya que se reputa perfecta desde que hay acuerdo en la cosa y en el precio.

De ambas especies de venta se ocupa el art. 1813 del Código Civil, que dice "La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte".

De este artículo se desprende que en nuestra legislación la regla general en esta materia es que la venta de cosa futura es siempre condicional, esto es, se reputa celebrada bajo la condición de que la cosa llegue a existir. La excepción a esa regla, que ese mismo artículo consagra, o sea que la venta no recae sobre la cosa misma que se espera que exista sino sobre la suerte, tiene cabida únicamente cuando así lo expresan las partes o cuando de la naturaleza del contrato aparece que lo que se compró fue la suerte.

Fluye de esto una consecuencia muy importante y es que en caso de duda, el juez debe declarar que la venta de cosa futura es un contrato condicional y no aleatorio, porque ello está más de acuerdo con su carácter conmutativo y porque a su favor existe la presunción de la ley que toda cosa futura se entiende venderse bajo la condición de que exista.

Sólo cuando esa presunción aparezca desvirtuada por una prueba en contrario, es decir, cuando las partes expresen el carácter aleatorio de la venta o éste consta de su naturaleza, puede el juez declarar que es un contrato aleatorio y no condicional, que no es un contrato cuya existencia depende de la cosa vendida, sino un contrato puro y simple.

Recapitulando, la compraventa sobre cosa futura puede asumir alguna de las formas siguientes:

A) Venta de cosa futura condicional: que es la regla general en esta materia conforme al art. 1813, la venta se entiende hecha bajo la condición de que la cosa futura llegue a existir, aun cuando las partes no lo digan.

Si la cosa no llega a existir, falla la condición y no hay contrato de compraventa.

B) Venta pura y simple o aleatoria: en este caso el contrato de compraventa es puro y simple. La obligación del vendedor es aleatoria; pero la del comprador, de pagar el precio, debe cumplirse siempre.

Determinar cuándo la compraventa es pura y simple o aleatoria depende: 1 -ya de la estipulación expresa de las partes, 2.- ya de la naturaleza del contrato, art. 1813.

3) La cosa vendida debe ser determinada:

Esto significa que la cosa vendida debe ser una especie o cuerpo cierto o bien una cantidad determinada o determinable de un género también determinado, art. 1461.

También la cosa vendida puede consistir en una cuota de una cosa en la que se tiene un derecho proindiviso, art. 1812.

Y también, puede recaer en un crédito, art. 1907.

Pero, es nula absolutamente, por prohibirlo el art. 1811 la venta de una universalidad jurídica que comporte todo el patrimonio, en otras palabras, es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros, o de unos y otros, ya se venda el total o una cuota.

No obstante esta prohibición, el propio art. 1811 acepta que una persona venda todos sus bienes, pero individualizándolos por escritura pública. En este caso, la venta comprenderá sólo aquellos objetos inventariados en la escritura pública y no otros, y cualquiera estipulación en contrario es nula.

Por excepción, es válida la venta de un derecho real de herencia, aunque éste tiene el carácter de universal y recae sobre una universalidad jurídica, art. 1801, inc. 2º.

4) La cosa vendida no debe pertenecer al comprador:

Así lo dice expresamente el artículo 1816.

La razón de que no valga la compra de cosa propia está en que una compraventa de esta naturaleza carecería de causa para el comprador, no se ve cuál sería el motivo, jurídico o psicológico, que podría tener una persona para comprar una cosa que ya le pertenece.

4.2. - Venta de cosa ajena.

El artículo 1815 del C. Civil dice en forma clara y precisa: “La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo”.

Esta disposición no es sino la consecuencia del carácter meramente productivo de obligaciones que en nuestra legislación tiene la compraventa. El objeto de este contrato es crear obligaciones. El vendedor está obligado únicamente a proporcionar al comprador la posesión libre y desembarazada de la cosa. No está obligado a transferir el dominio, sino que a entregar la cosa a que la venta se refiere. Siendo así, nada impide que las partes contraigan obligaciones respecto de una cosa ajena, puesto que en tal contrato concurren todos los requisitos necesarios para su validez.

La venta es válida porque hay un objeto sobre el cual recae la obligación del vendedor y porque no hay imposibilidad de entregar la cosa, ya que aquél puede llegar a adquirirla del dueño.

La venta no es en nuestro derecho un acto de enajenación, sino un contrato creador de obligaciones. Así como no puede enajenarse la cosa de otro, porque enajenar es transferir el dominio y sólo puede transferirlo el que lo tiene, se puede, sin embargo, vender la cosa ajena, porque vender no es enajenar sino contraer una obligación.

En Chile la venta de cosa ajena, por consiguiente, no es nula, es un justo título y, por lo tanto, posibilita al comprador para adquirir el dominio por prescripción; cabe recordar que la buena fe se presume.

Efectos de la venta de cosa ajena.

Para estudiar los efectos de la venta de cosa ajena hay que distinguir si la cosa ha sido o no entregada por el vendedor al comprador, porque en ambas situaciones las circunstancias que se presentan son diversas:

I. El vendedor ha entregado la cosa vendida al comprador:

En este caso, el verdadero dueño tiene derecho para reivindicar de manos del comprador el objeto vendido. En la venta de cosa ajena se está en presencia de una inoponibilidad por falta de concurrencia.

En efecto, el contrato de compraventa sobre cosa ajena celebrado entre comprador y vendedor es perfectamente válido, pero no obliga al verdadero dueño, no le es oponible, y es en virtud de esta inoponibilidad que puede reivindicar la cosa de manos del comprador.

Pero hay dos casos en que el dueño no podrá dirigirse contra el comprador, a saber:

1. Cuando el dueño ratifique la venta ejecutada por quien no tenía esa calidad; no hay inconveniente alguno para que así se haga y la ratificación produce pleno efecto, art. 1818.

2. Cuando el comprador haya adquirido por prescripción la cosa comprada, a esa excepción se refiere el artículo 1815 cuando dice: “mientras no se extingan por el lapso de tiempo”.

II. El vendedor no ha entregado al comprador la cosa vendida:

En este caso si el verdadero dueño ratifica la venta no se produce dificultad alguna. Pero si éste reivindica la cosa vendida de manos del vendedor, resulta que éste a virtud de ser desposeído de la cosa va a quedar en la imposibilidad de cumplir con la obligación que le impone el contrato de compraventa. Entonces el comprador podrá pedir la resolución del contrato con la correspondiente indemnización de perjuicios.

Hay otro caso en que la venta de cosa ajena produce amplios efectos, como si fuera en realidad venta de cosa propia: se trata de la situación contemplada en el artículo 1819, cual es la siguiente: se ha vendido y entregado una cosa ajena; si posteriormente a ello el vendedor adquiere el dominio se entenderá que el comprador es dueño de ella desde que se hizo la tradición.

4.3. - El precio.

“El precio es el dinero que el comprador da por la cosa vendida” dice el art. 1793.

El precio es el objeto de la obligación del comprador. Es un elemento esencial del contrato de compraventa, al igual que la cosa vendida, si no hay precio no hay compraventa, ya que faltaría el objeto de la obligación del comprador.

Requisitos del precio:

Tres son los requisitos que debe reunir el precio:

a) Debe ser pactado en dinero;
b) Debe ser real, y
c) Debe ser determinado.

a) Debe ser pactado en dinero:

El art. 1793 así lo dice en forma expresa.

Debe tenerse presente que lo que se exige es que el precio se pacte en dinero, no siendo forzoso que se pague en dinero. Puede ocurrir que con posterioridad a la celebración del contrato de compraventa sobrevenga una novación o una dación en pago por ejemplo, y si bien el precio se estipuló en dinero, después, en virtud de la novación o de la dación en pago, no se pagará en dinero.

Si el precio se conviene haciéndolo consistir en una cosa y no en dinero, no se trata de un contrato de compraventa sino que de uno de permuta o cambio, art. 1897.

El legislador consideró el caso en que el precio se pacte parte en dinero y parte en especies, en este caso se aplica la siguiente solución: si más de la mitad del precio consiste en dinero hay compraventa y, por el contrario, si más de la mitad de él consiste en especies se tratará de una permuta, art. 1794.

b) El precio debe ser real:

Esto es que debe ser fijado de tal manera que sea manifiesto que realmente el acreedor (vendedor) tiene derecho a exigirlo y el deudor (comprador) tiene la obligación de pagarlo.

Por ello no es precio real el simulado ni tampoco lo es el irrisorio o ridículo, esto es, aquel que por su falta de proporción con el valor de la cosa vendida pone de manifiesto que las partes no han tenido el propósito serio de que sea exigido.

Pero, si bien es cierto que el precio debe ser real, no es requisito de él que tenga equivalencia con el valor de la cosa vendida, ya que la falta de ésta entre los valores de la cosa y precio, sólo tiene relevancia jurídica cuando da lugar a la lesión enorme en la compraventa de bienes raíces, art. 1889.

c) El precio debe ser determinado:

Esto es que debe conocerse la cantidad precisa de dinero que constituye el precio, art. 1461 inc. 1º.

Dicha cantidad puede estar precisamente determinada en el contrato o bien puede ser determinada por las reglas o datos que el contrato contenga, art. 1461 inc. 2º.

Así, por ejemplo, la venta de cosa fungible "al precio corriente de plaza" es una venta de precio determinable en su cantidad con los datos que el contrato de compraventa contiene. Se aplica en este caso la norma contemplada en el art. 1808.

Luego, la determinación del precio puede hacerse de cualquier modo explícito en el contrato, art. 1808 inc. 2º y constituirá uno de los problemas objeto de la interpretación del contrato.

En materia de determinación del precio hay una regla esencial: jamás la fijación del precio puede quedar al arbitrio de uno solo de los contratantes, porque entonces no habría consentimiento a su respecto, ya que de acuerdo al art. 1801 el contrato de compraventa se perfecciona cuando las partes han convenido en cosa y precio. No obstante esta regla no impide que las partes convengan que la fijación del precio quede en manos de un tercero, art. 1809.

5. - Las solemnidades en el contrato de compraventa.

Hemos señalado anteriormente que el contrato de compraventa es por su naturaleza un contrato consensual que no necesita de ningún acto externo para perfeccionarse, sino únicamente del consentimiento de las partes. Sólo por excepción y en casos muy señalados se convierte en solemne.

Hay casos en los cuales la ley, en atención a la importancia de la cosa que es objeto del contrato o en atención a la voluntad de las partes, hace de él un contrato solemne.

Sabemos que son de la esencia misma del contrato de compraventa, considerado en su concepción meramente material, los requisitos de consentimiento, cosa y precio, que por sí solos la forman. Estos requisitos no pueden faltar jamás en el contrato de compraventa.

Pero, hay otros que aun cuando no son indispensables para que la venta adopte forma material, son al menos esenciales para que el contrato tome forma jurídica.

Estos requisitos que en ciertos casos se hacen indispensables para la existencia del contrato, son las solemnidades, o sea las formalidades externas, que deben llenarse para que el contrato produzca efectos jurídicos, y pueden ser establecidas por la ley o por la voluntad de las partes. En otras palabras se puede decir que en algunas ocasiones, para que el contrato de compraventa produzca efectos ante la ley, debe cumplir además de los tres requisitos mencionados, con ciertas solemnidades que pueden ser legales o voluntarias.

Las solemnidades, como se ha señalado, pueden ser legales o voluntarias, esto es, establecidas por la ley o por la *voluntad* de las partes.

5.1.- Solemnidades legales.

En el contrato de compraventa podemos encontrar, en ciertos casos, por un lado las solemnidades establecidas por la ley y por otros ciertas formalidades especiales.

Las primeras rigen respecto de todo contrato de compraventa que tenga por objeto ciertos y determinados bienes taxativamente enumerados por la ley. Esta solemnidad no puede faltar nunca en las ventas que la requieren como requisito esencial para la existencia del contrato.

Las segundas, o sea, las especiales, consisten en formalidades que exige la ley en ciertas ventas que se celebran en determinadas condiciones o entre determinadas personas. De ahí que tengan un carácter muy particular. Por regla general, no se exigen en atención a la naturaleza del contrato de venta ni son tampoco esenciales para su validez, como ocurre con las solemnidades comunes, sino en atención al estado o calidad de las personas a quienes pertenecen los bienes que se venden.

a) Solemnidades legales:

Se exige el cumplimiento de las solemnidades legales ordinarias en los siguiente casos:

1) Compraventa de bienes raíces;
2) Compraventa del censo;
3) Compraventa del derecho de servidumbre, y
4) Compraventa del derecho de herencia.

En estos cuatro casos debe concurrir la solemnidad legal ordinaria, que consiste en que el respectivo contrato de compraventa se otorgue por escritura pública.

No debe olvidarse que la solemnidad de la venta de bienes raíces es solamente la escritura pública, no revistiendo nunca este carácter la inscripción de la compraventa en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, lo cual es la tradición.

En relación con la compraventa de inmuebles hay que considerar la situación que se plantea respecto de los inmuebles por adherencia o destinación. Si la venta se efectúa separadamente de la del predio a que acceden, se trata de venta de cosas muebles, pues en tal caso nos encontramos ante un bien mueble por anticipación, art. 571. Por el contrario, si el inmueble por adherencia o destinación se vende conjuntamente con el predio a que accede, es venta de inmuebles y, por consiguiente, solemne.

En lo que dice relación a la compraventa de bienes raíces hay una situación de excepción en que no es necesario que se otorgue por escritura pública, y no por ello pierda su calidad de solemne, sino que la solemnidad es otra. Esta excepción la consagra el art. 68 de la Ley N° 14.171 que dice:

"Los actos y contratos señalados en el artículo anterior (se refiere en general a las diversas operaciones que puede ejecutar la Corvi tales como compraventas de inmuebles, préstamos, constitución y alzamiento de gravámenes, etc.) podrán otorgarse por escritura privada firmada ante Notario, debiendo éste proceder a la protocolización de oficio, a más tardar el día hábil siguiente (actualmente son 30 días) a aquel en que sea suscrita, dejando constancia en el original y copia. Mientras no se efectúe esta protocolización, el acto o contrato no surtirá efecto alguno. El documento que no hubiere sido protocolizado oportunamente, carecerá de todo efecto legal, sin necesidad de que su nulidad o ineficacia sea declarada por sentencia judicial".

b) Formalidades legales especiales:

Estas formalidades son establecidas, en su mayor parte, en atención al estado o calidad de las personas a quienes pertenecen los bienes vendidos, tales son las ventas de bienes raíces de incapaces que requieren de autorización judicial; la renta de bienes raíces de una persona sometida a guarda debe hacerse además en pública subasta, arts. 1754, 255, 393.

Entre la escritura pública que se exige siempre, salva la excepción señalada, y la autorización judicial y la pública subasta exigida en el caso de los incapaces hay una gran diferencia: la omisión de la escritura pública produce siempre nulidad absoluta; en tanto que la ausencia de la autorización judicial o de la pública subasta produce nulidad relativa.

5.2.- Solemnidades voluntarias o convencionales.

Nada obsta a que las partes convengan que una venta que es consensual no se repute perfecta mientras no se cumpla la solemnidad de la escritura pública o privada. Así dice el art. 1802. Las solemnidades voluntarias dan derecho a las partes para retractarse antes de otorgarse la escritura o antes de efectuarse un principio de entrega. Si se ha entregado la cosa significa que se ha dejado sin efecto la solemnidad acordada. La omisión del instrumento en estos casos no produce nulidad del contrato, ya que la venta sigue siendo consensual.

5.3.- Casos especiales de compraventa en relación con las solemnidades.

Se trata de las ventas forzadas en juicio ejecutivo y de las expropiaciones por causa de utilidad pública:

a) Ventas forzadas en juicio ejecutivo:

Las ventas forzadas que se hacen por el ministerio de la justicia son verdaderas compraventas, art. 1891, así lo ha dicho también la jurisprudencia (R. de D. y J. T. 27, sec. 1ª. pág. 202) entre las ventas forzadas y las voluntarias no hay sino dos diferencias:

1) En la venta forzada el juez es el representante legal del deudor o vendedor;

2) Como la venta forzada se hace en pública subasta la forma de determinar el precio es distinto a la de venta voluntaria, pues mientras en ésta el precio se establece por el acuerdo de las partes, en aquéllas se obtiene por la pugna de los interesados.

Luego, si la venta forzada es una verdadera compraventa debe cumplir las condiciones de ella y, por consiguiente, si recae sobre inmuebles es necesaria la escritura pública. El art. 495 del C.P.C. establece que el acta de remate tiene valor de escritura pública para el solo efecto de que las partes puedan exigir el otorgamiento de la escritura pública.

b) Expropiaciones por causa de utilidad pública:

En estos casos no hay compraventa porque falta el consentimiento del obligado que es el expropiado, quien aparece como vendedor. Por el contrario, la expropiación es por definición un acto de autoridad. En ella es la ley el título y el modo de adquirir.

6. - Las arras.

Están reglamentadas en los arts. 1803 a 1805.

Las arras consisten en la suma de dinero o de cosas muebles que una persona da a otra en prenda de que va a celebrar el contrato de compraventa.

Hay dos clases de arras: a) las que se dan como prenda de la celebración del contrato, art. 1803 y b) las que se dan como parte del precio o en señal de quedar convenidos.

Las arras que se dan en prenda de la celebración del contrato dan derecho a las partes a retractarse: el que dio las arras perdiéndolas y el que las recibió restituyéndolas dobladas, art. 1803.

Cualquiera de las partes puede retractarse y ello debe hacerse:

1. En los plazos estipulados;
2. Si no hay convención al respecto, hasta transcurridos dos meses contados desde la convención en que se dieron las arras;
3. Hasta el otorgamiento de la escritura pública;
4. Hasta la entrega de la cosa vendida.

La retractación no procede después de otorgar la escritura o después de la entrega, porque se ha perfeccionado la compraventa, art. 1804.

Las arras que se dan como parte del precio o en señal de quedar convenidos, no dan derecho a retracción, art. 1805.

Este tipo de arras es excepcional, siendo la regla general las que se analizaron antes, por ello se dice que las partes establezcan expresamente que las arras se dan en parte del precio o en señal de quedar convenidos, si nada se dice se presume de derecho que otorgan facultad para retractarse, es decir, que pertenecen a aquellas que se dan en prenda de la celebración del contrato, art. 1805.

Sin embargo, las arras dadas en parte de precio o en señal de quedar convenidos, dan derecho a retractación cuando el contrato debe otorgarse por escritura pública, derecho que subsiste hasta que ésta se otorgue, art. 1805.

7. - Normas sobre capacidad para el contrato de compraventa.

La regla general en materia de capacidad la da el art. 1446, según el cual lo normal es la capacidad, siendo la incapacidad la excepción, y requiriendo estar expresamente establecida por el legislador. Dicha norma la reitera en materia de compraventa el art. 1795.

De esta disposición se desprende que la incapacidad en materia de contrato de compraventa puede ser:

1. Incapacidad absoluta;
2. Incapacidad relativa, y
3. Incapacidad especial o particular, art. 1447.

Incapacidades especiales en el contrato de compraventa.

Sólo nos interesa el análisis de las incapacidades especiales respecto del contrato de compraventa, a las cuales se refieren los artículos 1796 a 1800 del Código.

Estas incapacidades son las siguientes:

a) Compraventa entre cónyuges no separados judicialmente o entre padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad:

El contrato de compraventa celebrado entre estas personas es nulo absolutamente, sea que la compraventa recaiga sobre bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, art. 1796.

El contrato de compraventa celebrado entre cónyuges no separados judicialmente es nulo, no importa si están casados en régimen de sociedad conyugal, separados de bienes o en régimen de participación en los gananciales. Sólo es válido este contrato cuando los cónyuges están separados judicialmente.

En caso contrario, se podría recurrir a este medio para traspasar ciertos bienes del patrimonio del marido al de la mujer, los que quedarían sustraídos a los acreedores de éste.

El Código prohíbe también la compraventa entre padre o madre e hijo sujeto a patria potestad, art. 243. Por lo tanto y de acuerdo con el texto del art. 1796 el contrato de compraventa entre el padre o la madre y el hijo emancipado es perfectamente válido. También es válido el contrato de compraventa que celebra el padre o la madre con el hijo sujeto a patria potestad respecto de los bienes que forman su peculio profesional o industrial, porque respecto de estos bienes el hijo se considera como emancipado, art. 251.

La sanción a la infracción del art. 1796 es la nulidad absoluta, porque se trata de un acto prohibido por la ley, arts. 10, 1466 y 1682.

b) Venta por el administrador de establecimientos públicos de bienes que administra, sin facultades de vender.

Esta incapacidad la contempla el art. 1797. Si la venta que hace ese administrador no está comprendida dentro de las facultades administrativas y no ha sido autorizado por el funcionario competente en forma expresa, ella es nula relativamente, ya que el art. 1797 no contempla una prohibición absoluta, sino que permite esta venta con autorización expresa de la autoridad competente.

c) Compra por ciertas personas de bienes en cuya venta tienen o han tenido intervención.

Establece esta incapacidad el art. 1798.

Los empleados públicos tienen especial prohibición de comprar los bienes que están encargados de vender, so pena de nulidad absoluta de la compra.

Además, los jueces, abogados, procuradores o mandatarios judiciales o escribanos no pueden comprar los bienes que se vendan a consecuencia del litigio en que ellos han intervenido, aunque la venta se haga en pública subasta. También la sanción en caso de infracción es la nulidad absoluta.

Debe tenerse presente que el art. 321 del C.O.T, ha ampliado esta prohibición respecto de los jueces y que el art. 481 del mismo cuerpo de leyes la ha hecho extensiva a los demás auxiliares de la administración de justicia.

Ha sido controvertido si la venta efectuada por un partidor en un juicio de participación, como mandatario de los comuneros, hecha a un procurador o mandatario de una de las partes cae o no dentro del art. 1798. En un fallo se declaró nula esta venta (R. de J., T. 30, sec. 1°. pág. 176); sin embargo, en otras sentencias la han considerado válida, en base al argumento de que la participación no es un juicio (T. 23, sec. I^{a}., pág. 599).

No debe olvidarse que nada impide que en los juicios el abogado pueda convenir con su cliente, por escrito y antes de comenzar a prestar sus servicios lo que se llama pacto de "cuota litis", que consiste en estipular que cierta parte de los derechos litigiosos del cliente sean entregados al abogado en pago de sus servicios profesionales. Dicho pacto debe reunir los siguientes requisitos:

a) La participación del abogado debe ser menor que la del cliente, y

b) Ambos deben quedar en libertad para resolver el pacto con los reembolsos correspondientes.

d) Compraventa por tutores y curadores.

Incapacidad establecida en el art. 1799. Disposición que nos remite al título "De la administración de los tutores y curadores" y dentro de ese título hay que atenerse a lo dispuesto en el artículo 412. En conformidad a esta disposición hay que hacer una distinción según los bienes del pupilo sean muebles o inmuebles:

1) Bienes muebles: puede comprarlos el guardador, pero con la autorización de los demás guardadores o de la justicia, de modo que si se omite dicha autorización el acto o contrato será nulo relativamente, porque el requisito se exige en consideración a la calidad o estado de la persona.

2) Bienes raíces: el art. 412 prohíbe terminantemente que el guardador compre bienes raíces del pupilo, ni aun con autorización judicial o de los otros guardadores no implicados. Esta norma es claramente prohibitiva y, en consecuencia, su infracción produce la nulidad absoluta del acto.

e) Compraventa de los mandatarios, síndicos y albaceas.

La establece el art. 1800. Hay que distinguir entre los mandatarios y los síndicos por un lado y los albaceas por otro.

El síndico de acuerdo con el art. 21 de la Ley de Quiebras, tiene la representación del fallido y de los acreedores en relación con los bienes comprendidos en la quiebra. Por ello se le aplica a éste la misma regla que a los mandatarios, es decir, el artículo 2144.

Albacea es la persona designada por el testador para hacer cumplir las disposiciones testamentarias. A su respecto se plantea un problema, porque si bien el art. 1800 dice que le es aplicable el art. 2144, el art. 1294 ubicado entre las normas relativas a los albaceas, les hace aplicable el art. 412. Cabe entonces preguntarse cuál de las disposiciones es la aplicable.

El problema tiene especial importancia tratándose de bienes inmuebles, porque aplicando el art. 2144 le sería posible al albacea comprarlos; en cambio, conforme al art. 412 ello le es imposible.

Se da solución a este problema aplicando la regla de hermenéutica que dice que una disposición especial prima sobre una general, luego debe aplicarse el art. 412, porque el art. 1294 una norma especial para los albaceas, que debe primar sobre la regla general del art. 1800.

8. - Efectos del contrato de compraventa.

Los efectos de un contrató son los derechos y obligaciones que de él emanan.

Perfeccionado el contrato de compraventa, una vez que las partes han convenido en la cosa y el precio, nacen para ambas derechos y obligaciones que el contrato estaba destinado a producir. Estos derechos y obligaciones pueden provenir de la ley o de la voluntad de las partes.

Siendo la compraventa un contrato bilateral surgen obligaciones para ambas partes:

Así el vendedor tiene dos obligaciones esenciales:

1. Entregar la cosa vendida, y
2. Sanear la cosa vendida al comprador.

Por su parte, el comprador tiene también dos obligaciones:

1. Pagar el precio, y
2. Recibir la cosa comprada.

Las obligaciones, que son de la esencia del contrato de compraventa son la de entregar la cosa vendida y pagar el precio, sin estas obligaciones no hay contrato de compraventa.

Nada obsta a que las partes, a más de las obligaciones que se han señalado para comprador y vendedor convengan en el establecimiento de otras, como ser imponer al comprador la obligación de destinar la cosa vendida a un fin determinado.

9. - Obligaciones del vendedor.

Las obligaciones propias del vendedor y que nacen del contrato de venta por el solo hecho de celebrarse, es decir, las obligaciones que la ley le impone son dos: la entrega de la cosa y el saneamiento de la misma. Sin perjuicio de ellas, los contratantes pueden convenir otras o atenuar o modificar esas dos. En tal caso deben pactarse expresamente, pues a falta de tal convenio, el vendedor no tiene sino las señaladas por la ley y en la extensión que ésta establece. Art. 1824.

9.1. - Obligación de entregar la cosa vendida. ^

La primera obligación del vendedor es la de entregar la cosa vendida: consiste esta obligación en conferir al comprador la posesión legal y material de la cosa objeto del contrato.

De acuerdo con las reglas generales si la cosa vendida es una especie o cuerpo cierto, el vendedor no sólo tiene la obligación de entregar la cosa, sino que dicha obligación se extiende a la conservación de la especie o cuerpo cierto, art. 1548.

Luego, cuando se trata de venta de una especie o cuerpo cierto la obligación de entregar la cosa comprende dos obligaciones o situaciones:

A) La necesidad del vendedor de conservar la especie o cuerpo cierto hasta la entrega, y

B) Conferir la posesión legal y material de la cosa vendida.

A) Conservación de la especie o cuerpo cierto hasta la entrega:

Para que esta situación se presente es necesario que las partes hayan convenido un plazo para la entrega, es decir, que tiene que mediar un plazo entre la fecha de la celebración del contrato y la época en que tiene que hacerse la entrega de la cosa, plazo durante el cual la cosa vendida permanece en poder del vendedor.

El art. 1548 impone la obligación de custodia y conservación de la cosa que se debe, al deudor, en este caso, al vendedor, so pena de pagar perjuicios al acreedor que no se constituya en mora de recibir.

La responsabilidad del deudor se extiende hasta la culpa leve si la pérdida de la cosa o su deterioro es culpable, art. 1547.

En caso de que la pérdida o deterioro de la cosa no se deba a culpa del deudor, se aplica el art. 1590 incs. I° y 2°, y también cuando la cosa se deteriora o destruye después que el comprador se ha constituido en mora de recibir, el comprador debe recibir la cosa en el estado en que se encuentre.

Ahora, si la destrucción o deterioro de la cosa vendida que se encuentra en poder del vendedor es fortuita, el riesgo es de cargo del comprador (acreedor de la cosa), luego si se produce esta situación se extingue la obligación del vendedor de entregar la cosa, pero subsiste la del comprador de pagar el precio. Hay una excepción a esta situación, la cual se refiere al caso de que la venta sea condicional: si la cosa parece antes de cumplirse la condición, el riesgo pertenece al vendedor, arts. 1550 y 1820.

Esta regla general en materia de riesgo tiene **aplicación** IMI el caso que reglamenta el art. 1821 inc. 1° que pone el riesgo de la cosa que se vende a peso o a medida, pero señalada de un modo que no pueda confundirse con otra a cargo del comprador, porque es venta de especie o cuerpo cierto. En cambio, el inciso 2° del art. 1821 pone el riesgo de la cosa indeterminada sobre el vendedor, ya que se trata de una venta de género.

En el caso de la venta de cosa a prueba o al gusto se trata de una venta condicional porque su perfeccionamiento está sujeto a la condición potestativa de que la cosa vendida guste al comprador; de ahí que si la cosa perece antes que el comprador manifieste su conformidad, la cosa se pierde para el vendedor. El art. 1823 que no hace sino que reiterar lo establecido por el art. 1486.

B) Obligación de conferir al comprador la posesión legal y material de la cosa vendida:

Surge aquí una discusión que ha ido cobrando mayor interés con el curso del tiempo y que consiste en determinar cuál es la verdadera obligación del vendedor.

1) Tesis clásica

La que hasta hace unos años constituía la tesis mayoritaria, cuando no única en la materia, sostenía que tal obligación se concretaba en entregar la cosa, entendiéndose cumplida al colocar al comprador en la posesión tranquila, pacífica y útil del bien comprado, sin que la transferencia del dominio fuese considerada una obligación esencial del vendedor. Su mejor exponente fue don Arturo Alessandri, quien sostenía lo que se ha dicho en cuanto la obligación del vendedor era entregar la cosa al comprador, sin que tenga el deber de hacerlo propietario de la misma.

Criticaba, en consecuencia, el artículo 1793 del Código Civil, en cuanto utilizaba la expresión “dar” cuando en realidad lo que debía y quería decir era “entregar” considerando éste un grave error del legislador.

En sustento de su parecer formula los siguientes argumentos:

a) La validez de la venta de cosa ajena establecida en el artículo 1815 del Código Civil. Conforme a dicha norma, la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos que asisten al dueño de la cosa vendida. Se sostiene que si el vendedor estuviese obligado a dar el dominio al comprador, entonces sólo podría vender aquellas cosas que son de su propiedad ya que sólo respecto de ellas podría cumplir tal obligación; de lo contrario, el contrato sería nulo. Del contrato de compraventa sólo surgen obligaciones para las partes, y el vendedor cumple con la suya colocando al comprador en la posesión pacífica y tranquila de la cosa comprada y este último no podría pedir la resolución del contrato fundado en que el primero no era dueño de lo que le vendió. Así lo ha sostenido alguna jurisprudencia (R.D.J., T. 47, sección 2ª., pág. 1).

La tesis contraria sostiene que se está confundiendo la validez del contrato con las obligaciones que emanan de él. Conforme a la dualidad título modo que impera en nuestra legislación, no existe ningún inconveniente para que dos personas celebren un contrato de compraventa respecto de una cosa ajena, en medida que de la compraventa, como de la mayoría de los demás contratos, sólo surgen obligaciones personales entre las partes que los celebran y ya verán ellas si están o no en condiciones de cumplirlas y cómo lo hacen, incluso de no haber existido el artículo 1815 estimamos que igualmente la venta de la cosa ajena hubiese sido válida. Por el contrato sólo se contrae una obligación; y adquirir una obligación es una cuestión muy distinta de cumplir la misma. Por lo tanto, la validez de la venta de cosa ajena no es fundamento a la hora de establecer cuál es la obligación del vendedor.

b) Un segundo argumento de la teoría clásica arranca del artículo 1824 del Código Civil, que establece que las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. Señalan que en base a tal disposición, queda claro que la obligación del vendedor es la de entregar, en realidad, colocar en posesión al comprador. Afirman que nuevamente aquí, el legislador incurrió en un error en cuanto utiliza la palabra "tradición", pero que sí resulta adecuado el uso de la palabra "entrega" que en manera alguna involucra la idea de transferencia de dominio.

La tesis contraria está de acuerdo en entender que entregar y tradir son cosas distintas. Pero, afirmar que en base a tal distinción puede sostenerse que el legislador cometió un error de redacción al usar la palabra "tradición" (en realidad, éste sería un nuevo error porque ya habría cometido otro con la voz "dar" en el artículo 1793), parece excesivo. Además, lo que sostiene la tesis clásica es que la obligación del vendedor es colocar en posesión de la cosa, y la disposición en comento habla de entregar, conceptos totalmente distintos y si se pretende sustentar en esta disposición, entonces la obligación del vendedor no sería ni siquiera de colocar en posesión sino con la mera entrega habría cumplido. En el mismo sentido, el artículo 1819 del Código Civil, establece que en el caso de la venta de cosa ajena, si luego el vendedor se hace dueño de ella, se mirará al comprador como su dueño "desde la fecha de la tradición", ratificando así que estamos frente al acto jurídico "tradición", no bastando una mera entrega.

c) El tercer argumento de la teoría clásica se funda en la obligación de saneamiento de la evicción. Esta obligación consiste en el deber del vendedor de amparar al comprador en el dominio y posesión de la cosa vendida y de indemnizarlo si eventualmente es privado de ella.

Se sostiene que al consagrar nuestro Código esta institución en los artículos 1837 y siguientes, ello lleva a que la obligación del vendedor no podría ser la de transferir el dominio, por cuanto si así fuera, no tendría sentido que existiese el saneamiento de la evicción ya que en caso de no concretarse la transferencia se aplicaría derechamente la

acción resolutoria; como no es así y la obligación de saneamiento sí existe, entonces se debe concluir que el vendedor no está obligado a transferir el dominio.

La tesis contraria sostiene que el comprador goza de ambas acciones; de saneamiento y resolutoria, en el evento de que no se le transfiera el dominio de la cosa vendida.

2) Tesis Moderna

Afirma que el vendedor está obligado a transferir el dominio de la cosa sobre la cual ha recaído el contrato de compraventa.

Sostenida principalmente por don José Joaquín Ugarte y respaldada por la mayoría de los autores contemporáneos, encuentra como fundamento los siguientes:

a) Todos los que se han indicado como críticas a lo sostenido por la teoría clásica.

b) La obligación del poseedor de restituir la cosa a su dueño legítimo. Si la obligación del vendedor fuese sólo dejar en posesión al comprador, entonces nos encontraríamos frente a dos obligaciones contrapuestas la que emana del contrato de compraventa de colocar en posesión y su obligación como poseedor no dueño de devolver el bien al propietario del mismo.

c) Los artículos 1793 en concordancia con los artículos 670 y 1824 del Código Civil. Conforme a tales disposiciones la obligación del vendedor es de "dar" y ello se cumple mediante la tradición del bien. A diferencia de la opinión clásica, estas normas no presentarían defectos sensibles en su redacción y constituirían un todo armónico.

d) Porque nadie celebra un contrato de compraventa en calidad de comprador, para adquirir la calidad de poseedor del bien comprado. Se compra para ser dueño y no para poseer y si no se adquiere el dominio, entonces el vendedor no habrá cumplido y lo mínimo es que el vendedor quede premunido de la acción resolutoria derivada de tal incumplimiento.

No obstante, nadie discute que en todo caso la obligación del vendedor de entregar al comprador la cosa vendida, consiste en conferirle la posesión legal y material de ésta.

En relación con esta materia es necesario distinguir si el vendedor es o no el verdadero dueño de la cosa vendida:

I. Situación en que el vendedor es el verdadero dueño:

La única forma en que podrá conferir la posesión al comprador es mediante la tradición efectuada en conformidad a las normas que la ley establece, esto es de acuerdo a los arts. 684, 686 y 724. De ahí que el art. 1824 diga que el vendedor debe hacer entrega o tradición, es decir, que si es el vendedor dueño tiene que transferir el dominio.

El vendedor que es dueño de la cosa vendida tiene una obligación de dar, art. 1548.

No obstante lo dicho no basta con que el vendedor haga tradición en aquellos casos en que ella se efectúa mediante la inscripción del título, ya que con ella sólo habrá conferido una posesión legal, art. 724, y él también tiene la obligación de conferir la posesión material. Luego en aquellos casos en que la tradición se hace por medio de la inscripción el vendedor tiene además la obligación de hacer entrega material de la cosa vendida, y antes no ha cumplido su obligación de entregar ni tampoco su obligación de dar, porque ésta contiene la de entregar.

II. Si el vendedor no es el verdadero dueño:

También deberá el vendedor conferir la posesión de la cosa al comprador mediante la correspondiente tradición, pero ésta será ineficaz para conferir el dominio y tan sólo otorgará la posesión de ella al comprador, arts. 682 y 683.

Pero, nótese que una vez hecha la tradición al comprador de la cosa ajena, ya está cumplida por el vendedor su obligación de entregar.

De modo que si el verdadero dueño con posterioridad reivindica contra el comprador, éste no podrá intentar en contra del vendedor la acción de cumplimiento o la de resolución del contrato, porque la obligación de entregar del vendedor ya estaba cumplida. Lo único que puede hacer es citarlo de evicción.

En virtud de la citación de evicción si el comprador es privado de todo o parte de la cosa por una sentencia judicial que reconozca el dominio de un tercero, puede exigir al vendedor la restitución del precio y varias indemnizaciones que se analizarán más adelante.

9.1.1. -Lugar en que debe hacerse la entrega.

Al reglamentar el contrato de compraventa nada dijo el legislador respecto al lugar en que debe hacerse la entrega de la cosa vendida, por consiguiente hay que aplicar las normas generales respecto al lugar en que debe hacerse el pago, es decir las de los arts. 1587, 1588 y 1589. De ellos se desprende que la cosa vendida debe ser entregada:

a) En el lugar que las partes hayan estipulado;

b) A falta de estipulación la entrega se hará en el lugar en que la especie o cuerpo cierto se encontraba a la fecha del contrato, si la cosa vendida es una especie; y se hará en el domicilio del deudor si la cosa vendida es una cantidad determinada de un género limitado.

Si el acreedor o el deudor hubiesen mudado de domicilio se aplica el art. 1589.

9.1.2. -Momento en que debe efectuarse la entrega o tiempo de la entrega.

Al respecto hay que distinguir las siguientes situaciones:

a) Si el contrato es puro y simple el vendedor debe efectuar la entrega de la cosa vendida tan pronto como quede perfecto el contrato de compraventa, porque su obligación se hace exigible en ese momento, art. 1826 inc. I^{o}.

b) Por el contrario, si el contrato es a plazo o bajo condición suspensiva el vendedor debe efectuar la entrega al vencimiento del plazo o al cumplimiento de la condición, ya que en ambos casos la exigibilidad de la obligación ha estado postergada y surge sólo en ese momento, arts. 1826 inc. I^{o}, 1485 inc. I^{o} y 1496 inc. I^{o}.

La determinación del momento o tiempo de la entrega adquiere especial importancia cuando el vendedor ha vendido una misma cosa a dos o más personas distintas, para el efecto de saber cuál de las ventas debe prevalecer.

En conformidad a lo que establece el artículo 1817 si alguien vende separadamente una cosa a dos o más personas, para determinar cuál venta prefiere, se considerará:

I. Si se ha vendido la cosa a dos o más personas, pero se ha entregado a una sola de ellas, ésta será preferida;

II. Si la cosa se ha entregado a dos o más personas, tendrá derecho a quedarse con ella, aquella a quien se le haya entregado primero, y

III. Si la cosa no se ha entregado a ninguno de los compradores “prevalecerá el título más antiguo”.

Hay que tener presente que cuando el Código habla de título más antiguo, se está refiriendo a la fecha de la compraventa. Así lo ha resuelto la jurisprudencia. “Para determinar cuál es el título más antiguo hay que atenerse únicamente a las fechas de las escrituras de compraventa. No procede sostener que la escritura que tiene fecha

posterior es más antigua porque emana de una promesa de venta otorgada con anterioridad a la otra. El art. 1817 al hablar de dos títulos se refiere a dos títulos traslaticios de dominio, o sea, a los que dan acción personal contra el vendedor para exigirle la entrega de la cosa vendida, caracteres de los cuales no participa la promesa de venta" (Rev. de D. y J., T. 22, sec. 1ª, pág. 1081).

Además, se ha resuelto que tratándose de inmuebles, la posesión a que se refiere el art. 1817 es la posesión legal que es conferida por la correspondiente inscripción del título en el Registro de Propiedad y no la posesión material. "Para el cumplimiento de la obligación de entregar que pesa sobre el vendedor respecto del comprador, debe llegarse hasta la verificación de la entrega material de lo vendido. Mas, cuando dos o más compradores discuten el mejor derecho sobre preferencia de títulos que consagra el art. 1817, sólo someten a resolución judicial una cuestión sobre declaración de dominio, cuya fuente es la tradición que, tratándose de bienes raíces se efectúa por la inscripción del título correspondiente en el Registro del Conservador, que es a la vez la única manera de adquirir la posesión.

En consecuencia, en la discusión sobre preferencia de títulos respecto de un inmueble debe tomarse como posesión que justifique la preferencia, la posesión legal basada en la inscripción de los títulos y cabe considerar como título preferente el que fuera primeramente inscrito".

9.1.3. - Cómo debe efectuarse la entrega.

Ya se ha visto anteriormente que la entrega se hace por la tradición de la cosa y respecto a ella se aplican las reglas generales que en tal materia establece el Código Civil:

a) Si la cosa es mueble se aplica el art. 684

b) Si es inmueble se aplican los arts. 686 y 724

En cuanto a lo que comprende la entrega habrá que estarse a las estipulaciones de las partes, será, por lo tanto, materia de interpretación del contrato.

En la venta de inmuebles quedan comprendidos los inmuebles por adherencia, porque ellos forman un solo todo con el inmueble por naturaleza que se vende; igualmente quedarán incluidos los inmuebles por destinación, art. 1830, aun cuando estos últimos pueden ser excluidos de la venta por convención de las partes.

9.1.3. - La entrega en la venta de predios rústicos.

Los predios pueden ser urbanos o rústicos. Para calificarlos en esta forma no se atiende a su ubicación sino al destino que ellos tengan. Si están destinados al cultivo agrícola, a la explotación de la tierra, se les cataloga de predios rústicos; por el contrario, si está destinado a la habitación, almacenes, edificios, es urbano.

Los arts. 1831 a 1834 se refieren a la entrega de predios rústicos solamente.

La entrega de un predio rústico es distinta según la forma en que se venda y los predios de esta naturaleza pueden venderse en dos formas:

a) Como especie o cuerpo cierto, y

b) Con relación a su cabida, art. 1831 inc. 1º.

La regla general es que los predios se venden como especie o cuerpo cierto, esto es, sin relación a su cabida. Debe entenderse que la venta se hace como especie o cuerpo cierto cuando no hay estipulación alguna en relación a la forma

como se hace la venta, art. 1831 inc. final.

Venta con relación a la cabida.

Se entiende que la venta se hace en relación a la cabida en aquellos casos en que el contrato de venta se expresa, de cualquier modo, la extensión, superficie o cabida del predio, salvo cuando no obstante haberse ella señalado, las partes estipulan expresamente que no habrá cuestión por la diferencia entre la cabida declarada y la cabida real, art. 1831.

La determinación de la cabida puede hacerse en cualquier forma, ya sea señalando la superficie total del predio o la superficie de las distintas partes que lo componen, art. 1831 incs. 3º, 4º y 5º.

La jurisprudencia ha resuelto que para que se entienda vendido un predio rústico en relación a la cabida no basta que ésta se exprese en el contrato, sino que también es necesario que el precio se determine en relación a la cabida. Se ha sostenido que en realidad este fallo no interpreta correctamente el inc. 3º del art. 1831.

Cuando un predio se vende con relación a su cabida, si el vendedor entrega la misma extensión que establece el contrato, no se produce dificultad alguna, pero sí se presentan problemas cuando la cabida declarada no coincide con la real.

Frente a este problema y para darle solución el Código hace una distinción entre las dos situaciones siguientes:

I. La cabida real resulta menor que la declarada,

II. La cabida real resulta mayor que la declarada.

I. La cabida real resulta menor que la declarada:

Esta situación la reglamenta el art. 1832, inc. 2º.

En este caso es necesario distinguir si la cantidad que falta para completar la cabida declarada excede o no a un 10% del valor de la cabida declarada:

1. Cuando la extensión que falta no excede de un 10% del valor de la cabida declarada, el vendedor está obligado a completar la cabida declarada, y si ello no le fuere posible a rebajar proporcionalmente el precio, pues ha entregado una extensión menor que la señalada en el contrato.

Ejemplo: Se dice en el contrato que se vende un predio rústico que tiene 100 hectáreas a $ 1,00 la hectárea, y en realidad al hacer la entrega resulta que al comprador sólo se le entregan 95 hectáreas. El precio de la cabida declarada es de $ 100,00, el precio de la extensión entregada es de $ 95,00, el precio de la extensión que falta es de $ 5,00. El 10% del valor de la cabida declarada es de $ 10,00 luego el precio de la extensión que falta es inferior al 10% del valor de la cabida declarada; por consiguiente, el vendedor debe completar la cabida declarada en 5 hectáreas, y si no le fuere posible debe rebajar proporcional mente el precio.

2 **-** Si la extensión que falta por entregar para cumplir el contrato excede al 10% del valor de la cabida declarada el comprador tiene un derecho alternativo:

a) O bien acepta la disminución del precio que le haga el vendedor,

b) Puede solicitar la resolución del contrato con indemnización de perjuicios por incumplimiento de la obligación del vendedor.

Ejemplo: Se dice en el contrato que se venden 100 hectáreas a $ 1,00 cada una, en realidad se entregan sólo 50 hectáreas. El precio de la extensión que falta es de $ 50,00 que es superior al 10% de la cabida declarada. Por consiguiente, el comprador tiene una opción: o acepta una disminución proporcional del precio, el que quedaría reducido a $ 50,00 o pide la resolución del contrato con indemnización de perjuicio por incumplimiento de la

obligación del vendedor.

II. La cabida real es mayor que la declarada:

El art. 1832 inc. 1º reglamenta esta situación.

En este caso hay que distinguir si el exceso del terreno entregado por el vendedor al comprador excede o no al valor del 10% del precio de la cabida real.

1. Si no excede al 10% el comprador está obligado a aumentar proporcional mente el precio.

Ejemplo: Se venden 100 hectáreas a $ 1,00 cada una, el vendedor entrega al comprador 103 hectáreas; el exceso es de 3 hectáreas cuyo valor es de $ 3,00; el 10% de la cabida real es de $ 10,3, pues el precio de ella es 103,00. Luego el precio sobrante es inferior al 10% del precio de la cabida real, por consiguiente, el comprador está obligado a aumentar proporcionalmente el precio en $ 3,00 debiendo recibir las 103 hectáreas.

2. Si excede al 10% el comprador tiene una opción: puede aumentar proporcionalmente el precio o desistir del contrato, indemnizándose en este caso los perjuicios conforme a las reglas generales.

Ejemplo: Se dice que se venden 100 hectáreas a $ 1 cada una, en realidad se entregan 130 hectáreas; el precio de la cabida real es de $ 130, siendo el del exceso de $ 30, el 10% de la cabida real alcanza a $ 13, luego el precio de la extensión sobrante es superior al 10% del precio de la cabida real. Por consiguiente, el comprador puede optar por aumentar proporcionalmente en $ 30 recibiendo las 130 hectáreas o desistirse del contrato.

En las reglas vistas puede comprobarse que el legislador ha dejado un margen -el 10%- en que puede oscilar la diferencia entre cabida real y cabida declarada; pero si la diferencia excede al 10% debe considerarse que el vendedor no ha cumplido y da derecho al comprador para solicitar la resolución del contrato.

Venta como especie o cuerpo cierto:

Se ha señalado que ésta es la regla general en la venta de predios rústicos, y ella se produce siempre que en el contrato de compraventa no se exprese la cabida o cuando expresándose ésta, se declara que no se alterará el precio aunque haya diferencia entre la cabida real y la declarada, art. 1831 inc. 2º.

La venta de un predio rústico como especie o cuerpo cierto puede hacerse en dos formas:

a) Sin señalamiento de linderos, y

b) Con señalamiento de linderos.

Si el predio se vende sin señalamiento de linderos, nada puede reclamar el comprador y cualquiera extensión que se le entregue implicará el cumplimiento de la obligación del vendedor, art. 1833 inc.1º.

La venta con señalamiento de linderos es la forma usual (se indican los deslindes del predio). En este caso el vendedor debe entregar toda la extensión comprendida entre los deslindes, art. 1833 inc. 2º. Ahora bien, si el vendedor no pudiere entregarla se aplica el art. 1832 inc. 2°, y en consecuencia habrá que ver si la cantidad que falta por entregar excede o no al 10% del precio de la extensión comprendida en los linderos; si no excede, tiene derecho a rebajar proporcional mente el precio; si excede, el comprador puede aceptar la rebaja del precio o puede desistirse del contrato.

Prescripción de estas acciones:

Sea que la venta del predio rústico se haga con relación a la cabida o como especie o cuerpo cierto, las acciones de las partes para reclamar de las diferencias en la entrega prescriben en el plazo de un año contado desde la entrega material o real. El plazo no se cuenta desde la entrega legal que se verifica por la inscripción, pues sólo la ocupación

material habilita para apreciar lo que efectivamente se entrega. (R. de D. y J., T. 27, sec. Iª, pág. 190).

Esta prescripción por ser especial no se suspende.

Aplicación extensiva de estas reglas:

Las normas de los arts. 1832 y 1833 sobre venta con relación a la cabida, se aplican también a las ventas de universalidades de hecho. Así, por ejemplo, si se vende una biblioteca con cinco mil libros y en la entrega faltan o sobran unidades, pueden aplicarse las normas de los arts. 1832 y 1833, según cual fuere el contenido de las estipulaciones.

Debe tenerse presente, que tratándose de venta de inmuebles, la aplicación de estas reglas no excluye la aplicación de la lesión enorme en su caso, ya que el fundamento de la lesión enorme es distinto del que informa o sirve de base a los arts. 1832 y 1833.

Gastos de la entrega.

Los gastos en que se deba incurrir para efectuar la entrega de la cosa vendida al comprador son de cargo del vendedor, salvo convención en contrario, arts. 1806 y 1825.

9.1.5. - Acciones del comprador contra el vendedor que no cumple la obligación de entregar.

Puede ocurrir que el vendedor no cumpla la obligación que le impone el contrato de venta, es decir, que no entregue oportunamente la cosa vendida, o que la cumpla de un modo imperfecto. Como la venta es un contrato bilateral, que no puede dejarse sin efecto por la sola voluntad de una de las partes, esa inejecución no acarrea su resolución ipso-jure. Por el contrario, el contrato subsiste, siendo el comprador árbitro para mantenerlo o para ponerle fin. De ahí que los efectos que producen ese incumplimiento se reducen a conferir al comprador dos acciones que tienen por objeto, una exigir la entrega de la cosa y la otra, la resolución del contrato de compraventa.

Estas acciones están establecidas en el inc. 2º del art. 1826 del Código Civil. Este artículo no es sino la reproducción de la regla general que para los contratos bilaterales consigna el artículo 1489 del mismo Código.

"¿Cuándo se entiende que el vendedor no ha cumplido su obligación de entregar? He aquí una cuestión que presenta dificultades.

La obligación del vendedor, según se ha dicho, comprende la de entregar la cosa en el lugar y tiempo convenidos, con todos sus frutos y accesorios y ciñéndose estrictamente a lo pactado. Aparte del hecho mismo de la entrega, esa obligación comprende varias otras que, en conjunto, forman la obligación de entregar. Desde que todas ellas constituyen la obligación de entregar y que el art. 1826, al conceder esas acciones no distingue en qué caso proceden, limitándose a indicar que si el vendedor no efectúa la entrega el comprador podrá ejercitarlas, es obvio decidir que la violación de cualquiera de ellas lo autorizan para pedir la resolución del contrato o su cumplimiento con indemnización de perjuicios. Por otra parte, el art. 1489 del Código Civil dispone que en todo contrato bilateral va subentendida la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Como lo pactado puede referirse, y efectivamente se refiere, tanto al hecho de entregar la cosa vendida, como a la obligación de entregarla en el lugar y tiempo debidos, de entregar sus frutos y accesorios y de hacerlo en la forma convenida, es claro que la infracción de cualesquiera de estos convenios coloca al comprador en situación de usar esos derechos.

La falta de entrega importa violación de la obligación del vendedor, y en este caso el comprador tiene derecho para pedir la resolución o el cumplimiento del contrato y en ambos casos con indemnización de perjuicios.

Pero para que el comprador pueda ejercitar esas acciones en caso de que el vendedor no cumpla su obligación de entregar la cosa vendida, es menester la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos: 1^0 que el vendedor esté constituido en mora de entregar; 2° que esta mora sea imputable a su hecho o culpa y 3° que el comprador haya pagado el precio, se allane a pagarlo o se le haya señalado un plazo para hacerlo.

9.1.6. - Derecho de retención del vendedor.

Puede suceder que después de celebrado el contrato de compraventa, pero antes de que se haya efectuado la entrega de la cosa vendida, disminuya considerablemente la fortuna del comprador. En este caso, el vendedor no está obligado a efectuar la entrega, aunque se haya estipulado un plazo para el pago del precio, mientras no se le pague éste o se le asegure convenientemente su pago, art. 1826 inc. final.

9.2. - Obligación de sanear la cosa vendida.

La segunda obligación del vendedor es la del saneamiento de la cosa vendida. El vendedor debe proporcionar al comprador la posesión tranquila y pacífica de la cosa vendida, y, además, una posesión útil.

Que la posesión sea pacífica quiere decir que ella no debe verse turbada por las acciones que los terceros hagan valer sobre la cosa vendida para privar de ella al comprador.

Que la posesión sea útil significa que la cosa vendida no debe tener vicios ocultos que la imposibiliten para su uso.

A estos dos aspectos por los cuales puede verse turbada la posesión se refiere el art. 1837 cuando dice que la obligación de saneamiento comprende dos objetos:

1. Amparar la posesión pacífica de la cosa (Saneamiento de la evicción).
2. Responder de los vicios ocultos de la cosa (Saneamiento de los vicios redhibitorios).

9.2.1. - Saneamiento de la evicción.

Consiste en la obligación del vendedor de garantizar la posesión pacífica de la cosa vendida, por ello también se la denomina obligación de garantía. Entra a jugar esta obligación cuando el comprador es perturbado en su posesión por terceros que pretenden hacer valer derechos sobre la cosa vendida.

La evicción está definida en el art. 1838 C. Civil que dice: “Hay evicción de la cosa comprada, cuando el comprador es privado del todo o parte de ella, por sentencia judicial”.

Esta obligación del vendedor presenta las siguientes características:

a) Es una obligación de la naturaleza del contrato, arts. 1444, 1839.

b) El vendedor no puede ejercer acciones que se traducirían en una perturbación o extinción de la posesión pacífica de la cosa adquirida por el comprador. De diversos preceptos -arts. 1837, 1845 y 1849- se desprende que es absolutamente inconciliable la obligación de defender al comprador de toda turbación con el ejercicio de la acción reivindicatoría o de cualquiera otra dirigida a perturbar o privar al comprador de la posesión pacífica de la cosa. Por el hecho de vender se contrae la obligación de amparar y defender al comprador, y ésta acarrea la de no atacarlo en el dominio y posesión pacífica de la cosa, situación inconciliable con la otra. Igual impedimento afecta a los herederos del vendedor, porque la obligación de saneamiento es transmisible.

a) La obligación del vendedor de defender y amparar al comprador es patrimonial, porque tiene este carácter lo que se demandaría, la posesión o el dominio de la cosa vendida. Por ser patrimonial la obligación se transmite a los herederos del vendedor y la acción a los del comprador.

REQUISITOS DE LA EVICCIÓN

De los arts. 1838 y 1839 se desprende que son tres los requisitos que deben concurrir para que haya evicción:

1) Que el comprador sea privado de todo o parte de la cosa;

2) Que la evicción provenga de un hecho anterior a la venta, y

3) Que la privación de todo o parte de la cosa sea por sentencia judicial.

1) Que el comprador sea privado de todo o parte de la cosa:

Se entiende que el comprador es privado de la cosa no sólo cuando es privado del todo o de una parte material de ella, sino también siempre que por sentencia judicial se declare en favor de un tercero la existencia anterior de algún derecho sobre la cosa que limite de cualquier modo el dominio que el comprador se propuso adquirir.

Así, hay privación de toda la cosa cuando, por ejemplo, ha habido venta de cosa ajena y el propietario de ella entabla la correspondiente acción reivindicatoría en contra del comprador y se ordena restituir la cosa; o también cuando un acreedor hipotecario hace uso de la acción de desposeimiento y quita la cosa al comprador.

Hay privación de parte de la cosa, por ejemplo, cuando se declara en favor de un tercero un derecho real limitativo del dominio y posesión de la cosa comprada, como ser un derecho de usufructo, o la propiedad fiduciaria.

2) La evicción debe producirse por causa anterior a la venta:

Este principio contemplado en el art. 1839, es de manifiesta equidad. No puede lógicamente hacerse responsable al vendedor por hechos acaecidos después de la venta, en los cuales no ha tenido ninguna participación.

3) Que la privación de todo o parte de la cosa se haga por sentencia judicial:

Esto es lo que viene a caracterizar la evicción, de tal forma que si la privación no se produce por sentencia judicial no existe evicción. Si se quita materialmente la cosa vendida al comprador, éste podrá ejercer las acciones que la ley le confiere: posesoria o reivindicatoría, según los casos; pero no habrá lugar a la evicción porque ésta requiere de una sentencia judicial.

En otras palabras, para que haya evicción se necesita que se inicie un juicio por un tercero en contra del comprador, y que en dicho litigio se dicte sentencia condenatoria en perjuicio de éste, vale decir, la sentencia debe condenarlo a entregar la cosa al demandante o reconocer en favor de éste un derecho real limitativo del dominio.

CONTENIDO DE LA OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO POR EVICCIÓN

El saneamiento de la evicción comprende dos etapas bien diferenciadas:

a) La primera etapa consiste en la obligación del vendedor de auxiliar al comprador defendiéndolo en el juicio que se ha iniciado en su contra.

b) La segunda, consiste en que una vez producida la evicción, esto es una vez que el comprador ha sido privado de todo o parte de la cosa, el vendedor debe indemnizarle todos los perjuicios que ello le cause.

Se trata de dos obligaciones totalmente diversas, nítidamente separadas, que se suceden una a otra.

La primera de ellas es una obligación de hacer, porque se trata de la ejecución de un hecho, ir en auxilio del comprador. Por ello es que el art. 1840 dice que el saneamiento es indivisible, característica que permite exigirlo de cualquiera de los herederos del vendedor.

En tanto que la segunda de estas obligaciones -la de indemnizar- es obligación de dar, y como tal tiene carácter divisible. El inciso 2º del art. 1840 establece claramente que esta obligación es divisible y que sólo puede exigirse a prorrata de las cuotas hereditarias de los herederos del vendedor.

A) Primera obligación: el amparo judicial.

Al entablarse en contra del comprador una acción judicial por un tercero que pretenda derecho sobre la cosa vendida, como ser una acción reivindicatoría, lo normal es que el vendedor no tenga conocimiento de ello ni de las pretensiones del tercero, por ello la ley exige al comprador que cite de evicción al vendedor por medio del procedimiento especial que para este efecto se establece en el Código de Procedimiento Civil (arts. 584 a 587), art. 1843.

La citación de evicción procede no sólo en el juicio ordinario sino también en cualquier otra clase de juicio, ejecutivo, posesorio, etc.

La citación de evicción debe hacerse, de acuerdo al artículo 584 C.P.C, antes de contestar la demanda.

Esta citación de evicción es de suma importancia, ya que si el comprador la omite, el vendedor no será responsable de la evicción, art. 1843 inc. 3º.

Si el comprador cita legal y oportunamente al vendedor, éste puede adoptar dos actitudes:

a) no comparece al juicio, y

b) comparece al juicio.

a) No comparece al juicio:

Si citado legalmente el vendedor no comparece al juicio y la cosa es evicta, entonces, de acuerdo al art. 1843, es obligado al saneamiento de la evicción, porque por su parte ha habido negligencia.

Pero, hay un caso en que el vendedor no responde de la evicción no obstante haber sido citado y no comparece al juicio, y es aquel en que el comprador pierde la cosa porque no opuso una excepción que le favorecía.

b) Comparece al juicio:

Si el vendedor comparece al juicio pueden presentarse dos situaciones:

I. El vendedor se impone de los antecedentes y comprueba que el tercero va a ganar el litigio, entonces puede allanarse a la evicción -paga el precio al comprador con la correspondiente indemnización-, art. 1845.

No obstante, en este caso, el comprador puede continuar el juicio, tiene perfecto derecho a ello, pero si pierde el litigio y se produce la evicción no podrá exigir al vendedor que le pague las costas del juicio ni el valor de los frutos con que hubo de satisfacer al tercero, art. 1845.

II. El vendedor comparece al juicio y asume la defensa en él.

Ello sucederá cuando el vendedor estime que las pretensiones del tercero carecen de fundamento y que tiene posibilidades de obtener en el litigio.

En este caso el vendedor pasa a ser parte principal en el juicio. La relación procesal se va a mantener entre el vendedor y el tercero. Por consiguiente, entre ellos se siguen todas las gestiones y actuaciones procesales, razón por la cual el comprador deja de ser parte principal en el proceso, pudiendo sí intervenir en él como coadyuvante en defensa de sus derechos, art. 1844.

En esta forma se sigue el juicio adelante y de él pueden resultar dos situaciones:

I. El vendedor gana el juicio: no prospera la acción del tercero; en este caso no se produce la evicción y de acuerdo al art. 1855 el vendedor no tiene ninguna responsabilidad y el comprador no tiene derecho a que aquél le indemnice las costas del juicio, salvo que la demanda fuese imputable a hecho o culpa del vendedor.

II. El vendedor pierde el juicio: aquí termina la primera etapa o parte de la obligación de saneamiento por evicción, finaliza la obligación de defender al comprador y surge la segunda obligación: indemnizar al comprador.

B) Segunda obligación: restitución del precio y pago de indemnizaciones.

Una vez evicta la cosa vendida por sentencia judicial ejecutoriada nace esta segunda obligación. El art. 1847 señala expresamente qué comprende esta segunda obligación del vendedor, el cual está obligado, en su virtud, a cinco prestaciones en favor del comprador, las cuales comprenden todo el saneamiento de la evicción; estas prestaciones son:

1) El vendedor debe devolver al comprador el precio de la cosa vendida:

Tiene la obligación de devolver íntegramente el precio recibido, aunque la cosa vendida haya disminuido de valor entre la venta y el tiempo de la evicción, art. 1847 N° 1.

Pero, para evitar que se produzca un enriquecimiento sin causa, si ha habido deterioro y este deterioro ha significado un beneficio para el comprador debe rebajarse proporcional mente el precio, art. 1848.

2) Debe indemnizar al comprador las costas del contrato de compraventa en que éste haya incurrido:

El vendedor debe pagar al comprador los gastos de escritura, de impuestos, etc., en que por la ley haya incurrido éste al perfeccionarse la venta. Luego, no quedan comprendidos los gastos convencionales, art. 1847 N° 2.

3) Debe devolver el valor de los frutos de la cosa comprada y que el comprador tuvo que entregar al tercero:

Esta obligación del vendedor tiene una limitación, ya que no debe el valor de los frutos percibidos durante el juicio y restituidos al tercero, cuando habiéndose él allanado a la evicción el comprador decidió continuar el litigio por sí mismo obteniendo una resolución desfavorable. Es lógico que en este caso no responda porque el juicio se continuó, en contra de su opinión, art. 1847 N° 3.

4) Debe indemnizar al comprador las costas del juicio:

Este reembolso opera con la misma limitación que el caso anterior, art. 1847 N° 4.

5) Debe devolver el aumento de valor que haya obtenido la cosa:

Es lógico que este aumento de valor se indemnice al comprador, pues corresponde a un interés económico que se ha incorporado a su patrimonio. Además como la evicción priva al comprador del aprovechamiento de este aumento de valor es justo que se le indemnice. Esta indemnización se rige por normas diferentes, según cual sea la causa del aumento de valor de la cosa, art. 1847 N° 5.

Indemnización del aumento de valor de la cosa:

El legislador reglamentó en forma minuciosa cómo debía indemnizarse el aumento de valor de la cosa en los arts. 1849 y 1850.

El aumento de valor puede deberse a dos razones:

a) Mejoras ejecutadas por el comprador,

b) Acción del tiempo o de la naturaleza.

a) Cuando el aumento de valor de la cosa se debe a mejoras que ejecutó el comprador, debemos distinguir si el vendedor estaba o no de buena fe, esto es si conocía o ignoraba al momento de la venta las causas de la evicción.

I. Si el vendedor estaba de buena fe está obligado solamente a indemnizar las mejoras necesarias y útiles que hubiera efectuado el comprador, pero sólo en caso de que estas mejoras no le hubieren sido pagadas a éste por el tercero que entabló la acción, ya que puede suceder que el tercero demandante fuera condenado a pagar dichas mejoras al comprador por concepto de prestaciones mutuas en el juicio respectivo, art. 1849.

II. Si el vendedor estaba de mala fe, esto es, que conocía la causa de la evicción al celebrarse el contrato, debe indemnizar al comprador todo aumento de valor experimentado por la cosa proveniente de mejoras, aun cuando éstas sean voluptuarias, con la misma limitación que el caso anterior, art. 1849 inc. 2º.

b) Cuando el aumento de valor de la cosa vendida se debe a causa natural o al transcurso del tiempo, el vendedor de buena fe debe pagar al comprador el aumento experimentado por la cosa, pero con un límite: no debe exceder del 25% (cuarta parte) del precio de la venta, art. 1850.

El vendedor de mala fe debe pagar todo aumento de valor originado por causa natural o transcurso del tiempo, sin limitaciones de ninguna especie, art. 1850.

Situación en las ventas forzadas:

En ellas el vendedor debe una sola prestación en el saneamiento por evicción: el precio. No debe las restantes indemnizaciones del art. 1847, debido a que el contrato de venta le ha sido impuesto, de modo que faltando su voluntad en el contrato no puede imputarse la evicción a su culpa, art. 1851.

Evicción parcial.

Consiste la evicción parcial en la privación que sufre el comprador de parte de la cosa comprada en virtud de una sentencia judicial y por causa anterior a la venta.

En este tipo de evicción hay que determinar si la parte evicta es de tal naturaleza que faltando ella el comprador habría o no celebrado el contrato de compraventa, o sea, hay que establecer si la paite evicta fue o no determinante en la celebración del contrato de compraventa.

a) Si la parte evicta fue determinante en la celebración del contrato el comprador tiene un derecho opcional:

1. Puede pedir la resolución del contrato con indemnización de perjuicios, art. 1852 inc. final y 1853, o
2. Puede pedir el saneamiento de la parte evicta, art. 1854.

b) Si la parte evicta no fue determinante, el comprador sólo tiene derecho a pedir el saneamiento de la parte evicta, art. 1854:

Establecer la magnitud de la parte evicta en cuanto a si es o no determinante en la celebración del contrato de compraventa es una cuestión de hecho.

Sujeto pasivo de la obligación de sanear la evicción.

El sujeto obligado al saneamiento de la evicción es no sólo el inmediato vendedor del comprador que posee la cosa evicta, sino también los antecesores de él en el dominio de la cosa, art. 1841.

Extinción de la obligación de saneamiento por evicción.

La obligación de sanear la evicción se extingue por prescripción, por renuncia y por otras causas legales:

a) Extinción por prescripción:

La obligación del vendedor de amparar judicialmente al comprador es imprescriptible. La prescripción que establece el legislador a este respecto sólo se refiere al saneamiento por evicción una vez que ésta se ha producido, esto es cuando se ha dictado la sentencia que priva al comprador de todo o parte de la cosa, es decir, la prescripción sólo dice relación con las obligaciones de restituir el precio y pagar las indemnizaciones del artículo 1847.

La obligación de restituir el precio de la cosa prescribe según las reglas generales (3 ó 5 años según la acción sea ejecutiva u ordinaria, art. 2515). Este plazo corre desde la fecha de la sentencia que produce la evicción y si no hay sentencia porque el comprador restituyó la cosa al tercero por haberse allanado el vendedor a la evicción, corre el plazo desde la restitución de la cosa, art. 1856.

La obligación de pagar las restantes indemnizaciones del art. 1847 prescriben en cuatro años contados en igual forma que en el caso anterior, art. 1856.

a) Extinción por renuncia:

El comprador puede renunciar a la acción de saneamiento de la evicción, ya que ella mira sólo a su interés y es un elemento de la naturaleza del contrato de compraventa, arts. 1839 y 1842.

Esta renuncia tiene los siguientes caracteres:

1º El vendedor aunque el comprador haya renunciado a la acción de saneamiento debe restituir el precio, ya que de lo contrario habría un enriquecimiento sin causa, art. 1852, incs. 1º y 2º.

2º Sin embargo hay casos en que ni siquiera tiene obligación de restituir el precio: a) Cuando el comprador adquirió la cosa a sabiendas de que era ajena, y b) Cuando el comprador tomó expresamente sobre sí el riesgo de la evicción especificándolo, art. 1852 inc. 3º.

La razón de ello es que en ambos casos el contrato de compraventa pasa a tener el carácter de aleatorio para el comprador y naturalmente que el precio se paga tomando en cuenta el riesgo de la evicción, por lo cual será menor que el que se habría pagado en caso de no presentarse esta situación, art. 1842.

b) Extinción por otras causas legales:

Se extingue también la obligación de saneamiento de la evicción en los siguientes casos:

1º Cuando el tercero que demanda y el comprador someten el asunto a arbitraje, sin conocimiento del vendedor y el árbitro falla en favor del tercero demandante, art. 1846 N° 1.

El fundamento de ello es que se trata de evitar la colusión entre el comprador y el tercero para perjudicar al vendedor.

Pero, si el vendedor consiente en que la cuestión sea sometida al conocimiento de un árbitro subsiste la obligación de saneamiento.

2º Si la evicción se produce porque la cosa se ha perdido por culpa del comprador, art. 1846 N° 2.

3º Cuando el comprador no citó de evicción al vendedor, art. 1843 inc. 3º.

4° Cuando citado el vendedor y no comparece, pero el comprador pierde la cosa por no haber opuesto una excepción o defensa que le pertenecía, art. 1843 inc. 3º.

9.2.2. - Saneamiento de los vicios redhibitorios.

Hemos señalado que el vendedor tiene la obligación de proporcionar al comprador la posesión pacífica de la cosa, pero, además, es evidente que si una persona compra una cosa, es con el objeto de que ésta le preste utilidad, la cual puede ser de distinta naturaleza. Es evidente entonces que el vendedor debe proporcionar al comprador la posesión útil de la cosa vendida, y precisamente desaparece la utilidad de la cosa cuando ella adolece de algún vicio oculto o redhibitorio.

El legislador civil no definió expresamente lo que se entiende por vicio redhibitorio, pero se acostumbra definirlo en la forma siguiente "es un defecto inherente a la cosa, que existía al tiempo de la venta, oculto para el comprador y que impide total o parcialmente el uso natural de la cosa".

Debe tenerse presente de que el vicio redhibitorio es diferente del error sustancial. Este último es el que recae sobre la sustancia o calidad esencial de la cosa.

El vicio redhibitorio se diferencia del error sustancial en que en el vicio redhibitorio hay un defecto o imperfección inherente a la cosa y que la hace inútil para su uso natural (situación objetiva); en cambio, en el error sustancial hay una equivocación o falso concepto de la parte sobre la sustancia o calidad esencial de la cosa con prescindencia de su calidad intrínseca (situación subjetiva).

Requisitos que debe reunir un vicio para tener el carácter de redhibitorio.

Se encuentran contemplados en el art. 1858 y son los siguientes:

1º Que el vicio haya existido al tiempo del contrato de compraventa.

2º Que sea grave.

3º Que sea oculto.

1º Que el vicio haya existido al tiempo de la venta:

Este requisito es de toda lógica ya que el vendedor no puede responder de los vicios que se hayan producido con posterioridad a ella, pues la cosa entonces ha dejado de estar en su poder y, por consiguiente, a su cuidado.

Para que se configure este requisito, no es necesario que el vicio redhibitorio exista en toda su gravedad al momento de la venta, sino que basta que exista en germen al tiempo de la venta y se desarrolle después. Así se ha resuelto que "Procede declarar la rescisión de la compraventa de un caballo si éste, al celebrarse el contrato, tiene una enfermedad incurable que, aunque no lo inhabilita durante cierto tiempo para prestar los servicios a que está destinado, lenta y fatalmente lo inutilizará".

2º Que el vicio sea grave:

Se entiende que el vicio es grave cuando el defecto es de tal naturaleza que impide total o parcialmente el uso de la cosa. Esto es una cuestión de hecho que el Juez deberá resolver en cada caso.

El N° 2 del art. 1858 en su segunda parte da una pauta que puede servir al juez para establecer si hay o no gravedad en el vicio, según si puede o no presumirse que el comprador conociendo el vicio hubiere o no comprado la cosa, o la hubiere comprado en un precio menor.

3º Que el vicio sea oculto:

El vicio es oculto cuando el comprador lo ignora por no habérselo manifestado el vendedor.

Pero hay casos en que no hay vicio redhibitorio no obstante el silencio del vendedor:

I. Cuando de parte del comprador ha habido negligencia para conocer el vicio, art. 1858 N° 3. Así "la no existencia de un camino en el fundo vendido no puede considerarse como vicio redhibitorio, porque no es un hecho oculto y es de tal naturaleza que el comprador no ha podido ignorarlo sin grave negligencia de su parte".

II. Cuando por su profesión u oficio, el comprador ha podido fácilmente conocer el vicio, art. 1858 N° 3. Así se ha resuelto que "el hecho de estar coloreado el arroz con azul de ultramar, si se considera vicio, sería fácilmente conocido del comprador comerciante en razón de su profesión".

Cláusulas que hacen redhibitorios vicios que no lo son.

El legislador autoriza expresamente que las partes en un contrato den a un vicio el carácter de redhibitorios aun cuando naturalmente no lo sea, art. 1863.

Debe tenerse presente que el art. 1863 dice "por el contrato", luego esta convención no puede celebrarse con posterioridad a él.

Efectos de los vicios redhibitorios.

Los efectos de los vicios redhibitorios no son otra cosa que los derechos que tiene el comprador ante un vicio de esta naturaleza, derechos que se traducen en dos acciones que el comprador puede intentar en contra del vendedor, ellas son:

a) La acción redhibitoria, y

b) La acción estimatoria o cuanti minoris.

El ejercer una u otra de estas acciones es un derecho opcional para el comprador, art. 1860.

a) La acción redhibitoria es la que tiene el comprador para solicitar judicialmente la resolución de la venta, art. 1857;

b) La acción cuanti minoris es la que posee el comprador para pedir una rebaja proporcional del precio, en este caso subsiste el contrato de compraventa, art. 1857.

La regla general señalada en el art. 1860 presenta algunas excepciones, en las cuales el comprador carece del derecho de opción y sólo puede ejercer la acción cuanti minoris, ellas son las siguientes:

1. Cuando los vicios no son graves, art. 1868.

2. Cuando la cosa perece después de perfeccionado el contrato en poder y por culpa del comprador, art. 1862 inc. 1°; pero si la cosa perece por un vicio inherente a ella, subsiste el derecho de opción para el comprador, art. 1862 inc. 2°.

Por otra parte, el legislador ha sido más riguroso con el vendedor cuando sabía el vicio que tenía la cosa y no lo manifestó al comprador, ya que en tal caso no sólo lo obliga a la restitución o rebaja del precio, sino que también a la indemnización de perjuicios en favor del comprador, art. 1861.

En las ventas forzadas no hay lugar al saneamiento de los vicios redhibitorios, salvo que el vendedor no haya podido o no haya debido ignorar los vicios de la cosa vendida y no los declaró a petición del comprador, pues en tal caso hay lugar a la acción redhibitoria y a la indemnización de perjuicios, art. 1865.

Extinción de la acción de saneamiento por los vicios redhibitorios.

La acción de saneamiento de los vicios redhibitorios se extingue:

a) Por renuncia: puede renunciarse porque es un elemento de la naturaleza del contrato. Sin embargo, la renuncia al saneamiento de los vicios redhibitorios no exime al vendedor de sanearlos cuando le eran conocidos y no lo

manifestó al comprador, art. 1859.

b) Por prescripción hay que distinguir si se trata de bienes muebles o inmuebles, arts. 1866, 1867 y 1869.

La acción redhibitoria prescribe en el plazo de seis meses respecto de los bienes muebles y en un año si se trata de inmuebles. Esto plazos pueden ampliarse o reducirse por estipulación de las partes y corren desde la fecha de la entrega material o real de la cosa vendida, art. 1866.

La acción cuanti minoris, por su parte, prescribe en un plazo de un año para los bienes muebles y de dieciocho meses para los inmuebles, este plazo corre también desde la entrega material. Don Arturo Alessandri R. estima que las partes también, en este caso, pueden ampliar o restringir el plazo de prescripción, ya que si se les negara esta posibilidad podría suceder que la acción cuanti minoris prescribiera antes que la redhibitoria si el plazo de esta última hubiera sido ampliado.

La computación de la acción cuanti minoris tiene una regla especial, en el caso de que la cosa vendida haya sido remesada a un lugar distante, art. 1870.

10. - Obligaciones del comprador.

El comprador tiene también dos obligaciones principales, tales son: recibir la cosa comprada y pagar el precio, las que están establecidas en los arts. 1793, 1871 y 1827.

La principal de estas obligaciones es la de pagar el precio, así lo establece el art. 1871.

10.1. - Obligación de recibir la cosa comprada.

Se encuentra contemplada en el art. 1827 que dispone que si el comprador se ha constituido en mora de recibir la cosa deberá abonar al vendedor los gastos de alquiler de los almacenes, graneros o vasijas necesarios para mantener la cosa vendida, y agrega que cesa la responsabilidad del vendedor por el cuidado de la cosa y que sólo responde de la culpa grave y del dolo.

Esta obligación del comprador es una lógica consecuencia de la obligación del vendedor de entregar la cosa (Causa).

Ante la negativa del comprador de recibir, el vendedor tiene dos posibilidades:

a) Pagar por consignación, art. 1598 y sgtes.

b) Pedir la resolución del contrato con indemnización de perjuicios, puesto que sobre el comprador pesa la obligación de recibir la cosa, art. 1498.

10.2. - Obligación de pagar el precio.

Esta es la principal obligación del comprador y es de la esencia del contrato.

En cuanto al tiempo y lugar del pago, prevalece lo que las partes han estipulado, de modo que si lo sujetan a plazo, condición, etc., habrá que estarse a ellas, pero si nada han convenido al respecto deben aplicarse las reglas generales sobre la materia contemplada en el art. 1872 inc. I^{o}.

Sobre esto hay que recordar que el pago no puede hacerse por parcialidades, salvo convención en contrario, art. 1591.

Si el vendedor se resiste a recibir el pago del precio el comprador puede pagar por consignación.

Derecho de retención del precio por el comprador:

La obligación de pagar el precio por el comprador se suspende cuando el comprador lo deposita en el tribunal con aprobación del juez, a causa de haberse perturbado su posesión de la cosa o de existir acciones reales sobre ella, no conocidas por el comprador, art. 1872 inc. 2º.

Debe tenerse presente que no se trata de pago por consignación sino de la retención judicial del precio. Dura este depósito o retención judicial hasta que el vendedor haga cesar las perturbaciones o caucione las resultas del juicio (posible evicción), art. 1872 inc. 2º.

Por ello se ha fallado que si un tercero obtiene un decreto judicial que prohíbe la inscripción de la venta de un inmueble por el comprador (medida precautoria de gravar o enajenar), el comprador puede ejercer este derecho (Rev. de D. y J., tomo 5, sec. 1ª, pág. 341).

Incumplimiento de la obligación del comprador de pagar el precio:

Si el comprador está en mora de pagar el precio y el vendedor cumplió su obligación de entregar la cosa, éste puede pedir en contra del comprador el cumplimiento de la obligación de pagar el precio o la resolución del contrato, en ambos casos con indemnización de perjuicios. Es decir, hace valer la condición resolutoria tácita del art. 1489, la cual se encuentra reiterada en el artículo 1873.

Tratándose de la resolución del contrato de compraventa hay algunas situaciones excepcionales que destacar:

1. En general, en la resolución no se deben los frutos percibidos en el tiempo intermedio entre la celebración del contrato y su resolución, art. 1488; pero en el contrato de compraventa, cuando la resolución se produce por el no pago, debe el comprador restituir los frutos ya sea totalmente cuando no ha pagado nada, ya en proporción a la parte no pagada del precio, si sólo lo pagó parcialmente, art. 1875 inc. 1º.

2. En cuanto al pago de expensas y deterioros, la regla general es que se presume la buena fe del deudor, pero en la compraventa se presume legalmente la mala fe del comprador si no ha pagado el precio, salvo que dicho comprador pruebe lo contrario, es decir que pruebe haber sufrido, sin culpa de su parte un detrimento en su fortuna tan grande que le haya sido imposible pagar el precio, art. 1875 inc. 3º.

El que se presuma la mala fe en materia de expensas y deterioros significa que se le abonarán al comprador las mejoras necesarias que hubiere hecho en la cosa, pero no se le pagarán ni las útiles ni las voluntarias, pudiendo eso sí llevarse los materiales, siempre que reúnan los requisitos de los arts. 910 y 911.

3. Si hay arras, la resolución por no pago del precio faculta al vendedor para retenerlas, si las ha recibido y para exigirlas dobladas si las había dado, art. 1875.

Efectos de la resolución respectos de terceros, cuando se produce por el no pago del precio:

El artículo 1876 establece que respecto de terceros la resolución del contrato de compraventa, producida por el no pago del precio se rige por los arts. 1490 y 1491, disposición que es inoficiosa porque de todas maneras se habrían aplicado esas disposiciones aunque nada se hubiera dicho al respecto.

El inc. 2º del art. 1876 amplía aún más el resguardo en favor del tercero estableciendo una inadmisibilidad probatoria amplia en favor de éste cuando en la escritura pública se dice que se pagó el precio, en tal caso sólo se admiten dos pruebas en contra de la declaración de pago del precio, que son:

1. Prueba de nulidad, y
2. Prueba de falsificación de la escritura.

Esta inadmisibilidad probatoria es en resguardo de los terceros, ya que el art. 1876 inc. 2º no es aplicable a las partes del contrato. Por consiguiente, entre el comprador y el vendedor, podrá probarse que no hubo pago del precio sin que exista inadmisibilidad probatoria alguna, salvo la que señala el art. 1709, aunque en la escritura se diga que se paga totalmente el precio, y en virtud de dicha prueba podrá pedirse la resolución de la venta o declararse la simulación del contrato.

11. - Pactos accesorios al contrato de compraventa

11.1.- Pacto comisorio.

No se insistirá sobre él ya que es una materia que se estudia en materia de obligaciones condicionales.

11.2.- Pacto de retroventa.

Es aquel por el cual el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad que se estipuló o, si nada se ha dicho, el precio que se hubiere pagado por la compra.

Se trata, en consecuencia, de una venta afecta a una condición resolutoria ordinaria potestativa del acreedor (vendedor).

En el fondo el pacto de retroventa es una caución, ya que el comprador recibe la cosa y no la restituye sino cuando se le reembolsa el precio que dio por ella o el que se haya estipulado. Esta suma es en realidad el monto del préstamo que hizo el comprador al vendedor, el cual en lugar de constituir una prenda por ejemplo, le vende al comprador.

Requisitos:

Para que sea válido el pacto de retroventa debe reunir los siguientes requisitos:

1. Debe estipularse al momento del contrato. El art. 1881 dice que el vendedor se reserva la facultad, con lo que indica que este pacto debe hacerse al momento mismo del contrato y no después.

2. Debe estipularse un precio que va a pagar el vendedor para recuperar la cosa, si nada se dice al respecto, dicho precio es el mismo de la venta.

3. Debe señalarse un plazo dentro del cual va a poder el vendedor hacer uso del derecho de recobrar la cosa que vende, art. 1885.

Las partes pueden estipular el plazo que deseen, pero éste no puede pasar de 4 años contados desde la fecha del contrato. Se ha resuelto que éste es un plazo de caducidad.

Efectos:

Al respecto hay que distinguir dos situaciones:

1. Si el vendedor no hace uso de la facultad de comprar la cosa vendida o si deja pasar el plazo dentro del cual tiene derecho a ella, se consolida el dominio en el comprador: de dueño condicional pasa a ser absoluto, puro y simple.

2. Si el vendedor ejercita el derecho de recobrar la cosa vendida dentro del plazo, deberá pedir judicialmente al comprador la restitución de la cosa vendida, art. 1885 inc. 2°.

Pero, deberá pagar al comprador las expensas invertidas en mejoras necesarias, no así las que correspondan a

mejoras útiles y voluntarias, salvo que se hubieren realizado con su consentimiento, art. 1883 inc. 2º.

Además, tendrá que indemnizar el comprador al vendedor los deterioros que puedan imputarse a su culpa, art. 1883 inc. 2º.

Para la restitución de la cosa al vendedor, se concede al comprador los plazos que señalan el art. 1885 inc. 2º.

Por último, de acuerdo con el art. 1882 en cuanto a los efectos que el pacto de retroventa produce respecto de terceros, deben aplicarse las normas de los arts. 1490 y 1491.

11.3. - Pacto de retracto.

Es una venta sujeta a la condición resolutoria de que si dentro de determinado plazo, que no puede pasar de un año, se presenta un tercero como comprador ofreciendo un mejor precio por la compra, esta se resuelve, a menos que el comprador primitivo o su adquirente, mejore en los mismos términos la compra.

Se aplican al pacto de retracto, una vez producida la resolución, las mismas reglas del pacto de retroventa, en cuanto a la restitución entre las partes y a los efectos respecto de terceros, art. 1886.

Finalmente, debe hacerse presente que en conformidad al art. 1887 pueden agregarse al contrato de venta cualquier otro pacto accesorio, siempre que sea lícito, los cuales se regirán por las reglas generales.

12. - Rescisión de la venta por lesión enorme.

El legislador chileno, al parecer para dar estabilidad a las transacciones jurídicas, no acepta la lesión como vicio general en los contratos.

No obstante, hay algunos contratos susceptibles de rescindirse por lesión enorme, siendo uno de ellos el de compraventa de bienes raíces, art. 1888.

La lesión enorme en la compraventa de bienes raíces "consiste en una desproporción grave entre el precio y el valor real de la cosa vendida". De modo que se presenta una falta de equivalencia en las utilidades recíprocas entre el vendedor y el comprador. Una de las partes obtiene una utilidad o ventaja desmedida, en tanto que la otra sufre perjuicio importante por la diferencia de valores. Para resguardar a las partes de estas situaciones, que pueden deberse a la explotación que una de ellas hace de la necesidad o debilidad de la otra, es que el art. 1892 establece que la acción por lesión enorme es irrenunciable.

a) Requisitos de la lesión enorme:

Dos son los requisitos que deben concurrir para que un contrato de compraventa sea susceptible de rescindirse por lesión enorme:

1º Que la lesión sea enorme en los términos del art. 1889, y

2º Que la compraventa sea susceptible de rescindirse por lesión enorme.

1° Que la lesión sea enorme:

Es evidente que al legislador no le interesa la lesión que no revista demasiada gravedad, ya que en todo contrato existe la posibilidad de que haya un margen razonable de especulación, el cual por lo general beneficia a uno de los contratantes. Pero, ha considerado necesario poner tope a ese margen de ganancia y por ello cuando la lesión es enorme autoriza que se rescinda el contrato. Hay que tener presente que la lesión enorme puede invocarla tanto el

vendedor como el comprador: la ley confiere derecho para ello a ambas partes.

Hay lesión enorme para el vendedor cuando el precio que recibe por la cosa es inferior a la mitad de su justo valor, si una cosa vale $ 1.000 y recibe por ella $ 450.

Para el comprador, hay lesión enorme cuando el justo precio de la cosa es inferior a la mitad del precio que paga por ella, por ejemplo si una cosa vale $ 400 y paga por ella $1.000, art. 1889.

Las reglas del art. 1889 están inspiradas en igual criterio respecto del vendedor como del comprador, resultando la lesión enorme de una comparación del precio real con el precio pagado.

En lo que respecta al justo precio hay que tener presente que él se toma en relación al momento del contrato, una variación posterior a esa época no tiene importancia.

2º Que la compraventa sea susceptible de rescindirse por lesión enorme:

No todas las ventas son rescindibles por lesión enorme, sino que sólo las ventas de bienes raíces; la razón de ello es la marcada preferencia que el legislador demuestra por la propiedad raíz y, además, porque los bienes muebles cambian con mayor facilidad de valor.

Dentro de las ventas de bienes raíces, debe tenerse presente que la lesión enorme no se aplica en aquellos casos en que la venta se haya hecho por el ministerio de la justicia, art. 1891. Ello se debe a que hay una intervención de la justicia y porque el precio se establece en pública subasta, excluyéndose por ello la posibilidad de lesión o abuso por parte del comprador.

Efectos de la lesión enorme:

La parte afectada por la lesión enorme sólo puede accionar contra la otra pidiendo la rescisión de la venta, es decir, que se deje sin efecto la venta y se proceda a las restituciones mutuas como en el caso de la nulidad.

El afectado no puede demandar solicitando que se le complete o rebaje el precio, ya que el derecho de hacer subsistir el contrato pagando la diferencia o devolviendo el exceso le corresponde opcionalmente sólo al culpable de la lesión y sólo puede ejercitarse una vez dictada la sentencia que declare la resolución, art. 1890 inc. Iº.

Declarada la rescisión por sentencia judicial, la parle a quien le es imputable la lesión tiene un derecho opcional, según se ha señalado:

1) Completa o devuelve la diferencia de precio según sea comprador o vendedor;

2) Acepta la rescisión de la venta con todas sus consecuencias, artículo 1890 inc. Iº.

Análisis de estas dos situaciones:

1) Si completa o devuelve la diferencia de precio, subsiste el contrato de venta. Si la lesión es imputable al comprador, este completa el precio pagando una diferencia; para calcular dicha diferencia debe reducirse el justo precio en un 10%, art. 1890 inc. Iº.

Si la lesión es imputable al vendedor, éste debe devolver el exceso del precio recibido, pagando la diferencia, para calcular la cual debe aumentarse el justo precio en un 10%, art. 1890 inc. 1º.

Es decir, el art. 1890 concede al culpable de la lesión una ventaja legítima del 10% del justo precio, que no se completa si es comprador y no se devuelve si es vendedor.

2) La parte a quien es imputable la lesión se allana a ella y queda sin efecto la compraventa, es decir se produce la rescisión.

En términos generales esta rescisión produce los mismos efectos que toda nulidad, aun cuando no lo es. Hay no obstante algunas diferencias:

a) El comprador no restituye ni intereses ni frutos, sino que a contar del día en que se le notificó la demanda, art. 1890 inc. 2º.

b) Las partes no se reembolsan los gastos que originó el contrato en su celebración, art-J890 inc. 2º.

c) El comprador no está obligado a indemnizar los deterioros de la cosa, salvo si se aprovechó de ellos, art. 1894.

d) Los derechos reales con que el comprador haya gravado la cosa comprada antes de la rescisión, no caducan ipso jure por la declaración de rescisión, sino que el comprador debe cancelar estos gravámenes, para restituir sin ellos la cosa al vendedor, art. 1895.

Extinción de la acción por lesión enorme.

Se extingue esta acción por tres causales:

1. Destrucción de la cosa, art. 1893 inc. Iº, ello porque destruida la cosa que se vendió es imposible su restitución, que es el efecto propio de la resolución.

2. Enajenación de la cosa, art. 1893 inc. 2º no hay acción reivindicatoría por lesión enorme si la cosa vendida salió del patrimonio del comprador, en lo cual se diferencia fundamentalmente de la nulidad, ya que el art. 1689 da acción reivindicatoría en contra de terceros poseedores.

Cuando el comprador ha enajenado la cosa, obteniendo en la venta un sobreprecio respecto a lo que él había pagado por ella procede en su contra una acción distinta de la rescisoria que es la acción indemnizatoria.

En este caso el comprador debe restituir el sobreprecio con un límite o tope, esto es, el justo precio de la cosa con deducción de un 10%, en lo que el sobreprecio excede de este tope, pertenece al comprador, art. 1893 inc. 2º.

3. Prescripción, opera en cuatro años contados desde la celebración del contrato, art. 1896, ésta es una prescripción especial, luego no se suspende, art. 1524, pero sí se interrumpe según las reglas generales.

13. - Contrato de permuta.

El contrato de permuta lo trata el legislador a continuación del de compraventa.

Por el contrato de permuta, dice el art. 1897, las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro.

Este contrato no presenta mayores novedades porque se rige en casi todo por las normas de la compraventa.

Así, el art. 1898 dispone que el contrato de permuta, por regla general será consensual, se perfecciona por el mero consentimiento, salvo que la cosa permutada o ambas sean bienes raíces o derechos hereditarios, en cuyo caso se requiere de escritura pública; por consiguiente, excepcionalmente será un contrato solemne siendo la solemnidad una escritura pública.

El art. 1889 dice que pueden permutarse las cosas que pueden venderse y que son hábiles para celebrar contrato de permuta las mismas personas que lo son para celebrar el de compraventa.

Finalmente, el art. 1900 establece la regla general: las reglas de la compraventa son aplicables a la permuta en lo que no sean contrarias a la naturaleza de ésta; cada permutante se considera como vendedor de la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mira como el precio que paga por lo que recibe en cambio

.

CAPÍTULO IX

DE LAS CAUCIONES

1. - Generalidades.

El patrimonio de una persona responde ante los acreedores de las obligaciones que aquélla pueda tener con éstos, es por ello que se habla del derecho de prenda general, reglamentado en el Código Civil en el art. 2465.

Puede suceder que el deudor disminuya su patrimonio causando, por ello, un daño a sus acreedores; si bien es cierto que para evitar esta situación existe la acción pauliana, no lo es menos que dicha acción no es siempre procedente, porque si no se reúnen los requisitos del art. 2468 no puede ejercitarse, y además, se trata de una acción que tiene señalado un plazo de prescripción muy breve: un año contado desde la fecha del acto o contrato.

Para precaver una posible insolvencia del deudor, y evitar los posibles riesgos de improcedencia de la acción pauliana, los acreedores para garantizar sus derechos, pueden recurrir a las llamadas cauciones, que se encuentran definidas en el art. 46 "Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda".

Las cauciones se clasifican en reales y personales.

Cauciones reales son aquellas en que la seguridad o garantía para el acreedor consiste en tener afectado al cumplimiento de la obligación principal un determinado bien mueble o inmueble perteneciente al deudor o incluso a un tercero.

Como esta clase de cauciones comporta un derecho real en favor del acreedor que se ejercita sobre el bien mismo, sin respecto a determinada persona, su eficacia como caución es superior a la de las personales.

Son cauciones de esta clase la prenda y la hipoteca.

Cauciones personales son aquellas en que la seguridad para el acreedor consiste en que puede hacer efectivo su crédito en un patrimonio distinto al deudor principal, ejemplo de esta clase de caución son la fianza y la solidaridad pasiva.

TÍTULO I

EL CONTRATO DE PRENDA

1. - Definición.

El art. 2384 del Código Civil da una definición del contrato de prenda, diciendo "Por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de un crédito", (inc. 1º).

Comentando esta definición el profesor Manuel Somarriva, dice que ella "es en realidad incompleta porque no da una idea clara de la garantía, queda más comprensible agregándole a la definición legal la siguiente frase: dándosele la facultad de venderla y pagarse preferentemente con el producto de la venta si el deudor no cumple sus obligaciones".

Conforme a la opinión del profesor Somarriva una definición correcta del contrato de prenda sería, en consecuencia, la siguiente: "Por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito, dándosele la facultad de venderla y de pagarse preferentemente con el producto de la venta si el deudor no cumple sus obligaciones".

El sistema del contrato de prenda establecido y reglamentado en el Código Civil, se encuentra actualmente profundamente alterado y modificado por leyes especiales que han creado las llamadas prendas sin desplazamiento; sin embargo reviste importancia el estudio de las normas del Código Civil relativas a este contrato, porque las prendas especiales si bien alteran los principios del C. Civil, en sus bases se atienen a él.

Entre las prendas especiales o sin desplazamiento podemos señalar las siguientes:

1. Prenda mercantil.
2. Prenda agraria.
3. Prenda industrial.
4. Prenda de valores mobiliarios en favor de los Bancos.
5. Prenda de la ley de compraventa de cosas muebles a plazo.
6. Prenda sin desplazamiento.

La diferencia fundamental entre la prenda reglamentada en el Código Civil y las prendas especiales, es que la primera es un contrato real, luego se perfecciona por la entrega de la cosa al acreedor; en tanto que en las segundas no existe este desplazamiento (de ahí que también se las llame prendas sin desplazamiento), de modo que la cosa dada en prenda permanece en manos del deudor. En éstas, para asegurar el derecho del acreedor el contrato es solemne y la entrega material se reemplaza por una inscripción en un registro especial.

En el sistema del Código Civil la entrega de la cosa dada en prenda es material, en cambio en las prendas especiales ella es ficticia, no hay desplazamiento, sino que una inscripción del contrato en un registro especial.

La finalidad de las prendas especiales es, justamente, el que no haya desplazamiento.

2. - Acepciones de la palabra prenda.

La palabra prenda tiene varias acepciones, a saber:

1º. Como contrato, art. 2384 inc. 1º.

2º. Como la especie misma dada en prenda, art. 2384 inc. 2º.

3º. Como derecho real, art. 577.

3. - Características de la prenda.

La prenda presenta las siguientes características:

1. Es un contrato, así lo establecen los arts. 2384 y 2392 que disponen que debe existir un acuerdo de voluntades. La prenda como contrato presenta las siguientes características:

a) Es un contrato unilateral, de él sólo nacen obligaciones para una sola de las partes: el acreedor prendario -que es el que recibe la cosa empeñada- ya que debe conservar la cosa, no debe usarla y tiene que restituirla una vez que el deudor cumpla la obligación principal. La única obligación de la esencia del contrato de prenda es la del acreedor prendario de restituir la cosa dada en prenda una vez que se haya cumplido la obligación principal.

b) Puede ser gratuito u oneroso, según la forma como se constituya, si junto con el contrato principal (oneroso) o con posterioridad a él (gratuito) y dependerá también de quién constituya la prenda, si lo hace el deudor principal será oneroso, si lo hace un tercero, será gratuito, art. 2388.

c) Es un contrato real, se perfecciona por la entrega de la cosa empeñada, efectuada por quien constituya la prenda -el deudor o un tercero- al acreedor, art. 2386.

a) Es un contrato accesorio, siempre garantiza o asegura el cumplimiento de una obligación principal, sin la cual no puede subsistir.

b) Es un contrato nominado, tiene reglamentación propia en la legislación.

1. Es un derecho real, el art. 577 lo menciona entre tales derechos. La eficacia de la prenda como caución deriva justamente de esta característica, porque da derecho a perseguir la cosa de manos de quien se encuentra, al igual que todo derecho real.

2. Es un crédito privilegiado, da origen a un crédito de segunda clase, y como privilegio es especial porque sólo puede hacerse efectivo sobre lo empeñado y no en los demás bienes del deudor, art. 1474.

3. Importa un principio de enajenación, la prenda reglamentada en el Código Civil importa un principio de enajenación. El art. 582 señala que el dominio comprende las facultades de uso, goce y disposición, si se pierde una de ellas hay un principio de enajenación, y tal cosa ocurre en la prenda en que el dueño no tiene ni uso ni goce de la cosa. Además, porque al constituir la prenda el deudor tácitamente acepta que si no cumple la obligación principal el acreedor enajenará la cosa y se pagará con el producto del remate.

4. La prenda para el acreedor prendario es un título de mera tenencia, pero conjuntamente con ello es dueño y poseedor del derecho de prenda.

5. La prenda es indivisible, porque toda la cosa empeñada y cada parte de ella garantiza el total de la deuda, arts. 1526 N° 1 y 2396 inc. 1º.

4. - Obligaciones susceptibles de caucionarse con prenda.

La regla general es que pueden caucionarse con prenda toda clase de obligaciones, incluso las naturales, pero en lo

que dice relación con éstas hay que hacer una distinción:

1 °) El deudor cauciona una obligación civil con prenda, si luego la obligación principal se transforma en natural, la prenda por su carácter de accesoria, se convierte también en natural.

2º) Si hay una obligación principal natural, se la puede caucionar con una prenda, conforme al art. 1472, pero ella debe ser otorgada por un tercero para que produzca acción. En este caso se origina una situación curiosa, la prenda que es una obligación accesoria va a dar acción en tanto que la obligación principal no la concede.

5. - Requisitos de la prenda.

Por su carácter de contrato debe cumplir con los requisitos de validez que la ley exige para todo contrato y que contempla el art. 1445.

Pero, además, tiene algunos requisitos especiales y propios:

1. Que el que da la prenda tenga capacidad para enajenar;
2. Que haya entregado la cosa dada en prenda, y
3. Que los bienes sean susceptibles de darse en prenda.

1. Que el que da la prenda tenga capacidad para enajenar:

La prenda puede constituirla el deudor o un tercero, artículo 2388, pero tanto el uno como el otro deben tener capacidad para enajenar la cosa, art. 2387.

En consecuencia, no basta para este contrato tener capacidad para contratar, es necesaria la capacidad para enajenar, y esta capacidad debe existir en quien constituye la prenda, sea el deudor o un tercero.

Al acreedor prendario le basta con tener capacidad de ejercicio, aunque no tenga la libre disposición, ya que a su respecto no hay enajenación sino que una seguridad para su crédito.

Además, en lo que respecta a la capacidad del constituyente el Código Civil exige formalidades especiales tratándose de los pupilos, art. 393.

2. Que haya entregado la cosa dada en prenda:

Los arts. 2384 y 2386, entre otras disposiciones, exigen que para que se perfeccione el contrato de prenda se requiere la entrega de la cosa empeñada. Esta no es una entrega ficta o simbólica, sino que una entrega real, material de la cosa, ello por las siguientes razones:

a) La ley habla de entrega y el sentido propio de esa palabra en el Diccionario, es el de poner una cosa en manos de otro.

b) La historia de la ley, don A. Bello en nota al art. 2552 del proyecto de 1853, que corresponde al actual art. 2386, señala que en esta materia sigue a Pothier, y éste exigía la entrega real.

c) Porque la única forma de que el acreedor quede en condición de cumplir la obligación de restituir que le impone el contrato es la entrega real.

d) Mediante este desplazamiento de la cosa se da publicidad al gravamen frente a terceros, evitando que el deudor retenga la especie en su poder aparentando así una solvencia que no tiene.

El Código Civil en el art. 2389 reglamenta la prenda de un crédito, esta prenda para su constitución requiere de dos

requisitos:

1. Entrega del título al acreedor prendario,

2. Notificación al deudor del crédito que consta en ese título para que sólo pague en manos del acreedor, prohibiéndosele hacerlo en otras manos.

3. Bienes susceptibles de darse en prenda: pueden ser objeto de la prenda todas las cosas muebles corporales o incorporales, excepto las naves de más de 50 toneladas de registro y las aeronaves, que no obstante ser bienes muebles se hipotecan conforme a las normas que da el C. Civil y el C. de Comercio, art. 2418.

Veremos algunas situaciones relacionadas con esta materia:

a) Los inmuebles por adherencia y destinación que se constituyen en garantía separadamente del predio a que acceden, se dan en prenda y no en hipoteca, ya que al constituirse el gravamen en esta forma recuperan su calidad de bienes muebles -muebles por anticipación- art. 571.

b) También los créditos muebles pueden darse en prenda, art. 2389.

c) El dinero también puede darse en prenda y en tal caso el acreedor se hace dueño del dinero que el deudor le ha entregado en prenda y, además, puede hacer uso de él, restituyendo en dinero otro tanto de la misma moneda y no el dinero específico que se le entregó, art. 2395 (en relación con el art. 2221 porque esta especie de prenda se asemeja al depósito irregular).

d) Las boletas de garantía son en cierta forma prendas de dinero por el valor que ellas representan.

El tomador de la boleta en el Banco es deudor prendario y la persona a quien se le entrega la boleta es el acreedor prendario, encontrándose el dinero depositado en el Banco, al no cumplirse la obligación por el deudor, el acreedor tendrá la boleta pudiendo hacerla efectiva cobrándole al Banco.

e) Es indiscutible que sólo los bienes presentes pueden darse en prenda, pero no los bienes futuros, porque para que haya prenda se requiere la entrega material, y respecto del bien futuro no se podrá cumplir con este requisito de la entrega material. Pero, respecto de bienes futuros podría pactarse un contrato de promesa de prenda, el cual posteriormente se transformaría en contrato real de prenda.

6. - Especialidad de la prenda.

No es otra cosa que la especificación o determinación que exige la ley en la prenda, tanto en relación con la cosa empeñada como con la obligación principal que ella garantiza.

1. Determinación de la cosa empeñada:

La cosa empeñada debe estar perfectamente individualizada en especie, ya que de otra manera no podría procederse a la entrega. Este principio de la especialidad de la prenda tiene aplicación aun respecto de las prendas especiales, no obstante que en ellas hay algunos casos de excepción, como el de la prenda industrial en la cual la prenda de la materia prima se extiende al producto manufacturado.

2. Determinación de la obligación principal garantizada:

Según este principio la obligación principal a que accede la prenda debe ser existente y cierta, en otras palabras, tiene que ser una obligación específica, esto es determinada. Lo que lleva obligatoriamente a analizar el problema de si

puede o no caucionarse con prenda obligaciones futuras. Al respecto la opinión de los autores nacionales se encuentra dividida.

Algunos estiman que no es posible caucionar con prenda obligaciones futuras, dando los siguientes argumentos en apoyo a su opinión:

El Código Civil no señala que puedan caucionarse con prenda obligaciones futuras, en tanto que respecto de la fianza, art. 2339 y de la hipoteca, art. 2413, lo dijo expresamente, de modo que al guardar silencio respecto de la prenda como caución de obligaciones futuras debe concluirse que ello no es procedente. Así lo estima, entre otros don Manuel Somarriva, quien dice "Al tratar de la prenda el Código guarda silencio respecto de la posibilidad de garantizar obligaciones futuras, en circunstancias que al ocuparse de la fianza y la hipoteca lo permite expresamente en los arts. 2339 y 2413. Este silencio debemos interpretarlo en el sentido de que el legislador no acepta la prenda para garantizar tal clase de obligaciones, silencio que resulta más sugestivo si consideramos que en el Código la prenda está precisamente ubicada entre la fianza y la hipoteca".

Agrega Somarriva que su opinión se ve reafirmada por la circunstancia de que el art. 2385 diga que la prenda supone siempre una obligación principal a la cual debe acceder, no haciéndose esa declaración respecto de las otras cauciones.

La razón de esta diferencia con las demás cauciones la encuentran los que participan de esta opinión en la forma como se perfecciona este contrato: por la entrega de la cosa dada en prenda al acreedor, de modo que el deudor pierde su tenencia, uso y goce. No parecería lógico entonces que el legislador prive de tales atributos al deudor autorizando una prenda para garantizar una obligación que puede no llegar a existir. Situación que no se presenta en la hipoteca, ya que en ella el constituyente no es privado de la tenencia del bien, y la fianza es una caución personal.

La jurisprudencia ha aceptado esta tesis. En sentencia publicada en el Tomo 28 sec. I pág. 125, la Excma. Corte Suprema sostuvo que "El contrato de prenda supone siempre una obligación principal a que accede y no se perfecciona sino por la entrega al acreedor.

En consecuencia, no reúne los requisitos constitutivos de la prenda, el acto a virtud del cual se estipula dar en prenda una suma de dinero que a la fecha de la constitución ni siquiera existía en el monto a que se le hace subir, ni accede a ninguna obligación principal, sino que estableció a fin de garantizar el fiel cumplimiento de un empleo y el correcto desempeño de las comisiones que se le confiasen, y si, además, no aparece que haya sido entregado al acreedor en la fecha en que se supone hecha la constitución de la prenda".

Se agrega, finalmente, que la prueba más fehaciente de que el C. Civil no acepta la prenda en obligaciones futuras e indeterminadas, se encuentra en que en los casos en que se ha contemplado esta forma de prenda -posteriormente al Código Civil- lo ha sido en virtud de una ley expresa (Ley N° 7.612 que modificó el art. 376 del Código aceptando esta forma de prenda para que el guardador caucione al pupilo las obligaciones futuras que pudieren resultar en su contra derivados de su administración), la ley de prenda industrial que contempla la procedencia de ella en garantía de obligaciones indeterminadas, etc.

La otra corriente acepta la opinión contraria, esto es de que se puede garantizar con prenda obligaciones futuras.

Estiman los sostenedores de esta posición que el argumento según el cual el legislador no haya contemplado expresamente esta forma de prenda no es suficiente, porque se trata de una materia contemplada en el Libro IV del C. Civil, esto es de normas supletorias de la voluntad de las partes, materia en la cual se puede hacer no aquello que el

legislador permite expresamente, sino que por el contrario se puede realizar todo aquello que no esté expresamente prohibido y en el Código Civil no hay norma alguna que prohíba esta forma de prenda.

Por otra parte, la circunstancia de que leyes posteriores la permitan está indicando que no tiene nada de ilícito ni va contra los principios legales. Así el art. I° de la Ley N° 4.287 sobre Prenda Mobiliaria en favor de los bancos la admite expresamente al decir: "Los bonos y cualesquiera otros valores mobiliarios o contratos que se celebren o hayan de celebrarse más adelante, se entenderán constituidos en prenda a favor de ésta por su sola entrega, siempre que no conste expresamente que dicha entrega se ha efectuado con un objeto distinto".

El art. 2401 establece lo que en doctrina se llama "prenda tácita", es un caso en que no obstante que el deudor extinga la obligación garantizada con prenda, al acreedor le es lícito retener la prenda si tiene contra el deudor otros créditos que reúnan los requisitos expresados en ese artículo. La razón que se da a esta disposición es que el legislador la establece interpretando la voluntad de las partes, porque si el acreedor exige prenda para una obligación, es lógico presumir que también la habría requerido para las obligaciones posteriores, ya que está demostrando su desconfianza en la solvencia del deudor, luego, si la prenda va a garantizar otras obligaciones que las pactadas en el contrato en virtud de una interpretación de la presunta voluntad de las partes, por qué no puede ser lícito un pacto en que expresamente los contratantes estipulen una cláusula de garantía general.

7. - Cláusula de garantía general prendaria.

Esta cláusula no es de tanta aplicación como la cláusula de garantía general hipotecaria, consiste esta última en que se constituye una hipoteca en favor de cierto acreedor, como ser un banco, y ella va a garantizar no sólo la obligación a que accede, sino todas las obligaciones presentes o futuras, directas o indirectas que pueda tenerse con ese acreedor.

La procedencia de este tipo de cláusula respecto de la prenda depende de la posición que se adopte en relación con el problema analizado anteriormente, si se estima que es procedente la prenda para garantizar obligaciones futuras debe aceptarse esta cláusula, si se acepta la posición contraria debe concluirse que es improcedente.

Cabe advertir que la Ley N° 4.287 sobre Prenda Mobiliaria en favor de los bancos; la Ley N° 5.687 sobre Prenda Industrial y la Ley N° 18.112 sobre Prenda sin Desplazamiento, admiten la cláusula de garantía general.

8. - Prenda de cosa ajena.

La prenda de cosa ajena es válida, encontrándose reglamentados sus efectos por los arts. 2390 y 2391.

Respecto del dueño de la cosa empeñada, el contrato de prenda es inoponible y, por consiguiente, éste tendrá en contra del acreedor prendario todas las acciones que competen al dueño en conformidad a lo establecido en el artículo 2390.

En las relaciones entre el deudor y el acreedor prendario, una vez restituida la cosa al dueño, se aplican las siguientes reglas:

El acreedor puede pedir al deudor prendario que se le entregue otra prenda de igual o mayor valor o que se le otorgue otra caución competente. Si no se da cumplimiento a ello caduca el plazo y la obligación se hace exigible de inmediato, art. 2391, art. 1496.

Hay una diferencia entre este caso de caducidad del plazo y el que se contempla en el art. 1496 N° 2, diferencia

que estriba en que este último artículo exige que haya hecho o culpa del deudor, en tanto que el art. 2391 no considera la culpa.

9. - Efectos del contrato de prenda.

Son los derechos y obligaciones que nacen del contrato, se analizarán separadamente respecto de acreedor y deudor.

A. Derecho del acreedor

El acreedor tiene los siguientes derechos:

1. Derecho de retención
2. Derecho de persecución
3. Derecho de venta
4. Derecho de preferencia
5. Derecho a indemnización de perjuicios.

Estos derechos pueden resumirse de la siguiente forma: el acreedor retiene la cosa mientras no se le pague, si se le quita tiene derecho de persecución de manos de cualquiera que la tenga; cuando llega el vencimiento de la obligación si no se le paga puede vender la prenda y si en ese momento hay varios acreedores, tiene una preferencia especial de segunda clase y un derecho para que se le indemnicen los perjuicios que se le hayan causado.

1. Derecho de retención:

Es la facultad que tiene el acreedor prendario para conservar la mera tenencia de la cosa mientras no se le pague:

a) La totalidad de la deuda en capital e intereses;

b) Los gastos necesarios en que haya incurrido el acreedor para conservar la cosa, y

c) Los perjuicios ocasionados por la tenencia, art. 2396 inc. I^{o}.

Casos en que no procede la retención:

La retención no procede en los siguientes casos:

a) Cuando el Juez autoriza al deudor para cambiar o reemplazar la cosa empeñada por otra si de ello no se sigue perjuicio para el acreedor, art. 2396 inc. 2°;

b) Cuando el acreedor abusa de la prenda. Se entiende que el acreedor abusa de la prenda cuando usa la cosa empeñada, art. 2396 inc. 3°.

Prenda tácita.

Consiste en que el acreedor tiene derecho a retener la prenda sin restituirla al constituyente, pese a que se extinguió la obligación principal, cuando dicho acreedor es titular contra el mismo deudor de otros créditos que deben reunir ciertos requisitos, art. 2401.

En la prenda tácita se está interpretando la voluntad de las partes, esta es una excepción a lo que señaláramos anteriormente, ya que el acreedor puede retener la prenda aunque se le haya cancelado la obligación caucionada con ella. Luego, se está alterando la regla general de que una vez pagada la obligación principal debe restituirse la prenda.

Requisitos de la prenda tácita:

Sus requisitos son los siguientes:

1º) Sólo hay aplicación de la prenda tácita cuando la prenda se ha constituido por el propio deudor, pero no cuando ella se ha constituido por un tercero, esto no lo dice expresamente el legislador, pero parece lógico llegar a esta conclusión, porque el tercero sólo puede obligarse a aquello que formalmente declara, y no por las obligaciones que con posterioridad surjan entre acreedor y deudor.

2º) Que los créditos sean ciertos y líquidos, o sea, que el nuevo crédito no sea condicional.

3º) Que el crédito se haya contraído con posterioridad a la obligación que estaba garantizada con prenda.

4º) Que el crédito se haya hecho exigible antes del pago de la obligación caucionada con la prenda. Los autores entienden que al decirse "antes del pago" se hace referencia al momento real y efectivo del pago y no al momento en que esto debió efectuarse de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

Carácter de la prenda tácita:

Se ha discutido si se trata de un simple derecho legal de retención del acreedor prendario o de una extensión, en virtud de la ley, del derecho de prenda por interpretación de la voluntad contractual.

Esta última parece ser la naturaleza o carácter de la prenda tácita, especialmente por lo dispuesto en el art. 2402 cuando dice "y si la prenda se hubiere constituido en favor de una sola obligación, se hubiere extendido después a otras, según el artículo precedente".

Es importante concluir una u otra cosa, porque si se trata de un derecho legal de retención, el acreedor no tendrá derecho a perseguir la cosa en contra de terceros, si la cosa sale de su poder o tenencia, en tanto que si es un derecho real de prenda obviamente que existirá el derecho de persecución.

Casos en que no tiene aplicación la prenda tácita:

La prenda tácita no tiene aplicación en los siguientes casos:

Iº) El art. 2404 establece que, no obstante la constitución de la prenda, puede el deudor vender la especie dada en prenda; y en este caso si el deudor vende la prenda a un tercero y éste le paga íntegramente al acreedor, éste está obligado a entregar la cosa y no puede negarse a ello, de acuerdo con el inciso final, ni aun alegando créditos que reúnan las condiciones del art. 2401.

2º) De acuerdo con el art. 2393 inc. final, el acreedor puede exigir la restitución de la mera tenencia de la cosa de manos de quien se encuentre, aun contra el propio deudor. Pero si por cualquier causa la cosa dada en prenda llega a manos del deudor, éste puede recuperar la prenda pagando íntegramente al acreedor el crédito, y en este caso -si la cosa por cualquier motivo ha vuelto a poder del deudor y éste paga el crédito- no puede el acreedor exigir la retención de la cosa alegando prenda tácita.

2. Derecho de persecución o de reivindicación:

Si bien el acreedor prendario, con respecto a la cosa dada en prenda es mero tenedor, con respecto a su derecho de prenda es dueño y poseedor; entonces, si es dueño de su derecho de prenda, el cual es un derecho real, es lógico que esté premunido de la acción reivindicatoría, que es la acción propia del dominio. Por otra parte, el mismo art. 891 dice que pueden reivindicarse todos los derecho reales, excepto el de herencia, este mismo principio lo encontramos consagrado en el art. 2393.

El acreedor puede reivindicar su derecho contra el mismo deudor; pero ya hemos dicho que si la cosa llega a manos del deudor, puede éste retenerla pagando íntegramente el crédito, en este caso cesa el derecho a reivindicar, porque a virtud del pago del crédito que hace el deudor al acreedor, se extingue la obligación y con ello la prenda.

3. Derecho de venta:

Se refiere a él el art. 2397.

Vencida la obligación el acreedor, si no se le ha pagado, puede ejercitar este derecho.

No tiene derecho el acreedor, si no se le paga, para disponer por sí y ante sí o para apropiarse de la cosa empeñada, sino que debe venderla en pública subasta. Nada impide que en ella pueda participar y adjudicarse la cosa. Esta venta en pública subasta es también un derecho del deudor, de modo que éste puede exigirla si el acreedor se queda con la especie dada en prenda.

En resumen, ante el incumplimiento de la obligación el acreedor prendario tiene que realizar la prenda en pública subasta para pagarse con el producto del remate, art. 2397 inc. I°. En este caso el acreedor ejerce la acción real emanada de la prenda, sin perjuicio de que tiene también la acción personal del crédito para perseguir otros bienes del deudor prendario.

Si el constituyente es un tercero, el acreedor tiene contra él sólo la acción real y no la personal, porque el tercero no está personalmente obligado.

Forma en que se realiza la prenda.

El procedimiento aplicable para la realización de la prenda está contemplado en el Decreto Ley N° 776 del año 1925 (ver apéndice del Código de Procedimiento Civil).

Este decreto derogó tácitamente una parte del artículo 2397. En efecto esta disposición en su inc. I° faculta al acreedor prendario para que a falta de postura admisible en el remate pida que se le adjudique en dominio la prenda, en pago de la deuda y previa tasación de peritos. Actualmente no posee este derecho ya que el Decreto Ley N° 776 no se lo reconoce, aún más en su art. 5° no exige mínimo para las posturas en el remate.

Por lo tanto, no puede darse el caso de que no haya posturas admisibles ya que no hay posturas mínimas.

Además, el inciso final del art. 1 ° del Decreto Ley citado dispone que el acreedor no puede apropiarse de la cosa en otra forma que aquella que señala dicho decreto ley, sin que en él se contemple el derecho que consagra el art. 2397 de que el acreedor pueda pedir que se le adjudique la prenda previa tasación de peritos.

4. Derecho de preferencia:

El crédito del acreedor prendario es un crédito privilegiado de segunda clase, art. 2474 N° 3. Este privilegio es especial de modo que sólo se ejerce sobre la cosa dada en prenda y si existiera un déficit, éste se paga como crédito valista, es decir, sin preferencia.

5. Derecho de indemnización:

Con motivo de la tenencia de la cosa dada en prenda, el acreedor prendario puede haber incurrido en gastos para la conservación de ella o puede haber sufrido perjuicios derivados de la misma tenencia de la prenda. En tal caso tiene derecho a que el deudor le pague estos gastos y goza de un derecho de retención mientras éste no se efectúe, art. 2396 inc. 1°.

B. Obligaciones del acreedor prendario

El acreedor prendario tiene las siguientes obligaciones:

1. - No usar la cosa empeñada:

El acreedor no puede usar en provecho propio la cosa empeñada porque tiene la calidad jurídica de depositario de ella, art. 2395, y el depositario no puede usar la cosa que se le confía en provecho propio. Si el acreedor usa la cosa empeñada el deudor puede solicitar la devolución inmediata, perdiendo el primero el derecho a la prenda, art. 2396 inc. 3º.

Pero, este derecho del acreedor no le impide el ejercicio de los siguientes derechos y facultades:

a) Usar la cosa si el deudor lo autoriza, art. 2395.

b) Emplear el dinero recibido en prenda, art. 2395 en relación con el art. 2221.

c) Que si la prenda es fructífera, pueda percibir los frutos e imputarlos a la deuda, art. 2403.

d) Que si recibió en prenda un crédito de dinero, debe cobrarlo a su vencimiento y aplicarle al pago de su crédito si fuere de igual naturaleza y luego rendirá cuenta al constituyente, art. 12 D.L. N° 776, de 1925.

2. Cuidar y conservar la cosa empeñada:

Esta obligación la tiene el acreedor prendario porque es mero tenedor asimilado al depositario, por consiguiente responde de culpa leve si la cosa se deteriora o menoscaba mientras esté en su poder.

3. Restituir la prenda una vez cumplida la obligación principal:

Esta obligación se hace exigible contra el acreedor, cuando el deudor ha pagado íntegramente la obligación principal e interés y ha indemnizado al acreedor los gastos y perjuicios que le ocasionaron la tenencia de la cosa, arts. 2396 inc. 1º y 2401 inc. 1º.

Cesa la obligación de restituir si la prenda se destruye fortuitamente.

En cambio puede hacerse exigible esta obligación de restituir antes del vencimiento del plazo o cumplimiento de la obligación si el acreedor usa la cosa sin el consentimiento del deudor, art. 2396 inc. 3º, y no se hace exigible esta obligación cuando opera la prenda tácita, art. 2401.

C. Derechos del deudor prendario

Son correlativos a las obligaciones del acreedor prendario:

1. Pedir indemnización contra el acreedor por destrucción o deterioro de la prenda, causados por culpa del acreedor, art. 2394.

2. Reemplazar la prenda si ello no perjudica al acreedor, art. 2396 inc. 2º.

3. Vender la cosa empeñada, pese a estar constituida en prenda y aunque la tenencia la tenga el acreedor, art. 2404.

4. Exigir la restitución anticipada de la prenda si el acreedor abusa, esto es, si usa la prenda, art. 2396 inc. final.

5. Exigir la restitución de la prenda al acreedor, ejercitando para ello la acción prendaria directa, una vez extinguida la obligación principal, art. 2401 inc. Iº.

6. Concurrir a la subasta de la prenda y adjudicársela en dominio pagando el precio del remate, art. 2398.

7. Por último, mientras no se haya consumado la realización de la cosa, el deudor puede pagar la deuda. Es el

principio del art. 2399. El pago debe ser completo y deben incluirse en él los gastos que se hubieren ocasionado.

D. Obligaciones del deudor prendario

La prenda es un contrato unilateral, de modo que sólo una de las partes se obliga, y ésta es el acreedor quien debe devolver la cosa una vez extinguida la obligación. No hay obligación alguna para el deudor una vez perfeccionado el contrato de prenda.

Sin embargo, excepcionalmente puede existir obligación para el deudor: pagar las indemnizaciones en los términos del art. 2396. El acreedor hará efectiva tal obligación mediante la acción prendaria contraria.

10. - Extinción de la prenda.

La prenda se extingue por vía consecuencial y por vía directa:

1. Extinción por vía consecuencial:

Siendo la prenda un contrato accesorio, si se extingue la obligación principal ella corre la misma suerte, por aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

Existen, sin embargo, ciertas peculiaridades en algunos modos de extinción de las obligaciones:

a) Novación: arts. 1642-1643, se extingue la prenda junto con la obligación principal, a menos que exista reserva de la prenda.

b) Prescripción: la prenda civil es un contrato real en que el acreedor tiene la tenencia de la cosa de modo que respecto a ella es deudor de su entrega extinguida que sea la obligación principal.

Mientras el acreedor prendario tiene la cosa no se puede decir que él va a poder adquirirla por prescripción, porque él es mero tenedor, está por consiguiente reconociendo dominio ajeno sobre la misma. Tampoco se puede sostener que el deudor pueda extinguir por prescripción la deuda en el intertanto, porque él ha entregado una cosa en prenda al acreedor, de modo que está reconociendo la existencia de su deuda mientras no se le devuelva la prenda. Cuando hay prenda, mientras el acreedor tenga la cosa, hay una interrupción natural de la prescripción, art. 2518.

De ahí que Planiol y Laurent estimen que la prescripción extintiva no tiene cabida en la prenda ya que siempre habría una interrupción natural. No lo cree así Somarriva, quien sostiene que la interrupción de la prescripción exige actos positivos. “El reconocimiento tácito de la obligación que hace el deudor, para que tenga la virtud de interrumpir la prescripción debe emanar de actos concluyentes, inequívocos. El hecho de que la cosa dada en garantía permanezca en poder del acreedor es innegable que no reúne los requisitos necesarios para que se le considere como un reconocimiento tácito de la obligación. Confirma lo dicho la circunstancia de que según la opinión unánime de los autores, los actos de reconocimiento tácito que importan la interrupción de la prescripción son de carácter positivo; tales como solicitar esperas del acreedor, hacer pagos parciales, etc. y no los de carácter negativo, como sería la inacción del deudor para recuperar la prenda”.

2. Extinción por vía principal:

Se produce en aquellos casos en que a pesar de que se extingue la prenda subsiste la obligación principal, tales son:

a) Los modos de extinguir del art. 1567 cuando operan sólo respecto de la prenda.

b) La destrucción completa y fortuita de la cosa, art. 2506 inc.1º.

c) Cuando el acreedor prendario pasa a ser dueño de la cosa dada en prenda, art. 2406 inc. 2º, porque no puede tenerse la calidad de acreedor prendario de cosa propia.

d) Por extinción del dominio del constituyente en virtud de una condición resolutoria, art. 2406 inc. 3º. En este caso la prenda se extingue sea que el acreedor prendario esté de buena o mala fe, esto es, sin importar si supo o no la existencia de la condición resolutoria, es una excepción al art. 1490.

Pero el acreedor de buena fe puede exigirle al deudor otra prenda de igual o mayor valor u otra caución competente, y si el deudor no lo cumple puede solicitar el cumplimiento de la obligación principal, operando la caducidad del plazo, arts. 2406. inc. 3º y 2391. El acreedor de mala fe no tiene esta opción.

e) Cuando el acreedor abusa de la prenda, art. 2396.

f) Cuando el tercero dueño de la especie la reivindica, art. 2390.

g) Por realización de la prenda.

TÍTULO II

DEL CONTRATO DE HIPOTECA

1. - Definición.

El art. 2407 dice que la hipoteca es "un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor".

Esta definición ha sido bastante criticada, pero si bien ella no precisa los caracteres de la hipoteca da una idea de lo que el legislador entiende por hipoteca. Desde luego, dice que es la prenda que recae sobre bienes inmuebles, lo cual la diferencia de la prenda que tiene por objeto bienes muebles, y, además, establece que no se perfecciona por el desplazamiento de la cosa de manos del deudor a las del acreedor.

Somarriva define la hipoteca en la siguiente forma: "es un derecho real que recae sobre un inmueble, pero permaneciendo en poder del que lo constituye, da derecho al acreedor para perseguirlo de manos de quien se encuentre y de pagarse preferentemente con el producido de la subasta".

Se dice que es la más importante de las cauciones, y que ha facilitado en mucho el crédito.

2. - Características.

2.1. - Es un derecho real.

La hipoteca es siempre un derecho real. En el proyecto de 1853, Andrés Bello hacía hincapié en que era un derecho real y el actual artículo 577 la señala entre tales derechos.

Pero como derecho real, la hipoteca difiere de los demás derechos de igual naturaleza porque en éstos, trátese del dominio, del usufructo, de la prenda, de la servidumbre, hay una relación directa entre la cosa sobre la cual recae el derecho y su titular; ellos se ejercitan mediante el goce o tenencia de la cosa. Nada de esto sucede en la hipoteca, en la cual la forma de ejercitar el derecho se materializa en la facultad que tiene el acreedor de pedir la venta de la cosa hipotecada en caso de que el deudor no cumpla la obligación principal.

De ahí que algunos autores, como Bonnecasse y Planiol, sostengan que el acreedor hipotecario tiene un derecho real de segundo grado, porque no hay relación directa entre el acreedor y la cosa, como en los de primer grado, sino sólo un crédito contra la cosa.

Por ser la hipoteca derecho real se ejerce sobre el bien gravado sin respecto a determinada persona. De este carácter se desprende que el acreedor goza del derecho de persecución, expresamente reconocido en el art. 2428 que le permite perseguir la finca hipotecada de manos de quien se encuentre y a cualquier título que la haya adquirido.

2.2. - Es un derecho inmueble.

Así se desprende de los arts. 580, 2407 y 2418. Sin embargo, existen casos en que es un derecho mueble: cuando la hipoteca recae sobre una nave.

Por ser un derecho inmueble, la tradición de la hipoteca se efectúa por medio de una inscripción, art. 686.

Pero la hipoteca es un derecho accesorio, el acreedor detenta dos derechos: un derecho real y accesorio -la hipoteca- y un derecho de crédito, que es el principal, y que tiene el carácter de mueble. Pero no obstante ser accesorio el derecho de hipoteca es superior al principal.

Es por esta razón que algunos autores sostienen que siendo la hipoteca un derecho accesorio y si el derecho principal es mueble, la hipoteca también debe tener dicho carácter. Pero no es esta la opinión mayoritaria, ya que se estima que la hipoteca puede mantener su carácter de inmueble, aunque la obligación principal sea mueble, es decir, no hay que atender a si la obligación principal es mueble o inmueble para catalogar la hipoteca, la cual es siempre inmueble.

2.3. - Es un derecho accesorio.

Obligaciones susceptibles de garantizarse con hipoteca:

El carácter accesorio de la hipoteca está reconocido expresamente en el art. 46.

La obligación principal tiene que ser válida, ya que si es nula, la hipoteca también lo es porque como accesorio sigue la suerte de lo principal.

Con hipoteca se puede garantizar toda clase de obligaciones, civiles, naturales, de dar, hacer o no hacer, etc.

Puede incluso caucionarse con hipoteca obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto.

Las razones que se dan para estimar que es procedente caucionar con hipoteca obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto son:

- La ley hace alusión a ellas en el art. 2427 y en el art. 2431; en este último dice, expresamente, que la hipoteca podrá limitarse a una suma determinada, con tal que así se exprese inequívocamente. Ello hace concluir que, a contrario sensu, acepta que la obligación puede estar indeterminada en cuanto a su monto, si no se expresa que se limita a una cantidad determinada. Cuando se limita la hipoteca a una determinada suma, se llama “hipoteca de máxima”.
- Además, en conformidad al art. 376 la fianza que por lo general está obligado a rendir el guardador para entrar en el ejercicio de su cargo puede sustituirla por una hipoteca suficiente, y esta hipoteca, que debe otorgarse antes de entrar a desempeñar el cargo, va a caucionar una obligación indeterminada en su monto, porque la finalidad de esas hipotecas es garantizar el buen desempeño del cargo, y no se sabe si al terminar la guarda afectará responsabilidad al guardador, no menos por consiguiente, a cuánto, traducido en dinero va a alcanzar dicha responsabilidad. Es decir, al tiempo de constituirse la hipoteca no existe ninguna obligación determinada sino sólo una obligación posible.
- Por otro lado el art. 81 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces en su número 4 exige un requisito que sólo tiene aplicación cuando se ha limitado la hipoteca, en caso que ella sea indeterminada no se aplica.
- Esta misma argumentación lleva a concluir, aun cuando ello ha sido muy controvertido, que también es posible caucionar con hipoteca obligaciones indeterminadas en cuanto a su naturaleza, vale decir, obligaciones futuras. El art. 2413 inc. final, el art. 376, el art. 455 y el art. 517 permiten sostener que ello es posible.

Cláusulas de Garantía General Hipotecaria.

Hemos señalado que la deuda garantizada con hipoteca puede ser indeterminada en cuanto a su monto y que existen razones para sostener que las obligaciones futuras pueden también ser garantizadas con hipoteca.

Ello nos lleva al problema de determinar si es o no válida la llamada cláusula de garantía general hipotecaria. Consiste dicha cláusula en establecer que todas las obligaciones, presentes o futuras, directas o indirectas que tenga o llegue a tener el deudor con el mismo acreedor quedarán garantizadas con una hipoteca.

La eficacia de semejante cláusula ha sido discutida, siendo la opinión predominante que es válida.

Aceptan la validez de la cláusula en estudio, entre otros, Somarriva, Meza Barros.

En sentido contrario opinan F. Alessandri y Rafael Mery. Las razones que aducen para oponerse a la cláusula son:

a) Aplicaciones de los principios generales de Derecho: conforme a éstos el objeto de los actos jurídicos debe ser determinado. En la cláusula en estudio no estando determinado el objeto de la obligación ésta sería nula. El art. 1461 exige que el objeto esté determinado a lo menos en cuanto a su género, lo que no se cumpliría de aceptar dicha cláusula. Además, el inc. 2º de la citada disposición dice que la cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Pero, como puede apreciarse, esta observación es poco afortunada porque se confunde el objeto del contrato principal con el objeto de la hipoteca, es decir del contrato accesorio. El objeto de la hipoteca no es la suma o sumas garantizadas con ello, sino que es el inmueble dado en garantía.

b) El art. 2431 en materia de hipoteca, en su inciso primero señala que la hipoteca puede limitarse a una cantidad, con tal que así se exprese inequívocamente, de modo que da a entender que podría ser indeterminada esa cantidad. Pero agrega que "no extenderá en ningún caso a más del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal, aunque así se haya estipulado". Sería esta una ley prohibitiva, en que existe un interés público debido a la especialidad de la hipoteca.

c) También se argumenta que en conformidad a los arts. 2432 del Código Civil y 81 del Reglamento del Registro del Conservador de Bienes Raíces, la inscripción hipotecaria debe contener la fecha y la naturaleza del contrato a que accede, requisito con el cual no podría cumplir la cláusula de garantía general hipotecaria, demostrándose así su improcedencia. Este razonamiento es más aparente que real. La letra del artículo 2413 no deja duda en cuanto a que la hipoteca puede otorgarse antes o después del contrato; luego entonces la exigencia del art. 2432 hay que interpretarla racionalmente en el sentido de que debe cumplirse con ella cuando el contrato que garantiza se haya celebrado antes o coetáneamente con la hipoteca, pero no cuando aquél sea un contrato futuro.

Las razones que se dan para sostener la validez de la cláusula de garantía general hipotecaria son, a más de los vistos anteriormente:

a) La hipoteca con esta cláusula incide en obligaciones futuras e indeterminadas, que como se ha visto admiten ser caucionadas con hipoteca. El art. 2413 se pone incluso en el caso de que la hipoteca se haya constituido antes del contrato a que accede.

b) El art. 81 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, en su N° 4 dice "La inscripción de la hipoteca contendrá: 4º. La suma determinada a que se extiende la hipoteca en el caso de haberse limitado a determinada cantidad". Luego, si no se limita a cierta cantidad, se está en presencia de una cláusula de garantía general, no existiendo, entonces, necesidad de dejarlo expresado en la inscripción.

c) La historia de la ley. Don Andrés Bello en esta materia se aparta de la legislación francesa siguiendo al derecho español en el cual se da validez a esta cláusula.

Reviste especial importancia la determinación de la validez de esta cláusula, pues la casi totalidad de los bancos e

instituciones financieras operan con ella, de resultar que no es válida se producirían numerosos trastornos en las operaciones bancarias y crediticias.

Problemas que presenta el art. 2431:

Este artículo faculta la limitación de la hipoteca a una determinada suma con tal que se exprese inequívocamente, de modo que debe admitirse que puede limitarse la hipoteca a una determinada cantidad. Hipoteca de máxima se denomina aquella en que se ha limitado el monto a que alcanza.

Para algunos, como Somarriva, la hipoteca de máxima es un derecho que se confiere al deudor para pedir la reducción de la hipoteca cuando ella garantiza obligaciones indeterminadas. Si el acreedor no acepta dicha reducción debe recurrirse a la justicia, para que haga la limitación. Esta puede hacerse de común acuerdo, pero si éste no se produce, debe recurrirse al juez competente. Para ello, según el autor citado, debe emplearse el procedimiento ordinario, otros en cambio sostienen que debe ser el sumario.

El deudor hará valer este derecho cuando, teniendo una hipoteca sobre un bien de gran valor que garantice una obligación de poco monto, desee constituir otras hipotecas.

El art. 2431 inc. 1º. dice "La hipoteca podrá limitarse a una determinada suma, con tal que así se exprese inequívocamente; pero no se extenderá en ningún caso a más del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal, aunque así se haya estipulado".

Fabres estima que la segunda parte de esta disposición es prohibitiva. "¿Por qué se prohíbe que la hipoteca se extienda en ningún caso a más del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal? Porque el duplo es suficiente garantía y aleja todo peligro y si puede ocurrir un caso extraordinario, no lo toma en cuenta, en conformidad a la regla de derecho, las leyes se hacen para los casos ordinarios. Porque la hipoteca es un gravamen perjudicial para el deudor y así por ejemplo el inmueble gravado no se toma en cuenta para otras responsabilidades del deudor sino con descuento del gravamen...".

Somarriva no participa de esta opinión, sostiene que el inciso 2º del artículo en comentario da lugar a otra interpretación. ¿Qué sucede si la hipoteca pasa del duplo? Sostiene el profesor citado que en tal caso el deudor tendrá derecho para que se reduzca la hipoteca a dicho importe y reducida se hará a su costa una nueva inscripción, en virtud de la cual no valdrá la primera sino hasta la cuantía que se fijare en la segunda, cree sin embargo que lo es aplicable sólo a las obligaciones indeterminadas, porque respecto de las determinadas no existe limitación alguna ya que las partes conocían el monto de la obligación en el momento de constituir la hipoteca, no pudiendo existir gravamen excesivo para el deudor que se obliga a sabiendas de la extensión de su responsabilidad. Tal cosa no acontece tratándose de obligaciones indeterminadas, de manera que en defensa de terceros y del deudor hipotecario se ha establecido esta limitación.

Somarriva hace en relación con esta materia la siguiente distinción:

A) Se otorga una hipoteca de máxima, es decir se señala expresamente su límite, por ejemplo hasta $ 100.000, en este caso la garantía por capital e interés no puede exceder de esa suma.

B) Se constituye una hipoteca para caucionar una obligación determinada que produce intereses, por ejemplo para garantizar un préstamo de $ 100.000 se hipoteca un inmueble. Puede ocurrir que al momento de hacer efectiva la hipoteca los intereses sean superiores a la deuda, supongamos que en el caso propuesto asciende a $ 120.000 ¿podrá pedirse en tal caso que se reduzca la hipoteca al duplo de la obligación principal? ¿En qué caso propuesto podrá

pedirse que la hipoteca se reduzca a $ 200.000? Somarriva no lo cree posible, estima que el art. 2491 no lo permite, los intereses corren hasta la extinción de la deuda y se pagan con la misma preferencia que sus créditos.

C) Se constituye una hipoteca que garantiza una obligación indeterminada, puede suceder que exista una cláusula de garantía general por ejemplo, en esta situación el deudor puede solicitar que se limite la hipoteca al duplo de la obligación principal.

2.4. - Constituye una limitación del dominio.

A pesar de que el art. 732 no enumera la hipoteca entre las limitaciones del dominio, es evidente que tiene ese carácter. En efecto, en virtud de su constitución el propietario del inmueble no puede ejercer su derecho de dominio en forma absoluta, no puede destruir el inmueble, ni gozar de él en términos que lesionen los derechos del acreedor hipotecario, porque entonces recibiría aplicación el art. 2427 a que nos referiremos más adelante.

2.5. - Constituye un principio de enajenación:

Según hemos visto, el propietario al gravar sus bienes con hipoteca se desprende de parte del dominio, luego es evidente que ella encierra un principio de enajenación; de esta característica se deducen consecuencias interesantes, tales como que para hipótecar se requiere capacidad para enajenar, que no puede darse en hipoteca bienes embargados, etc.

2.6. -Da origen a una preferencia.

La hipoteca es una garantía y como tal no sería completa si no gozara de preferencia para el pago; el art. 2470 señala la hipoteca entre las cuales da preferencia y el art. 2477 dice que la tercera clase de créditos comprende los hipotecarios.

2.7. - Es indivisible.

Consagran esta característica los arts. 2408 y 1526 número 1.

Consiste la indivisibilidad en que cada una de las cosas dadas en hipoteca y cada parte de las mismas son obligadas al pago total de la deuda a que acceden, del mismo modo toda la deuda y cada parte de ella está garantizada con hipoteca.

El carácter indivisible de la hipoteca no es un elemento de la esencia sino que de la naturaleza, de modo que el acreedor puede renunciar a la misma, si lo hace debe ser en forma expresa. Consentida la división respecto a una parte de la hipoteca, el resto de la misma sigue siendo indivisible.

3. - Clases de hipoteca.

En Chile la hipoteca es un derecho real, generalmente convencional, sólo por excepción existe la hipoteca legal en los arts. 660 y 662 del Código de Procedimiento Civil.

El art. 662 del C. de Procedimiento Civil dice: "En las adjudicaciones de propiedades raíces que se hagan a los comuneros durante el juicio divisorio o en la sentencia final, se entenderá constituida hipoteca sobre las propiedades adjudicadas para asegurar el pago de los alcances que resulten en contra de los adjudicatarios, siempre que no se pague de contado el exceso a que se refiere el art. 660. Al inscribir el Conservador el título de adjudicación, inscribirá a la vez la hipoteca por el valor de los alcances.

Podrá reemplazarse esta hipoteca por otra caución suficiente calificada por el partidor".

Es el caso de una comunidad, en la cual existen bienes raíces. En la partición se acuerda adjudicar a uno de los comuneros, ya sea en un comparendo o en el laudo arbitral, uno de los bienes raíces. Esa adjudicación excede del 80% del haber probable. De modo entonces que debe fijarse primero cuál es el haber probable. Por el exceso puede el comunero pagar una suma de contado, pero si no hace ese pago, queda constituida una hipoteca legal sobre el inmueble para garantizar un posible alcance, es decir, saldo en contra del heredero. Los requisitos son:

a) Que se adjudique un bien raíz
b) Que la adjudicación exceda del 80% del haber probable
c) Que no se pague el exceso de contado
d) Que se inscriba la hipoteca.

Esta hipoteca es legal, sólo en lo que respecta a su fuente, ya que la establece el C.P.C., pero en todo caso debe inscribirse al igual que toda otra hipoteca. El título es la ley, y el modo de adquirir el derecho de hipoteca es la inscripción.

4. - Fuentes de la obligación de constituir hipoteca.

La obligación de constituir hipoteca puede emanar:

1º Del acuerdo de las partes

2º De una resolución judicial

3º De la ley.

En este sentido puede hablarse de hipoteca legal, convencional o judicial, pero en estricto derecho todas las hipotecas son convencionales, salvo el caso del art. 662 del C.P.C.

Hipoteca judicial es aquella que tiene su origen en una resolución judicial de la cual arranca la obligación de constituir hipoteca; ejemplos en el art. 755 hay una resolución judicial que ordena que se preste caución de conservación, la que puede ser prenda, fianza o hipoteca. En caso de optarse por una hipoteca, ésta seria convencional como toda hipoteca, pero la obligación de otorgarla nace de una resolución judicial, luego es impropio hablar de hipoteca judicial.

Se ha discutido si vale o no una hipoteca que no es convencional, sino que nace de una declaración unilateral de voluntad.

La mayor parte de la doctrina estima que no vale esta clase de hipotecas, por las siguientes razones:

a) Los arts. 2409 y 2411 hablan de "contrato".

b) La letra de los arts. 2432 N° 2 y 2433, la primera de estas disposiciones señala los requisitos de las inscripciones hipotecarias y se refiere al "contrato".

El número segundo señala que "si la hipoteca se ha constituido por acto separado...", lo cual daría lugar a concluir

que se acepta la hipoteca otorgada por un acto unilateral. Sin embargo, el artículo siguiente se pone en el caso de que falte alguna de las designaciones del art. 2433, estableciendo que no se anulará por falta de algunos requisitos, "siempre que se haya indicado la fecha de la inscripción, la firma del Conservador y que de por medio de la inscripción o del contrato o contratos citados en ella, pueda venirse en conocimiento de lo que en la inscripción se eche de menos". Es decir, no se comprende la posibilidad de que la hipoteca se haya constituido por un acto unilateral de voluntad. Todavía más, esas disposiciones están en el libro IV, que trata de los contratos, y entre ellos de las cauciones.

Se ha sostenido también que la declaración unilateral de voluntad no sería eficaz porque la hipoteca, en cuanto derecho real, requiere de una tradición y ésta a su vez de un título. La tradición sirve para adquirir un derecho real y requiere de un título, que en este caso debe ser un contrato hipotecario, salvo el caso del art. 662 del Código de Procedimiento Civil, en que el título es la ley.

La tradición es fundamentalmente una convención, un acuerdo de voluntades.

5. - Características del contrato de hipoteca.

Las características del contrato de hipoteca son las siguientes:

1. Puede celebrarse entre acreedor y deudor, o entre el acreedor y un tercero.
2. Es un contrato unilateral.
3. Es un contrato accesorio.
4. Es un contrato solemne.

1. Puede celebrarse entre acreedor y deudor, o entre el acreedor y un tercero:

Por lo general, el contrato de hipoteca se celebra entre acreedor y deudor, pero nada obsta a que un tercero quien hipoteque un bien propio para garantizar una deuda ajena, tercero que, como dicen los arts. 2414 y 2430, no contrae obligación personal de ninguna especie. Es la misma situación que existe en la prenda, donde se vio que la garantía puede ser constituida por el propio deudor o por un tercero.

Es distinta la situación cuando la hipoteca se constituye por el deudor que cuando lo hace un tercero, si es el deudor quien la constituye, el acreedor dispone de dos acciones: la personal contra el patrimonio del deudor y la real en contra de la cosa dada en hipoteca.

En cambio, si la hipoteca es constituida por un tercero, el acreedor no dispone sino de la acción real en contra del inmueble.

2. Es un contrato unilateral:

La forma como se constituye la hipoteca le da el carácter de contrato unilateral, porque en él sólo resulta obligado el constituyente -sea el deudor o un tercero- a transferir al acreedor el derecho real de hipoteca, mientras que éste no contrae obligación alguna.

3. Es un contrato accesorio:

El contrato hipotecario es accesorio, porque de acuerdo con el art. 1442 supone la existencia de una obligación principal cuyo cumplimiento esté garantizado. Pero ese carácter no es obstáculo para que conforme al art. 2413 la

hipoteca se otorgue antes del contrato a que acceda.

4. Puede ser tanto gratuito como oneroso:

Este es un punto de difícil solución, en general los autores no se pronuncian sobre el particular, afortunadamente el calificar la hipoteca como contrato gratuito y oneroso es sólo una cuestión doctrinaria, pues para el caso en que tal calificación tendría importancia, esto es para la procedencia de la acción pauliana, ello fue zanjado expresamente por el legislador en el art. 2468 equiparando la hipoteca a los contratos onerosos.

5. Es un contrato solemne:

No hay discusión alguna respecto a que la hipoteca es un contrato solemne, y que la solemnidad del contrato es la escritura pública, art. 2409.

El problema se plantea en relación con el art. 2410 que dispone "La hipoteca deberá además ser inscrita en el Registro Conservatorio; sin este requisito no tendrá valor alguno; ni se contará su fecha sino desde la inscripción".

¿La inscripción que exige la disposición transcrita es sólo la tradición del derecho de hipoteca, o es al mismo tiempo solemnidad del contrato de hipoteca?

Sobre esto hay dos opiniones:

Arturo y Fernando Alessandri, entre otros, sobre la base de los arts. 2409 y 2410 deducen que el contrato hipotecario requiere dos solemnidades: otorgamiento de escritura pública e inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces. En concordancia con esta opinión la inscripción juega dos roles: solemnidad del contrato y tradición del derecho real de hipoteca.

En concepto de la mayoría de los autores, sin embargo, la opinión es errada. Según ellos, la solemnidad del contrato hipotecario está constituida por el otorgamiento de escritura pública, y la inscripción es únicamente la tradición del derecho real. Lo mismo que en la compraventa de bienes raíces, que se reputa perfecta por el otorgamiento de escritura pública y cuya inscripción no constituye solemnidad, sino únicamente tradición del derecho de dominio. Asimismo, la hipoteca, queda perfecta por la escritura pública y la inscripción no es más que la tradición del derecho real de hipoteca.

Se dan las siguientes razones:

a) Es cierto que el art. 2410 dice que además la hipoteca debe inscribirse en el Registro de Hipotecas y que sin ello no tendrá valor alguno. Pero en este caso el legislador se refiere a la hipoteca no como contrato, sino como Derecho real, y no cabe la menor duda de que para que exista derecho real de hipoteca es necesaria la inscripción. Esto resulta evidente si se toma en consideración que el art. 2407 define la hipoteca como derecho real, como el derecho de prenda constituido sobre inmuebles, y si en ese art. se está refiriendo al derecho real de hipoteca, es lógico estimar que en el art. 2410 también se refiere a él.

b) En conformidad al art. 2411 los contratos hipotecarios celebrados en país extranjero dan hipoteca en Chile, pero mediante su inscripción en el Registro, se reconoce la existencia del contrato de hipoteca antes de que se efectúe la inscripción.

c) De acuerdo con el art. 2419 la hipoteca de bienes futuros es válida y da derecho al acreedor a hacerla inscribir a medida que el constituyente vaya adquiriendo los bienes. Está demostrado que hay contrato válido sobre bienes futuros, que el contrato existe, que es válido, y tal es así que da derecho a solicitar la inscripción. Si se otorga un

derecho al acreedor, es porque ya hay contrato.

d) Andrés Bello señala en el Mensaje del Código Civil que la transferencia de todo derecho real y del dominio exige una inscripción, y agrega que sin efectuarse ella el contrato puede existir pero no da derecho real alguno. Luego, en forma genérica, sin determinar de cuál derecho real se trata acepta que antes de la inscripción el contrato sea perfecto.

e) Si la inscripción fuera solemnidad del contrato y además tradición del derecho real sucedería que mientras no se practica la inscripción el contrato no estaría perfecto, y por consiguiente no podría pedirse su cumplimiento, que es precisamente la tradición del derecho real de hipoteca.

6. - Elementos del contrato de hipoteca.

Son los mismos que para todo contrato señala el artículo 1445.

1. Consentimiento:

A su respecto no se presenta novedad alguna en el contrato de hipoteca, en consecuencia son aplicables las reglas generales.

El consentimiento puede prestarse por medio del mandatario, se requiere eso sí que en el mandato se haga mención expresa de la facultad de hipotecar, porque ella no está comprendida entre las facultades ordinarias del mandato, no se la menciona en el art. 2132.

Se ha discutido si el mandato para hipotecar debe o no constar en escritura pública; ya se ha visto que el contrato de hipoteca es solemne, siendo la solemnidad la escritura pública. La Excma. Corte Suprema sostuvo en un tiempo que si el acto para el cual se daba el mandato era solemne, el mandato también debía serlo, ya que se seguía la teoría de la ficción en materia de representación.

Sin embargo, no parece necesario que el mandato sea solemne en tal caso, porque la ley, en el art. 2123, ha indicado cómo puede otorgarse el mandato, Además, hoy día no se acepta la teoría de la ficción sino que la de la representación modalidad de los actos jurídicos. Además, los contratos de mandato y de hipoteca se rigen, cada uno, por sus reglas particulares.

2. Objeto:

Se aplica las reglas generales en esta materia.

Los posibles problemas que al respecto pueden presentarse dicen relación con el objeto ilícito, específicamente con la determinación de si las normas del art. 1464 alcanzan al contrato de hipoteca o a la inscripción. Es sabido que el contrato no implica enajenación, luego la posible ilicitud no alcanzaría, en principio, a la hipoteca como contrato sino sólo a la inscripción. Es al practicarse la enajenación cuando se produce el objeto ilícito, enajenación que se produce una vez hecha la inscripción de la hipoteca. En conclusión, aun cuando haya embargo, por ejemplo, puede celebrarse el contrato de hipoteca, pero no puede procederse a la inscripción del mismo, esto es, a la tradición del derecho real de hipoteca.

3. Capacidad:

También en ella se siguen las reglas generales.

El art. 2414 establece las reglas de capacidad en materia de hipoteca.

Respecto de los incapaces hay normas especiales: para los pupilos, art. 393, para el hijo sujeto a patria potestad, para la mujer casada en régimen de sociedad conyugal, en lo que dice relación con sus bienes propios, art. 1754.

7. - Bienes que pueden hipotecarse.

En conformidad al art. 2418 pueden ser hipotecados:

1. Los inmuebles que se poseen en propiedad.
2. Los inmuebles que se poseen en usufructo.
3. Las naves.

Pero además pueden hipotecarse:

- La cuota de un comunero sobre la cosa común, art. 2417
- La pertenencia minera.

1. Inmuebles que se poseen en propiedad:

Al decir el art. 2418 que pueden hipotecarse los bienes raíces que se poseen en propiedad, se está refiriendo a la hipoteca del derecho de propiedad en sí mismo, como queda de manifiesto por el hecho de referirse acto continuo a los inmuebles que se poseen en usufructo.

Desde luego los inmuebles que pueden hipotecarse son los llamados inmuebles por naturaleza, pero también los inmuebles por adherencia y los inmuebles por destinación, arts. 570 y 568, no obstante estos dos últimos no pueden hipotecarse separadamente del predio a que se adhieren o a que están destinados. Constituida la hipoteca sobre un inmueble por naturaleza, se entiende que se comprenden los inmuebles por adherencia y por destinación, art. 2420.

Puede hipotecarse la propiedad plena, la propiedad nuda o la fiduciaria, art. 2418 no distingue.

Si se hipoteca la nuda propiedad, y vigente la hipoteca se extingue el usufructo, consolidándose el dominio en manos del nudo propietario, el gravamen afectaría a la propiedad plena, pues en virtud de lo dispuesto en el art. 2421 la hipoteca se extiende a todos los aumentos que reciba la cosa hipotecada.

La hipoteca de la propiedad fiduciaria está expresamente reglamentada en el art. 757.

2. Inmuebles que se poseen en usufructo:

El art. 2418 al decir que pueden hipotecarse los inmuebles que se poseen en usufructo induce a error porque da a entender que lo que el usufructuario hipoteca es el inmueble en sí mismo, cuando en realidad lo que se le permite gravar es su derecho de usufructo.

La hipoteca del usufructo no significa que su sola constitución de acreedor faculta para percibir los frutos. Será el usufructuario quien continuará percibiéndolos. El acreedor hipotecario tendrá derecho a ellos cuando ejercitando su derecho de tal embargue el usufructo, sin que, conforme lo establece el art. 2423, se extienda su derecho a los frutos percibidos por el usufructuario.

3. Hipoteca de naves:

Esta materia está reglamentada por la Ley N° 3.500 y no por el Código de Comercio como dice el art. 2418. Sólo son susceptibles de hipotecarse las naves de más de cincuenta toneladas, incluso las que están en construcción en un astillero.

- Hipoteca de bienes futuros:

En conformidad al art. 2419 los bienes futuros son susceptibles de hipotecarse. Se hipoteca los bienes sobre los cuales se tiene un derecho eventual, limitado o rescindible.

En conformidad al art. 2416 se pueden hipotecar los bienes raíces aun cuando sobre ellos se tenga un derecho eventual, limitado o rescindible, eso sí que entendiéndose hipotecados con esa limitación, aunque no se exprese. La regla señalada es innecesaria y no constituye sino una aplicación del principio según el cual nadie puede transferir más derechos que los que tiene.

Por otra parte, el art. 2416 se pone en el caso que el inmueble hipotecado esté sujeto a una condición resolutoria, y dice que tendrá lugar lo dispuesto en el art. 1491, lo que en otros términos significa que declarada la resolución se extingue la hipoteca o no, según la condición conste o no en el título respectivo inscrito u otorgado por escritura pública.

- Hipoteca de cosa ajena:

Es discutida su validez, hay quienes opinan que ella no sería válida, se fundan en:

1. El art. 2414 que establece que puede constituir hipoteca sobre sus bienes la persona que tenga capacidad para enajenar: se argumenta que al decir "sus bienes" está exigiendo en el constituyente el dominio en los bienes que hipoteca.

2. El art. 2418 dice que la hipoteca sólo puede recaer sobre los inmuebles que se poseen en propiedad o usufructo.

De ambas disposiciones se pretende colegir que la hipoteca de cosa ajena adolece la nulidad, en cuanto prohiben su constitución y por tratarse de un acto prohibido, de acuerdo con el artículo 10, hay nulidad absoluta.

No es la anterior, sin embargo la opinión de la mayoría de los autores, éstos sostienen que la hipoteca de cosa ajena es válida, dando las siguientes razones para sostener su opinión:

1. La regla general en el derecho chileno es que los contratos sobre cosa ajena son válidos, incluso más, la tradición de las cosas por quien no es el verdadero dueño de ellas también es válida conforme a los arts. 682 y 683, de modo que el adquirente queda en la misma situación que el tradente. No existen razones particulares para que el Código se aparte en materia de hipoteca del sistema general.

2. La prenda sobre cosa ajena se permite expresamente, de modo que no habría por que estimar que no procede aplicar un principio semejante en materia de hipoteca.

3. La ley no dice categóricamente que para la validez de la hipoteca se requiera dominio de parte del constituyente, lo cual no puede inferirse de los arts. 2414 y 2416 como se pretende. Resulta un tanto violento sostener que la primera de estas disposiciones es prohibitiva, que impide hipotecar un bien ajeno. Al querer referir la expresión "sus bienes" al dominio se la desnaturaliza, dándosele un alcance que no es el querido por el legislador; dicha expresión se refiere a los bienes que están en poder del que constituye la hipoteca, sea éste dueño o no de ellos.

4. El derecho de hipoteca puede adquirirse por prescripción, ya que conforme al art. 2498 inc. 2º pueden adquirirse por medio de ella los derechos reales que no estén expresamente exceptuados, ahora bien en conformidad al art. 2512 el derecho de hipoteca se rige, en cuanto a su prescripción por las mismas reglas que el dominio, lo que significa en otros términos que puede adquirirse por prescripción ordinaria o extraordinaria. Y si se estima que la hipoteca de cosa ajena adolece de nulidad de acuerdo con el artículo 704 sería un título injusto que daría origen a la posesión irregular y ésta a la prescripción extraordinaria, resultando así que la hipoteca jamás se podría adquirir por

prescripción ordinaria, con lo cual no se respetaría lo dispuesto por el art. 2412.

5. El art. 2417 permite la ratificación, la que no es procedente en caso de que haya nulidad absoluta.

Efectos de la hipoteca sobre cosa ajena:

a) Sería un título de aquellos que habilitan para adquirir por prescripción.

b) Para el dueño, tal hipoteca es inoponible de modo que podría solicitar la cancelación de la misma.

c) En la práctica es difícil que exista hipoteca sobre cosa ajena, porque el Conservador de Bienes Raíces revisa y controla las inscripciones que se le solicitan.

- Hipoteca de cuotas.

El art. 2417 dice que un comunero puede hipotecar su cuota aun antes de la participación, durante la comunidad. Para analizar los efectos de esta hipoteca es menester hacer una distinción: 1) si una vez efectuada la partición se adjudica al comunero el bien que hipotecó, subsiste la hipoteca; 2) si por el contrario el bien se adjudica a otro comunero caduca la hipoteca, pero, con todo, en este último caso podrá subsistir sobre el bien o bienes adjudicados a otros comuneros siempre que ellos den su consentimiento por escritura pública y que se deje constancia de esta escritura al margen de la inscripción hipotecaria.

Respecto a éstos se ha discutido qué es lo que se hipoteca si la cuota en la comunidad o la cuota en el inmueble. Manuel Somarriva se inclina por lo segundo argumentando que la hipoteca recae siempre sobre inmuebles y que la comunidad no es un inmueble.

- Hipoteca de unidades de un inmueble acogido a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria.

De acuerdo al artículo 16 de la Ley N° 19.537 las unidades de un condominio pueden hipotecarse o gravarse libremente, sin que sea necesario para ello del acuerdo de la asamblea de copropietarios. En caso de ponerse término a la copropiedad la hipoteca sobre la unidad respectiva subsiste.

La hipoteca constituida sobre una unidad de un condominio se extiende a los derechos que en los bienes comunes le corresponda, y quedan comprendidos en la inscripción de la hipoteca.

Se establece expresamente que se puede constituir hipoteca sobre una unidad de un condominio en proyecto en construcción, para cuyo efecto deberá archivarse provisionalmente en el Conservador de Bienes Raíces respectivo un plano en que estén singularizadas las respectivas unidades de acuerdo con el permiso de construcción otorgado por la Dirección de Obras Municipales. Esta hipoteca gravará la cota del terreno que corresponda a la respectiva unidad desde la fecha de la inscripción de la hipoteca, y se radicará en la unidad y los derechos que le correspondan, sin necesidad de nueva escritura e inscripción desde la fecha del certificado de la Dirección de Obras Municipales que declare acogido el inmueble al régimen de Copropiedad Inmobiliaria, debiendo procederse al archivo en la Sección Especial del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo del plano del condominio.

La inscripción de esta hipoteca debe contener además de las menciones que indica el art. 2432 números 1, 2, 4 y 5 del Código Civil las señaladas en los N°s. 4 y 5 del inciso segundo del artículo 12 de la Ley N° 19.537, esto es, la ubicación y los deslindes del condominio a que pertenezca la unidad y el número y ubicación que corresponda a la unidad en el plano referido precedentemente.

Esta disposición presenta dos características que la diferencia de la hipoteca corriente, tales son:

1. Se permite la hipoteca de una cosa futura -el piso o departamento- de acuerdo, por lo demás, con lo establecido

en el art. 2419.

2. Mientras no se construye el edificio -cosa principal y futura- se hipoteca el suelo, que es accesorio.

8. - Adquisición del derecho real de hipoteca.

El derecho real de hipoteca puede adquirirse por tradición, prescripción, sucesión por causa de muerte, cesión y subrogación del crédito hipotecario.

1. Tradición:

El derecho real de hipoteca se adquiere por tradición la cual se efectúa por la inscripción del título en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de la comuna o agrupación de comunas en que está ubicado el inmueble, arts. 670 inc. 2º, 2410 del C.C. y 32, 52 N° 1 y 54 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces.

Requisitos de la inscripción:

Se encuentran señalados en el art. 2432 y en el art. 81 del Reglamento, ellos son:

a) Individualización del acreedor y deudor, sean personas jurídicas o naturales.

a) Hacer referencia al título, es decir, al contrato de constitución de la hipoteca y al archivo en que se encuentre.

b) Individualización del bien raíz sobre el cual recae la hipoteca.

c) Si está limitada a una determinada suma se hará constar tal determinación y la suma a que asciende.

d) Fecha de la inscripción y firma del Conservador de Bienes Raíces. Esta exigencia es imprescindible, de modo que si falta la hipoteca es nula, ya que de no ser así, no se sabría el orden de prelación de las hipotecas sobre un mismo inmueble en el caso de existir varias.

En el caso del art. 2433 el único requisito que es indispensable y cuya omisión trae consigo la nulidad de la inscripción es la fecha y firma del Conservador. No sucede lo mismo con la omisión de los otros requisitos, siempre que por medio de la inscripción misma o del contrato o contratos mencionados en ella pueda venirse en conocimiento de lo que falte en la inscripción.

En el caso de hipoteca de una unidad de un inmueble acogido a la ley de copropiedad inmobiliaria la inscripción debe reunir los requisitos del art. 12 de la Ley N° 19.537.

1. Prescripción:

El derecho real de hipoteca puede adquirirse por prescripción, se ha señalado que la hipoteca de cosa ajena es válida, de tal manera que si ella llega a ser inscrita podrá adquirirse por prescripción en conformidad a los arts. 670, 682, 689, 715, 2512 y 2513.

La sentencia que declare la prescripción debe inscribirse para que produzca sus efectos respecto de terceros, el art. 52 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces la menciona entre los títulos que deben inscribirse.

2. Sucesión por causa de muerte:

Como consecuencia del carácter accesorio que tiene la hipoteca, si el crédito que ella garantiza lo adquiere el heredero o legatario por sucesión por causa de muerte, también pasa a sus manos el derecho de hipoteca.

El heredero o legatario adquiere la hipoteca ipso jure, por el solo hecho de que se le difiera la asignación, sin necesidad de inscripción alguna en el Conservador de Bienes Raíces.

3. Cesión del crédito hipotecario:

La cesión del crédito comprende las hipotecas y cualesquiera otras cauciones que garanticen el crédito, de acuerdo con lo prescrito en el art. 1906. Es una aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

La mayor parte de la doctrina (Somarriva, Alessandri, etc.) estima que la hipoteca pasa del cedente al cesionario por el solo hecho de la cesión del crédito, sin necesidad de nueva inscripción.

La opinión anterior no es compartida por Rafael Mery, quien sostiene que debe hacerse la inscripción de la hipoteca a nombre del nuevo acreedor, aunque el crédito no requiera de inscripción. En su opinión no cabe duda que la cesión de créditos comprende la de sus accesorios, pero añade que éstos deben cumplir con sus estatutos particulares, los cuales respecto de la hipoteca obligan a realizar la inscripción. El art. 2410 la requiere para la tradición de la hipoteca.

Dice Mery "si bien la hipoteca constituye un elemento accesorio del crédito, tal circunstancia no le hace perder su naturaleza propia de derecho real. El crédito, elemento principal, continúa siendo un derecho personal y la hipoteca mantiene su calidad de derecho real".

Siempre la hipoteca es un derecho real y como tal requiere de inscripción para poder ser transferido; el art. 1906 se refiere a la tradición del título no a la del derecho real.

Añade Mery que no hay que olvidar que las normas sobre cesión de créditos se refieren a los derechos personales y que la hipoteca es un derecho real. Y que no basta decir que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ya que aunque la hipoteca sea un accesorio, no es menos cierto que tiene un estatuto jurídico propio distinto, el cual debe respetarse.

4. Subrogación en el crédito hipotecario:

La subrogación, sea legal o convencional, art. 1612, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo. Por eso el subrogante adquiere de pleno derecho, conjuntamente con el crédito, la hipoteca que lo garantiza.

9. - Cosas a las que se extiende la hipoteca.

Los arts. 2420, 2421, 2422 y 2423 establecen que la hipoteca comprende no sólo el bien raíz gravado sino también los inmuebles por adherencia o destinación, los aumentos y mejoras que recibe la cosa hipotecada, las rentas de arrendamiento que ésta devengue y las indemnizaciones debidas por los aseguradores de ella.

a) Los inmuebles por destinación, art. 570. Si al vender un inmueble se entiende también vendidos los inmuebles por destinación, igual regla tiene aplicación en materia de hipoteca.

Naturalmente que es necesario que los inmuebles por destinación pertenezcan al dueño del inmueble gravado, de lo contrario no tendrían tal carácter y no se verían afectados por la hipoteca.

Los bienes muebles que están destinados permanentemente al uso, cultivo o beneficio del inmueble -pasando a tener el carácter de inmuebles por destinación- por voluntad del dueño del terreno, por esa misma voluntad puede quitarles este carácter, enajenándolos a terceros y desde ese momento deja de afectarlos la hipoteca, art. 2420.

b) Inmuebles por adherencia, art. 568, también quedan comprendidos en la hipoteca del inmueble a que adhieren como consecuencia del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, e indiferentemente que existan o no al momento de la hipoteca.

Si el dueño enajena separadamente los inmuebles por adherencia, éstos, en conformidad al art. 571, pasan a ser muebles por anticipación y dejan de estar afectos a la hipoteca.

c) Aumentos que sufra el bien hipotecado, art. 2421.

d) La indemnización debida por los aseguradores del inmueble hipotecado, art. 2422. El fundamento de ello es que el legislador establece una subrogación real en la cual el monto del seguro reemplaza al inmueble hipotecado, art. 555 del C. de Comercio.

e) Las rentas devengadas en el inmueble hipotecado, art. 2422.

10. - Efectos de la hipoteca.

1. Efectos respecto del dueño de la cosa hipotecada:

Hay que distinguir dos situaciones:

a) Antes que el acreedor ejercite la acción hipotecaria:

No obstante la constitución de la hipoteca, el dueño del inmueble conserva las facultades inherentes al dominio, esto es, las de usar, gozar y disponer del inmueble hipotecado.

Para disponer del inmueble hipotecado lo autoriza el artículo 2415, el cual aún más, le reconoce esta facultad no obstante cualquier estipulación en contrario. Si se llegare a estipular que el dueño del inmueble gravado con hipoteca no puede enajenarlo, semejante pacto adolecería de nulidad absoluta por objeto ilícito, artículos 1466 y 1682. Se justifica esto porque la enajenación del inmueble dado en garantía no perjudica al acreedor, porque éste en virtud del derecho de persecución pueda hacer valer su derecho, aun encontrándose el inmueble en manos de terceros.

El art. 2415 faculta también al dueño para hipotecar nuevamente el inmueble sin que valga estipulación alguna en contrario. Tampoco perjudica esto al acreedor, porque en conformidad al art. 2477 las hipotecas prefieren por el orden de sus fechas, de manera que el primer acreedor hipotecario va a tener preferencia sobre los demás para pagarse.

El acreedor hipotecario está obligado a respetar los arrendamientos siempre que éstos consten por escritura pública inscrita con anterioridad a la hipoteca, art. 1962 N° 3. Si no se cumple con estos requisitos no está obligado el acreedor hipotecario a respetar los arrendamientos.

En síntesis, antes que el acreedor ejerza la acción hipotecaria el propietario dispone de todas las facultades inherentes al dominio, pero sólo puede ejercerlas en términos tales que no se lesione los derechos del acreedor disminuyendo la garantía, porque en ese evento el legislador, para resguardar sus derechos, lo faculta para tomar las medidas que indica el art. 2427.

El art. 2427 tiene aplicación cuando el inmueble se pierde o deteriora, como la ley no distingue respecto de la causa de la pérdida o deterioro se comprende tanto la originada por actos materiales como las causadas por actos jurídicos, y también tiene aplicación sea que la pérdida se deba a caso fortuito o a un hecho culpable o doloso del dueño.

b) Después que el acreedor ejercita la acción hipotecaria.

El acreedor hipotecario ejercita su acción embargando el bien hipotecado; desde ese momento cesa la facultad del propietario de gozar y disponer del inmueble y sus accesorios. No puede enajenar el inmueble hipotecado y, si lo hace, de acuerdo al art. 1464 habría objeto ilícito, y por consiguiente la enajenación sería nula absolutamente.

11. - Derechos del acreedor hipotecario.

La hipoteca concede al acreedor tres derechos principales: venta, persecución y preferencia.

1. Derecho de venta.

Se refiere a él el art. 2424 que señala que el acreedor hipotecario tiene sobre la cosa hipotecada los mismos derechos que el acreedor prendario sobre las cosas dadas en prenda, y el art. 2397 señala este derecho para el acreedor prendario.

En realidad el acreedor hipotecario dispone de dos acciones:

a) Acción personal contra el deudor, y

b) Acción hipotecaria.

La acción personal se hace efectiva sobre todos los bienes del deudor, sobre la totalidad de su patrimonio; en tanto que la acción hipotecaria sólo dice relación con la finca hipotecada.

El ejercicio de la acción hipotecaria, que cuando se dirige contra el deudor principal se confunde con la acción personal, se tramita de acuerdo con el procedimiento ordinario o el del juicio ejecutivo. Se aplicará este último cuando tanto la obligación principal como la hipoteca consten en un título que en conformidad al art. 434 del Código de Procedimiento Civil sea ejecutivo.

La acción hipotecaria es siempre real, porque emana de un derecho real; es siempre inmueble, ya que recae sobre inmuebles y se dirige contra el actual poseedor del bien raíz hipotecado, sea o no el deudor principal y tiene por objeto realizar el inmueble en pública subasta, para que el acreedor se pague con el producto de ella.

Para efectuar la realización hay que sacar la finca hipotecada a remate, de modo que opera una especie de subrogación entre la cantidad de dinero que se obtenga de la realización y con la cual se pagará al acreedor; el dinero entra a reemplazar al inmueble y sobre él se hará efectivo el derecho del acreedor. La tasación del inmueble será el avalúo que tenga para el impuesto territorial, pero el deudor tiene derecho a que se tase la propiedad por peritos. Luego se fija día y hora para el remate, publicándose cuatro avisos en un periódico del Departamento. El pago, por regla general, es al contado, salvo que en las bases del remate se señale otra cosa.

Si no existen posturas puede adjudicarse el inmueble al acreedor. Esa es en resumen la forma de proceder al remate de la finca hipotecada.

Hemos señalado que el art. 2397 prohíbe que el acreedor se apropie de la prenda como forma de pago de la deuda, la misma regla es aplicable a la hipoteca. Se confiere el derecho de venta, pero ella debe ser en pública subasta.

2. Derecho de persecución.

Mientras el inmueble hipotecado permanece en poder del deudor la acción hipotecaria se confunde con la acción personal. Pero si la finca dada en garantía pasa a manos de un tercero entonces aparece nítidamente la acción hipotecaria, porque contra éste no puede ejercitarse la acción personal sino que nace para el acreedor el derecho de persecución consagrado en el art. 2428 inc. I°.

En términos generales son terceros poseedores todos aquellos que son dueños o poseedores de la finca hipotecada sin que se hallan obligados personalmente al cumplimiento de la obligación.

Caso típico de tercer poseedor es el que adquiere la finca hipotecada.

En cuanto al que hipoteca un inmueble propio para garantizar una deuda ajena, puede encontrarse en dos

situaciones, según que se halla obligado o no personalmente a la deuda. Si no se ha obligado personalmente es tercer poseedor y procede en su contra el derecho de persecución. Pero si se ha obligado personalmente para lo cual en conformidad a los arts. 2414 y 2430 inc. I° se requiere pacto expreso, es evidente que no es tercer poseedor, y entonces se le perseguirá de la misma manera que al deudor principal.

El fiador hipotecario no es tercer poseedor, porque el fiador se obliga personalmente a la deuda, y es característica del tercer poseedor que no esté obligado personalmente a la deuda.

El tercer poseedor no puede oponer el beneficio de excusión, el art. 2429 le niega expresamente este derecho, esta misma regla se aplica al que hipoteca un bien para garantizar una deuda ajena, sea que se haya obligado personalmente o no, art. 2430. inc. 2°.

Cesa el derecho de persecución: si existe purga de la hipoteca, de acuerdo con el art. 2428 y en caso de expropiación por causa de utilidad pública.

De acuerdo a lo señalado para que proceda el derecho de persecución es necesario que la finca se encuentre en manos de un tercer poseedor, pero ello no basta, es necesario, además, que la deuda garantizada sea exigible y que la hipoteca se encuentre inscrita.

La acción hipotecaria dirigida en contra del tercer poseedor toma el nombre de: acción de desposeimiento. Es la misma acción hipotecaria pero hecha valer en contra del tercer poseedor, es decir, de aquel que no se encuentra personalmente obligado al pago de la deuda. Tratándose de la acción de desposeimiento hay un procedimiento especial, señalado en los arts. 758 a 763 del Código de Procedimiento Civil.

La acción de desposeimiento es una acción inmueble, art. 580.

El procedimiento que se usa para entablar la acción de desposeimiento es el siguiente: el acreedor tiene que notificar al tercero, éste tiene un plazo de 10 días contado desde la notificación para adoptar una de las siguientes actividades:

a) Pagar la deuda,
b) Abandonar la finca, y
c) No hacer nada.

a) Pagar la deuda:

Si el tercer poseedor paga la deuda se subroga en los derechos del acreedor, conforme al art. 2429 inc. 2°.

b) Abandona la propiedad:

Se realiza este abandono poniendo el inmueble a disposición del Tribunal, antes que haya vencido el plazo de 10 días contado desde la notificación de la demanda.

No debe creerse que por el hecho del abandono de la finca que hace el tercero, ésta va a pasar a ser de dominio del acreedor. El abandono no constituye una dación en pago, no significa transferencia de dominio. El único efecto que produce es el de poner la finca a disposición del tribunal, con el objeto de que se saque a remate y se pague al acreedor. Así el tercero se libra de responsabilidad.

c) No hacer nada:

En este caso el acreedor puede entablar en su contra la acción de desposeimiento.

La acción de desposeimiento se tramita en forma de juicio ordinario si el acreedor no tiene título ejecutivo, y en

forma de juicio ejecutivo, si lo tiene. Si se tramita como juicio ejecutivo, el acreedor sólo puede pedir que el tercero le abandone la finca, ya que no puede demandar el pago de la deuda al tercero, porque éste no se encuentra personalmente obligado a ella.

El deudor debe indemnizar al tercero que abandona la finca hipotecada o es desposeído de ella, art. 2429 inc. final.

3. Derecho de preferencia:

La hipoteca es un crédito de tercera clase, su preferencia es especial y recae sólo sobre la finca hipotecada, de manera que si su valor no alcanza a pagar toda la deuda, el déficit pasa a la quinta clase de créditos, art. 2490. Si hay varias hipotecas sobre un mismo inmueble ellas prefieren según el orden de sus fechas y las de una misma fecha según el orden material de sus inscripciones.

12. - Extinción de la hipoteca.

La hipoteca puede extinguirse por vía principal y por vía consecuencial.

Se extingue la hipoteca por vía de consecuencia cuando se produce la extinción de la obligación principal. Sin embargo, hay un caso en que, no obstante ello, subsiste la hipoteca: cuando en la novación se hubiere hecho reserva de la hipoteca, art. 1644.

Se produce la extinción de la hipoteca por vía principal cuando no obstante subsistir el crédito que se garantiza, se extingue la hipoteca, y ello sucederá por aplicación de alguno de los modos de extinguir que enumera el art. 1567 entre los casos de extinción de la hipoteca por vía principal cabe destacar:

a) Renuncia de la hipoteca: el acreedor puede renunciar a la hipoteca, pero como las renuncias son de electos relativos, la obligación principal subsiste. No porque se renuncie a la obligación accesoria, se extingue la principal.

La renuncia debe hacerse por escritura pública y tomarse nota de ella al margen de la inscripción respectiva. Ello siempre que el acreedor tenga capacidad para renunciar, art. 2434.

b) Purga de la hipoteca: es la extinción de la hipoteca cuando el inmueble es sacado a remate en pública subasta ordenada por el juez, siempre que se cite a los acreedores hipotecarios y que el remate se verifique una vez que haya transcurrido el término de emplazamiento. Si en dicho remate no se obtiene lo suficiente para pagar a todos los acreedores hipotecarios, respecto de aquellos que no alcanzaron a pagarse se extingue la hipoteca aunque no se haya pagado la obligación principal.

Puede ocurrir que un inmueble esté gravado con varias hipotecas y que el valor que se obtuvo por él en el remate no alcance para pagar a todos los acreedores hipotecarios. Las hipotecas que garantizaban las obligaciones que se pagaron se extinguen por dicho pago y a su respecto no hay purga, pero aquellos acreedores que no alcanzaron a pagarse ven también extinguirse las hipotecas que les servían de garantía aunque no se haya pagado sus créditos; respecto de estos últimos hay purga de la hipoteca, art. 2428.

Respecto de los acreedores hipotecarios no pagados se extinguen las hipotecas por purga de ellas, pero conservan su acción personal contra el deudor.

La purga de la hipoteca opera en favor de quien se adjudicó el inmueble en el remate.

Requisitos para que opere la purga de la hipoteca:

Son los siguientes:

1) Pública subasta;

2) Notificación de los acreedores hipotecarios, y

3) Transcurso del término de emplazamiento.

1) Pública subasta:

Se requiere que un tercero haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta ordenada por el juez. La pública subasta a que se refiere el art. 2428 se refiere a las ventas forzadas que se efectúan como consecuencia de un juicio. Si la finca se adquiere por un tercero en una pública subasta que no es consecuencia de un litigio no hay purga de la hipoteca.

En la purga de la hipoteca se plantea un problema en relación con el Código de Procedimiento Civil, en efecto el art. 499 de dicho cuerpo de leyes se pone en el caso de que no se presenten postores al remate, estableciendo lo siguiente: "Si no se presentaren postores en el día señalado, podrá el acreedor solicitar cualesquiera de estas dos cosas a su elección:

1. Que se le adjudiquen por los dos tercios de la tasación los bienes embargados.

2. Que se reduzca prudencialmente por el tribunal el avalúo aprobado. La reducción no podrá exceder de una tercera parte del avalúo".

Conforme al artículo señalado una de las cosas que puede solicitar el acreedor, en caso de no presentarse postores al remate, es que se le adjudique el bien objeto del remate. El problema que puede originarse en relación con esto es que quien pide la adjudicación puede no ser el primer acreedor sino uno de grado posterior ¿qué sucede en tal caso con las hipotecas de los acreedores de grado superior? ¿hay o no purga respecto a ellos?

Al respecto, debe distinguirse si la adjudicación opera en favor del primer acreedor hipotecario o de uno de grado posterior:

A) Si la adjudicación opera en favor del primer acreedor hipotecario y se han reunido los requisitos de la purga de la hipoteca, ésta se produce, en el sentido de que si el valor de adjudicación no alcanza a pagar a los acreedores de grado posterior se extinguen sus hipotecas.

B) Si la adjudicación opera en favor de otros acreedores que no sea el primero, no hay purga, las hipotecas no se extinguen. No hay purga porque así lo establece el art. 492 C.P.C.

El art. 492 C.P.C. da un derecho de opción a los acreedores de grado anterior al que provoca el remate: puede elegir entre ser pagado con el producto del remate o mantener las hipotecas.

1) Notificación a los acreedores hipotecarios:

Para que opere la purga de la hipoteca, es menester que se cite personalmente a los acreedores hipotecarios, art. 2428 inc. 3º.

Por "citación personal" debe entenderse "notificación personal", así se ha resuelto por la jurisprudencia.

La citación tiene por objeto que los acreedores adopten las medidas que juzguen adecuadas para que la finca se realice en el mejor precio posible con el fin de que el que se obtenga alcance para satisfacer la totalidad de sus créditos.

Debe notificarse a todos los acreedores, tanto a los de grado anterior como a los de grado posterior.

Puede ocurrir que sacada la finca a remate éste no tenga lugar, sea porque no hay postores, se suspendió, etc., en

este caso si ella se vuelve a sacar a remate o se fija una nueva fecha, hay que notificar otra vez a los acreedores, pero no es necesario que dicha notificación sea personal, puede ser por cédula y aun por el estado diario.

2) Transcurso del término de emplazamiento:

Entre la notificación de los acreedores y el día del remate debe haber transcurrido el término de emplazamiento, art. 2428.

La disposición es oscura, pero su alcance práctico permite discernir su significado. La notificación debe lógicamente hacerse antes del remate y con una anticipación adecuada para que cumpla su objetivo. La subasta debe hacerse una vez transcurrido el término de emplazamiento. En otras palabras, un término igual al de emplazamiento debe transcurrir entre la fecha de la notificación y la de la subasta.

Se ha entendido que el término de emplazamiento a que la ley se refiere es el señalado para el juicio ordinario.

Consignación del precio del remate.

El precio de la subasta debe consignarse a la orden del juez que dispuso la subasta.

Con los fondos consignados, los acreedores hipotecarios serán cubiertos en el orden que corresponda, art. 2428 inc. 3º.

Consecuencia de la falta de citación oportuna de los acreedores:

La única consecuencia que se sigue es que subsisten las hipotecas de los acreedores no citados y, por lo tanto, su derecho de perseguir la finca en poder del tercer adquirente.

En este evento el subastador se subroga en los derechos de los acreedores hipotecarios a quienes pagó: rematada nuevamente la finca por el acreedor hipotecario no citado, se pagará el subastador preferentemente y, de este modo, aunque pierda la finca no perderá el precio pagado por ella, art. 1610 N° 2.

Reforma introducida por el Código de Procedimiento Civil.

El art. 492 del Código de Procedimiento Civil ha modificado ligeramente el art. 2428 del Código Civil, dice dicha disposición "Si por un acreedor hipotecario de grado posterior se persigue la finca hipotecada contra el deudor personal que la posea, el acreedor o los acreedores de grado preferente, citado conforme al art. 2429 del Código Civil, podrán, o exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate según sus grados, o conservar sus hipotecas sobre la finca subastada, siempre que sus créditos no estén devengados".

La reforma no consiste, ciertamente, en que sólo deben ser citados para la subasta los acreedores de grado preferente, debe citarse a todos los acreedores de grado anterior o posterior al que insta para la realización de la finca.

Consiste la modificación en que los acreedores de grado preferente tienen la facultad de optar entre pagarse de sus créditos con el producto de la subasta o conservar su derecho de hipoteca. Esta facultad no compete a los acreedores de grado posterior que deben ser pagados con el precio del remate si fuere suficiente para ello.

El inc. 2º del art. 492 C.P.C. añade: "No diciendo nada en el término de emplazamiento, se entenderá que optan por pagarse sobre el precio de la subasta".

Dos son las condiciones indispensables para que los acreedores de grado preferente puedan ejercitar la opción:

a) Que se persiga la finca "contra el deudor personal que la posea". Por lo tanto, no tiene cabida la opción si se persigue la finca contra un tercer poseedor;

b) Es preciso que el crédito no sea exigible. Los acreedores de grado preferente pueden optar por conservar sus hipotecas “siempre que sus créditos no estén devengados”, en otros términos, el acreedor cuyo crédito es exigible sólo puede demandar el pago con el producto del remate.

Cancelación de la hipoteca.

Esta no es una manera de extinguir la hipoteca, sino una consecuencia de la extinción. La cancelación puede efectuarse en tres formas:

1) Puede ser convencional: acreedor y deudor, de común acuerdo, en virtud de que el deudor pagó la obligación garantizada con la hipoteca, cancelan la inscripción hipotecaria.

2) Puede efectuarse sólo por el acreedor, en virtud de su renuncia al derecho de hipoteca.

3) También puede hacerse judicialmente, esto es, por orden judicial, lo que acontecerá principalmente en los casos siguientes:

a) Cuando se expropie el inmueble hipotecado por causa de utilidad pública;

b) Cuando el deudor, en juicio ordinario, así lo solicite, lo que hará cuando no obstante haber pagado la obligación garantizada con hipoteca, el acreedor no cumple con cancelar ésta, y el juez ordena la cancelación;

c) En el caso del art. 2428, con respecto a los acreedores citados a la subasta y que no alcanzaron a pagarse con el producto del remate, y

d) Cuando se declare judicialmente la nulidad de la hipoteca.

Posposición de la hipoteca.

Consiste en el acto por el cual un acreedor hipotecario consiente en que una hipoteca constituida con posterioridad a la suya, pase a ser preferente.

La posposición debe hacerse por medio de una escritura pública, y es motivo de una nueva inscripción, no se hace por medio de una anotación al margen de la nueva inscripción.

TÍTULO III

CONTRATO DE FIANZA

1. - Definición.

Define la fianza el artículo 2335.

La fianza no es una "obligación", sino un contrato accesorio que se celebra entre el acreedor y el fiador. La necesidad en que se encuentra el fiador de satisfacer total o parcialmente la obligación, en subsidio del deudor principal, es el efecto propio y fundamental de este contrato.

Es una garantía personal, pero cuando hay fianza el acreedor tiene dos acciones para hacer efectivo su crédito: el derecho de perseguir la obligación en los bienes del deudor, en virtud del derecho de prenda general, y el derecho de perseguir la obligación en los bienes del fiador. El acreedor, entonces, dispone de dos derechos de prenda general: uno en los bienes del deudor, y otro en los del fiador.

2. - Carácter contractual de la fianza

La fianza siempre es un contrato. El artículo 2336 dice que la fianza puede ser convencional, legal o judicial. Pero de él no se desprende que haya fianza sin forma contractual, la disposición citada sólo expresa que "la obligación de rendir fianza" puede emanar de la voluntad de las partes, de la ley o del juez. Pero, en cualquier caso, la fianza debe constituirse por medio de un contrato.

3. - Características del contrato de fianza.

a) Es consensual: excepcionalmente reviste el carácter de solemne, como ser:

I. La fianza que debe rendir tutores y curadores; para que les discierna el cargo debe constituirse por escritura pública, art. 855 C.P.C.;

II. La fianza mercantil, que debe otorgarse por escrito, art. 820
C. de Comercio;

b) Es unilateral: sólo una de las partes se obliga para con la otra, la cual no contrae obligación alguna. Del art. 2335 se desprende que quien se obliga es el fiador para con el acreedor a cumplir la obligación en todo o parte, si no la cumple el deudor principal. El deudor es extraño al contrato de fianza, art. 2345.

La fianza sería bilateral si el acreedor se obligara a pagar una remuneración al fiador por el servicio que le presta, pero en este caso degenera en otro contrato: el seguro.

c) Es un contrato gratuito: tiene por objeto sólo la utilidad de una de las partes, sufriendo el gravamen el fiador.

Pero, puede estipularse una remuneración a favor del fiador: cuando ella se pacta entre fiador y acreedor, en tal caso, como se ha señalado, la fianza degenera en un contrato de seguro.

También puede pactarse una remuneración entre fiador y deudor, lo dice expresamente el art. 2341, sin embargo este contrato celebrado entre fiador y deudor en que se pacta una remuneración es un contrato innominado, y no uno de fianza, porque éste se celebra entre fiador y acreedor, el deudor es extraño a dicho contrato, como se desprende claramente del art. 2345.

d) Es accesorio: a más de las consecuencias propias de esta característica hay que tener presente la que el fiador

no puede obligarse a más de lo que deba el deudor principal ni en términos más gravosos que éste, art. 2343.

No obsta a lo anterior nada obsta a que el fiador se obligue en términos más eficaces que el deudor principal, por ejemplo otorgando una hipoteca cuando la obligación no está garantizada con tal caución, art. 2344 inc. 2º.

e) Es patrimonial: por consiguiente se transmite a los herederos, art. 2352.

4. - Requisitos del contrato de fianza.

La fianza debe reunir todos los requisitos comunes a los contratos, pero por su carácter accesorio requiere además de una obligación principal.

a) Consentimiento: como el contrato de fianza es consensual se perfecciona por el solo consentimiento, respecto de esto debe tenerse presente que la ley requiere que éste sea expreso, no bastándole uno tácito, art. 2347.

Como la fianza impone graves obligaciones al fiador, la ley ha exigido que su consentimiento sea expreso; en cambio la voluntad del acreedor puede ser tácita. Al decir que la fianza no se presume, el legislador ha establecido una norma relativa a la persona que se obliga como fiador.

En lo que dice relación con la prueba, la fianza está sujeta a las reglas generales.

b) Capacidad: el fiador debe tener capacidad para obligarse como tal, art. 2350 inc. 1º.

El art. 2342 da una norma referente a la capacidad de ciertas personas para obligarse como fiadores. Los títulos referidos en dicha norma sólo consignan reglas especiales relativas a las condiciones en que pueden obligarse como fiadores los pupilos, los cuales de acuerdo al art. 404 requiere: 1) Autorización judicial previa;
2) Que la fianza se otorgue en favor de un descendiente o ascendiente, o del cónyuge, y 3) que se invoque una causa urgente y grave.

La fianza, como los demás actos del hijo de familia, debe ser autorizada o ratificada por el padre, art. 261; la fianza en este caso obliga directamente al padre y subsidiariamente al hijo, hasta concurrencia del beneficio que reporte.

c) Objeto de la fianza: la obligación principal puede ser de dar, hacer o no hacer, pero la obligación del fiador será siempre de dar, y de dar una suma de dinero, art. 2343 incs. 2º y 4º.

Si la obligación afianzada es de hacer, el fiador no se obliga a ejecutar el hecho en lugar del deudor, sino que garantiza el pago de los perjuicios que la infracción cause al acreedor.

La obligación de no hacer se resuelve en la indemnización de perjuicios, si el deudor la contraviene y no puede deshacerse lo hecho. La fianza de una obligación de esta naturaleza no hace responsable al fiador sino de los perjuicios derivados del incumplimiento, art. 2343 inc. 3º.

El contrato de fianza debe reunir, además, los siguientes requisitos especiales:

1. La fianza debe consistir siempre en que el fiador pague una suma de dinero, art. 2343 inc. final. Si una persona se obliga a pagar una especie o cuerpo cierto o a ejecutar un hecho si el deudor principal no cumple, no hay fianza sino un contrato innominado o, quizás una cláusula penal.

2. Se requiere que exista una obligación principal a la cual la fianza accede, y esta obligación principal puede ser de diversa naturaleza.

Así, de acuerdo al art. 2338, puede ser civil o natural (art. 1472); conforme al art. 2339 la obligación principal puede ser pura y simple o sujeta a modalidad; y, además, ella puede ser futura, lo dice expresamente el art. 2339. Pero la fianza de obligaciones futuras tiene la característica de dar al fiador el derecho de retractarse mientras no exista la

obligación principal; pero al retractarse, el fiador debe dar aviso de su retracción al acreedor, aplicando al respecto el art. 2173 del mandato.

Por último, se ha señalado precedentemente que pueden afianzarse obligaciones de dar, hacer y no hacer.

5. - Clases de fianza.

La fianza puede clasificarse en diversas formas:

1) En cuanto a su origen la fianza puede ser convencional, legal o judicial, art. 2336.

En esta clasificación no se atiende al origen de la obligación del fiador, la cual es siempre convencional, sino al de la obligación del deudor principal de rendir fianza.

Ejemplos de fianza legal: arts. 89, 374, 376, 775 y 777.

Ejemplos de fianza judicial: arts. 932, 1292 y 1313.

Esta fianza siempre debe apoyarse en el texto expreso de la ley.

La fianza legal y la judicial se rigen por las mismas reglas que la convencional, art. 2336 inc. 3º.

Existen entre ellas, sin embargo, las siguientes diferencias:

a) De acuerdo al art. 2337 la fianza legal y la judicial pueden suplirse con prenda o hipoteca; en cambio la convencional no puede suplirse en contra de la voluntad del acreedor.

b) En la fianza judicial, el fiador no dispone del beneficio de excusión, art. 2358 N° 4.

2) La fianza puede ser simple o solidaria.

La fianza simple está sometida a las reglas generales de la fianza, no ofreciendo particularidades especiales.

La fianza solidaria puede serlo en dos aspectos: con respecto al deudor y con respecto a los demás fiadores, si hay dos o más.

Si la fianza es solidaria con respecto a los demás fiadores, impide oponer el beneficio de división, es decir aquel que permite, cuando hay varios fiadores, que éstos pidan que se les persiga por su cuota en la fianza.

Si la fianza es solidaria respecto de los deudores, su estipulación significa renuncia al beneficio de excusión.

No es lo mismo obligarse como fiador solidario que como fiador y codeudor solidario, ya que en este último caso se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. La estipulación en virtud de la cual una persona se obliga como fiador y codeudor solidario tiene importancia porque deja establecido de antemano la falta de interés del codeudor en la obligación, art. 1522.

3) La fianza puede ser civil o comercial, según accede a una obligación civil o mercantil. Tiene importancia esta clasificación, porque mientras la fianza civil es un contrato consensual, la mercantil de acuerdo al art. 820 del Código de Comercio debe constar por escrito.

4) La fianza puede ser simple, prendaria o hipotecaria.

En la fianza simple, el fiador obliga todos sus bienes, indistintamente, al cumplimiento de la obligación. En este tipo de fianza el acreedor dispone de dos acciones personales para requerir el pago de su crédito: una contra el deudor principal y otra contra el fiador.

En la fianza prendaria, el fiador, además, de obligarse como tal, constituye una prenda para garantizar el

cumplimiento de la obligación, en este caso el acreedor tiene contra el fiador la acción personal que emana de la fianza y la real que emana de la prenda.

En la fianza hipotecaria el acreedor puede dirigirse contra el fiador hipotecario exigiendo el cumplimiento de la obligación de acuerdo a las reglas de la fianza o entablando en su contra la acción real de hipoteca -derecho de persecución-, art. 2430.

5) La fianza puede ser limitada o ilimitada.

Es limitada cuando se restringe a una cantidad determinada o se establecen claramente las obligaciones que el fiador toma sobre sí.

Es ilimitada cuando no se determinan las obligaciones que garantiza el fiador o la cuantía de su responsabilidad, es decir, se extiende a la obligación principal con todos sus accesorios.

Cuando la fianza es limitada el fiador sólo responde hasta la suma convenida o por las obligaciones determinadas, art. 2367 inc. 3º.

Si la fianza es ilimitada, no se extiende a más que la obligación principal y sus accesorios, arts. 2343 y 2344.

El legislador ha precisado la extensión de la fianza que no está limitada en su cuantía, art. 2347. El fiador está obligado a pagar: a) el capital de la obligación; b) los intereses y c) las costas.

6. - Obligación de rendir fianza y calidades del fiador.

I) Personas obligadas a rendir fianza:

Generalmente el deudor tiene libertad para constituir fianza, pero está obligado a constituirla a petición del acreedor cuando:

a) Así se hubiere estipulado entre acreedor y deudor, art. 2348 N° 1;

b) La fortuna del deudor haya menguado de manera que sea de temer que no cumpla sus obligaciones, art. 2348 N° 2;

c) Haya motivo para temer que el deudor se ausente del país con ánimo de establecerse en otra parte y no deje bienes suficientes para responder de sus deudas, art. 2348 N° 3; y

d) El fiador del deudor cae en insolvencia, art. 2349.

II) Calidades del fiador:

El fiador debe reunir las siguientes calidades:

a) Ser capaz de obligarse como fiador; no debe ser una de las personas comprendidas en el art. 2342;

b)) Tener o señalar domicilio dentro del territorio jurisdiccional de la respectiva Corte de Apelaciones,

c) Tener bienes más que suficientes para hacer efectiva la fianza. El art. 2350 señala cuáles bienes se toman en cuenta y cuáles no para estos efectos.

7. - Efectos de la fianza.

Los efectos de la fianza deben analizarse desde un triple punto de vista:

a) Entre fiador y acreedor;

b) Entre fiador y deudor, y

c) Entre los cofiadores.

a) Efectos entre el fiador y el acreedor:

Deben considerarse en dos momentos:

I. antes que el acreedor demande al fiador, y

II. con posterioridad a esa demanda.

I. Antes que el acreedor demande al fiador puede éste pagarse la deuda en los mismos casos en que podría hacerlo el deudor principal, art. 2353. Pero si el fiador paga la deuda antes de que ésta se haya hecho exigible, no puede repetir contra el deudor sino una vez que la obligación se haya hecho exigible, art. 2373.

Cuando la obligación se ha hecho exigible, lo normal es que el fiador espere que el acreedor tome la iniciativa, pero de acuerdo al art. 2356 tiene derecho a requerir al acreedor a fin de que persiga primero al deudor principal, y si no obstante este requerimiento el acreedor no lo hace, no es responsable el fiador de la insolvencia del deudor que se produzca con posterioridad.

II. El acreedor demanda al fiador. Para que el acreedor pueda demandar al fiador es necesario que la obligación sea exigible. El acreedor puede dirigirse contra el fiador mediante el procedimiento ordinario o el ejecutivo, pero para hacer uso de este último es necesario que tanto la obligación principal como la fianza consten en título ejecutivo.

Demanda el fiador, dispone de cuatro derechos para defenderse:

1) El beneficio de excusión;

2) El beneficio de división;

3) La excepción de subrogación, y

4) Las excepciones reales inherentes a la obligación.

1) Beneficio de excusión:

En virtud de este beneficio el fiador puede exigir que se persiga primero la obligación en los bienes del deudor principal, y en las hipotecas o prendas constituidas por éste para garantizar el pago, art. 2357.

También recibe el nombre de beneficio de orden, porque tiene por objeto que se persiga primero al deudor, y sólo si éste no paga que se proceda en contra del fiador.

El beneficio de excusión es facultativo, art. 2357. Pero hay casos en que el fiador no puede oponer dicho beneficio, y hay otros en que el acreedor está obligado a practicar la excusión aunque el fiador no oponga el beneficio.

A) Casos en que el fiador no puede oponer el beneficio de excusión:

- Cuando lo hubiera renunciado expresamente, art. 2360,
- Cuando se haya obligado como fiador y codeudor solidario con respecto al deudor, art. 2358 N° 2,
- Cuando la obligación afianzada es natural. El beneficio de excusión tiene por objeto que el acreedor persiga primero al deudor principal y si la obligación afianzada es natural, como no produce acción, sería absurdo que el fiador pudiera oponer tal beneficio, ya que el acreedor no podría dirigirse contra el deudor principal, art. 2358 N° 3,
- Cuando la fianza se ha constituido por orden judicial, art.2358 N° 4.

B) Casos en que el acreedor está obligado a practicar la excusión no obstante que el fiador no le oponga el beneficio:

- Cuando así se hubiere pactado expresamente entre acreedor y fiador;
- Cuando el fiador se hubiere obligado en forma expresa e inequívoca a pagar únicamente lo que el acreedor no pueda obtener del deudor principal, art. 2365 inc. 2º. En este caso el fiador no será responsable de la insolvencia del deudor cuando concurran las siguientes circunstancias:

i) Que el acreedor haya tenido medios para hacerse pagar en los bienes del deudor;

ii) Cuando haya sido negligente en servirse de estos medios.

Requisitos del beneficio de excusión:

a) Que el fiador no esté privado del beneficio, esto es que no se encuentre en uno de los casos en que no puede oponerse;

b) Que lo oponga en tiempo oportuno, art. 2358 N° 5. El Código de Procedimiento Civil ha precisado la oportunidad para hacerlo valer: en el juicio ordinario, como excepción dilatoria, arts. 303 N° 5 y 305; en el juicio ejecutivo en el escrito de oposición a la ejecución, arts. 464 N° 5 y 465.

c) Que el fiador indique al acreedor bienes del deudor para perseguir el cumplimiento de la obligación, art. 2358 N° 6.

Al respecto hay que señalar:

Que no se tomarán en cuenta los bienes que señala el art. 2359, sea por las dificultades de su realización, sea porque resulta difícil que el acreedor pueda pagarse con ellos.

No es indispensable que los bienes sean bastante para obtener un pago total, art. 2364; pero los bienes tienen que tener la importancia suficiente para que pueda obtenerse un resultado serio, de lo contrario este beneficio se traduciría en una burla para el acreedor.

Costos de la excusión:

El acreedor tiene derecho a que el fiador le anticipe los costos de la excusión, art. 2361.

El beneficio de excusión procede una sola vez

Así lo establece el art. 2363. El fiador debe señalar todos los bienes del deudor y no puede pretender, a pretexto de que la excusión no produjo resultados o los bienes fueron insuficientes, señalar otros bienes del deudor. Esta regla tiene una excepción: el que los bienes hayan sido adquiridos posteriormente por el deudor principal, art. 2363 inc. 2º.

El beneficio de excusión en las obligaciones solidarias

El fiador debe señalar para la excusión los bienes del deudor a quien afianzó, pero si se trata de una obligación solidaria y afianzó a uno de los deudores, el fiador tiene derecho a que se persiga previamente la obligación principal en los bienes de todos los deudores solidarios y no únicamente en los del deudor que él afianzó, art. 2362.

Caso del subfiador

El subfiador puede oponer el beneficio de excusión tanto respecto al deudor principal como al fiador, y puede pedir al acreedor que persiga primero al deudor y luego al fiador, y, si ambos no pagan, entra él a responder de la obligación.

Efectos del beneficio de excusión.

Son los siguientes:

a) Como excepción dilatoria suspende la entrada en juicio.

b) Cesa la persecución del acreedor contra el fiador y debe dirigirse contra el deudor principal.

c) Si con los bienes del deudor se produce el pago parcial de la deuda, ésta se extingue parcialmente, art. 2364; pero subsiste la acción del acreedor contra el fiador por el saldo insoluto.

d) Si con los bienes del deudor se paga totalmente la deuda, se extingue la obligación y la fianza.

2) Beneficio de división:

Cuando hay dos o más obligados a una prestación, la regla general es que cada deudor sólo está obligado a pagar su parte o cuota en la deuda, salvo que ésta sea solidaria. Lo mismo sucede en la fianza: si hay varios fiadores cada uno sólo está obligado a pagar su parte o cuota en la deuda, art. 2367.

La división de la deuda entre los cofiadores opera de pleno derecho.

Requisitos del beneficio de división.

Para que el fiador pueda oponer el beneficio de división al acreedor deben concurrir las siguientes condiciones:

- Que haya varios fiadores;
- Que los fiadores no se hayan obligado como fiadores solidarios; la fianza solidaria no da derecho a este beneficio;
- Que todos los fiadores sean de un mismo deudor, y
- Que todos los fiadores afiancen una misma obligación del deudor.

El beneficio de división no es sino una consecuencia del carácter de conjuntas que tienen las obligaciones de los fiadores.

Forma de división de la deuda entre los fiadores.

Por regla general se divide por partes iguales. Esta regla tiene dos excepciones:

1ª. cuando uno de los fiadores cae en insolvencia, de acuerdo al art. 2367 la insolvencia de éste grava a los demás, pero no se entiende que un fiador esté en insolvencia cuando tiene un subfiador, porque éste entra a reemplazar al fiador, y

2ª. cuando un fiador en forma expresa e inequívoca ha limitado a determinada cantidad su responsabilidad; en este caso sólo está obligado hasta el monto de lo pactado, art. 2367 inc. final.

3) Excepción de subrogación:

Se refieren a ello los arts. 2335 y 2381 N° 2.

Cuando el fiador paga al acreedor se subroga en sus derechos de acuerdo al art. 1610 N° 3. Puede suceder que por un acto propio del acreedor el fiador vaya a estar en la imposibilidad de subrogarse en los derechos contra el deudor, en este caso el fiador tendrá derecho a que se le rebaje de la demanda del acreedor todo lo que hubiere podido obtener del deudor principal o de otros fiadores. Si el fiador pierde totalmente los derechos que podría tener contra el deudor, la fianza se extingue totalmente, artículo 2381 N° 2.

4) Derecho a oponer todas las excepciones reales inherentes a la obligación.

De acuerdo al art. 2354 puede oponer al acreedor todas las excepciones reales inherentes a la obligación, pero no las personales del deudor.

b) Efectos entre el fiador y el deudor.

A este respecto hay que distinguir dos situaciones: efectos antes que el fiador haya hecho el pago y efectos con posterioridad a él.

I. Derecho que tiene el fiador antes de que haya hecho el pago: de acuerdo con el art. 2369 tiene derecho el fiador a que el deudor le releve de la fianza o le caucione sus resultados o le consigne medios de pago para responder de ella. Las circunstancias que autorizan al fiador para ejercer estos derechos las enumera taxativamente el artículo 2369.

Para obtener el relevo de la fianza es necesario que concurra el consentimiento del acreedor, ya que es con éste que el fiador ha celebrado el contrato de fianza.

Aviso mutuo del fiador y del deudor antes del pago de la deuda: habiendo en la fianza dos personas obligadas a pagar, el legislador, en principio, les impone la obligación de avisarse mutuamente cuando hayan efectuado el pago.

Si el deudor paga sin dar aviso al fiador, es responsable para con éste de lo que por ignorancia de la extinción de la deuda pagare de nuevo, pero tendrá acción contra el acreedor por el pago indebido, art. 2376.

Si paga el fiador, sin dar aviso al deudor, se produce una doble consecuencia:

1) Si a su vez el deudor también paga la deuda, el fiador no tendrá recurso alguno en su contra, pero puede repetir contra el acreedor, art. 2377 inc. 2º.

2) El pago del fiador puede privar al deudor de las excepciones que pudo oponer al acreedor, dichas excepciones puede hacerlas valer contra el fiador cuando éste intente las acciones encaminadas al reembolso, art. 2377.

II. Derechos que tiene el fiador después que ha realizado el pago:

El fiador tiene contra el deudor dos acciones:

1) La acción de reembolso, que emana de la fianza, art. 2370, y

2) La acción subrogatoria en virtud del artículo 1610 N° 3.

1) Acción de reembolso: se la denomina, además, acciones personales, en atención a su origen, porque es propia del fiador, a diferencia de la acción subrogatoria en que el fiador ejercita los derechos de su acreedor, cuyo lugar pasa a ocupar en virtud de la subrogación.

El fiador que ha pagado al acreedor tiene derecho a que el deudor le restituya lo pagado más los intereses y gastos. Luego, la acción de reembolso abarca el monto de lo pagado, los intereses de esta suma y los gastos que le hubiere ocasionado todo ello al fiador. Pero no hay inconveniente para que además demande al deudor la indemnización de los perjuicios por incumplimiento de contrato.

Condiciones para el ejercicio de la acción de reembolso:

a) Que la obligación principal se haya extinguido por el pago que ha hecho el fiador o por otros medios que le signifiquen a éste un empobrecimiento. Si la obligación se extingue por un medio no oneroso para el fiador, no tiene acción de reembolso, art. 2374.

b) Que el pago hecho por el fiador sea un pago útil, que realmente extinga la obligación, art. 2375 N° 3.

c) Que el fiador no esté privado de la acción, el art. 2375 señala dos casos en que éste está privado de tal acción:

- cuando ha afianzado una obligación puramente natural.

- cuando se obligó contra la voluntad del deudor, sin embargo, incluso en este caso goza de la acción cuando el pago ha extinguido la deuda.

Además, no tiene acción de reembolso cuando paga sin dar aviso al deudor y éste a su vez paga la deuda, art. 2377 inc. 2º.

d) Que entable la acción en tiempo oportuno, esto es, después del pago, por excepción no podrá intentar la acción cuando la obligación no era aún exigible, esto es si pagó anticipadamente, artículo 2373.

Por otro lado, debe intentar la acción antes de que ella prescriba.

Contra quién se dirige la acción de reembolso:

Ello depende de diversas situaciones:

1) Si hay un solo fiador y un solo deudor, se dirige contra el único deudor;

2) Si hay varios deudores solidarios y un fiador que los ha afianzado a todos, éste puede entablar la acción contra todos o cada uno por el total;

3) Si hay varios deudores solidarios, pero el fiador afianzó a uno sólo, puede dirigirse exclusivamente contra el deudor por él afianzado y no contra los otros deudores, art. 2372.

2) Acción subrogatoria: la contempla el artículo 1610 N° 3 también el art. 2429.

Hay ciertos casos en que el fiador no goza de la acción subrogatoria:

- cuando la obligación principal es natural
- cuando el fiador pagó sin dar aviso al deudor, el cual ignorando la extinción de la deuda, la paga nuevamente, art. 2377.

Diferencia entre la acción subrogatoria y la de reembolso.

1. La acción de reembolso corresponde al fiador por derecho propio, por la subrogatoria ejercita los derechos del acreedor;

2. La acción de reembolso abarca el monto de lo pagado por el fiador, más los intereses y gastos, la subrogatoria sólo comprende lo que realmente pagó el fiador al acreedor;

3. La acción de reembolso es una acción sin garantía; la subrogatoria tendrá las garantías y privilegios de que gozaba la obligación principal.

c) Efectos de la fianza entre los cofiadores.

Para que tenga lugar se requiere que hayan dos o más fiadores. Si es así y cada uno de los fiadores ha pagado su cuota en la deuda porque hicieron uso del beneficio de división, no hay problema, pero si un fiador paga más de lo que le corresponde, el art. 2378 dice que se subroga al acreedor por el exceso en contra de los otros fiadores.

Los cofiadores pueden oponerse entre sí las excepciones reales y las suyas personales, art. 2379.

8. - Extinción de la fianza.

Puede extinguirse por vía principal y por vía de consecuencia. Como obligación accesoria se extingue por vía de consecuencia, cuando se extingue la obligación principal, art. 2381 N° 3.

Además, se extingue por vía principal, y en este caso puede ser por cualquiera de los medios señalados en los arts. 1567 y art. 2381.

La ley se refiere, en especial, a la dación en pago y a la confusión como modos de extinguir la fianza, arts. 2382 y 2383.

CAPÍTULO X

CONTRATO DE MANDATO

1. - Definición.

Se encuentra definido en el artículo 2116 del Código Civil como "un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera".

De esta definición se desprende:

1) Que es un contrato.
2) Que es un contrato de confianza.
3) Que su objeto consiste en la gestión de uno o más negocios.
4) Que la gestión se realiza por cuenta y riesgo del mandante.

Por regla general, todos los actos jurídicos pueden realizarse por medio de mandatario siendo un ejemplo de ello el matrimonio, artículo 103. Excepción: el testamento, artículo 1004.

2. - Mandato y representación.

Como por regla general el mandatario es representante del mandante, los efectos del contrato que aquél celebra se producen para el mandante y no para el mandatario.

Sin embargo, esta característica del mandato, -el que lleva envuelta la representación- no es esencial, porque un mandatario puede contratar a nombre propio y no a nombre del mandante, conforme lo autoriza el artículo 2151 y, en este caso, quedará obligado para con el tercero el mandatario y no el mandante.

La representación no es un elemento de la esencia del mandato, sino uno de la naturaleza de éste.

3. - El mandato versa siempre sobre actos jurídicos.

El mandato no puede referirse a actos materiales puesto que envuelve la idea de representación como elemento de la naturaleza, de manera que debe recaer siempre sobre actos jurídicos.

4. - Características del contrato de mandato.

I) Puede ser gratuito o remunerado, artículo 2117. Tiene importancia saber si el mandato es gratuito o remunerado para determinar la responsabilidad del mandatario la cual, obviamente, será mayor cuando el mandato sea remunerado.

Se ha resuelto que el mandato es un contrato remunerado, salvo que se estipule lo contrario, ello aunque el Código

no lo dice expresamente se desprende del artículo 2158 N° 3, que señala entre las obligaciones del mandante la de pagar la remuneración estipulada o usual. La forma de determinar la remuneración del mandatario se aplica en el silencio de las partes lo que indica que el mandato por regla general es remunerado.

Si el contrato es oneroso podrá ser, a su vez, conmutativo o aleatorio. Será conmutativo, si la remuneración se pacta sin consideración al éxito o fracaso del negocio encomendado, en la medida que el mandatario cumpla su obligación de ejecutar el encargo conforme a las instrucciones del mandante; y será aleatorio, si el derecho a la remuneración sólo existe para el mandatario en el evento de tener éxito en la gestión encargada.

2) Puede ser unilateral o bilateral; si es gratuito, tendrá, en principio, el carácter de unilateral, a menos que existan otras obligaciones que sean de cargo del mandante, como por ejemplo la de proveer de fondos al mandatario; si es remunerado será necesariamente bilateral.

3) El mandato es un contrato principal en la medida que subsiste por sí mismo sin precisar de otra convención.

4) Por regla general es consensual, artículos 2123 y 2124.

La norma del artículo 2124 está de más, porque como contrato el mandato tiene que perfeccionarse por el acuerdo de voluntades, teniendo sí el mérito de recordarnos que se aplican aquí las reglas de formación del consentimiento, de los artículos 97 y siguientes del Código de Comercio. Adicionalmente, esta misma disposición deja en claro que la aceptación puede ser tácita, constituyéndose en tal la ejecución del encargo por parte del mandatario.

Este mismo artículo, en su inciso tercero, contiene una regla especial, que consiste en que aun después de aceptado el mandato, el mandatario puede retractarse, siempre que el mandante esté en condiciones de ejecutar él el mandato o cometerlo a otra persona. Es importante considerar lo excepcional que resulta el hecho de que después de manifestada la aceptación y, en consecuencia, después de formado el consentimiento para dar origen al contrato de mandato, pueda el aceptante retirar su manifestación de voluntad.

En cuanto al mandante que formula una oferta de mandato, éste podrá retirarla a condición de que lo haga antes de que se produzca la aceptación y de que tal retractación se manifieste en forma expresa o tácita.

Por último, en relación con la formación del consentimiento en el mandato, cabe recordar que es un contrato donde el silencio constituye manifestación de voluntad: así lo señala el artículo 2125.

Existen, no obstante casos de mandatos solemnes. Don David Stitchkin señala que el mandato es consensual siempre, salvo que las partes convengan que sea solemne o que la ley establezca ciertas solemnidades, como sucede en los artículos 103 del Código Civil y 6 del Código de Procedimiento Civil.

Mandato para celebrar un acto jurídico solemne.

El problema en esta materia es si el mandato puede ser consensual cuando el encargo que se efectúa a través del mismo supone un acto solemne. Algunos autores sostienen que el mandato debe cumplir las mismas solemnidades que el contrato encomendado, fundándose en que si la ley exige solemnidad para un acto jurídico, tal solemnidad no puede fraccionarse y se extiende a los elementos esenciales de dicho acto. Uno de esos elementos es el consentimiento, el cual está contenido en el mandato y por tanto también debe ser solemne. Todo ello fundado en la parte final del artículo 2123.

Otros autores afirman que dicha doctrina es errada, porque el artículo 2123 debe interpretarse literalmente: dice que el mandato es consensual y que no se admite en juicio la testimonial, sino con arreglo a las reglas generales, esto

es a los artículos 1708, 1709 y 1710. El error de la primera opinión proviene de la confusión entre dos actos: el mandato y el negocio para el cual éste se confiere. Por el mandato sólo se encarga el negocio, y la voluntad para la celebración de este último se manifiesta en el acto encargado y sólo allí es exigible la solemnidad; la voluntad que contrata es la del mandatario y es esta voluntad la que debe manifestarse en forma solemne y no la voluntad del mandante quien puede hacerlo en forma consensual.

Así concluyen que el mandato es consensual incluso cuando es para realizar negocios solemnes.

La jurisprudencia tiene fallos en ambos sentidos aunque los más recientes apuntan hacia la segunda interpretación.

5) El mandato es un contrato de confianza. Lo que se desprende de la propia definición del artículo 2116 en cuanto una persona "confía" a otra la gestión de sus negocios.

Lo anterior lo transforma en un contrato "intuito persona", es decir, en que la consideración del individuo es la causa principal y determinante del mandato.

Esta situación se visualiza claramente desde el punto de vista del mandante, quien escogerá determinada y cuidadosamente la persona a quien efectúa el encargo. Creemos que, asimismo, también desde el punto de vista del mandatario se plantea esta selección de su mandante, particularmente cuando se trata de un mandato sin representación.

El carácter de contrato de confianza acarrea consecuencias de importancia, en particular en lo referente a la extinción del contrato como se verá más adelante.

5. - Diferencias entre mandato y arrendamiento de servicios.

Presentan las siguientes diferencias:

1) El arrendamiento de servicios recae sobre actos materiales, el mandato sobre actos jurídicos:

2) El mandato lleva naturalmente envuelta la idea de representación, lo que no sucede con el arrendamiento de servicios.

6. - Diferencias entre mandato y agencia oficiosa.

Se diferencian en que el mandato es un contrato y supone voluntad del mandante; en cambio la agencia oficiosa es un cuasicontrato, en el cual una persona gestiona los intereses de otra, sin tener mandato para ello.

No obstante, existe relación entre ambas instituciones.

Así, si una persona, actuando de buena fe, obró en virtud de un mandato nulo, se convierte en agente de negocios; artículo 2122.

Otro punto de vinculación, más complejo que el anterior, se refiere a una persona que ha iniciado sus actuaciones como agente de negocios y con posterioridad el interesado ratifica lo obrado por éste; la duda es si producto de esta última actuación, la agencia oficiosa se transforma o no en mandato, siendo relevante la respuesta para determinar el estatuto jurídico que regirá a las partes así como a los terceros.

El tema es discutido siendo don David Stitchkin del parecer que no se muda la naturaleza jurídica, por cuanto no existe el imprescindible acuerdo de voluntades, cuya ausencia no puede suplirse por una mera ratificación; de parecer contrario son don Guillermo Correa y la doctrina francesa en general.

7. - Requisitos del mandato.

Como todo contrato debe cumplir los requisitos generales de éstos. Pero hay algunas reglas especiales respecto de la capacidad, contenidas en el artículo 2128.

Capacidad del mandante: el mandante requiere la capacidad necesaria para ejecutar los contratos que el mandatario va a celebrar por él.

En ausencia de tal capacidad habrá nulidad absoluta o relativa del mandato dependiendo de si la incapacidad es absoluta o relativa.

Capacidad del mandatario: de acuerdo al artículo 2128 el mandatario puede ser un relativamente incapaz, ello porque la incapacidad relativa se encuentra establecida para proteger el patrimonio de los incapaces, pero nada impide que esos incapaces actúen por cuenta de otras personas y comprometan el patrimonio de éstas. Si una persona capaz confiere mandato a un incapaz relativo, es porque confía en su gestión, el legislador adopta medidas para proteger a los incapaces, mas no a los capaces. Si el incapaz relativo contrata a nombre propio será necesaria la autorización de su representante legal, pero si lo hace en representación del mandante entonces, por aplicación del artículo 1448, podrá contratar por sí solo.

Es evidente que no puede ser mandatario un absolutamente incapaz por cuanto carece de voluntad.

En cuanto a los relativamente incapaces, el artículo 2128 sólo menciona al menor adulto. Stitchkin sostiene que dicha norma es extensiva a todos los incapaces relativos, es decir, se extiende al disipador interdicto; otros autores afirman que se excluye al disipador en razón de que éste no tiene suficiente juicio y discernimiento.

8. - Mandato general y mandato especial. Artículo 2130.

El mandato puede ser general o especial dependiendo de si él está otorgado para la generalidad de los negocios del mandante, en cuyo caso estaremos frente a un mandato general, o bien, si el mismo fue otorgado para uno o más negocios específicamente determinados, o bien, para un conjunto de negocios determinados en cuanto a su género, en cuyo caso estaremos frente a un mandato especial.

Como puede apreciarse el criterio diferenciador está dado por el universo de negocios encomendados y no por las facultades conferidas al mandatario.

9. - Facultades del mandatario.

Lo que se dirá se aplica tanto al mandato general como al mandato especial.

La regla primordial en la materia está dada por el artículo 2131, en cuanto el mandatario deberá ceñirse rigurosamente a los términos del mandato, lo cual se ve ratificado por lo dispuesto en el artículo 2134 en cuanto la recta ejecución del mandato, no sólo implica cumplir el encargo, sino que utilizar los medios que el mandante dispuso para tal cumplimiento. Así, lo esencial es la voluntad del mandante, para cuyo establecimiento, en caso de duda, habrá de recurrirse a los artículos 1560 y siguientes del Código Civil.

Hacen excepción a la regla precedente los casos en que la ley autoriza al mandatario para obrar de otro modo, lo que ocurre en los casos de los artículos 2134 inciso 2º, 2147, 2148 y 2150 inciso 2º.

Ahora bien, en ausencia de manifestación expresa, es decir, cuando el mandante se limita a conferir poder sin expresar las facultades con que debe obrar el mandatario, el Código entrega en los artículos 2132 y 2133 ciertas reglas que buscan establecer las prerrogativas con que obrará el mandatario.

El artículo 2132 da cuenta del denominado mandato de simple administración en cuya virtud el mandatario puede ejecutar actos conservativos y actos de administración. Así lo señala la disposición citada y hace, además, una enumeración no taxativa de los actos de administración que comprenden aquellos del giro ordinario del mandante. En cambio, este mandatario no puede ejecutar actos de disposición y aquellos para los cuales requiere de poder especial.

Por su parte, el inciso 1º del artículo 2133, con el objeto de evitar que el mandatario abuse de sus facultades, establece que aun cuando el mandato señale que el mandatario tiene facultades para obrar como mejor le parezca, ello no le da derecho a ejecutar actos para los cuales requiere poder especial, y no puede tampoco alterar la sustancia del negocio encomendado.

Pero esta disposición no se refiere a la forma en que debe ejecutar el mandato, por lo que, sin perjuicio de las prevenciones anteriores, el mandatario pareciere, en virtud de esta cláusula, quedar liberado de la limitación del inciso 2º del artículo 2134.

En cuanto al mandato con facultad de libre administración a que se refiere el artículo 2133 inciso 2º, pareciere ser, esencialmente, una cláusula de prevención interpretativa, en el sentido que es el legislador quien establece que, en presencia de ella, el juez no puede interpretarla extendiendo su alcance a actos más allá de los establecidos por las leyes.

Finalmente, conforme al artículo 2132 inciso 2º, la ley establece que para exceder las facultades del inciso Iº de dicha disposición se precisa de un poder especial.

Prohibiciones a que está sujeto el mandatario en el ejercicio de su mandato:

1) De acuerdo al artículo 2127, si el mandante nombra a dos o más mandatarios, cada uno de ellos debe actuar por su cuenta, salvo que el mandante se los haya prohibido en forma expresa y en este caso todo lo que hagan separadamente es nulo. En realidad más que un caso de nulidad se trata de una situación de inoponibilidad, el acto que el mandatario ejecuta aisladamente es inoponible al mandante, no se ve cuál sería el vicio de nulidad.

2) No puede colocar el dinero del mandante a interés sin el consentimiento de ese; artículo 2146.

3) No puede comprar lo que el mandante le ha encargado vender; ni venderle a éste lo que le encargó comprar, salvo que intervenga expreso consentimiento del mandante; artículo 2144.

4) Encargado por el mandante de poner dinero a interés, no puede tomarlo para sí a ese título, salvo expreso consentimiento del mandante; artículo 2145.

Obligaciones del mandatario en el desempeño de su cometido.

El mandatario está obligado a actuar dentro de las facultades y los límites con que se le haya otorgado el mandato, artículo 2131.

De acuerdo a la citada disposición, el mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo. Al respecto debe recordarse lo establecido por el artículo 1546, principio con el que está acorde el artículo 2134 inciso 1º.

Como puede suceder que los medios por los cuales el mandante haya deseado que se lleve a efecto el mandato no pudieren emplearse, el mandatario podrá emplear otros equivalentes, si la necesidad le obligare a ello, pero siempre

que se obtuviere completamente de ese modo el objeto del mandato, artículo 2134 inciso 2º.

Si el mandatario se halla en la imposibilidad de cumplir el mandato con arreglo a las instrucciones del mandante, no está obligado a constituirse en agente oficioso, pero debe tomar las providencias conservativas que las circunstancias exijan.

Como no es posible dejar expuesto al mandante a sufrir perjuicios por no haberse previsto oportunamente los medios de que debe hacer uso el mandatario, éste debe actuar en la forma que más se acerque a sus instrucciones y que más convenga al negocio, artículo 2150 inciso 2º.

10. - Responsabilidad del mandatario.

Conforme al artículo 2129 el mandatario responde de culpa leve, pero esta responsabilidad es más estricta si el mandato es remunerado; no dice el Código que responda de culpa levísima. Si el mandatario se ha visto obligado a aceptar el mandato, su responsabilidad será menor, pero la ley no señala que responda de culpa grave. Lo que se pretende en esta disposición es entregar al juez una orientación, particularmente a la hora de establecer eventuales perjuicios de que pudiera ser responsable el mandatario.

El mandatario no responde al mandante de la solvencia del deudor con quien ha contratado. Sin embargo, el artículo 2152 establece que si por una cláusula especial el mandatario se hace responsable de la solvencia del deudor y de los embarazos y dificultades del cobro, responderá también de caso fortuito y fuerza mayor. Este es un caso excepcional. Pero cabe señalar que estas cláusulas transforman el contrato en que se incluyan en un contrato innominado; no se trata de un verdadero contrato de mandato, hay representación, pero el mandatario responde de la solvencia del deudor y se le mira como principal deudor. Dicho contrato tiene de mandato, de contrato de seguro y de fianza.

11. - Rendición de cuenta de la gestión del mandato.

Esta obligación la establece el artículo 2155, y en esto se diferencia el mandato del arrendamiento de servicios donde el empleado no tiene esta obligación. Tiene por objeto que el mandante tome conocimiento de la forma como se ha ejecutado el encargo, sobre los resultados del mismo y la restitución al mandante de aquello que recibió para el cumplimiento de su cometido.

La rendición de cuentas procede tanto cuando el mandatario ha actuado en nombre del mandante como cuando lo ha hecho a nombre propio, siendo particularmente relevante en este segundo caso, por cuanto será éste el momento en que transferirá al mandante los derechos que adquirió en el cumplimiento del encargo.

Esta rendición de cuenta, en principio, será extrajudicial, pero si las partes no se ponen de acuerdo, tal rendición será judicial, siendo éste un tema de arbitraje forzoso.

El mandante puede exonerar al mandatario de esta obligación, porque ella está establecida en su interés. Pero si lo exime no significa que el mandatario quede exonerado de los cargos que contra él justifique el mandante. Esta disposición, artículo 2155, hace aquí una aplicación de lo dispuesto en el artículo 1465, según el cual la condonación del dolo futuro no vale.

El mandatario, dentro de la rendición de cuentas al mandante, debe darla con relación a los intereses de los dineros de éste, y al respecto el artículo 2156 hace una distinción:

1) Intereses de dinero del mandante que el mandatario ha empleado en propia utilidad: el mandatario debe intereses corrientes a contar del día que empleó los dineros del mandante.

2) Intereses del saldo en contra del mandatario, que resulten de las cuentas, los debe desde que se le constituya en mora.

12. - Delegación del mandato.

En principio parece difícil que el mandatario pueda delegar, porque el mandato es un contrato de confianza. Sin embargo en lo que dice relación con la delegación del mandato debe hacerse las siguientes distinciones:

1) En el contrato de mandato se ha autorizado expresamente la delegación y se ha indicado a quién se puede efectuar. En este caso el mandatario delegante queda libre de toda responsabilidad y se entiende que se constituye nuevo mandato entre el mandante y el mandatario delegado. Y este nuevo mandato sólo puede ser revocado por el mandante.

2) En el contrato de mandato se autoriza al mandatario para delegar, pero no se indica a quién puede hacerse la delegación. Por regla general, el mandatario que delega no es responsable, salvo que haya delegado el mandato en una persona manifiestamente incapaz o insolvente.

3) En el contrato de mandato no se prohíbe ni se autoriza la delegación. Puede también el mandatario delegar su mandato, pero lo hace por su cuenta y riesgo ya que frente al mandante, responderá de los hechos del delegado como de los suyos propios.

4) En el contrato de mandato se prohíbe expresamente la delegación; el mandatario no puede delegar.

Lo señalado se refiere a las relaciones entre mandante y mandatario. Pero para que a virtud de una delegación quede obligado el mandante con respecto a terceros, se requiere que haya autorizado o ratificado la delegación.

Reglamentan la delegación del mandato los artículos 2135, 2137 y 2138.

13. - Obligaciones del mandante.

Propiamente, cuando el mandato no es remunerado el mandante no tiene obligaciones derivadas del mandato mismo, porque en tal caso el contrato es unilateral. En este caso las obligaciones no nacen propiamente del contrato de mandato.

En cambio, cuando el contrato es bilateral, nacen obligaciones para el mandante, siendo la principal pagar al mandatario la remuneración estipulada.

Las obligaciones del mandante pueden reducirse a las siguientes:

1. Debe indemnizar al mandatario los perjuicios que hubiere sufrido con motivo del mandato y los gastos en que haya incurrido, artículo 2158;

- El mandante está obligado a poner a disposición del mandatario lo necesario para que lleve a cabo el mandato;
- Debe devolver al mandatario los anticipos de dinero que éste hubiere hecho, con el interés corriente;
- El mandante está obligado a indemnizar al mandatario todos los gastos que se le hubiere ocasionado con motivo del mandato, y
- También está obligado el mandante a indemnizar al mandatario todo perjuicio que le hubiere ocasionado la ejecución del mandato.

El mandante no puede negarse a dar cumplimiento a estas obligaciones alegando que el negocio no le fue útil, salvo que de parte del mandatario hubiere existido culpa.

Si el negocio encomendado al mandatario no ha tenido éxito o pudo desempeñarse a menor costo, el mandante no puede dispensarse del cumplimiento de sus obligaciones sino probando culpa del mandatario. El artículo 2158 inciso final hace recaer el peso de la prueba sobre el mandante, lo cual es una excepción a la prueba de la culpa porque el que imputa la culpa debe probarla.

2. El mandante debe pagar la remuneración al mandatario, si el mandato es remunerado. Esta puede ser fijada por acuerdo de las partes, por el juez, la ley o bien la usual (determinada por la costumbre), artículo 2158.

3. El mandante debe cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario dentro de los límites del mandato, artículo 2160. En realidad ésta no es una obligación del mandante sino el efecto del contrato de mandato. Si el mandatario se excede en sus atribuciones, tales actos serán, en principio, inoponibles al mandante.

14. - Efectos del mandato entre mandante y terceros.

Hay que distinguir si el mandatario actuó a nombre propio o en representación del mandante, y si lo hizo dentro de los límites del mandato o se extralimitó.

a) El mandatario actúa a nombre propio. En este caso no obliga al mandante respecto de terceros (artículo 2151), pero bien puede el mandante exigir al mandatario que le ceda los derechos que ha adquirido con ocasión de cumplir el mandato.

b) Actúa en representación del mandante. Hay que subdistinguir:

b 1) Actúa dentro de los límites del mandato. En este caso obliga al mandante (artículo 2160 inciso 1º).

b2) Se extralimita: Los actos del mandatario no obligan al mandante y le son inoponibles en cuanto exceden el mandato, a menos que lo ratifique. En todo caso, el mandante podrá accionar contra el mandatario extralimitado por los perjuicios que pudiere resultar de aquellos actos.

Si la gestión encomendada se ha cumplido parcialmente y dicha gestión es susceptible de cumplimiento parcial, obliga al mandante (2161)

Si no es posible el cumplimiento parcial de la gestión, el mandante no será obligado por la ejecución parcial, sino en cuanto le aprovechare.

15. - Extinción del mandato.

El artículo 2163 señala varias causales de extinción del mandato, entre las cuales hay algunas que permiten ponerle término en forma unilateral, a pesar de ser un contrato y por tanto un acto jurídico bilateral. Se explica por ser un contrato de confianza.

También puede terminar por los modos de extinguir generales contemplados en el artículo 1567, en lo que le fueren aplicables, así por ejemplo, la resciliación.

CAUSALES DE EXTINCIÓN

El mandato puede extinguirse:

1. Por el desempeño del negocio para el que fue constituido.

2. Por la expiración del plazo o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato.

3. Por la revocación del mandante.

Ello deriva del carácter de contrato de confianza. La revocación es una facultad discrecional del mandante, sea el contrato oneroso o gratuito. Esta facultad puede ser renunciada por el mandante, es decir, puede obligarse en el contrato a no revocar el mandato concedido al mandatario, esta renuncia es perfectamente lícita, porque sólo atañe al interés particular del mandante.

El pacto de no revocabilidad del mandato tiene justificación particularmente en el caso en que el mandato interese también al mandatario. La infracción de la obligación de no revocar el mandato, esto es revocarlo, significa incumplir una obligación de no hacer, que se traduce, según el artículo 1555, en la obligación de indemnizar perjuicios. (En la práctica esto se garantiza conviniendo una cláusula penal para el caso de que el mandante no cumpla con el pacto de irrevocabilidad).

La revocación puede ser expresa o tácita (2164) y en cuanto a su extensión puede ser total o parcial (2165). Produce efectos desde el día que es conocida por el mandatario (2165), sin perjuicio que actos posteriores del mandatario puedan obligar al mandante(2173).

Revocación tácita: Cuando se encarga el mismo negocio a distinta persona. También puede ser parcial; así el artículo 2164 inciso 2º dice "Si el primer mandato es general y el segundo es especial, subsiste el primer mandato para los negocios no comprendidos en el segundo".

No hay una forma precisa para dar conocimiento de la revocación al mandatario; en todo caso, corresponde al mandante probar que el mandatario supo la revocación, lo que es importante porque si el mandatario no ha tenido conocimiento de la revocación los actos que éste celebre obligan al mandante.

4) Por la renuncia del mandatario.

Es la contrapartida de la facultad para revocar que tiene el mandante (artículo 2167). La renuncia puede hacerla el mandatario sea un mandato remunerado o gratuito, y debe ponerla en conocimiento del mandante, pero ella no pone término al mandato sino después de haber transcurrido un término razonable para que el mandante pueda proveer a los negocios encomendados. Así, si el mandatario renuncia, notifica y se desentiende de la gestión, continúa siendo responsable de los perjuicios que se le puedan ocasionar al mandante, a menos que se halle en la imposibilidad de administrar por enfermedad u otra causa que haga imposible la continuación de la gestión por parte del mandatario (artículo 2167 inciso 2º).

Tratándose del mandato judicial (artículo 10 del C.P.C.) el mandatario debe notificar la renuncia al mandante poniendo en su conocimiento el estado del pleito. La renuncia produce sus efectos transcurrido que sea el término de emplazamiento a contar de la notificación de la renuncia del mandatario al mandante (sigue vigente el mandato).

5) Por la muerte del mandante o mandatario. Nueva demostración del carácter de contrato de confianza.

La muerte del mandante pone término al mandato, cesa el mandatario en sus funciones, pero si esta suspensión irrogare perjuicios a los herederos del mandante el mandatario está obligado a finalizar la gestión iniciada (artículo 2168). Excepcionalmente no se extingue el mandato por la muerte del mandante (artículo 2169) cuando está destinado a ejecutarse después de la muerte de éste.

La muerte del mandatario también pone término al mandato, pero la ley en resguardo de los intereses del mandante obliga a los herederos del mandatario a dar aviso de la muerte al mandante y harán en favor de éste lo que puedan y las circunstancias exijan siempre que estos herederos fueren hábiles para administrar sus bienes.

El incumplimiento de esta obligación los hace responsables de los perjuicios que pudieren ocasionárseles al mandante (artículo 2170).

6) Por la quiebra o insolvencia del mandante o del mandatario (resguardo de terceros).

7) Por la interdicción de uno o de otro. La interdicción es una medida judicial que priva de la administración de sus bienes a una persona, y puede provenir de demencia, sordomudez y disipación.

La interdicción del mandatario extingue el mandato, porque si no puede administrar sus bienes tampoco podrá administrar los de terceros.

La interdicción del mandante pone término al mandato; lógico si el mandante carece de facultad de administrar, tampoco el mandatario que sólo manifiesta voluntad del mandante. Además, la representación del interdicto la tendrá su curador.

8) Por la cesación de las funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en ejercicio de ella.

Por ejemplo, si el representante legal de una Corporación confiere un mandato, ese mandato se extinguirá cuando él cese en sus funciones. Sin embargo, hay un fallo que dice que en este caso el mandato no termina pues el otorgamiento del contrato de mandato sería un acto de la Corporación. Esto es discutible.

9) Si la mujer soltera que ha otorgado un mandato se casa posteriormente el mandato subsiste, pero el marido podrá revocarlo a su arbitrio siempre que se refiera a bienes que están bajo la administración de éste (artículo 2171).

Comentario final: Si se trata de un mandato conferido a varios mandatarios que deban actuar conjuntamente, la concurrencia de cualquiera de las causales de terminación respecto de uno de ellos extingue el mandato (artículo 2172).

Efectos de la expiración de mandato respecto de terceros. (Mandato Aparente)

El artículo 2173 dispone: “En general, todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada del mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del mandato será válido y dará derecho a terceros de buena fe contra el mandante.

Quedará asimismo obligado el mandante, como si subsistiera el mandato, a lo que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe; pero tendrá derecho a que el mandatario lo indemnice”.

Esta regla se refiere a los efectos que se producen por la expiración del mandato o mandato aparente.

Los actos que realiza el mandatario después de haber expirado el mandato son, en principio, inoponibles al mandante.

Con todo, en protección de los terceros, excepcionalmente, pueden obligar al mandante frente a terceros de buena fe que ignoraban el hecho de haber cesado el mandato al tiempo de contratar con el pretendido mandatario.

En efecto, si al tiempo de cumplir el encargo el mandatario no tiene conocimiento de la expiración de mandato (artículo 2173 en inciso I^{o}), o aun cuando éste tuviere conocimiento de tal circunstancia (artículo 2173 en inciso 2°), el mandante puede quedar obligado con terceros de buena fe. Si el mandatario tenía conocimiento de la extinción estará de mala fe y deberá indemnizar de todo perjuicio al mandante, pero ello no obsta para que respecto de los terceros de buena fe (en cuanto ignorantes de la extinción del mandato) tal expiración resulte inoponible, y ejercerán su acción no contra el mandatario sino contra el mandante.

Según el artículo 2173 inciso 3° "Cuando el hecho que ha dado causa a la expiración del mandato hubiere sido notificado al público por periódicos, y en todos los casos en que no pareciere probable la ignorancia del tercero, podrá el juez en su prudencia, absolver al mandante", es decir, en tal caso los actos del mandatario no obligarán al mandante.

16. - Naturaleza de los servicios de las profesiones que suponen largos estudios.

El artículo 2118 señala que "Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato".

El Código no dice que estos servicios constituyen mandato sino que se sujetan a tales reglas. En general se trata de arrendamiento de servicios inmateriales (así se califica la relación entre una Empresa y su contador C. Stgo. T. 77, sección 2, pag. 130).

17. - Prueba.

El mandato en cuanto a su prueba está sujeto a las reglas generales. Es decir se le aplican, cuando corresponda, las limitaciones de los artículos 1708 y 1709.

CAPÍTULO XI

CONTRATO DE MUTUO

1. - Definición.

El artículo 2196 lo define en la siguiente forma: "El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad.

El que da en mutuo se llama mutuante; y el que recibe, mutuario".

2. - Características del contrato de mutuo.

El contrato de mutuo presenta las siguientes características:

1) Sólo puede recaer sobre cosas fungibles:

En este caso debe entenderse por cosas fungibles no las que define el art. 575, que confunde fungibles con consumibles, sino que aquellas "que por presentar entre sí una igualdad de hecho se consideran como de igual poder liberatorio".

En general el mutuo puede recaer sobre cualquier cosa fungible, pero en la actualidad el que tiene preponderancia es el mutuo de dinero; el de otras especies tiene escasa trascendencia, hasta el punto que para muchos el mutuo se identifica con el préstamo de dinero.

2) Es un contrato real:

Se perfecciona por la tradición de la cosa, y ella transfiere el dominio al mutuario, art. 2197. La tradición puede hacerse por cualquiera de los medios que establece el art. 684 del Código Civil.

Haciéndose dueño el mutuario de la cosa, puede consumirla o disponer de ella a su arbitrio.

La tradición produce un doble efecto; 1) perfecciona el contrato de mutuo, y 2) produce la transferencia del dominio de la cosa prestada, esta es una situación excepcional porque lo normal es que el título (contrato) preceda a la tradición.

3) Es un contrato unilateral:

Origina obligación sólo para una de las partes, el mutuario, quien debe devolver lo que se le ha prestado, pero no en especie, sino otras del mismo género y calidad y en la misma cantidad que se le prestó.

4) Es un contrato principal:

Subsiste por sí solo, no requiriendo de otro contrato.

5) Puede ser gratuito u oneroso:

El mutuo es gratuito por naturaleza, por ello si nada se dice se entiende que tiene este carácter. Pero las partes pueden haber convenido que se paguen intereses, caso en el cual es oneroso.

Para que el mutuo sea con intereses, ello debe haberse convenido por las partes.

No sucede así en las operaciones de crédito de dinero, definidas en el artículo 1º de la Ley N° 18.010, ya que el artículo 12 de esta ley dispone "La gratuidad no se presume en las operaciones de crédito de dinero. Salvo disposición de la ley o pacto en contrario, ellas devengarán intereses corrientes, calculados sobre el capital o sobre el capital reajustado en su caso". Es decir, tratándose de operaciones de crédito de dinero, la regla es precisamente la inversa de la que hemos señalado como general para el mutuo, en ellas para que no se devenguen intereses debe haber o una disposición legal o un pacto expreso de las partes que así lo establezca.

Si consideramos que hoy en día la mayor parte de los mutuos constituyen operaciones de crédito de dinero, llegamos a la conclusión que en la práctica la regla es que el mutuo sea oneroso.

6) Es un título traslaticio de dominio:

Tiene este carácter porque naturalmente sirve para transferir el dominio; ya hemos dicho que la entrega por la cual se perfecciona el contrato de mutuo es una tradición y la tradición es un modo de adquirir el dominio.

3. - Capacidad de las partes.

Veremos separadamente la situación del mutuante y la del mutuario:

A. Como la tradición por la cual se perfecciona el contrato de mutuo implica la transferencia del dominio, el mutuante debe ser capaz de enajenar y además ser dueño de la cosa dada en mutuo.

Si el mutuante no es capaz de enajenar el contrato de mutuo adolecerá de un vicio de nulidad.

En tanto que, si no es dueño de la cosa dada en mutuo, ésta puede reivindicarse, mientras conste su identidad.

Desaparecida la identidad, el que recibió la cosa de mala fe es obligado al pago inmediato con el máximo de intereses que la ley permita estipular; en cambio el mutuario de buena fe es obligado sólo al pago de los intereses estipulados después de transcurridos diez días, arts. 2202 y 2200.

B. El mutuario debe ser capaz de obligarse. Si no lo es, el mutuo adolecerá de un vicio de nulidad, y declarada ésta tiene aplicación lo dispuesto en el art. 1688.

4. - Efectos del contrato de mutuo.

Los efectos de un contrato, según se ha señalado en reiteradas ocasiones, son los derechos y obligaciones que él genera, siendo el mutuo un contrato unilateral, sólo genera obligaciones para una de las partes: el mutuario, y esa obligación es la de restituir la misma cantidad de cosas del mismo género y calidad que las que él recibió.

La forma como debe efectuarse la restitución dependerá de si lo prestado es dinero o cosas fungibles que no sean dinero.

a) Restitución de cosas fungibles que no son dinero:

En este caso el mutuario deberá restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad, no importando para este efecto las variaciones que el precio de la cosa haya experimentado en el tiempo intermedio entre la entrega y la restitución.

Si no es posible restituir cosas del mismo género y calidad o el acreedor no lo exigiere, puede el mutuario pagar lo que valgan en el tiempo y lugar en que ha debido hacerse el pago, art. 2198.

b) Restitución en el mutuo de dinero:

El Código Civil, hasta la dictación del D.L. 455 del año 1974, siguió el sistema nominalista, según el cual si se ha prestado dinero, sólo se debe devolver la suma numérica expresada en el contrato. Es lo que establecía el artículo 2199. Es decir se estaba al valor nominal de la moneda, sin considerar las variaciones que pudiera haber experimentado su poder adquisitivo. Ello era una evidente injusticia especialmente en períodos de alta inflación.

El D.L. N° 455 de 1979 derogó el artículo 2199 del Código Civil y reglamentó las llamadas "operaciones de crédito de dinero". Esta materia hoy día está regulada por la Ley N° 18.010, que derogó el D.L. N° 455, estableciendo una nueva normativa sobre dicha materia.

De acuerdo al art. 1º de la Ley N° 18.010 "son operaciones de crédito de dinero aquellas por las cuales una de las partes entrega a la otra o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención.

Constituye también operación de crédito de dinero el descuento de documentos representativos de dinero, sea que lleve o no envuelta la responsabilidad del cedente.

Para los efectos de esta ley, se asimilan al dinero los documentos representativos de obligaciones de dinero pagadero a la vista, a un plazo contado desde la vista o a un plazo determinado".

Desde la vigencia de estos cuerpos legales se aplica en Chile el sistema valorista, esto es aquel que atiende no a la suma numérica del dinero prestado, sino a su poder adquisitivo. Así, el artículo 12 de la Ley N° 18.010 dispone que "La gratuidad no se presume en las operaciones de crédito de dinero. Salvo disposiciones de la ley o pacto en contrario, ellas devengan intereses corrientes, calculados sobre el capital o sobre el capital reajustado, en su caso".

Por su parte el artículo 2º de la misma ley distingue entre intereses de operaciones no reajustables y reajustables. Debiendo tenerse presente que en la determinación del interés para operaciones no reajustables se considera normalmente la variación experimentada por el índice de Precios al Consumidor en el período correspondiente.

Además, el artículo 3º de la ley citada establece que las partes que no sean empresas bancarias, sociedades financieras o cooperativas de ahorro y crédito, pueden convenir libremente cualquier forma de reajuste en las operaciones de crédito de dinero.

5. - Plazo para la restitución de las cosas dadas en mutuo.

Para determinar la época en que debe restituirse lo prestado hay que distinguir si en el contrato se estipuló o no un plazo para dicho efecto.

Si se convino un plazo hay que estarse a él, y la restitución deberá efectuarse a su vencimiento. No obstante el artículo 2204 faculta al mutuario para pagar toda la suma prestada, aun antes del término estipulado, porque en este

caso puede renunciar al plazo que está establecido en su favor; pero si se han pactado intereses no puede pagar antes del vencimiento del plazo sin el consentimiento del acreedor.

Tratándose de las operaciones de crédito de dinero la ley faculta expresamente al deudor para anticipar su pago, aun contra la voluntad del acreedor, siempre que, si se trata de operaciones no reajustables, pague el capital y los intereses estipulados, que correrían hasta la fecha del vencimiento pactada, y que si es una operación reajustable, paga el capital reajustado hasta el día del pago efectivo más los intereses convenidos calculados sobre dicho capital por todo el plazo pactado, art. 10.

Ahora si no se ha convenido un plazo, éste es establecido por la ley, la que dispone que sólo puede exigirse la restitución transcurridos diez días contados desde la entrega, arts. 2200 y 13 de la Ley N° 18.010.

Si se hubiere convenido que el mutuario pague cuando le sea posible, entonces y en conformidad al art. 2201 puede el juez, atendidas las circunstancias, fijar el plazo dentro del cual deberá pagar.

6. - Obligaciones eventuales del mutuante.

Hay que tener presente que estas posibles obligaciones del mutuante son eventuales, y que surgen de la celebración del contrato, no al momento de éste sino que con posterioridad.

El art. 2203 dispone "El mutuante es responsable de los perjuicios que experimente el mutuario por la mala calidad o los vicios ocultos de la cosa prestada, bajo las condiciones expresadas en el artículo 2129. Si los vicios ocultos eran tales que conocidos no se hubiera probablemente celebrado el contrato, podrá el mutuario pedir que se rescinda".

7. - Los intereses.

De acuerdo con el art. 2º de la Ley N° 18.010 "en las operaciones de crédito de dinero no reajustables, constituye interés toda suma que recibe o tiene derecho a recibir el acreedor, a cualquier título sobre el capital. En las operaciones de crédito de dinero reajustables, constituye interés toda suma que recibe o tiene derecho a recibir el acreedor por sobre el capital reajustado".

Económicamente, el interés representa la renta del capital de que el acreedor se priva por prestárselo a otro; jurídicamente, son frutos civiles del crédito, art. 647.

Clases de intereses:

En lo que dice relación con las diversas clases de intereses la Ley N° 18.010 presenta una innovación respecto de lo que establecía la legislación anterior. En efecto los intereses se reducen a sólo dos clases eliminándose el interés legal, que contemplaba el art. 2207 que fue derogado por dicha ley.

La Ley N° 18.010 establece sólo dos clases de intereses:

a) interés corriente, y

b) interés máximo convencional.

a) Interés corriente:

Es el interés promedio cobrado por los bancos y las sociedades financieras establecidas en Chile, en las operaciones que realicen en el país, art. 6º inc. 1º Ley N° 18.010.

La determinación de dicho interés corriente corresponde a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la cual puede distinguir, para estos efectos, entre operaciones reajustables y no reajustables, o según los plazos a que se hayan pactado tales operaciones.

En la práctica, el citado organismo se limita a fijar el interés corriente para operaciones reajustables y no reajustables.

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para establecer los promedios señalados, debe hacerlo en relación con las operaciones efectuadas durante cada mes calendario; y las tasas de interés corrientes, así determinadas, deben publicarse en el Diario Oficial durante la primera quincena del mes siguiente, para que tengan vigencia hasta el día anterior a la próxima publicación.

Con esta forma de determinación de los intereses se pretende que ellos sean un fiel reflejo de las condiciones imperantes en el mercado para las operaciones de crédito de dinero, debiendo, por consiguiente, para este efecto atenderse a su naturaleza, plazo, reajustabilidad y moneda en que se pacten.

b) Interés máximo convencional:

Se define el interés máximo convencional como aquel que no excede en más de un 50 % al interés corriente que rija al momento de la convención.

Sanciones al cobro de intereses excesivos:

La ley no permite que se pacten intereses superiores al máximo convencional y, si así se hiciere, se incurre en sanciones, respecto de las cuales hay que distinguir el aspecto civil y el penal.

Desde un punto de vista civil, la ley prohíbe que se estipulen intereses superiores al máximo convencional y si ello llegare a hacerse, el pacto se tiene por no escrito, reduciéndose los intereses al corriente que rija al momento de la convención.

Si se hubiere cobrado intereses en exceso, ellos deberán restituirse reajustados, art. 8º Ley N° 18.010.

Considerando el problema desde el punto de vista penal, hay que tener presente que la Ley N° 18.010 no hace referencia al artículo 472 del Código Penal, como lo hacía su antecesor, el D.L. N° 455. Sin embargo, ello no afecta en nada a la existencia del delito de usura, que es un hecho delictual perfectamente tipificado en el artículo citado.

Forma y plazo de estipulación de intereses:

En las operaciones de crédito de dinero los intereses sólo pueden estipularse en dinero y se devengarán día a día.

En este aspecto hay que resaltar un punto importante, cual es que se modifica, sólo para los efectos de las operaciones de crédito de dinero regidas por la Ley N° 18.010, la forma de computar los plazos de meses y años que establece el artículo 48 del Código Civil, cuando dispone que los plazos de meses son de 30 días y los de años de 360 días para los efectos de la mencionada ley.

La modificación señalada tiene aplicación sólo para el cálculo de los intereses en las operaciones de crédito de dinero con tasas mensuales y anuales; pero para lo que dice relación con el vencimiento de los efectos de comercio con que se documente la operación, los plazos de meses y años se computarán en la forma que establece el art. 48 del Código Civil, al igual que todo otro plazo que incida en ellas, salvo los que digan con el cálculo de intereses que se sujetan a la norma especial señalada.

Estipulación de intereses:

El texto de los artículos 12 y 14 de la Ley N° 18.010 es, aparentemente, contradictorio, ya que el primero de ellos establece que la gratuidad no se presume en las operaciones de crédito de dinero, y que salvo disposición de la ley o pacto en contrario, dichas operaciones devengan intereses corrientes, es decir, presume los intereses mencionados. En tanto que la segunda norma pareciera exigir que el pacto en que se estipulan intereses conste por escrito.

Estimamos que dichas disposiciones deben interpretarse en la siguiente forma, fundándonos en el contexto de la ley: las operaciones de crédito de dinero, por regla general, devengan intereses corrientes, lo cual la ley presume; si se pacta un interés superior al corriente o se exonera de su pago, ello debe constar por escrito y si no se hiciere así, la sanción es la ineficacia enjuicio de dicho pacto.

Por otra parte, si no se han estipulado intereses y ellos se pagan por el deudor; éste no puede pedir la devolución de lo pagado por concepto de intereses ni imputar dicho pago al capital, art. 15 Ley N° 18.010.

Anatocismo:

El anatocismo consiste en que los intereses devengados por un crédito y no pagados al acreedor, se capitalicen y devenguen a su vez intereses, es decir se producen intereses de intereses.

En el Código Civil existían dos normas al respecto, el art. 1559 N° 3 que dispone: "Los intereses atrasados no producen interés" y el artículo 2210 que disponía: "Se prohíbe estipular intereses de intereses".

Fue materia muy debatida, si la regla del artículo 2210 del Código Civil era una norma sólo aplicable al contrato de mutuo o si era de aplicación general. Predominaba la primera posición, fundada principalmente en que por el carácter prohibitivo de dicho artículo no podía extenderse a otras situaciones.

La Ley N° 18.010 derogó expresamente el art. 2210, poniendo término a dicha discusión y, además, permite expresamente el anatocismo.

El pacto en que se establece el anatocismo está sujeto a las siguientes reglas:

a) La capitalización de intereses debe hacerse en cada vencimiento o renovación de la obligación;

b) La capitalización de intereses no puede hacerse por períodos inferiores a 30 días. Esto significa que los intereses capitalizados por períodos inferiores no pasan a formar parte del capital y siguen considerándose intereses para los efectos de determinar si se ha excedido el interés máximo convencional.

Se establece una norma especial para la situación de las operaciones vencidas, en las cuales los intereses siempre se capitalizan, salvo que expresamente se hubiere pactado lo contrario. Este pacto debe constar por escrito para los efectos probatorios.

Recibo de pago:

El otorgamiento de recibo de pago por el capital hace presumir el pago de intereses y del reajuste en su caso, art. 17 Ley N° 18.010.

El recibo de pago de intereses correspondiente a tres períodos consecutivos y del capital cuando éste se deba pagar en cuotas, por igual lapso, hace presumir el pago de los intereses o cuotas anteriores.

Las anteriores son presunciones simplemente legales y, por consiguiente, admiten prueba en contrario, recayendo, eso sí, el peso de la prueba sobre el acreedor.

CAPÍTULO XII

CONTRATO DE COMODATO

1. - Definición.

El comodato, también llamado "préstamo de uso", "es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminado su uso.", artículo 2174.

La parte que entrega la cosa se denomina "comodante" y el que la recibe, "comodatario".

2. - Características del contrato de comodato.

a) Es un contrato real:

Este contrato se perfecciona por la entrega de la cosa. El art. 2174 inc. 2º incurre en este aspecto en una impropiedad, porque señala que "este contrato no se perfecciona sino por la "tradición" de la cosa" lo cual no es efectivo, ya que este contrato se perfecciona por la entrega de la cosa como se ha señalado, desde que es un título de mera tenencia, en que el comodatario reconoce el dominio del comodante a quien debe restituirle la misma especie que recibió al producirse el término del comodato.

Confirma lo señalado el artículo 2176 que establece que el comodante conserva todos sus derechos sobre la cosa dada en comodato, pero queda limitado en su ejercicio por los derechos que tiene el comodatario.

b) Es esencialmente gratuito:

Sólo el comodante se grava en beneficio del comodatario, y este último no está sujeto a ningún gravamen en beneficio de aquél.

El ser gratuito es un elemento de la esencia del comodato, porque si llega a convenirse una remuneración por el uso de la cosa, el contrato se torna en arrendamiento.

c) Es un contrato unilateral:

Sólo genera obligaciones para el comodatario, ya que debe conservar la cosa que le fue prestada y restituirla al comodante al término del contrato.

d) Es principal:

Subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención.

3. - Responsabilidad de comodatario.

El artículo 2178 dispone que "el comodatario es obligado a emplear el mayor cuidado en la conservación de la cosa, y responde hasta de la culpa levísima". Lo cual es una aplicación de la regla general en materia de culpa ya que como hemos señalado el contrato de comodato beneficia al comodatario, esto es, al deudor, y conforme al artículo 1547 el deudor es responsable de la culpa levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio.

No obstante lo señalado, esta regla puede tener excepciones que son las que señala el artículo 2179, según el cual el comodatario puede responder de la culpa leve cuando el comodato va a beneficiar también al comodante, y de la culpa grave o lata, cuando sólo beneficia al comodante.

4. -El comodato y la prueba testimonial.

En materia de prueba el comodato hace excepción a las limitaciones de la prueba testimonial establecidas en los artículos 1708 y 1709 del Código Civil, en efecto, el artículo 2175 establece que "el contrato de comodato podrá probarse por testigos, cualquiera que sea el valor de la cosa prestada".

La razón de lo anterior se encuentra en que éste es un contrato de confianza con el cual el comodante no persigue beneficio alguno. Si tiene confianza en el comodatario como para prestarle una cosa, es lógico que no le exija que ello conste por escrito.

5. - Requisitos del contrato de comodato.

Además de los requisitos generales de todo contrato, deben concurrir en el comodato algunos de carácter especial:

a) La cosa no debe ser consumible, ya que el comodatario tiene que devolver la misma cosa que le fue prestada, y las cosas consumibles se destruyen por su uso;

b) Debe tratarse de una especie o cuerpo cierto, ya que el comodatario debe "restituir la misma especie".

6. - Comodato de cosa ajena.

En esta materia se sigue la orientación general del Código Civil de dar validez a los contratos sobre cosa ajena, ello por las razones que se expusieron al analizar la venta de cosa ajena. En materia de comodato el artículo 2188 reconoce la validez del comodato sobre cosa ajena, al establecer que si la cosa prestada no pertenece al comodante y el dueño no la reclama antes de terminar el comodato, no tiene derecho el comodatario a demandar perjuicios contra el comodante, salvo que éste haya tenido conocimiento que la cosa era ajena y no se lo haya advertido.

7. - Obligaciones que surgen del comodato.

Se ha señalado precedentemente que éste es un contrato unilateral porque sólo resulta obligado el comodatario. Pues bien, sobre éste pesan tres obligaciones:

1) Obligación de conservación de la cosa:

El artículo 2178, en parte ya analizado, al referirnos a la responsabilidad del comodatario, impone a éste la

obligación de "emplear el mayor cuidado en la conservación de la cosa", por ello está obligado a indemnizar los deterioros que ésta experimente, salvo los que provengan de caso fortuito, pero incluso hay casos en que el comodatario responde de éste, tales son los que se indican en los incisos finales del artículo 2178.

2) Obligación de usar la cosa en conformidad a lo convenido, y si nada se ha estipulado, según el uso ordinario que se dé a la cosa:

El artículo 2177 dispone que el comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso convenido, o a falta de tal acuerdo, en el uso ordinario de las de su clase. La misma norma da derecho al comodante a demandar indemnización de perjuicios y poner inmediato término al contrato, aun cuando hubiera plazo pendiente en caso de infringirse esta obligación.

3) Obligación de restituir la especie prestada al término del comodato:

Esta es obligación de la esencia del contrato de comodato. El comodatario es un mero tenedor y como tal pesa sobre él la obligación de restituir la cosa.

Dicha restitución debe hacerla al término del plazo estipulado, y si no se hubiere convenido plazo después del uso para el cual fue prestada la cosa.

Pero hay casos en que el comodante puede solicitar la restitución antes del vencimiento del plazo estipulado, tales son los que señala el artículo 2180 del Código Civil.

Por regla general el comodatario no puede negarse a cumplir la obligación de restituir al comodante la cosa que se le ha prestado, pero esta regla presenta las siguientes excepciones:

a) Cuando la cosa haya sido perdida, hurtada o robada, a su dueño, o que se embargue judicialmente en manos del comodatario. En caso que se haya prestado una cosa perdida, hurtada o robada y el comodatario tiene conocimiento de ello, debe ponerlo en conocimiento del dueño, dándole un plazo razonable para reclamarla. Si no lo hiciere así responderá de los perjuicios que se causen al dueño, artículo 2183.

b) Cesa la obligación de restituir desde que el comodatario toma conocimiento que él es el verdadero dueño de la cosa prestada. Pero si el comodante le disputa el domino debe devolverla, salvo que pueda acreditar breve y sumariamente que él es el dueño, artículo 2185.

c) También cesa la obligación de restituir si el comodante debe indemnizaciones al comodatario y éste hace uso del derecho de retención que le confiere el artículo 2193, pudiendo retener la cosa en su poder hasta el pago de las indemnizaciones que se le adeudan.

8. - Pluralidad de comodatarios de una cosa.

De acuerdo al artículo 2189 "Si la cosa ha sido prestada a muchos, todos son solidariamente responsables". El problema es a cuál de las obligaciones del comodatario se aplica la solidaridad que establece esta norma. Al respecto hay que tener presente que, de acuerdo al artículo 1526 número 2, si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, como sucede en el comodato, aquel de los codeudores que la posea es obligado a entregarlo. Se trata de un caso de indivisibilidad de pago, por consiguiente la solidaridad no puede referirse a esta obligación. Al parecer ella dice relación con la obligación de indemnizar perjuicio.

9. - Obligaciones del comodante.

Ya se ha señalado que el comodato es un contrato unilateral en el cual solamente resulta obligado el comodatario, pero por excepción puede resultar obligado el comodante. Las obligaciones que pueden afectar al comodante se encuentran señaladas en los artículos 2191 y 2192 y en síntesis son las siguientes:

a) El comodante está obligado a devolver al comodatario las expensas extraordinarias en que haya incurrido éste en la conservación de la cosa dada en comodato. Hay que tener presente que esta obligación pesa sólo con las expensas extraordinarias.

b) El comodante debe indemnizar al comodatario de los perjuicios que le hubiere causado con motivo de la mala calidad de la cosa prestada, artículo 2192.

Hay que tener presente que estas dos obligaciones que pueden pesar sobre el comodante no alteran la calidad de unilateral del contrato de comodato, pues ellas no se generan al momento de perfeccionarse el contrato, sino que con posterioridad.

10. - Acciones para demandar la restitución de la cosa.

Para demandar la restitución de la cosa prestada el comodante dispone de la acción personal emanada del contrato de comodato y también de la acción reivindicatoría.

11. - Extinción del comodato.

El contrato de comodato se extingue de acuerdo con las reglas generales aplicables a los contratos. Pero, a su respecto, hay también una causal especial de terminación, cual es la muerte del comodatario. Se ha señalado que el comodato es un contrato intuito persona, por ello si fallece el comodatario sus herederos no tienen derecho a continuar el uso de la cosa, salvo que ella haya sido prestada para un servicio particular que no puede diferirse o suspenderse.

Lo que sucede es que con la muerte del comodatario el uso y goce de la cosa no pasa a sus herederos, pero subsisten las obligaciones que nacen del comodato a su respecto, art. 2186.

Hay que tener presente que la muerte del comodante no pone término al comodato, así lo dice expresamente el artículo 2190.

12. - Comodato precario.

El comodato precario se encuentra reglamentado en los artículos 2194 y 2195, conforme a los cuales el comodato se denomina precario cuando la cosa prestada debe restituirse cuando lo solicite el comodante. La regla general es que se fije un plazo para la restitución de la especie prestada o que el momento de la restitución esté determinado por el uso ordinario de ella, pero en el comodato precario la restitución deberá hacerse en cualquier momento a petición del comodante.

El artículo 2195 señala que “Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo para su restitución”.

El comodato precario es un comodato y surge del acuerdo de voluntades entre comodante y comodatario.

Diferente de él es el “precario” que es el goce de un bien hecho por un tercero por mera tolerancia o ignorancia del

propietario. El “precario” es una situación de hecho y no un contrato.

Para que exista “precario” deben concurrir los siguientes requisitos:

a) Que recaiga sobre una cosa singular y determinada.

b) Que el que esté gozando de ella lo haga por mera tolerancia o ignorancia del dueño, art. 2195 inciso 2º.

FONDO DE PUBLICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

- **COLECCIÓN DE ESTUDIOS:**
  - Estudios de Derecho Procesal
    Julio Salas Vivaldi
- **COLECCIÓN DE MONOGRAFÍAS:**
  - De la responsabilidad civil en general y de la responsabilidad delictual entre los contratantes
    Orlando Tapia Suárez
  - De la Responsabilidad Extracontractual
    René Ramos Pazos
  - Responsabilidad del Estado, falta de servicio y responsabilidad objetiva en su actividad administrativa
    Fabián Huepe Artigas
- **COLECCIÓN DE MANUALES:**
  - Actos y Contratos Administrativos
    Julia Poblete Vinaixa
  - Apuntes de Derecho Procesal Penal
    El Ministerio Público y el Proceso Penal Oral
    Héctor Oberg Yáñez, Macarena Manso Villalón, Julio Salas Vivaldi, Gonzalo Cortez Matcovich, Remberto Valdés Hueche, Lorena Sandaña Jeno
  - Contratos
    Hernán Troncoso Larronde
    Carlos Álvarez Cid
  - Contrato Individual de Trabajo
    Gabriela Lanata Fuenzalida
  - Derecho Constitucional
    Hernán Molina Guaita
  - Derecho de Aguas
    Francisco Segura Riveiro
  - Derecho de Familia
    Hernán Troncoso Larronde
  - De las Obligaciones
    Hernán Troncoso Larronde
  - Derecho Sucesorio
    Hernán Troncoso Larronde
  - El Recurso de Nulidad
    Gonzalo Cortez Matcovich
  - Instituciones Políticas
    Hernán Molina Guaita
  - Manual de Código Tributario
    Abundio Pérez Rodrigo
  - Recursos Procesales Civiles
    Héctor Oberg Yáñez, Macarena Manso Villalón
  - Régimen Legal del Nuevo Proceso Laboral Chileno
    Rodolfo Walter Díaz, Gabriela Lanata Fuenzalida

HERNÁN TRONCOSO
CARLOS ÁLVAREZ

COLECCIÓN

La presente obra está destinada a entregar al lector una guía que le permita una aproximación expedita a la estructura orgánica y funcional de los principales contratos que regulan la actividad económica de nuestro país.

Se sostiene sobre la base de un ordenamiento sistemático que sigue los parámetros generalmente aceptados por nuestra doctrina y jurisprudencia, con la particularidad de que, incorporando en su texto la esencia de los problemas y discusiones que se han originado en torno a los contratos estudiados, tal labor se desarrolla en el marco de un esfuerzo de síntesis que mantiene el adecuado análisis de cada punto específico. Este proceder permite visualizar cada aspecto tratado, engarzándolo de mejor manera en el contexto del contrato en que está inmerso.

Preferentemente destinado a los estudiantes de las carreras de derecho, su lectura resulta igualmente útil para el abogado que precisa de una respuesta rápida e inmediata, para sus cuestionamientos cotidianos.

CONTRATOS
HERNÁN TRONCOSO L. - CARLOS ÁLVAREZ C
Formato 15,8 x 21 cm
272 págs